

Pablo Cococcioni

DERECHO PROCESAL PENAL

Teoría y práctica del sistema acusatorio de Santa Fe

Prólogo

Suele ocurrir que el título bajo el que se presenta un libro no refleja fielmente su contenido. Eso no es sin embargo lo que ocurre en este caso, donde las expresiones titulares: “DERECHO PROCESAL PENAL. Teoría y práctica del sistema acusatorio de Santa Fe”, indican con claridad los temas sobre los que se expondrá y la perspectiva desde la que se lo hará. Ello así por cuanto, como se advertirá, sin omitir los fundamentos teóricos sobre los que se asientan las afirmaciones y conclusiones a que llega sino por el contrario dando cuenta de ello, el autor considera y engarza la teoría y la práctica del derecho procesal penal vigente en Santa Fe, entregándonos al cabo una obra útil y sabia.

Es posible afirmar que la provincia de Santa Fe se encuentra todavía al día de hoy en una etapa de afirmación de su nuevo derecho procesal penal (al que le falta, es verdad, regular el juicio por jurados, tarea que se confiara a una ley especial que se encuentra retardada); esto por cuanto si bien el abandono del viejo proceso de corte inquisitivo ocurrió desde un punto de vista formal en el año 2007 cuando se aprobó el nuevo Código Procesal Penal, no fue sino hasta el 2014 que el mismo adquirió efectiva vigencia, siendo posible solo a partir de ese momento comenzar con su efectiva instrumentación y a través de ella formular apreciaciones concretas sobre lo que constituirían sus valores, yerros u omisiones, sobre la interpretación considerada dogmáticamente acertada de sus regulaciones, sobre los resultados producidos en la realidad con su aplicación, sobre la satisfacción o insatisfacción de los fines que se habrían pretendido con el nuevo digesto procesal, sobre la eventual necesidad de modificaciones a su texto y sobre muchas otras cuestiones que la realidad fue revelando.

Pero también a partir de ese año 2014, sucedió que jueces, profesionales del derecho, docentes y cátedras universitarias, se encontraron ante la necesidad de considerar otra nueva situación cual fue que la sustitución del viejo Código Procesal por otro tan distinto, que no solo provocó el cambio de normas lega-

les, sino que también impuso procesalmente el surgimiento de nuevos modos de actuar y hasta de un parcialmente distinto lenguaje jurídico, para lo cual fue necesaria una preparación que capacitara para manejarse en un sistema procesal regido por principios de oralidad y celeridad que hacían y hacen menester saber expresarse veloz y claramente. Todo ello debió ser considerado, y lo que hasta entonces había constituido un estudio teórico y especulativo de la nueva regulación procesal (llevado ciertamente a cabo por autores de gran valía, cuyas obras no han perdido importancia), se encontró ante una nueva exigencia cual la de incorporar la consideración de la realidad generada por la aplicación cotidiana del nuevo Código.

Pero a todo lo dicho ha de agregarse aún la aparición, no novedosa ni determinada por el nuevo Código pero sí cada vez más fuerte y exigida por nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (que considera arbitrario apartarse del criterio fijado en sus decisiones salvo apreciación de elementos que ella no hubiera valorado), de la práctica de acudir a precedentes jurisprudenciales como fundamento o apoyo para pronunciamientos judiciales, dato éste que ligado a los ya referidos principios de oralidad y celeridad, exigió a los operadores del sistema tener rápida y fácilmente al alcance los mismos.

Pues bien, esta obra considera todo ello y da tratamiento y respuesta satisfactoria a las cuestiones problemáticas aparecidas.

Para simplificar el acceso a sus contenidos colocándolos incluso al alcance de los estudiantes de derecho, no solo presenta un muy minucioso “Índice” de temas sino que al mismo adosa un “Glosario” que facilita la comprensión de los términos técnicos utilizados en el texto, culminando su tarea facilitadora del estudio con la inclusión al término de cada “Capítulo” de una síntesis explicativa de aquello a lo que ya se acaba de considerar. Incorpora esquemas y cuadros sinópticos esclarecedores. Da cuenta de herramientas de litigación en el juicio oral y en audiencias previas. Realiza un excelente y provechoso resumen explicativo de la historia de las diversas formas del proceso penal que existen o existieron en el mundo occidental y en nuestro país. Concreta una muy buena cita de documentos internacionales, fallos de Cortes Supremas y Tribunales tanto internacionales cuanto nacionales, todos extremadamente útiles hoy en día tal como ya viéramos. Analiza minuciosamente el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, sus reglas y expresiones, estudiando reflexivamente el grado de conocimiento necesario para el dictado de sus distintas resoluciones. Lleva a cabo un minucioso análisis de los sujetos procesales y su actuación. Suministra, en fin, una serie de acertados consejos prácticos.

Muy lejos está el detalle precedente de constituir una acabada pormenorización de los temas analizados en el libro; es simplemente un relato efectuado para que quien se acerca al mismo comprenda la vastedad de los asuntos tratados, el acierto y claridad con el que se lo hizo, y la admirable síntesis explicativa que supo lograrse. De este modo pudo conformar, como adelantara, un libro útil y sabio.

Por mi parte quedo totalmente seguro del significativo valor de esta obra, no cabiéndome duda alguna respecto a que el autor ha conseguido ampliamente cumplir los propósitos que lo llevaron a escribirla.

Dr. JULIO DE OLAZÁBAL

Profesor Titular de Derecho Penal Parte General y Parte Especial (FCJS - UNL)
Ex Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

Presentación

He escrito este libro con la intención de ofrecer una exposición orgánica y concisa de la materia, destinada a estudiantes de grado y a quienes se inicien en el ejercicio profesional.

La sanción del Código Procesal Penal de Santa Fe en 2007 ha motorizado una ingente producción bibliográfica. Sin embargo, esta producción usualmente ha adoptado el formato de código comentado o de monografía. La práctica profesional y docente nos estaba mostrando que faltaba una obra que pudiera hacer de bisagra, entre la manualística de uso (que ya acusaba un grado no menor de desactualización), y estas obras de exégesis y profundización, pensadas más para un uso estrictamente profesional o como producto de la investigación científica.

Así llegamos a la idea de escribir una obra general, que incluyera algunos recursos de utilidad práctica. No sólo pensando en quienes se inician en el ejercicio profesional, sino también en quienes se formaron y ejercieron en el viejo sistema o en otras ramas del derecho, y con toda legitimidad quieran asomarse a conocer nuestro nuevo modelo de enjuiciamiento penal. Teniendo en cuenta esta posible utilidad, se intercalaron referencias jurisprudenciales —principalmente de la CSJN—, cuadros sinópticos, síntesis de cada capítulo y comentarios relativos a las técnicas de litigación implicadas en cada etapa procesal.

Pero más allá de estos aditamentos, hemos buscado que este libro tuviera un tono pedagógico. Esta búsqueda quedó plasmada en los múltiples aspectos —algunos de detalle— que hacen a la composición de la obra: lenguaje claro y directo; ausencia de citas textuales, notas al pie y párrafos de profundización en fuente menor; jurisprudencia sólo citada de manera contextual y en formato abreviado; referencias doctrinarias limitadas a la mención del autor; expresiones en otros idiomas reducidas al mínimo y acompañadas de indicación fonética.

Intencionalmente se ha dedicado una mayor extensión y profundidad a los temas considerados centrales en el marco del nuevo proceso penal. Como contrapartida, otros temas son tratados de manera más esquemática, o dando de ellos apenas una breve noticia.

Para facilitar la lectura, se ha abundado en títulos y subtítulos, y se ha agregado un glosario de términos técnicos usuales.

Ya a título personal, agradezco la valiosa colaboración prestada por amigos, alumnos y colegas, que se materializó no sólo mediante aportes técnicos directos (que los hubo y no fueron pocos), sino también en las formas más sutiles del intercambio de ideas y hasta del apoyo y aliento continuos, sin los cuales esta empresa no hubiera podido concluir satisfactoriamente. En ambos sentidos, destaco la colaboración de Matías Drivet, Juan Manuel Oliva, Marcelo Hidalgo, Juan Manuel Neffen y Débora Antonela Winkler.

Agradezco especialmente al profesor Julio de Olazábal, quien además de brindarme su generosa y permanente colaboración se ha dejado convencer para officiar como prologuista.

Los materiales que sirvieron de base para este libro pertenecen a épocas diversas. Algunos datan de los inicios de mi práctica docente, bajo la tutela del profesor Jorge Vázquez Rossi. A la memoria de mi inolvidable mentor dedico esta obra.

PABLO COCOCCIONI

Índice

Prólogo.....	5
Presentación	9
Índice.....	11
Glosario.....	27
Abreviaturas usuales	33
Capítulo 1. El derecho procesal penal.....	35
a) Política criminal y derecho penal	35
¿Qué es la política criminal?	35
Sujetos de la política criminal.....	36
El poder punitivo	36
b) Derecho Penal y Derecho Procesal Penal	37
El Derecho Penal y su compartimentación.....	37
El Derecho Penal en sentido amplio	38
Derecho Penal sustantivo y procesal: importancia de la distinción	39
c) Normas penales sustantivas y procesales	40
El criterio de Hart.....	40
d) Normas y principios	41
e) El derecho procesal penal como rama del derecho.....	42
f) Fuentes del derecho procesal penal	42
El Bloque de Constitucionalidad y sus fuentes interpretativas	42
Fuentes infraconstitucionales	43
<i>Síntesis del capítulo</i>	44

Capítulo 2. Los modelos de proceso penal.....	45
a) Aclaración sobre la utilidad y los alcances de la perspectiva histórica....	45
b) Acusatorio clásico, material y adversarial	45
Acusatorio clásico	46
Acusatorio material.....	46
Acusatorio adversarial	47
c) Inquisitivo	48
Surgimiento.....	48
Recepción y significado político.....	49
d) Reforma del inquisitivo (mixto)	50
Surgimiento.....	50
Caracteres.....	50
Evolución y críticas.....	50
e) Reforma del mixto (acusatorio formal)	51
Surgimiento.....	51
Caracteres.....	51
f) El proceso penal en Argentina.....	52
La reacción contra el sistema inquisitivo colonial	52
Recepción del sistema inquisitivo (1888-1939).....	52
Hacia el sistema mixto (1939-1991).....	53
Hacia el acusatorio formal (1991-actualidad).....	54
g) La situación en Santa Fe	54
La perduración del sistema inquisitivo.....	54
Los proyectos de reforma.....	55
La jurisprudencia de la CSJN y el Código de 2007	55
Transición y entrada en vigencia	56
El Código de 2007: caracteres	56
h) Tendencias actuales.....	58
<i>Síntesis del capítulo</i>	59

Capítulo 3. Bases constitucionales del proceso penal.....	61
a) Constitución y proceso penal.....	61
Los dos niveles	61
Diseño constitucional del proceso penal.....	62
La Constitución, ¿impone un proceso adversarial?.....	62
b) Principios garantizadores.....	63
c) Legalidad	64
Principio de legalidad penal o material	64
Principio de legalidad procesal	65
d) Juicio previo	65
Formulación general	65
Postura de Maier	66
El juicio: ¿derecho del acusado o cuestión de interés público?	66
e) Inocencia.....	67
Formulación general	67
¿Presunción, estado o situación?.....	67
Proyecciones	68
Carga de la prueba.....	68
Beneficio de la duda.....	69
Estado de libertad durante el proceso	72
f) Debido proceso	72
g) Derecho de defensa	73
Defensa material.....	73
Defensa técnica	74
h) Protección de la persona y de su ámbito privado	75
La teoría de los círculos concéntricos (Binder).....	75
Los tres niveles de protección.....	76
Las garantías procesales como reflejo de normas prohibitivas.....	76
i) Protección contra la persecución penal múltiple	77

Formulación general	77
Alcances.....	77
Las tres identidades	78
Mecanismos procesales para plantear la garantía	79
Recurso del acusador y persecución múltiple.....	79
j) Plazo razonable.....	80
Formulación general	80
Criterio rígido o flexible	81
El criterio flexible en la jurisprudencia	81
El criterio rígido en doctrina.....	82
k) Derecho al recurso.....	83
Primera etapa: postura restrictiva.....	83
Segunda etapa: reconocimiento del derecho	83
Tercera etapa: ampliación del ámbito de revisión	84
Doble instancia, derecho al recurso, doble conforme.....	85
l) Garantías relativas al órgano de juzgamiento	85
Independencia	86
Imparcialidad.....	86
Juez natural	88
Juicio por jurados	88
m) Otras proyecciones del orden jurídico internacional.....	90
Protección de la víctima	91
Delitos priorizados.....	91
Perspectiva de género.....	92
<i>Síntesis del capítulo</i>	93
Capítulo 4. Estructura del proceso penal	97
a) El juicio como etapa y como hipótesis.....	97
La centralidad del juicio	97
El juicio ante los mecanismos negociales	98

Función alternativa del juicio	98
b) Etapas del proceso: síntesis	99
Presentación esquemática	99
Investigación penal preparatoria	99
Procedimiento intermedio	100
Juicio oral.....	100
Etapa recursiva	101
Etapa ejecutiva.....	101
c) Principios políticos o de actuación.....	102
Nociones generales	102
Principio de oficialidad	102
Principio acusatorio formal	103
Principio acusatorio material.....	103
Principio adversarial.....	104
Principio de instrucción	104
Principio de oralidad	105
<i>Síntesis del capítulo</i>	106
Capítulo 5. Sujetos	107
a) Sujetos y sistemas procesales	107
b) La víctima	107
Caracterización general.....	107
Derechos de la víctima	108
c) La fiscalía	109
El modelo burocrático-judicial (derecho continental)	109
El modelo político-criminal (derecho norteamericano)	109
La cuestión en Santa Fe: caracterización del MPA	110
Misión, funciones y perfil institucional.....	111
Estructura orgánica.....	111
d) Los organismos investigativos	114

La policía en función de investigación	114
Niveles de especialización	114
e) El querellante	116
Nociones generales	116
Tipología según su legitimación	116
Tipología según su forma de actuación	117
El querellante en el Código de Santa Fe	118
Procedimiento de constitución como querellante	120
Facultades y deberes	120
f) La persona imputada	121
Nociones generales	121
Comienzo y fin de la calidad de imputado	121
Comunicación de derechos	122
g) La defensa técnica	123
Generalidades de la defensa en materia penal	123
La defensa en el viejo sistema y en el modelo anglosajón	123
La defensa penal en el nuevo sistema: caracterización del SPPDP	124
h) El tribunal	125
Nociones generales	125
La competencia penal	126
Criterios para determinar la competencia	126
Integración unipersonal o pluripersonal del tribunal	128
i) Noticia de otros intervinientes	129
La Oficina de Gestión Judicial	129
Noticia sobre las partes civiles en otros sistemas	130
<i>Síntesis del capítulo</i>	131
Capítulo 6. Acción penal	133
a) Acción penal y sistemas procesales	133
Sistemas acusatorios: principio de disponibilidad	133

Sistema inquisitivo: principio de obligatoriedad.....	133
Disponibilidad y obligatoriedad como modelos opuestos.....	134
Las excepciones en ambos modelos.....	135
El principio de oportunidad	135
Oportunidad: fundamentos.....	136
b) Marco normativo de la acción penal.....	138
El Código Penal como ley marco	138
Las regulaciones locales y la postura compatibilista.....	138
La acción penal en el Código de Santa Fe	138
La reforma del Código Penal.....	139
c) Régimen vigente	140
<i>Síntesis del capítulo</i>	142
Capítulo 7. Prueba	143
a) La prueba y su tratamiento legal.....	143
b) Conceptos fundamentales del fenómeno probatorio	144
Nociones generales	144
Objeto de prueba	145
Órgano de prueba	146
Evidencia material	149
Medio de prueba	150
Forma de introducción	152
c) Aspectos técnicos del interrogatorio cruzado	155
Nociones generales	155
Examen directo.....	156
Contraexamen.....	159
Réplicas.....	161
Uso de declaraciones previas	162
Introducción y acreditación de evidencia material	162
Objeciones	163

d) Medios de prueba en particular	165
Nociones generales	165
Testimonio.....	165
Peritaje	166
Testimonio experto	167
Declaración del imputado.....	167
Careo.....	168
Testimonio de personas en especial situación de vulnerabilidad	169
Reconocimiento de personas	170
Reconstrucción del hecho.....	172
e) Momentos del fenómeno probatorio	172
Nociones generales	172
Valoración de la prueba	174
f) Límites al ingreso de información al proceso	175
Nociones generales	175
Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba	175
Límites a la búsqueda de evidencia material	176
Allanamiento	177
Interceptación de comunicaciones	178
g) La salvaguarda del juego limpio en relación a la prueba	179
Nociones generales	179
Las Reglas Brady	179
El deber de revelar evidencia	180
Régimen de los actos definitivos.....	181
Prueba instada por la defensa	181
h) Prueba prohibida, ilícita e irregular.....	182
Nociones generales	182
Regla de exclusión y efecto extensivo	183
Fundamentación.....	184

Excepciones o teorías de validación	184
<i>Síntesis del capítulo</i>	186
Capítulo 8. Coerción procesal	187
a) Nociones generales.....	187
El poder coercitivo	187
Clasificaciones	187
b) Medidas de coerción que afectan la libertad de la persona imputada ...	188
La situación del imputado en los distintos modelos de proceso	188
El encarcelamiento preventivo: debates sobre su naturaleza y su legitimidad	189
Principios limitadores.....	190
Requisitos	191
Supuesto material	191
Necesidad de la medida	194
¿Qué riesgos justifican el dictado de una medida coercitiva?	196
c) Medidas no privativas de libertad y medidas de atenuación	198
Nociones generales	198
Diferenciación legal	198
Zonas grises y medidas combinadas o híbridas	199
d) Procedimiento y medidas coercitivas previas	200
Requisitos formales.....	200
Detención	201
Control jurisdiccional de la detención.....	203
Cuestiones problemáticas	203
Aprehensión.....	204
Exposición esquemática	205
Actuación de la fiscalía en la audiencia de medidas coercitivas	207
Posibles estrategias defensivas.....	208
Rol del tribunal.....	210

e) Vicisitudes de las medidas coercitivas	210
Revisión	210
Cesación.....	211
f) Otras medidas que afectan la libertad de las personas	212
Incomunicación	212
Citación.....	212
Arresto	213
Medidas de coerción genérica	213
g) Medidas de coerción real.....	213
Nociones generales y aplicación supletoria del CPCyC	213
Decomiso	214
Secuestro de objetos y documentos	214
<i>Síntesis del capítulo</i>	215
Capítulo 9. Alternativas al juicio contencioso	217
a) Las alternativas en la reforma procesal penal	217
Caracterización general.....	217
Su surgimiento como institutos de excepción.....	217
Las alternativas en el nuevo sistema	218
b) Concepto y tipos.....	219
Concepto y función genérica	219
Tipología.....	219
c) Desestimación y archivo preliminar	220
Caracterización general.....	220
Causales.....	220
Procedimiento.....	221
d) Archivo fiscal	222
Caracterización general.....	222
Causales.....	223
Procedimiento.....	223

e) Archivo a solicitud de la defensa y archivo jurisdiccional	224
Instancia defensiva.....	224
Archivo jurisdiccional	225
f) Sobreseimiento.....	225
Caracterización general.....	225
Causales.....	226
Sobreseimiento por presentación conjunta.....	227
Sobreseimiento a pedido de parte	227
Efectos.....	227
g) Criterios de oportunidad.....	228
Caracterización general.....	228
Funciones	229
Supuestos legales	229
Limitaciones.....	230
Procedimiento.....	231
Observaciones a la regulación actual del instituto	232
h) Suspensión del procedimiento a prueba	234
Caracterización general.....	234
Funciones	235
Procedencia	236
Contenido del acuerdo y procedimiento	236
Improcedencia	237
Casos especiales.....	238
Alternativas en cuanto al cumplimiento.....	238
i) Procedimiento abreviado	238
Caracterización general.....	238
Mecanismos de abreviación formal	239
Abreviación material en el sistema continental	239
Abreviación material en el sistema adversarial	240

Críticas.....	241
Regulación en el Código de Santa Fe	242
<i>Síntesis del capítulo</i>	244
Capítulo 10. Etapas previas al juicio	245
a) Investigación penal preparatoria (IPP).....	245
Nociones generales	245
Relación con los organismos investigativos	245
Rol del tribunal durante la IPP	246
Audiencia imputativa (formalización de cargos)	246
Conclusión de la IPP	248
b) Procedimiento intermedio	249
Nociones generales	249
Finalidades.....	250
Aspectos procedimentales	252
Críticas a la regulación actual.....	254
c) Audiencias previas al juicio	255
La oralización de las etapas previas y el surgimiento de las APJ	255
Caracterización.....	255
Más allá de las APJ: las audiencias diversas al juicio	257
<i>Síntesis del capítulo</i>	258
Capítulo 11. Juicio oral y sentencia.....	259
a) Caracterización general de la etapa de juicio	259
La centralidad del juicio	259
Caracteres.....	259
b) Estructura y desarrollo	263
Esquema general	263
Preparación del debate	264
Debate	264
Producción de la sentencia	266

c) Rol de los sujetos	267
El tema desde la TGP y desde las Reglas de Mallorca	267
Rol del tribunal.....	269
Rol de la fiscalía.....	270
Rol de la querella.....	270
La persona imputada.....	270
Rol de la defensa técnica	271
d) La sentencia	272
Nociones generales	272
Estructura	272
El deber de fundamentación.....	273
e) Correlación entre acusación y sentencia	275
Nociones generales	275
El principio de congruencia	275
Congruencia y calificación jurídica.....	276
Imposibilidad de aplicar sanciones más severas que las solicitadas.....	278
f) Una cuestión pendiente: la cesura del juicio.....	279
Nociones generales	279
Funciones	280
Situación en Argentina y a nivel local.....	280
<i>Síntesis del capítulo</i>	281
Capítulo 12. Recursos	283
a) Lo conceptual y lo terminológico	283
Nociones generales	283
Criterios restrictivos y mecanismos de naturaleza dudosa	283
b) Clasificación	284
Recursos en sentido estricto y en sentido amplio	284
Recursos ordinarios, extraordinarios y excepcionales	285
c) Conceptos básicos de la mecánica recursiva	285

Recurribilidad objetiva y subjetiva	286
Condiciones de interposición	287
Sustanciación	288
Efectos.....	288
d) Recursos en particular	289
Reposición	289
Apelación	290
Casación, casación ampliada y recurso innominado	292
Inconstitucionalidad	292
Recurso Extraordinario Federal	293
Revisión	294
<i>Síntesis del capítulo</i>	295
Capítulo 13. Procedimientos especiales	297
a) Algunas distinciones: procedimientos especiales e institutos compositivos	297
b) Procedimientos especiales basados en la distinta gravedad y complejidad del caso.....	298
Nociones generales y antecedentes	298
Procedimiento contravencional.....	298
Procedimiento por flagrancia	299
Procedimiento extendido	299
c) Procedimiento por delito de acción privada	299
d) Noticia de otros procedimientos especiales.....	300
Procedimiento para la reparación del daño	300
Hábeas Corpus	300
Proceso penal juvenil.....	301
<i>Síntesis del capítulo</i>	302
Capítulo 14. Ejecución penal.....	303
a) Aspectos procesales del derecho de ejecución penal.....	303
Surgimiento.....	303

Dos modelos de control de los lugares de encierro	303
Los juzgados de ejecución penal	304
b) Ejecución de la pena privativa de libertad	305
La ley 24.660 y el Código de Santa Fe.....	305
La abolición del fuero especializado	305
Los incidentes de ejecución.....	306
c) Ejecución de penas y medidas no privativas de libertad	306
<i>Síntesis del capítulo</i>	306
Lecturas de complemento	309

Glosario

Archivo fiscal: Resolución desincriminatoria, dictada por el fiscal una vez realizada la audiencia imputativa en caso de mediar certeza negativa o insuficiencia probatoria para acusar.

Archivo jurisdiccional: Resolución dictada por el tribunal, a pedido de la defensa, ante la negativa del fiscal a archivar.

Atenuación de la coerción: Modificación de la forma de cumplimiento de la prisión preventiva ya impuesta. También pueden considerarse medidas coercitivas autónomas, en principio más gravosas que las medidas no privativas de libertad.

Audiencia imputativa: Audiencia que tiene por objeto comunicar al imputado la atribución delictiva que pesa en su contra y brindarle información tendiente al ejercicio de sus derechos en un marco garantizador. Se realiza en sede judicial o fiscal, según el imputado se encuentre o no detenido. En la literatura jurídica adversarial, esta instancia se denomina *formulación de cargos*.

Audiencia preliminar: Audiencia que tiene lugar durante el llamado procedimiento intermedio, y que ordinariamente tiene como propósito agotar las posibilidades de arribar a una salida alternativa, o subsidiariamente preparar, ordenar y sanear el eventual juicio oral.

Audiencias previas al juicio: La expresión refiere a las audiencias que tienen lugar en la etapa investigativa y hasta el procedimiento intermedio, y que en general comparten una caracterización en común (estructura flexible, rol proactivo del tribunal, argumentatividad como regla, brevedad y agilidad) y hasta una técnica específica de litigación, que las diferencia del juicio plenario. Con la oralización de las instancias recursivas y ejecu-

tivas, comienza a plantearse un concepto más amplio de *audiencias diversas al juicio*.

Cesación de la prisión preventiva: Instituto que limita la duración de la prisión preventiva, en base a la desproporción con la gravedad de la pena en expectativa o al vencimiento de su plazo máximo legal.

Cesura del juicio: División del juicio de conocimiento en dos etapas, a fin de tratar separadamente la autoría o participación en el hecho punible, de las circunstancias relevantes para la individualización de la pena.

Colegio de Jueces: Entidad conformada por la totalidad de los jueces de idéntica competencia material, territorial y funcional, a los fines de integrar aleatoriamente el tribunal que intervendrá en un caso concreto. También llamado *pool de jueces*.

Control de detención: Instancia en la que el tribunal ejerce el control de la legalidad y forma de cumplimiento de la detención, al ser llevado el imputado ante su presencia. En nuestro sistema, esto se prevé en ocasión de la audiencia imputativa judicial.

Declaraciones previas: Actos o manifestaciones de los órganos de prueba con anterioridad al juicio, intraprocesales o extraprocesales, registrados o plasmados por cualquier medio. Carecen de entidad probatoria autónoma (por lo que no se considera “evidencia”, término que se reserva para la evidencia material), aunque se permite limitadamente su utilización en interrogatorio.

Defensa material: Actividad defensiva desarrollada en el marco del proceso por la propia persona imputada, ya sea a través de su declaración o realizando actividades que implican la transmisión voluntaria de información.

Defensa técnica: Actividad defensiva de carácter técnico-jurídico, que como regla está a cargo de abogados particulares u oficiales (la autodefensa técnica se considera excepcional). Consiste en el despliegue de actos de postulación, contralor, probatorios, recursivos y de otro tipo, que de ordinario exigen contar con un conjunto de conocimientos y destrezas específicos.

Detención: Medida coercitiva privativa de libertad, de corta duración, dictada por la fiscalía con el propósito de asegurar la presentación del imputado ante el tribunal.

Evidencia (como grado de convicción): Nivel de conocimiento en el que se considera un hecho como imposible de negar, no siendo necesaria mayor acreditación. Equivalente práctico de la certeza, principalmente en el marco de resoluciones desincriminatorias (archivo fiscal, archivo jurisdiccional y sobreseimiento).

Evidencia material: Elementos de convicción consistentes en una materialidad objetiva, tales como documentos, objetos e informes. Poseen entidad probatoria autónoma, aunque como regla deben introducirse en juicio a través de testigos u otro órgano de prueba.

Extensión extraordinaria de la prisión preventiva: Prórroga de la prisión preventiva, que permite superar el plazo máximo ordinario de dos años.

Fiscalía: Órgano estatal a cargo del ejercicio de la acción penal pública. En el marco de los actuales modelos acusatorios, le incumbe también la dirección de la actividad investigativa.

Imputado/a: Persona señalada como autor o partícipe de un hecho afirmado como delictual. En general, basta con el mero señalamiento para que se reconozca a una persona como imputada, a efectos de hacerle saber los derechos que le corresponden por tal calidad.

Interrogatorio cruzado: Mecánica de tipo adversarial para el interrogatorio de los testigos y otros órganos de prueba. Consiste en la examinación a cargo de la parte que ofrece el testimonio, con posibilidad de que la contraria contraexamine luego, teniendo ambos exámenes objetivos, estructuras y técnicas diferenciadas.

Investigación penal preparatoria: Etapa procesal a cargo del fiscal, con control jurisdiccional. Tiene por finalidad el esclarecimiento del hecho con apariencia delictual, la individualización de las personas imputadas, la recolección de elementos de convicción y el cumplimiento de las diligencias y actos tendientes al avance del proceso. En los sistemas reformados, también tiene como finalidad específica la aplicación de salidas alternativas.

Juicio: Etapa central del proceso, cuyo núcleo es un debate oral, público y contradictorio entre las partes, ante un tribunal imparcial. También se lo denomina *plenario* (antiguamente, por oposición al *sumario*, que era la etapa investigativa), *juicio de conocimiento* (en la formulación de Binder, por oposición al *juicio compositivo*) o *juicio contencioso* (nuestra postura, ya que tiene lugar ante la falta de resolución del conflicto por vías alternativas). En otro sentido, razonamiento contenido en la sentencia (como juicio lógico, según la postura de Maier).

Jurado: En sentido propio, cuerpo jurisdiccional encargado de dictar un veredicto, producto de la deliberación y votación secretas, sobre la culpabilidad de la persona acusada. Este es el modelo de jurado puro, propio del sistema anglosajón. En el mundo continental, suele usarse el término *jurado escabinado* para referirse a los tribunales mixtos.

Medidas no privativas de libertad: Medidas coercitivas de menor impacto, que en general implican el sometimiento de la persona imputada al cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Su amplificación en el contexto de los sistemas reformados constituye un intento por reducir el uso de la prisión preventiva.

Oportunidad: En sentido estricto (criterios de oportunidad), desistimiento reglado y controlado de la acción pública. Alguna doctrina utiliza el término en un sentido más amplio (principio de oportunidad), aludiendo al mismo como fundamento de los institutos que atenúan el principio de obligatoriedad de la acción pública o alguno de sus corolarios. En esta última acepción, el principio de oportunidad fundamentaría institutos como los criterios de oportunidad, la suspensión del procedimiento a prueba y hasta el procedimiento abreviado.

Perito: Persona que declara sobre hechos que conoció por encargo judicial y sobre los que posee una especial versación. El perito deberá producir un dictamen escrito, cuya naturaleza es discutida (ordinariamente funcionará como declaración previa, aunque para algunos excepcionalmente puede considerarse evidencia material).

Prisión preventiva: Medida coercitiva que consiste en privar a la persona imputada de su libertad ambulatoria sin haber condena firme. Existen múltiples debates sobre su naturaleza y su legitimidad, y en general las legislaciones tienden a rodear al instituto de ciertas garantías y de ofrecer un conjunto de otras medidas que permitan cierto escalonamiento o gra-

dualidad en la coerción, quedando la prisión preventiva como último recurso.

Procedimiento abreviado: Instituto que permite acordar entre las partes la aplicación de una pena, prescindiendo del debate contradictorio. En su regulación actual exhibe rasgos que lo acercan al modelo adversarial, aunque la jurisprudencia parece rechazar esta idea.

Prueba: El término hace referencia a distintos fenómenos. En el marco de nuestro sistema, se debería denominar prueba a aquellos elementos de convicción producidos o exhibidos válidamente durante el juicio, y en los cuales el tribunal debe basar su sentencia. Por el contrario, las declaraciones previas y cualquier otro elemento no introducido de esta forma no podrán válidamente fundar el decisorio.

Querellante: Persona que actúa en el proceso como acusador privado. La figura del querellante reconoce diversas modalidades en el derecho comparado, en cuanto a su legitimación y a su forma de actuación.

Revisión de la prisión preventiva: Reexamen sobre la subsistencia de los motivos que justifican la prisión preventiva, a la luz de nuevos elementos o del transcurso mismo del tiempo.

Sentencia: Pronunciamiento judicial que decide sobre el mérito del caso, una vez tramitado íntegramente el proceso. La definición alude principalmente a la llamada sentencia material, aunque también existe la sentencia formal (aquella que recepta una cuestión previa) y la sentencia de reenvío (como producto de un recurso).

Sobreseimiento: Pronunciamiento judicial de contenido desincriminatorio, dictado por presentación conjunta o a pedido de una de las partes, en caso de mediar certeza negativa sobre el hecho. La reforma no contempla el sobreseimiento por duda insuperable, situación que en nuestro sistema da lugar al archivo fiscal o jurisdiccional.

Suspensión del procedimiento a prueba: Pronunciamiento jurisdiccional que suspende el avance del proceso penal, por un plazo durante el cual el imputado se compromete a observar determinadas reglas de conducta. El instituto comparte algunos caracteres con las demás alternativas al juicio contencioso, aunque su naturaleza resulta discutida. La jurisprudencia

dencia actual tiende a reconocerle naturaleza sustantiva, en cuanto genera un verdadero derecho en cabeza del imputado.

Teoría del caso: A efectos prácticos, es la versión de los hechos sostenida por cada litigante y presentada ante el tribunal a través de diversas actividades. Estructuralmente, contiene una teoría fáctica, una teoría probatoria y una teoría jurídica. Se considera que una buena teoría del caso debe ser simple, coherente, verosímil y compatible con la evidencia no controvertida.

Testigo: Persona que declara en el proceso sobre hechos que percibió de manera accidental o espontánea. En un sentido más amplio, refiere a quienes actúan como órgano de prueba (como los peritos, o la persona imputada).

Tribunal: En general, órgano jurisdiccional, ya sea unipersonal o pluripersonal. Puede ser puramente técnico, o estar integrado en forma conjunta por jueces permanentes y jurados accidentales (en este caso, se denomina *tribunal mixto* o *jurado escabinado*).

Víctima: Persona ofendida o particularmente afectada por un hecho delictual, aunque no se trate necesariamente del titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. En general se reconoce como víctima a quien se presente como tal, permitiéndole ejercer los derechos derivados de tal calidad.

Abreviaturas usuales

CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CEDH	Comisión Europea de Derechos Humanos
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CN	Constitución Nacional
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CPP	Código Procesal Penal (de Santa Fe, salvo indicación)
CSFe	Constitución de Santa Fe
CSJSFe	Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
CSJN	Corte Suprema de Justicia de la Nación
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
MPA	Ministerio Público de la Acusación
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
SPPDP	Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Capítulo 1. El derecho procesal penal

a) Política criminal y derecho penal

¿Qué es la política criminal?

§ 1. El libro debe empezar por algún lado. Y por múltiples motivos, me ha parecido útil dar cuenta inicialmente de la inserción del sistema penal -y del proceso penal en particular- en el ámbito más amplio de la *política criminal*. Es decir: partimos de la idea de que el proceso penal -y el sistema penal en su conjunto- es una manifestación de la política criminal. Pero, ¿qué se entiende por “política criminal”?

Proponemos una aproximación a esta pregunta, diciendo que *la política criminal es el conjunto de acciones estatales tendientes a controlar el delito*. Acciones que pueden ser de diversa naturaleza. Colocar cámaras de videovigilancia en zonas de gran incidencia delictiva es una acción de política criminal. Mejorar la iluminación en determinados sectores, cuando se considera que la oscuridad puede constituir un factor de riesgo, es una acción de política criminal. Un programa de intervención comunitaria en un barrio con índices elevados de criminalidad o violencia, es una acción de política criminal.

El límite a veces se vuelve borroso. Las acciones estatales se consideran de política criminal *en la medida en que están particularmente orientadas a influir sobre el fenómeno delictual*. Por ejemplo, es un lugar común decir que los problemas de criminalidad se solucionarían con más educación, o con más inclusión social, o mejorando la economía. Si bien esto puede ser en parte cierto, está claro que inaugurar una escuela o instituir un programa de ayuda social no constituyen de por sí acciones de política criminal.

No obstante, es correcto afirmar que la mayoría de las políticas estatales se interrelacionan y complementan entre sí, pudiendo surtir efectos -positivos o negativos- en una pluralidad de campos. Por ejemplo, un programa de educa-

ción sexual (política educativa) puede contribuir a prevenir el contagio de enfermedades (política de salud). En otro sentido, los períodos de crisis económica con reducción del empleo (variable de la política económica) son frecuentemente asociados, a largo plazo, a la producción de situaciones de marginalidad (problema de política social) y al aumento de los delitos (problema de política criminal). Por ello, la política criminal, para ser eficaz, debe ser necesariamente *interagencial*: debe relacionarse con los actores no penales -por así llamarlos-, dentro del Estado y fuera de él.

Sujetos de la política criminal

§ 2. La política criminal *reconoce como sujeto primario al Estado*, a través de sus diversos segmentos: órganos legislativos, ministerios del poder ejecutivo, fiscalías, agencias policiales y penitenciarias, gobiernos locales, entre otros. La interrelación de estos segmentos puede tener momentos de tensión, e incluso de enfrentamiento, aunque también hay numerosos ejemplos de actuación coordinada entre distintas agencias.

Si bien la política criminal es una actividad eminentemente estatal, ello no excluye la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan formular propuestas, realizar críticas, participar en instancias de diálogo y, eventualmente, actuar en coordinación con los organismos estatales. En nuestro medio, hay ejemplos concretos de esta articulación entre Estado y sociedad civil en materia de política criminal:

- Los consejos asesores regionales, que funcionan como organismos de apoyo a la gestión de las fiscalías.
- Los consejos de seguridad que funcionan en algunos municipios y comunas.
- Las experiencias de control comunitario de reglas de conducta.
- Las iniciativas de persecución penal comunitaria.

El poder punitivo

§ 3. Como se ha señalado inicialmente, la política criminal comprende un amplísimo abanico de acciones estatales.

Algunas de estas acciones son jurídicamente inocuas, es decir que no lesionan ni ponen en peligro los derechos de los ciudadanos (por ejemplo, mejorar la iluminación en determinado lugar con el fin de prevenir situacionalmente

los asaltos). Sin embargo, otras acciones implican el sacrificio, en cierta medida, de algunos de aquellos derechos.

Motivos de orden histórico han determinado que se considere al poder punitivo como la manifestación más violenta de la coacción estatal. De ahí que se haya contrapuesto a la política criminal el Derecho Penal, entendido como un sistema normativo e institucional de protección del individuo frente al Estado, y en particular frente a la amenaza de la pena estatal. Dicho de otro modo, el Derecho Penal confronta, cuestiona y limita a la Política Criminal. Esta idea ha sido actualizada doctrinariamente señalando que el Derecho Penal es un discurso de contención y reducción del poder punitivo (Zaffaroni), o destacando la tensión esencial entre Derecho Penal y Política Criminal (Binder).

Sin embargo, y aunque aceptemos la especificidad del fenómeno penal por motivos históricos, políticos y sociales, debe reconocerse que existen importantes zonas para el ejercicio de la violencia estatal en la órbita del Derecho Privado. ¿Quién podría decir, por ejemplo, que un desalojo forzoso es menos violento, o menos coactivo, que una multa? Pues bien, el primero no reviste carácter penal y la segunda sí. Ello no debe llevar a desconocer que el fenómeno penal ha dado sobrados motivos para que estemos por demás de prevenidos, pero sí debe corrernos la venda sobre la supuesta inocencia de los asuntos civiles en comparación a los penales.

Estas consideraciones requieren ser complementadas con algunas precisiones.

b) Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

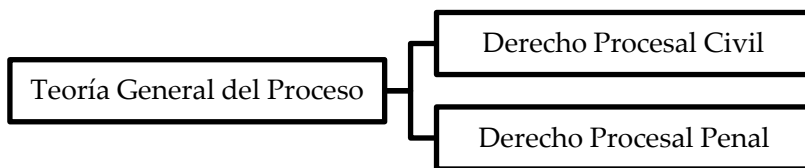
El Derecho Penal y su compartimentación

§ 4. El Derecho Penal, desde su origen como sistema de protección frente al poder punitivo, se ha ocupado de tres grandes temas:

- La definición y delimitación de los supuestos que habilitan aquel ejercicio (teoría del delito).
- La determinación de las consecuencias jurídicas de la infracción (teoría de la reacción penal).

- El procedimiento para establecer si están dadas todas las condiciones para la aplicación de sanciones penales en el caso concreto (teoría del proceso penal).

Por razones de vieja data, los dos primeros ítems se desarrollaron en forma conjunta bajo la denominación de Derecho Penal Sustantivo, mientras que el estudio de las reglas del procedimiento dio origen al Derecho Procesal Penal, que eventualmente pasó a convertirse en un capítulo de la llamada Teoría General del Proceso.

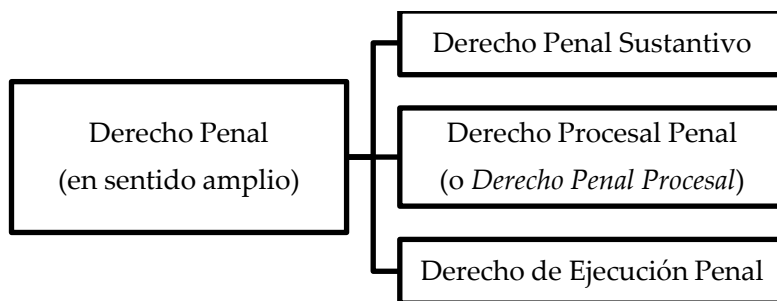


Este enfoque integral y autónomo del fenómeno procesal ha tenido un importante rendimiento práctico en nuestra materia. Por ejemplo, al definir el proceso como debate entre dos iguales ante un tercero imparcial, o al establecer que las medidas de coerción personal están sujetas a los presupuestos generales de las medidas cautelares. Pero, en contrapartida, ha erosionado la potencialidad teórica del proceso penal para establecer límites garantizadores frente al poder punitivo.

El Derecho Penal en sentido amplio

§ 5. Frente a esta versión aséptica y un tanto despolitizada del Derecho Procesal Penal, se ha propuesto reentroncarlo, junto con el Derecho Penal Sustantivo, en un *Derecho Penal en sentido amplio o integrado*, comprensivo de las disciplinas jurídico-penales limitadoras del poder punitivo. Por lo que alguna doctrina propone referirse al Derecho Procesal Penal como *Derecho Penal Procesal* (por ej., Vázquez Rossi), para enfatizar aquel entroncamiento común.

Esta perspectiva también permite resolver satisfactoriamente la ubicación disciplinar del *Derecho de Ejecución Penal*, que por ser una rama híbrida (congrega normas sustantivas, procesales y administrativas) difícilmente pueda adscribirse por completo al Derecho Penal en sentido estricto o a una eventual Teoría General del Proceso.



Este Derecho Penal, del que hablamos en sentido amplio, es el que condiciona y limita el ejercicio del poder punitivo, tensionando así con la política criminal en la cual se inscribe ese ejercicio. Desde esta perspectiva, resultan discutibles algunas formulaciones según la cual el Derecho Penal viene a materializar o a realizar una determinada política criminal. Más bien lo que hace es condicionar, limitar y racionalizar, hasta donde sea posible, la más severa de sus herramientas: el poder punitivo.

Derecho Penal sustantivo y procesal: importancia de la distinción

§ 6. La perspectiva integral que se sostiene no impide distinguir conceptualmente Derecho Penal Sustantivo y Derecho Procesal Penal. De hecho, esta distinción resulta absolutamente necesaria, porque la facultad de dictar el Código Penal corresponde al Congreso de la Nación (art. 75.12, CN), mientras que las regulaciones procesales se consideran una materia reservada por las provincias (art. 5 y 121, CN). Por ello, la naturaleza sustantiva o procesal de determinado instituto es lo que indicará si es el orden nacional o el local el que posee atribuciones legiferantes para regularlo.

Con todo, el deslinde de competencias entre la nación y las provincias no ha sido pacífico. Algunos puntos conflictivos son:

- El Código Penal contiene normas que son claramente procesales (por ej., el régimen de la acción penal), lo cual se intentó justificar de distintas formas.
- Existen instituciones cuyo funcionamiento requiere necesariamente de la concurrencia de disposiciones sustantivas y procesales (por ej., cómputo de la prisión preventiva). En este caso, se habla de normas *complejas, ambivalentes o bifuncionales*.

- La propia Constitución Nacional genera serias dudas cuando atribuye al Congreso la facultad de establecer el *juicio por jurados* para causas criminales (CN, 24, 75.12 y 118). Hay quienes opinan que estas cláusulas habilitan a la Nación a dictar una ley marco para todo el país (Maier), lo cual acarrearía la centralización en gran medida del derecho procesal penal.

§ 7. Hay otra razón para distinguir el derecho penal sustantivo del procesal. El carácter penal sustantivo de una norma o de un instituto vuelve aplicable un conjunto de principios constitucionales referidos exclusivamente a la definición de un hecho como delictivo y a la determinación de las consecuencias legales de la infracción. Centralmente, estamos hablando del principio de legalidad penal (art. 18, CN), con las reglas y criterios de interpretación que se derivan del mismo.

c) Normas penales sustantivas y procesales

§ 8. Aun reconociendo que las normas penales sustantivas y procesales comparten un significado limitador común respecto de la política criminal, las cuestiones señaladas anteriormente llevan a que deba haber algún criterio distintivo entre ellas.

El criterio de Hart

§ 9. Ha resultado bastante útil acudir a la distinción -formulada por Hart- entre *normas que imponen deberes* (imperativas) y *normas que otorgan facultades* (potestativas).

Las normas del derecho penal sustantivo imponen deberes, entendiendo que las prohibiciones son deberes negativos (por ej., no matar). La infracción a este deber (delito) es asociada a la imposición de una pena (sanción). Este tipo de normas se comprende fácilmente recordando la idea kelseniana.

Las normas procesales usualmente no imponen deberes cuyo incumplimiento se sanciona, sino que otorgan potestades. En este caso, la conducta no es obligatoria, pero sí resulta necesaria para producir determinados efectos jurídicos. Por ejemplo: para lograr la revocación de una sentencia, hay que interponer un recurso, dentro del plazo y con las formalidades que establece la ley, y si no se lo hace no hay sanción alguna, pero no será posible lograr la

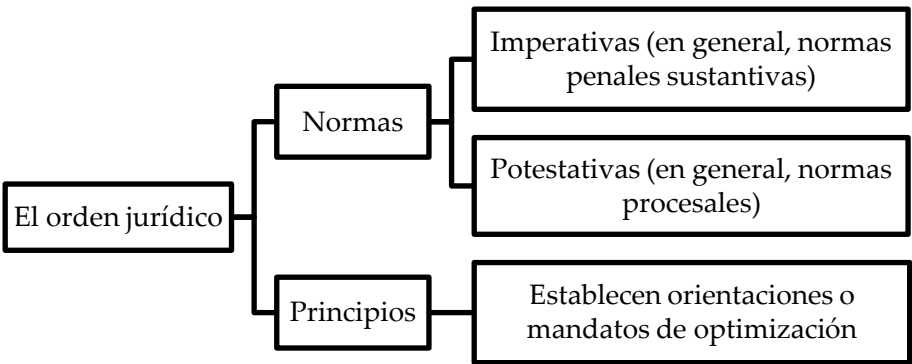
revocación. Esto tiene alguna relación con la noción de carga procesal, pero las normas potestativas exceden en mucho nuestra materia.

d) Normas y principios

§ 10. El orden jurídico está compuesto de *normas y principios*. Las normas usualmente tienen alguno de los formatos que acabamos de describir, según impongan deberes u otorguen facultades. En ambos casos, se aplican en forma disyuntiva, rigen o no rigen según se den o no los hechos que son su presupuesto. Si éstos se dan, se producen las consecuencias jurídicas.

Los principios, en cambio, rigen en más o en menos. Es decir, en cada caso concreto hay que hacer un balance de los principios en juego (Dworkin). Otra formulación de esta idea es que los principios son mandatos de optimización, es decir que ordenan que algo sea realizado dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto implica la necesidad de realizar ponderaciones en caso de colisión de principios (Alexy).

Como veremos, el derecho procesal penal no puede seguir siendo definido como un *conjunto de normas que regulan el proceso penal*, sencillamente porque el derecho en sí ya no es visto como un conjunto sólo de normas.



e) El derecho procesal penal como rama del derecho

§ 11. Hasta hace algún tiempo, era frecuente clasificar al derecho procesal penal como derecho *interno, público y local*. Sin desconocer que en términos generales esa caracterización sigue siendo correcta, debe aclararse que actualmente esos rasgos se encuentran en cierto declive.

- Las fuentes del derecho procesal penal están atravesando un proceso de *internacionalización*, producto de la consagración de principios garantizadores en instrumentos internacionales.
- También vivimos un proceso de *internacionalización parcial de la jurisdicción penal*. A partir de las grandes catástrofes humanitarias del siglo veinte, se ha expandido el criterio universal para el juzgamiento de crímenes contra la humanidad, llegando en algunos casos a instituirse tribunales supranacionales.
- La revalorización de la víctima y la idea del proceso penal como un ámbito de composición de los conflictos sociales ha generado un cierto rasgo *privatista* en los actuales procesos de reforma. En el mismo sentido puede interpretarse el nuevo florecimiento de la acción penal privada ejercida mediante querrela particular.
- La discusión respecto a la posible facultad nacional de regular el juicio por jurados, las normas procesales contenidas en leyes sustantivas, y en general el abuso de la supuesta indistinción entre derecho penal sustantivo y procesal, son flancos desde los que hoy *se pone en debate que se trate de un derecho eminentemente local*.

f) Fuentes del derecho procesal penal

El Bloque de Constitucionalidad y sus fuentes interpretativas

§ 12. Las normas y principios que rigen el proceso penal reconocen como fuente principal el bloque de constitucionalidad, integrado por la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos con idéntica jerarquía (CN, 75.22).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado un gran valor a la jurisprudencia de los organismos de protección del sistema interamericano.

Especialmente, y a partir del caso “Ekmekdjian c/ Sofovich” (1992), se reconoce que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Este criterio fue luego aplicado en los fallos “Arancibia Clavel” (2004), “Simón” (2005), “Verbitzky” (2005), “Llerena” (2005), “Casal” (2005), “Gramajo” (2006) y “Arriola” (2009), entre muchos otros.

Por la importancia que reviste para nuestra materia, debe destacarse el *Proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Penal* (Reglas de Mallorca). Nuestra Corte nacional ha señalado, en el precedente “Llerena” (2005), que dicho proyecto adelanta la consolidación de una interpretación de las normas internacionales.

Fuentes infraconstitucionales

§ 13. También son fuentes del derecho procesal penal las normas procesales contenidas en leyes de fondo, la Constitución Provincial y la legislación local común.

En el ámbito de la provincia de Santa Fe, el cuerpo normativo de mayor relevancia para nuestra materia es, sin lugar a dudas, el Código Procesal Penal (ley 12.734 y modificatorias).

Otras leyes de importancia son:

- Ley 13.013 (Ministerio Público de la Acusación).
- Ley 13.014 (Defensa Penal).
- Ley 13.018 (Justicia Penal y Oficina de Gestión Judicial).
- Ley 13.459 (Organismo de Investigaciones).
- Ley 13.494 (Protección de Víctimas y Testigos, y Fondo Provincial de Re-compensas).
- Ley 13.579 (Administración y destino de efectos relacionados con la actividad ilícita).
- Ley 13.774 (Código de Convivencia).

Síntesis del capítulo

1. *La política criminal es el conjunto de actividades estatales tendientes a controlar el delito. Es una actividad estatal, que implica relacionamientos con la sociedad. Su manifestación históricamente más violenta es el poder punitivo.*
2. *El Derecho Penal nace como un sistema de protección frente al poder punitivo. Hoy se plantea la necesidad de recuperar una idea de Derecho Penal en sentido amplio, que supere las compartimentaciones aun reconociendo diferencias entre las normas penales sustantivas y procesales.*
3. *Fuentes.*
 - a. *Bloque de Constitucionalidad: Constitución Nacional, tratados con igual jerarquía, instrumentos no convencionales, precedentes.*
 - b. *Infraconstitucionales: Código Procesal Penal y leyes de complemento.*

Capítulo 2. Los modelos de proceso penal

a) Aclaración sobre la utilidad y los alcances de la perspectiva histórica

§ 14. Las consideraciones histórico-políticas que se formulan a continuación tienen como único propósito explicar los distintos modelos de proceso penal desde una perspectiva realista. Aun así, la explicación de cada modelo termina siendo un tanto esquemática, como inevitablemente lo impone la necesidad de tipificar cada sistema procesal penal concreto dentro de unas pocas categorías conceptuales.

Debe quedar claro que los modelos de proceso penal son sólo eso, modelos explicativos, que en modo alguno deben confundirse con los sistemas “reales” vigentes en un determinado contexto geográfico, histórico y político. No debe sorprender, entonces, el hallazgo de *algún rasgo inquisitivo en un sistema acusatorio*, o a la inversa.

b) Acusatorio clásico, material y adversarial

§ 15. El término acusatorio es utilizado promiscuamente para designar una pluralidad de sistemas diversos, por lo cual deben aclararse en alguna medida sus distintas acepciones.

- Se designa como *acusatorio clásico* al antiguo modelo grecorromano.
- Se designa específicamente como *acusatorio material* al primitivo sistema de los germanos. Pero en un sentido más amplio, la expresión alude a los sistemas o institutos que tienden a enfatizar el rol de los protagonistas originarios del conflicto.

- Se designa como *acusatorio adversarial* al sistema vigente en los países anglosajones.
- Más adelante se tratará el sistema *acusatorio formal*, que no deriva del acusatorio sino del inquisitivo.

Acusatorio clásico

§ 16. El *acusatorio clásico* tiene su origen en la democracia ateniense, y con diferencias menores es el que adopta Roma en la etapa de la república. Obviamente, utilizamos los términos “democracia” y “república” de acuerdo a los criterios de ciudadanía vigentes en aquellos contextos históricos.

El proceso comenzaba con la acusación por parte del ofendido (acción privada). En caso de delitos que afectaban a la comunidad (por ej., envenenamiento de aguas), cualquier ciudadano estaba facultado para acusar (acción popular).

La acusación daba lugar a un debate oral, público y contradictorio entre las partes. Correspondía al acusador la carga de la prueba, y la defensa era absolutamente libre, pudiendo en algunos casos delegarse la defensa en otro ciudadano.

La jurisdicción estaba ordinariamente a cargo de tribunales populares integrados por ciudadanos (había excepciones, en general relacionadas con los delitos políticos), actuando un funcionario oficial al solo efecto de dirigir el debate y en su caso imponer y ejecutar la sentencia. La deliberación y votación eran secretas, y el veredicto era inapelable.

En el caso de Roma, el advenimiento del imperio coincide con el declive del proceso acusatorio. En esta etapa, la acusación privada comienza a ser suplida paulatinamente por la actuación oficiosa de funcionarios estatales, quedando así sentada una de las bases de lo que sería luego el sistema inquisitivo.

Acusatorio material

§ 17. Los antiguos pueblos germanos no distinguían entre infracciones penales y civiles. En su derecho de base consuetudinaria, el crimen representaba la pérdida de la paz, por la posibilidad de venganzas recíprocas entre clanes. La ausencia de una autoridad estatal formal hacía que los medios de resolución

enfataran la participación directa de los protagonistas del conflicto, por lo que este sistema suele denominarse *acusatorio material*.

Normalmente, los conflictos se resolvían por medio del *combate* entre los contendientes, aunque podía evitarse el combate físico mediante el *juicio público*. Debe aclararse que, para los germanos, la prueba rendida en juicio no perseguía convencer al tribunal de cómo ocurrieron los hechos que dieron lugar al conflicto, sino que consistía en juramentos rituales y fórmulas místicas. El desarrollo posterior de esta prueba ritual dio lugar a las *ordalias* o *juicios de dios*, cuya práctica se generaliza hacia la Edad Media.

Otra forma de evitar el combate era la *reparación*, que podía ser económica (por ej., mediante una entrega de ganado) o simbólica (por ej.: el castigo del infractor a manos de su propia tribu). Si bien desde una perspectiva actual el sistema de los germanos puede parecer un tanto primitivo, la reconducción de los conflictos sociales hacia mecanismos de reparación es la idea que subyace a algunas de las actuales vías compositivas, tales como la *suspensión del procedimiento a prueba* o algunos casos de *criterios de oportunidad*.

Acusatorio adversarial

§ 18. A comienzos del medioevo, Britania es invadida por pueblos germanos (particularmente anglos, jutos y sajones), dando lugar a un proceso de recepción del derecho consuetudinario germánico en los territorios ocupados. La evolución de este derecho común consuetudinario dará lugar al *proceso adversarial inglés*.

Este sistema originariamente se basa en la acción privada o popular, que da lugar a un juicio público ante un jurado de vecinos del lugar de los hechos. Esto es entendido como un derecho del acusado, a punto tal que más adelante los anglosajones reivindicarán el “juicio de sus pares” como una forma de resistir el yugo normando durante el siglo XI.

Algunas garantías típicas del modelo adversarial son consagradas en la Carta Magna de 1215, arrancada a Juan sin Tierra por los nobles ingleses. Si bien se trata de un instrumento que establece garantías principalmente en favor de los nobles, desde una perspectiva actual se lo puede rescatar en cuanto significó un límite al poder real.

§ 19. En la evolución posterior del proceso penal inglés, con la formulación de cargos se da intervención al *oficial de custodia*, que viene a ser un funcionario policial con facultades de ejercer la acción penal. Recién en la década de 1980 se

institucionaliza la *fiscalía*, que aun así no desplaza al oficial de custodia, sino que lo complementa.

El jurado resuelve por íntima convicción, siendo el veredicto irrecurrible en cuanto al fondo. No obstante, debe señalarse que en el proceso penal inglés existe una muy desarrollada rama del derecho dedicada a las reglas de admisibilidad, pertinencia y valoración de la prueba. Con lo cual, si bien el contenido del veredicto no es modificable, el procedimiento que lleva a su dictado es susceptible de anulación.

§ 20. La colonización inglesa en América del Norte a partir del siglo XVII genera una profunda *asimilación cultural del proceso adversarial* por parte de los colonos. En particular, la institución del juicio por jurados fue posteriormente invocada como un medio de resistencia frente al opresor colonial.

El sistema estadounidense es considerado, hasta el día de hoy, el modelo prototípico de proceso adversarial, aún más que el propio modelo inglés. Y a diferencia de éste, está claro que el modelo norteamericano le otorga una relevancia política notable a la figura del fiscal, a punto tal que la Fiscalía General es prácticamente contemporánea a la declaración de independencia (1776). Con todo, el carácter público de la persecución penal no ha trastocado el carácter acusatorio del sistema, que sigue siendo un proceso de partes. Exagerando un poco, podría decirse que el fiscal norteamericano posee sobre la acción penal pública casi el mismo poder de disposición que entre nosotros se concede a la acción privada.

c) Inquisitivo

Surgimiento

§ 21. El advenimiento de la Inquisición en la Europa continental dio lugar al modelo procesal que hasta hoy lleva su nombre. Este procedimiento reconoce como fuentes el *derecho romano imperial tardío*, en cuanto presupone la actuación de funcionarios dedicados a la investigación oficiosa de los delitos, y el *derecho de los pueblos germánicos*, principalmente por la utilización de pruebas místicas como las ordalías o juicios de dios. A partir de la prohibición de las ordalías -decretada por el Concilio de Letrán de 1215-, la base probatoria de este procedimiento pasa a ser la *confesión*, frecuentemente obtenida mediante tortura.

El procedimiento era secreto, y progresivamente fue imponiéndose la registración escrita, a causa de las sucesivas apelaciones que permitía la jerarquía eclesiástica. Con el tiempo fueron consagrándose pautas rígidas de apreciación de la prueba (prueba tasada), especialmente para determinar en qué casos procedía la aplicación de la tortura.

Recepción y significado político

§ 22. En los inicios de la modernidad, las monarquías europeas se apropiaron del modelo de la Inquisición, dando lugar al *sistema inquisitivo secular*, en un fenómeno que se conoce como la *recepción*. Este sistema pasará a ser una poderosa herramienta de centralización del poder real, en desmedro de los estamentos feudales y del propio poder eclesiástico. Los instrumentos más representativos de este sistema inquisitivo secular son:

- Las Partidas de Alfonso el Sabio, de mediados del siglo XIII.
- La Lex Carolina (1532), primer antecedente orgánico del derecho penal alemán.
- La ordenanza francesa de Luis XIV (1670).

Desde el punto de vista político, el sistema inquisitivo viene a materializar la expropiación del conflicto a sus protagonistas originarios, a manos de la organización estatal. Representa también el reemplazo de la participación popular en la administración de justicia por funcionarios estatales: los jurados son reemplazados por jueces permanentes, y la acusación privada es reemplazada por el impulso oficioso del procedimiento.

En su desarrollo posterior, este sistema irá perdiendo algunos de sus rasgos más atroces, particularmente con la proscripción de la tortura y su reemplazo por el interrogatorio inquisitivo.

§ 23. Debe mencionarse que la Inquisición no logró instalarse en Inglaterra, debido a la ruptura de la monarquía inglesa con la Iglesia Católica Romana hacia el siglo XVI. Aunque hubo persecución religiosa por parte de la corona, esta práctica no llegó a consolidarse institucionalmente, ni se extendió al enjuiciamiento de delitos comunes. El proceso penal inglés continuó su propia evolución dentro del modelo adversarial, aun en períodos de restauración del catolicismo.

d) Reforma del inquisitivo (mixto)

Surgimiento

§ 24. El período napoleónico en Francia da lugar al *sistema mixto*, materializado con el Código de Instrucción Criminal de 1808. Políticamente, este sistema representa la solución de compromiso entre el modelo inquisitivo de la monarquía y el acusatorio de la etapa revolucionaria.

La posterior expansión de este sistema en Europa viene de la mano de la prédica sobre las bondades del juicio oral, que era su gran innovación. Ya a inicios del siglo XX, la implantación del sistema mixto va acompañada de una importante labor técnica y doctrinaria, como en el caso del Código italiano de 1913, reformado en 1930 durante el régimen fascista.

Caracteres

§ 25. En su formulación más técnica, el sistema tiene una primera etapa eminentemente investigativa, a cargo de un juez de instrucción. En esta etapa, la defensa está sumamente limitada por el secreto de sumario, y el imputado permanece como regla encarcelado, a menos que se den los supuestos que taxativamente habilitan la excarcelación. La declaración del imputado ya aparece rodeada de ciertas garantías, aunque en general no es obligatoria la presencia del defensor.

Concluida la instrucción, la acusación da paso al juicio oral. Sin embargo, el trámite en algunos casos es por demás de rígido: comienza con la lectura de la acusación, se reproduce la declaración indagatoria, y los testigos suelen ser interrogados en primer término por el propio juez, o por el presidente del tribunal. La sentencia debe dictarse de manera fundada, y en general sólo es atacable por recurso de casación, ya que el juicio oral se considera de instancia única en cuanto a los hechos.

Evolución y críticas

§ 26. A pesar de su estructuración formalmente mixta, la evolución posterior de este sistema acentuaría sus caracteres inquisitivos, otorgando un predominio creciente a la etapa instructoria. En general, se permite que el tribunal de juicio interroge en primer término al imputado y a los testigos, lo cual

compromete seriamente su imparcialidad. Las declaraciones de testigos y peritos son reemplazadas por la lectura de las actas del expediente (incorporación por lectura), llegándose en algunos casos al extremo de tener por incorporadas las actas por aceptación de las partes (incorporación ficta), con lo cual el juicio oral pierde toda relevancia como ámbito de debate público.

Estas deformaciones -que no solo derivan de la práctica judicial, sino en muchos casos de la letra precisa de los códigos respectivos- han llevado a algunos autores a caracterizar este sistema como *inquisitivo atenuado* o *inquisitivo oral*, reservando la denominación de *mixto* para lo que aquí se llama *acusatorio formal*.

e) Reforma del mixto (acusatorio formal)

Surgimiento

§ 27. En la segunda mitad del siglo XX, Alemania Occidental emprende la ardua tarea de reformar su sistema penal luego de la experiencia del nacional-socialismo. Este proceso incluyó varias reformas a la Ordenanza Procesal Penal de 1877, que a su vez había implicado la superación del modelo anterior, de corte napoleónico.

Caracteres

§ 28. El sistema alemán puede considerarse *formalmente acusatorio*, en cuanto las funciones de investigar y juzgar están íntegramente separadas, lo cual distingue este modelo del inquisitivo puro, y aun del mixto. La investigación está a cargo del fiscal, quien tiene la responsabilidad de promover la acción penal pública. El juicio es oral y público, y según el caso el tribunal puede ser técnico (integrado por uno o más jueces permanentes) o mixto (integrado por jueces permanentes y por ciudadanos sin titulación jurídica).

No obstante, la ordenanza conserva hasta la actualidad algunos rasgos inquisitivos residuales, como la facultad del tribunal de observar los acuerdos presentados por las partes, o de formular preguntas aclaratorias a los testigos. Además de estas particularidades, el sistema en general persigue la efectividad en la persecución del delito y la búsqueda de la verdad. Esto ha llevado a decir que es un *proceso acusatorio con principio de instrucción*, a diferencia del modelo

angloamericano, que es enteramente un proceso de partes. Para formular comparaciones con un criterio más contemporáneo, a veces nos referiremos a este modelo como “continental”, para denotar que es un acusatorio mediado por el fenómeno histórico de la Inquisición, a diferencia del acusatorio adversarial de origen comunitario que aquí llamaremos “anglosajón”.

El modelo acusatorio formal ha sido adoptado por otros países europeos a partir de la década de 1970, y es una de las fuentes principales de las reformas procesales en América Latina.

f) El proceso penal en Argentina

La reacción contra el sistema inquisitivo colonial

§ 29. Los territorios americanos colonizados por España estuvieron sometidos al sistema inquisitivo de las Partidas, recogido en la Nueva Recopilación (1567) y en la Novísima Recopilación (1805).

Durante la etapa independentista iniciada en 1810, el rechazo hacia este sistema es contundente. Así, las primeras legislaciones patrias prevén expresamente garantías de protección contra el poder estatal, clausuran la inquisición, prohíben la tortura y promueven el juicio por jurados.

Con la sanción de la Constitución Nacional en 1853, se consolida esta tendencia garantizadora y nuestro país se enrola decididamente en el modelo acusatorio, llegándose a mencionar el juicio por jurados en tres pasajes del texto constitucional: en los artículos 24, 67.11 (actual 75.12) y 99 (actual 118).

Recepción del sistema inquisitivo (1888-1939)

§ 30. En cumplimiento de las mandas constitucionales citadas, se generan los proyectos de 1873, de *código de procedimientos en lo criminal y de instauración del juicio por jurados*.

Los proyectos, inspirados en la legislación norteamericana, regulaban una etapa preparatoria a cargo de un juez, una etapa de admisión de la acusación a cargo de un gran jurado, y un juicio oral ante un jurado de ocho miembros que actuaba bajo la dirección de un juez técnico. Se inscribía claramente en el modelo adversarial, aun teniendo algún rasgo inquisitivo en la etapa preparatoria.

§ 31. Estos proyectos no recibieron tratamiento legislativo, y en 1888 se sanciona el proyecto presentado por Manuel Obarrio. El *Código Obarrio*, inspirado en el modelo español de la restauración borbónica, representa la consagración del sistema inquisitivo casi en estado puro (con las inevitables adaptaciones de la época, como la prohibición del tormento).

El procedimiento se podía iniciar de oficio; el sumario era escrito y secreto, y estaba a cargo de un juez profesional; el juicio también era escrito y a cargo de otro juez, siendo la sentencia susceptible de apelación.

El Código Obarrio sirvió como modelo para las legislaciones provinciales, con lo cual a principios del siglo XX la práctica totalidad del país había adoptado el sistema inquisitivo. Ello a pesar de la posterior incorporación del juicio oral a opción del acusado, que tendría una casi nula aplicación práctica, en los códigos de Buenos Aires y San Luis.

Hacia el sistema mixto (1939-1991)

§ 32. El código de Córdoba de 1939, obra de Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler, inicia la oleada de reformas que consagraría el *sistema mixto en Argentina*.

El código cordobés se inspiró en el código italiano de 1913. El proceso constaba de una instrucción formal a cargo de un juez, cumplida la cual la acusación daba lugar a un juicio oral, público y contradictorio, ante un tribunal unipersonal o pluripersonal según el caso, que debía valorar la prueba según el sistema de la sana crítica racional. Contra la sentencia cabía el recurso de casación, mientras que algunas resoluciones instructorias eran apelables.

Se preveía, con carácter excepcional y para delitos leves, la citación directa. Este instituto consistía en una investigación sumaria a cargo del fiscal, luego de la cual se abría el juicio oral, por lo que puede considerarse un antecedente de la actual investigación preparatoria de los modelos acusatorios.

El sistema mixto fue ampliamente difundido por la doctrina nacional, y en las décadas siguientes sería adoptado por la práctica totalidad de las provincias argentinas. El orden nacional lo incorpora recién en 1991, con medio siglo de atraso respecto de su antecedente cordobés y después de haberse desechado (nuevamente) un proyecto de corte acusatorio: el Proyecto Maier, de 1986.

Hacia el acusatorio formal (1991-actualidad)

§ 33. Mientras la nación avanzaba tardíamente hacia la implementación del modelo mixto, en 1991 Córdoba y Tucumán inician una nueva oleada reformista, esta vez de corte acusatorio formal. Esta etapa se inspira mayormente en el Proyecto Maier de 1986, en la ordenanza alemana y en el código italiano de 1988.

Si bien en términos generales se conserva el vocabulario y la sistemática de las legislaciones anteriores, se incorpora la investigación preparatoria a cargo del fiscal, terminando definitivamente con el modelo napoleónico de instrucción jurisdiccional.

Además, se profundizan los rasgos garantizadores y se otorga una mayor relevancia a la figura del fiscal, aunque manteniendo como regla la obligatoriedad de la acción pública. En este sistema, se asigna al juez el control de ciertos actos investigativos, especialmente en salvaguarda de derechos individuales (por ej., autorizar el allanamiento de morada o la detención cautelar). En determinados casos, el acusado puede optar por un tribunal mixto, integrado por tres jueces y dos ciudadanos legos.

A partir de la experiencia cordobesa, la mayoría de los códigos de Argentina comienzan a avanzar hacia sistemas acusatorios, o como mínimo profundizan los rasgos acusatorios en el marco de sistemas mixtos.

g) La situación en Santa Fe

La perduración del sistema inquisitivo

§ 34. En 1895 Santa Fe dictó un código de corte netamente inquisitivo, según el modelo del Código Obarrio. En este marco, la instrucción era escrita y secreta, a cargo de un juez, y en general el proceso podía iniciarse y desarrollarse de oficio, con puntuales actuaciones de la fiscalía. Concluida esta etapa, el juez decretaba la apertura del juicio, que era escrito. En el juicio intervenía un juez distinto al de la instrucción, lo cual ha llevado a algún desprevenido a calificar este sistema como mixto.

§ 35. La reforma de 1971 pretendió instituir el modelo mixto, consagrando una mayor amplitud de la defensa, algunas garantías elementales del imputado y aumentando las exigencias para el dictado de la prisión preventiva.

Previó también el juicio oral a opción del acusado en algunos casos, al igual que en los códigos de principios de siglo. Todo lo cual no alcanza a cumplir con los parámetros básicos de un sistema mixto, ya que como regla el juicio plenario seguía siendo escrito y el rol del acusador era meramente formal. De hecho, el código consagraba expresamente la facultad del juez de dictar condena, aunque el fiscal pidiera la absolución.

Dentro de las reformas parciales que se sucedieron, debe destacarse que en 2003 se incorporaron institutos típicos de los modelos acusatorios, como el juicio abreviado, la investigación fiscal preparatoria (con carácter optativo), la sustitución de la prisión preventiva, los derechos de la víctima y la prohibición de condenar sin solicitud fiscal. Si bien esta reforma no modificó sustancialmente el funcionamiento del sistema, debe reconocerse que la sustitución de prisión preventiva logró cierta adecuación del sistema excarcelatorio a la jurisprudencia de la época.

Los proyectos de reforma

§ 36. La idea de implementar el modelo acusatorio en Santa Fe data -por lo menos- desde el retorno de la democracia. El atraso del sistema vigente era notorio, si se repara en que estamos hablando del único sistema procesal penal escriturista que quedaba en pie Argentina, y uno de los pocos que quedaban en el mundo.

En 1993 se presenta un anteproyecto redactado por los profesores Jorge Vázquez Rossi, Julio de Olazábal, Ramón T. Ríos y Víctor Corvalán. Se siguió el modelo acusatorio del Proyecto Maier, aunque con notorias mejoras técnicas. Este proyecto no logró aprobación legislativa, pero constituyó el antecedente más importante del proyecto de 2006, que en 2007 se convertiría en nuestro actual Código Procesal Penal.

La jurisprudencia de la CSJN y el Código de 2007

§ 37. Mientras tanto, el vetusto modelo inquisitivo seguía cosechando críticas, dentro de las cuales debe señalarse la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en la década de 2000 adopta definiciones fundamentales en cuanto al proceso penal:

- En el fallo “Casal” (2005), se realiza un análisis crítico del sistema implantado por el Código Obarrio, sistema que a grandes rasgos continuaba vigente en Santa Fe.
- En el fallo “Llerena” (2005), se pone en evidencia la afectación a la imparcialidad que surge de la intervención del juez en la etapa instructoria.
- En “Diesser” (2006) se aplica el precedente “Llerena”, pero con relación a la intervención de los jueces de cámara en distintas etapas procedimentales. En este caso, la corte nacional contradujo categóricamente el criterio de la corte santafesina, que había avalado la constitucionalidad del sistema.

El precedente “Diesser” puso en evidencia la deslegitimación constitucional del sistema vigente. Tal fue el rechazo al modelo inquisitivo defendido a ultranza durante décadas, que finalmente el proyecto de 2006, redactado por una comisión presidida por Julio de Olazábal y Ángel Baltuzzi, comenzó a recibir un inusitado nivel de adhesión. El proyecto fue formalmente presentado como el producto de un plan estratégico integrado por la práctica totalidad del arco institucional santafesino, siendo aprobado por votación unánime en 2007.

Transición y entrada en vigencia

§ 38. En 2008 se insertaron algunas normas del código nuevo dentro de la sistemática del código anterior aún vigente, generándose así un *código de transición*. Esta hibridación no resultó sencilla, pero en general se coincide en rescatar la vigencia parcial del principio acusatorio, el nuevo sistema de medidas cautelares, la modificación del régimen de la acción penal, e inclusive el juicio oral obligatorio para ciertos delitos, que permitió cierto precalentamiento en técnicas de litigación.

Luego de la estructuración inicial de los nuevos organismos (fiscalía, defensa, oficina de gestión judicial y colegio de jueces), el nuevo código entró en vigencia el 10 de febrero de 2014, ya con alguna reforma al texto original.

El Código de 2007: caracteres

§ 39. El código vigente posee todos los caracteres estructurales del *modelo acusatorio formal*, ya que combina la persecución penal oficial -que viene a materializar el interés público en la represión del delito- con la separación

entre las funciones de acusar, defender y juzgar. Algunas de sus principales características son:

- *La acción penal pública está regida por el principio de legalidad atenuada*, es decir que su ejercicio resulta obligatorio para la fiscalía a menos que se verifique alguna excepción legalmente prevista (criterios de oportunidad).
- *La investigación preparatoria está a cargo de la fiscalía*, que actúa con la colaboración de los organismos investigativos y policiales.
- *El impulso procesal es absolutamente de parte*, estando vedado a los jueces resolver de oficio.
- *El imputado es claramente reconocido como sujeto de derechos*, y aparece rodeado de un cúmulo de garantías desde el inicio del proceso. La defensa técnica tiene un amplísimo margen de actuación, y en general el sistema tiende a asegurar la defensa efectiva y no meramente formal.
- *El juicio es oral*, y también *son orales las principales instancias del proceso*, siendo excepcional la imposición de la forma escrita.
- *La sentencia es recurrible por apelación*, permitiéndose la revisión íntegra del fallo.

§ 40. Algunos institutos parecen poner en duda el carácter acusatorio formal del modelo santafesino. Específicamente, la ambigua regulación del rol del juez frente a los acuerdos de parte da lugar a que la práctica judicial adquiera, en algunos contextos, notas claramente adversariales.

De todos modos, cabe aclarar que las últimas reformas al código parecen fortalecer el principio de interés público, al establecer controles jerárquicos al interior de la fiscalía. La presencia de estos controles, y de reglas tabuladas para la concesión de salidas negociadas, limitan fuertemente cualquier posible idea de discrecionalidad en el ejercicio de la acción pública.

Por ello consideramos, al menos a nivel general, que el proceso penal santafesino se inscribe en el modelo acusatorio formal. Sin que ello implique negar la existencia de reglas puntuales propias del modelo adversarial, lo cual es coherente con la dinámica actual de nuestra materia. Puede afirmarse, sintéticamente, que estamos ante un sistema *acusatorio formal heterodoxo*, que incorpora herramientas provenientes de distintas tradiciones jurídicas.

h) Tendencias actuales

§ 41. Dentro de los actuales procesos de reforma en Argentina y en América Latina, la tendencia general es el avance hacia el modelo acusatorio formal. Aunque debe señalarse que en determinados contextos se mantiene la estructura del sistema mixto, con enmiendas de corte acusatorio.

Como innovaciones puntuales, deben mencionarse en primer término aquellas que tienden a la *modernización del procedimiento* y a la *búsqueda de la eficiencia*. Algunos ejemplos son:

- La oralización de las etapas previas al juicio oral.
- La amplificación de los mecanismos de descongestión, tales como las salidas tempranas y los institutos compositivos o negociales.
- La incorporación de herramientas de gestión en los organismos del sistema judicial, como la evaluación de rendimiento, el trabajo por objetivos y la asignación dinámica de recursos.
- La tecnología aplicada al sistema penal, como el registro audiovisual de audiencias, la audiencia por videoconferencia, la vigilancia electrónica y el legajo virtual.

Otro conjunto de innovaciones incorpora ideas y criterios propios del acusatorio material y del acusatorio adversarial. Así, tenemos:

- El corrimiento del interés público en favor del interés individual de la víctima, a través de la potenciación del rol del querellante, la posibilidad de conversión de la acción pública en privada y la introducción de criterios de justicia restaurativa para la concesión de salidas alternativas.
- La profundización la idea de *proceso de partes*, plasmada en la regulación del interrogatorio cruzado, la prohibición absoluta de que los jueces interroguen a los testigos, y la concepción del tribunal como árbitro del litigio o como homologador de acuerdos.
- La reinstalación del juicio por jurados al estilo anglosajón, o acudiendo a la mixtura entre el modelo anglosajón y el europeo continental.

Síntesis del capítulo

1. Sistema acusatorio.

- a. Clásico. Antiguos sistemas de las repúblicas ateniense y romana, en los que se establecen las formas esenciales del modelo: acusación privada o popular, estado de libertad, contradictorio y defensa, oralidad y publicidad, participación popular.*
- b. Material. Derecho consuetudinario de los pueblos germánicos, basado en la concepción del crimen como pérdida de la paz, y en un modelo de enjuiciamiento que combina el combate, la prueba mística y la composición entre clanes.*
- c. Adversarial. Evolución en el contexto anglosajón como proceso de partes y ante jurados populares. Posterior recepción en América del Norte, con la incorporación de la Fiscalía.*

2. Inquisitivo.

- a. Antecedentes: Inquisición canónica, derecho imperial tardío.*
- b. Implica la sustitución de la participación popular por la intervención de funcionarios estatales permanentes. Procedimiento consistente en una investigación secreta y plasmada en actas, que tiene al imputado como objeto de prueba. Estructuración vertical de la magistratura y múltiples instancias recursivas como medio de control jerárquico.*
- c. La búsqueda de la verdad como objetivo ilimitado del proceso penal, y legitimación del tormento. Prueba tasada, en particular la confesión y su efecto de plena prueba.*

3. Mixto.

- a. Proceso dividido en dos etapas. Instrucción predominantemente inquisitiva, y juicio oral ante jurados, tribunales mixtos o tribunales técnicos.*
- b. En su evolución posterior, se acentúan los rasgos inquisitivos. Predominio de la etapa instructoria.*

4. Acusatorio formal.

- a. Surgimiento en la Alemania de posguerra. Sintetiza la división de roles al interior del proceso, con el interés público en la persecución del delito.*
- b. Investigación preparatoria a cargo de la fiscalía. Imparcialidad del tribunal.*

5. Argentina.

- a. *Sistema inquisitivo colonial. Crítica y opción por el modelo opuesto, en la etapa independentista y en la Constitución Nacional.*
- b. *El Código Obarrio de 1888. Adopción y expansión del sistema inquisitivo.*
- c. *Código de Córdoba de 1939. Sistema mixto y expansión del juicio con debate oral.*
- d. *El sistema acusatorio. Proyecto Maier. Códigos de la década de 1990. Situación actual.*
- e. *La situación en Santa Fe. La perduración del sistema inquisitivo y la sanción del Código Procesal Penal de 2007.*

Capítulo 3. Bases constitucionales del proceso penal

a) Constitución y proceso penal

Los dos niveles

§ 42. La idea de que la Constitución Nacional establece las garantías fundamentales que deben observarse en el proceso penal es compartida de manera unánime. Constituye el *primer nivel de desarrollo* de la relación entre constitución y proceso penal, y en general se trata de una idea que no ha sido objetada por ninguna corriente doctrinaria de relevancia actual.

§ 43. En un *segundo nivel de desarrollo*, hay autores que no sólo extraen de la Constitución las garantías relativas al proceso penal, sino también el modelo de proceso penal mismo. En otras palabras, hay quienes consideran que la Constitución opta expresamente por alguno de los sistemas que se han expuesto.

Este segundo nivel de análisis se corresponde con lo que la doctrina llama “paradigma constitucional” (Vázquez Rossi) o, en una expresión similar, “diseño constitucional del proceso penal” (Binder).

El núcleo de estas posturas doctrinarias es la idea de que el constituyente ya ha establecido claramente qué sistema procesal penal deberá adoptarse, y en todo caso la tarea del legislador común es reglamentar ese designio constitucional, sin poder modificarlo o sustituirlo por otro.

Esta idea viene a confrontar con la postura tradicional, según la cual la Constitución no se inclina por ninguno de los modelos de proceso, correspondiendo al legislador común dicha elección. En Argentina, esta postura es la que se corresponde históricamente con el código inquisitivo de 1888 y con su autor, Manuel Obarrio.

Diseño constitucional del proceso penal

§ 44. La doctrina extrae este diseño constitucional (utilizamos la expresión de Binder debido a su simplicidad) a partir de una serie de argumentaciones que trataremos de sintetizar.

- Vázquez Rossi y Maier explican que las cláusulas constitucionales que establecen el *juicio por jurados* (artículos 24, 75.12 y 118, en la redacción actual) expresan una clara opción en favor del modelo acusatorio, por cuanto el juicio por jurados supone necesariamente la oralidad, la publicidad, el pleno derecho de defensa, el estado de inocencia, la neutralidad del juez y, en definitiva, todas las características de un proceso acusatorio adversarial.
- Los mismos autores, junto con otros como Hendler, explican la vinculación que existe entre los sistemas procesales y el *contexto histórico y político*. Extraen como conclusión, que existe una clara relación entre los períodos revolucionarios, independentistas y democráticos, con el modelo acusatorio. En Argentina, esta vinculación resulta clara desde los inicios del proceso emancipatorio.
- Otras posturas vinculan el modelo acusatorio con el *sistema republicano de gobierno* (CN, art. 1), en cuanto implica la división de roles al interior del proceso, que viene a ser una manifestación de la *división de poderes*.
- Señala Binder que la propia Constitución sigue el formato acusatorio en la regulación del *juicio político*: en efecto, corresponde a la Cámara de Diputados *acusar* (CN, 53), y a la Cámara de Senadores *juzgar en juicio público* (CN, 59).
- Finalmente, se ha sostenido que el sistema acusatorio es el que resulta más idóneo para *salvaguardar las garantías individuales* durante el proceso. Con lo cual la Constitución no impondría un determinado modelo procesal en forma directa, sino en la medida en que esto resulta útil o necesario para el cumplimiento de otras cláusulas constitucionales.

La Constitución, ¿impone un proceso adversarial?

§ 45. Las dos primeras argumentaciones se orientan a desprender del texto y de la historia constitucional la necesidad de que el proceso penal sea de tipo acusatorio. Y específicamente, se alude al modelo acusatorio adversarial, lo cual también resulta coherente con las fuentes constitucionales.

En cambio, puede advertirse que los argumentos relacionados con el sistema republicano y con el valor modélico del juicio político bien pueden ser

satisfechos con un sistema acusatorio formal, que en esencia cumplimenta con la división de roles procesales que esta perspectiva reclama (separación de las funciones de investigación y juzgamiento). Lo mismo puede decirse de la visión utilitaria del modelo procesal en orden a la protección de otros principios: no puede afirmarse de modo concluyente que el acusatorio formal sea menos respetuoso de las garantías individuales que el modelo adversarial.

El reconocimiento constitucional del modelo acusatorio formal viene de la mano de la *internacionalización de las fuentes del derecho procesal penal*. En particular, instrumentos como las Reglas de Mallorca aluden expresamente a parámetros típicos de aquel modelo (como la separación entre las funciones de investigación y juzgamiento, o la imparcialidad judicial), y ni siquiera mencionan institutos más claramente adversariales como el juicio por jurados.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte nacional -en especial a partir de los fallos “Llerena” y “Casal”, ambos del año 2005- expresa un cierto corrimiento del paradigma constitucional originario, de corte anglosajón, en favor de una interpretación progresiva anclada en los precedentes del sistema interamericano y en los desarrollos de la Europa continental.

b) Principios garantizadores

§ 46. La temática de los principios o garantías constitucionales es una de las más desarrolladas en doctrina, por lo que existen distintas formulaciones y clasificaciones. Además, debe tenerse presente que la constitucionalización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CN, 75.22) produjo una ampliación del catálogo de garantías, o por lo menos una consagración explícita de garantías que antes debían obtenerse por deducción. Por ende, las explicaciones doctrinarias también se han ido actualizando en parte, para receptar esta nueva realidad normativa e integrarla a una mirada general de las bases constitucionales del proceso penal.

§ 47. Los principios constitucionales suelen ser clasificados de distintas formas. Según si refieren principalmente al procedimiento o a la organización judicial que supone (Maier), según si pueden desprenderse o no del estándar de debido proceso (Vázquez Rossi), según su finalidad específica de protección (Binder), entre otras que propone la doctrina. También es frecuente que los principios se deriven unos de otros, en una estructuración lógica de género a especie.

Estos intentos clasificatorios suelen ser opacados por las innumerables situaciones intermedias y zonas grises. Por ejemplo, la llamada “doble instancia” puede ser vista como una cuestión relativa a la organización judicial, pero el derecho al recurso no deja de ser una garantía relativa al procedimiento. Y es discutible si se deriva del derecho de defensa en juicio, o si recién nace como garantía con su consagración internacional.

Sin dejar de reconocer que se trata de una cuestión de gran interés científico para nuestra materia, a los efectos de este manual nos conformamos con que estos problemas queden apenas planteados a modo introductorio. Con lo cual se expondrán los principios fundamentales de corrido y en forma autónoma, tratándose como proyecciones o derivaciones de un principio sólo aquellas que generalmente son aceptadas como tales.

c) Legalidad

§ 48. La palabra “legalidad” se utiliza para designar principios y reglas diversos, por lo cual debe ser siempre adjetivada para aclarar a qué significado nos estamos refiriendo.

Principio de legalidad penal o material

§ 49. El principio de *legalidad material*, propio del derecho penal sustantivo, tiene aplicación en el ámbito específico del proceso, en cuanto todo acto de persecución penal requiere de un hecho que mínimamente revista apariencia delictiva. Esto resulta ineludible para la información de derechos al imputado (CPP, 101.2), para la aprehensión en flagrancia (213), para ordenar la detención (214), para solicitar medidas de coerción personal (220, 221), para delimitar el objeto de la investigación preparatoria (253), para formalizar denuncia (262, 265.4), para habilitar la actuación policial (268), para formalizar audiencia imputativa (274, 275), para formalizar la acusación (295.4), para disponer la apertura del juicio (304.2), para instar y para admitir el procedimiento abreviado (339.2, 341) y para formular querrela por delito de acción privada (350.4).

En contrapartida, cuando no se verifica una mínima y provisional apariencia delictiva en el hecho, el Código impone -según el caso- la desestimación de la denuncia (273), el archivo fiscal (289.1), el archivo jurisdiccional (290), el

sobreseimiento (306) o la declaración de inadmisibilidad del procedimiento abreviado (341).

Principio de legalidad procesal

§ 50. Suele denominarse *principio de legalidad procesal* a la exigencia genérica de que el proceso penal esté sujeto al imperio de la ley. Surge de la cláusula que establece la necesidad de juicio previo basado en ley (CN, 18).

Concretamente, este principio se traduce en los siguientes corolarios:

- *Sujeción del proceso a las reglas legalmente establecidas* (CPP, 1). En general, se refiere a la necesidad de que las partes puedan conocer previamente las reglas de juego, en orden a poder desplegar una estrategia procesal con arreglo a las mismas. En un sentido más específico, conlleva la imposibilidad de modificar arbitrariamente las reglas procesales respecto de los casos ya iniciados (algunos autores equiparan esta cláusula a la *irretroactividad* de las normas penales sustantivas).
- Invalidez de la prueba obtenida ilegalmente o en violación a garantías constitucionales (CPP, 162).
- Interpretación restrictiva de toda cláusula que limite los derechos o libertades individuales (CPP, 10, 11).

No debe confundirse el *principio constitucional de legalidad procesal* con el llamado *principio político de legalidad o de obligatoriedad de la acción penal*, que en rigor es uno de los sistemas que rigen el ejercicio de la acción penal pública (ver Capítulo 6).

d) Juicio previo

Formulación general

§ 51. La prohibición de penar sin juicio previo surge del artículo 18 constitucional, y en general se lo vincula a la idea de proceso previo: dicho de otra manera, nadie puede ser penado sin la previa tramitación del procedimiento establecido legalmente para el juzgamiento de los casos criminales.

Esta cláusula proscribe para nuestro sistema la posibilidad de reacción inmediata ante el delito, más allá de los excepcionales casos en los que la ley

autoriza la coacción directa (aprehensión civil, legítima defensa). Pero como pauta general, la reacción estatal ante el delito se encuentra mediada por el proceso establecido legalmente para verificar si están dadas las condiciones para una sentencia de condena.

Postura de Maier

§ 52. En una posición minoritaria, el profesor Maier interpretaba la garantía como el requerimiento de *sentencia previa* como paso lógico previo a la aplicación de la pena. En este marco, la palabra “juicio” es tomada en una de sus acepciones: como la operación lógica que realiza el tribunal en la sentencia. Para nosotros, entender la garantía con este alcance tiene al menos dos problemas:

- Primero, vuelve totalmente innecesaria la garantía, puesto que la prohibición de aplicar pena sin sentencia previa ya está contenida en el *principio de inocencia*.
- Segundo, porque dentro de la sistemática constitucional la palabra “juicio” no alude a su significado lógico, sino al *juicio como etapa contradictoria del proceso*. Así ocurre cuando se habla del *juicio por jurados* (CN, 24, 75.12, 118), de la *defensa en juicio* (CN, 18), del *juicio político* (CN, 59), del eventual *juicio* penal contra los funcionarios destituidos (CN, 60, 115) y del *juicio para la suspensión de senadores y diputados* (CN, 70).

De este segundo apartado podemos extraer una proyección de la garantía de juicio previo: el procedimiento penal debe contar con una etapa que conceptualmente pueda ser considerada un “juicio” según el marco constitucional. Dentro del procedimiento reglado por la ley, debe existir una instancia pública, contradictoria, donde el acusado pueda ejercer con plenitud su defensa. En este sentido, más exigente, es que debe entenderse el significado de “juicio previo”.

El juicio: ¿derecho del acusado o cuestión de interés público?

§ 53. Se ha discutido si el tránsito por la etapa plenaria es obligatorio en todo caso, o si se trata de un derecho renunciable por el acusado. En este sentido, la incorporación de mecanismos resolutivos distintos del juicio contradictorio, y en particular de aquellos con posibilidad de desembocar en una condena penal (típicamente: procedimiento abreviado), ha sido entendida como una concesión a esta idea.

Sin embargo, la jurisprudencia local y nacional no termina de asimilar la idea del juicio abreviado como renuncia al juicio contradictorio: en la esfera local, por la amplitud que se le reconoce al control judicial del acuerdo (fallo “Ruiz”, CSJSFe, 2019), y a nivel nacional, por la idea de que el interés público tiene primacía sobre el interés individual del acusado en la forma de juzgamiento (específicamente, en relación al juicio por jurados como derecho disponible por el acusado: fallo “Canales”, CSJN, 2019).

e) Inocencia

Formulación general

§ 54. El *principio de inocencia* surge implícitamente de la prohibición de penar sin juicio previo (CN, 18) y explícitamente de los tratados (CADH, 8.2; PIDCP, 14.2). Desde su origen, ha sido específicamente relacionado con el derecho a no ser tratado como culpable hasta que una sentencia firme determine tal calidad. Constituye un axioma típico de los modelos acusatorios, en contraposición al sistema inquisitivo, que presumía la culpabilidad del imputado y buscaba por todos los medios que éste confesara.

¿Presunción, estado o situación?

§ 55. La formulación del principio como *presunción de inocencia* ha llevado a cierta doctrina a entender, erróneamente, que se trata de una valoración anticipada sobre lo que podríamos llamar la inocencia real del imputado: la circunstancia de haber sido o no autor o partícipe de un hecho delictivo. Esta confusión ha perdurado a través del tiempo, y ha provocado que algunos autores hayan reformulado el principio, denominándolo *estado de inocencia* para denotar que se trata de un estado o situación jurídica y no de una verificación empírica, o trato de inocente, atendiendo a lo que es esencialmente su repercusión práctica.

Conceptualmente, hoy entendemos la presunción de inocencia (así la siguen llamando los principales instrumentos) como una situación jurídica en la que se encuentra la persona imputada durante todo el transcurso del proceso, sin importar el grado de avance del mismo o el grado de comprobación de la imputación delictiva. No importa tampoco que se trate de un culpable confeso,

de un reincidente o de una persona sobre la que pesan evidencias abrumadoras. Aun en cualquiera de estas situaciones, estamos ante una persona que *debe ser tratada como si fuera inocente* (Maier).

Proyecciones

§ 56. Las principales repercusiones o proyecciones de la presunción de inocencia son: la carga probatoria en cabeza del acusador, el beneficio de la duda y el estado de libertad durante el proceso.

Carga de la prueba

§ 57. La primera y más obvia repercusión de la presunción de inocencia es que no puede exigirse al imputado que demuestre ser inocente, sino que incumbe a los acusadores aportar pruebas de su culpabilidad y desvirtuar aquella presunción (o destruir aquel “estado”, para los que prefieren no hablar de “presunción”).

En lenguaje acusatorio, podría decirse que la carga de la prueba pesa sobre los acusadores. Sin embargo, todavía no es común en nuestro medio hablar de “cargas probatorias” en el proceso penal. Esta resistencia se sustenta en una idea profundamente inquisitiva: la idea de que en el proceso penal no hay carga probatoria, porque el juez debe investigar y descubrir la *verdad real*. La noción de carga probatoria, en cambio, se construye sobre la idea civilista de *verdad formal*, e implica que las partes deben soportar la falta de prueba.

Intentaremos aclarar este embrollo con un ejemplo. Supongamos que, en nuestro actual sistema, la fiscalía se olvida de ofrecer para el juicio una prueba fundamental. La consecuencia es obvia: dicha prueba no podrá ser producida, y el imputado deberá ser absuelto. Pues bien, esto no era así en los modelos inquisitivos y mixtos: en este caso, el tribunal debía ordenar las pruebas necesarias para esclarecer el hecho. La tarea de producir la prueba no pesaba sobre una de las partes, sino que correspondía en conjunto a todos los intervinientes, incluyendo al propio tribunal. En este contexto, obviamente no puede hablarse de “carga probatoria”, ya que la carga implica la posibilidad de soportar consecuencias desfavorables derivadas de la falta de prueba. Esto era inaceptable en materia penal, ya que el descubrimiento de la verdad como objeto-fin del proceso era considerado de orden público.

Aceptando que se trata de una cuestión controvertida, volvamos a lo nuestro: la carga de la prueba pesa sobre los acusadores.

- En el caso de la *fiscalía*, además existen deberes legales al respecto, cuya infracción podrá tener efectos disciplinarios (de hecho, existen deberes también en relación a la evidencia favorable al imputado: *Reglas Brady*). Pero en el marco del proceso, cuando la fiscalía no prueba alguna proposición fáctica, el efecto es que no se la puede tener por probada. Pesará sobre la fiscalía tal consecuencia disvaliosa (para nosotros, esto es sinónimo de “carga”).
- Respecto de los *querellantes*, la consecuencia procesal de la falta de prueba es idéntica: deberá soportar que el hecho no se tenga por probado (afrontará la carga de no haber probado).
- A estas alturas, es innecesario aclarar que el *tribunal* no tiene deberes ni facultades para producir prueba no ofrecida por las partes. Tampoco soporta carga probatoria alguna, puesto que carece de interés en el caso.
- La *persona imputada*, como hemos adelantado, no tiene carga probatoria alguna. Tiene todo el derecho de permanecer inactivo en ese sentido, aunque por supuesto tiene *derecho* también a ofrecer y que se produzca prueba en su favor. Alguna duda se ha presentado cuando se esgrime una *defensa positiva* (por ejemplo, legítima defensa) o una *coartada* (por ejemplo, cuando afirma que al momento del hecho se encontraba en otro lugar). En estos casos tampoco pesa sobre la defensa la carga probatoria, aunque para que la fiscalía se considere obligada a investigar estas alegaciones el planteo debe ser oportuno.

Beneficio de la duda

§ 58. El *beneficio de la duda* se relaciona en algún sentido con la cuestión de las cargas probatorias, ya que es una cláusula que viene a llenar el vacío probatorio: el estado de duda implica que no se ha cumplimentado exitosamente con la carga de probar.

El beneficio de la duda es un complemento necesario de la presunción de inocencia: obliga al tribunal a fallar dentro de una opción binaria (absolución o condena), no pudiendo abstenerse de decidir ni aplicar una pena disminuida (como era la *pena extraordinaria* de los romanos) invocando la falta de prueba.

Tradicionalmente se entendía que el beneficio de la duda operaba con exclusividad al momento de la sentencia. Es decir, la duda era la ausencia de la certeza positiva necesaria para el fallo condenatorio. Nuestro código extiende

el alcance del principio a *cualquier grado e instancia del proceso* (CPP, 7), lo cual requiere alguna aclaración.

La duda suele ser definida como la *falta de certeza*. Pero esa definición tiene un problema: está atada al momento específico del dictado de la sentencia. Si este concepto se aplicara con la extensión dispuesta por el CPP, 7, caeríamos en el problema de que se requeriría certeza para prácticamente cualquier decisión, anulándose la posibilidad de dictar ciertas resoluciones con un grado cognoscitivo menor. Por ello, resulta necesario aclarar que la entidad de lo que consideramos “duda” dependerá del grado de conocimiento mínimo exigido para cada instancia del proceso:

- Al momento de dictar sentencia, será considerado “duda” todo estado cognoscitivo inferior a la *certeza* sobre la culpabilidad del acusado (certeza positiva). El estándar no está consagrado específicamente en nuestro derecho, aunque surge por derivación ya que se trata de la aplicación más clásica del beneficio de la duda.
- En un escalón menor, para el dictado de prisión preventiva (y por extensión, de otras medidas coercitivas personales) se exige *probabilidad* sobre la autoría o participación punible del imputado en el hecho investigado (CPP, 220.1). En este caso, se estará en duda siempre que el tribunal no esté seguro de haber alcanzado dicho nivel de conocimiento (probabilidad positiva respecto del supuesto material).

Otras instancias resolutivas plantean niveles de conocimiento más accesibles, particularmente para los momentos iniciales del proceso. Así, se exigen *motivos razonables* para ordenar requisa personal (CPP, 168, primer párrafo), y *motivos suficientes o fuerte presunción* para ordenar la requisa vehicular (CPP, 168, segundo párrafo).

Por otra parte, un acto tan relevante como la detención no impone un nivel determinado de conocimiento sobre los hechos que la sustentan: Puede ser ordenada cuando la fiscalía *estime* estar en condiciones de formalizar audiencia imputativa (CPP, 214). Más allá de esta carencia, doctrinariamente se suele acudir al estándar de “sospecha”, que en el viejo sistema habilitaba el llamado a indagatoria.

Ahora bien, ¿cómo juega el beneficio de la duda ante instancias resolutivas de contenido desincriminatorio? Como veremos, se requiere *certeza negativa* para disponer el archivo fiscal por algunos supuestos (CPP, 289.1.a-b-c), como también -y por remisión a dicho instituto- para dictar el sobreseimiento en caso de controversia (CPP, 306). En estos casos, parece difícil sostener que la duda beneficie al imputado, ya que usualmente la regla de la duda tiende a evitar la

afectación de derechos sin un piso mínimo de conocimiento: en este caso, no se trata de evitar la lesión a un derecho, sino de lograr una desincriminación anticipada.

Sí juega expresamente el beneficio de la duda en el caso del CPP, 289.2, que regula el archivo fiscal por *duda insuperable*. Por derivación, también rige en el caso de archivo jurisdiccional (CPP, 290). De todos modos, no se trata en este segundo caso de una mera duda, sino de un *estado intelectual complejo*, compuesto por la *duda* sobre los supuestos materiales, más la *improbabilidad* de incorporación de nuevas evidencias. En el caso del archivo jurisdiccional, además se requiere *certeza* en cuanto al vencimiento del plazo.

Sin pretender agotar el tema, que sin duda puede complejizarse en su análisis, proponemos definir los distintos grados de conocimiento exigidos para cada instancia resolutoria de la siguiente manera:

- ***Certeza positiva***: ausencia de duda razonable. Es el grado cognoscitivo más exigente, impuesto como regla para dictar una condena. Nótese que en este caso, el beneficio de la duda opera de forma más exigente: se considera “duda” -y conduce a la absolución- todo estado intelectual inferior a la certeza.
- ***Certeza negativa***: que las causales desincriminatorias resulten evidentes, más allá de toda duda razonable. Este estándar se impone para el archivo fiscal en el supuesto del CPP, 289.1, y para el sobreseimiento a pedido de parte (CPP, 306).
- ***Probabilidad***: es el predominio de los elementos de cargo sobre los de descargo. Se relaciona principalmente con las medidas de coerción personal, en cuanto al supuesto material. Indirectamente, también para la evaluación de los riesgos procesales se requiere de alguna forma un juicio probabilístico (por ej., predominio de los indicadores que sugieren peligro de fuga, sobre los que sugieren determinado nivel de arraigo). De todas maneras, veremos que este estado intelectual debe interpretarse de acuerdo al momento procesal del que se trata, por lo cual también suele ser definido como “sospecha vehemente”.
- ***Improbabilidad* (o *probabilidad negativa*)**: predominio de los elementos que niegan cierta hipótesis. En nuestro sistema, el archivo fiscal por duda insuperable requiere que se considere improbable la incorporación de nueva evidencia (CPP, 289.2).
- ***Duda***: en sentido estricto, es la indefinición que surge de existir cierto equilibrio entre los elementos de cargo y de descargo. Unida al vencimiento de determinado plazo, la duda se convierte en insuperable y ha-

bilita el archivo fiscal por imperio del CPP, 289.2. Pero, como hemos visto, en un sentido más amplio rige el beneficio de la duda siempre que no se alcance el nivel de conocimiento mínimo para afectar los derechos de la persona (principalmente, nos referimos al dictado de sentencia condenatoria y a las medidas de coerción personal).

Estado de libertad durante el proceso

§ 59. El *estado de libertad durante el proceso* es una consecuencia lógica del principio de inocencia: qué forma más contundente de tratar a una persona como culpable, que mandarla a prisión. La regla es formulada, ya con carácter autónomo, en los instrumentos contemporáneos (CADH, 7; PIDCP, 9; Reglas de Mallorca, 20), y en general es recogida por las legislaciones procesales (en nuestro caso: CPP, 10).

En cualquiera de sus versiones, el principio nunca ha sido formulado en términos absolutos, en el sentido de vedar por completo la privación de la libertad durante el proceso. La aceptación -aun habiendo voces críticas- de la legitimidad de la prisión preventiva y de otras medidas de coerción personal, hace que la regla opere más bien limitando o conteniendo las manifestaciones más arbitrarias del encarcelamiento preventivo, sin llegar a proscribirlo por completo.

De este complejo normativo surge una serie de principios garantizadores que atañen específicamente a la situación del imputado frente a las medidas de coerción: *instrumentalidad, trato de inocente, judicialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, gradualidad* (o *subsidiariedad*), *idoneidad* y *provisoriedad*.

f) Debido proceso

§ 60. Para quienes sostienen la interpretación estricta de la garantía de juicio previo (como requerimiento de *sentencia previa*, cuestión que para nosotros remite al principio de inocencia), las cuestiones analizadas en el apartado anterior se relacionan con la exigencia de debido proceso previo.

Independientemente de ello, hay coincidencia doctrinaria en que el principio de debido proceso es un estándar que engloba el conjunto de garantías individuales que debe observar el procedimiento establecido en la ley para

considerarse acorde a la Constitución. Por lo que cabe también hacer una distinción histórica entre dos concepciones del debido proceso:

- La idea de *debido proceso legal*, vinculada históricamente a la era napoleónica y al sistema mixto, remite a la necesidad de que el procedimiento penal esté regido por la ley (principio de legalidad en sentido procesal).
- La idea de *debido proceso constitucional*, surgida a partir de la segunda posguerra, exige que el procedimiento establecido por la ley observe el conjunto de garantías individuales establecidos en la Constitución.

En este segundo sentido, puede decirse que el debido proceso se vincula con la idea de *proceso penal según constitución* (Vázquez Rossi). A punto tal se lo considera una especie de “supragarantía”, que el citado autor incluye dentro de sus derivaciones a la práctica totalidad de las garantías individuales (sólo deja con cierta autonomía los principios de *legalidad* y *judicialidad*).

g) Derecho de defensa

§ 61. La Constitución Nacional establece que *es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos* (CN, 18), cláusula que es especificada y complementada por los tratados (CADH, 8; PIDCP, 14).

El derecho de defensa penal tiene dos facetas esenciales: la *defensa material* y la *defensa técnica*.

Defensa material

§ 62. La *defensa material* se deriva del derecho de toda persona a ser oída (CADH, 8.1), y comprende:

- La facultad de prestar declaración en su descargo, que incluye la presentación espontánea, la declaración durante la audiencia imputativa, el uso de la palabra durante el juicio y la posibilidad -aunque debatida- de brindar testimonio. También comprende la necesidad de expresar libremente su aceptación durante la solicitud de procedimiento abreviado.
- Como presupuesto de lo anterior, se requiere el conocimiento previo y detallado de la imputación que se formula.

- La facultad de participar activamente en medidas investigativas o probatorias que requieran de su colaboración personal, como la reconstrucción del hecho o el careo.
- La facultad de abstenerse de cualquiera de las actividades anteriores, negándose a colaborar activamente con medidas probatorias, o simplemente guardando silencio.
- La facultad de designar un abogado para que ejerza su defensa técnica implica, en principio, una decisión por parte del propio imputado, derivada también del derecho de defensa material.
- Aunque discutida en doctrina, la necesaria comparecencia personal del imputado debería considerarse un presupuesto de la defensa material, ya que se deriva de la *prohibición del juicio penal en rebeldía*. De todos modos, la ausencia del imputado una vez abierto el debate no impide la prosecución del juicio (CPP, 125, segundo párrafo, y 310).

Defensa técnica

§ 63. La *defensa técnica* comprende el derecho a ser representado y asistido por abogados. Corresponderá a los defensores técnicos diseñar la estrategia procesal a seguir, articulando los planteos en la forma que corresponda. El derecho a contar con un abogado defensor es considerado mayoritariamente como irrenunciable, siendo excepcional la autorización para la autodefensa técnica (que puede rechazarse cuando de ello resulte un perjuicio evidente, según el CPP, 114). No obstante, las fuentes internacionales admiten indistintamente ambas posibilidades (en particular: CADH, 8.2.d), aunque la opción por defecto es que el Estado le proporcione un defensor (CADH, 8.2.e).

Asimismo, la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio (CN, 18) impone que la actividad defensiva deba tener, por lo menos, un piso mínimo de efectividad. No basta para satisfacer los estándares constitucionales que el acusado tenga patrocinio letrado de manera formal, sino que debe recibir una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor (ver fallos “Núñez”, CSJN, 2004, e “Iñigo”, CSJN, 2019).

En particular, la defensa técnica incluye las siguientes facultades:

- Acceso a la información y a los elementos de prueba, salvo reserva de las actuaciones.
- Contar con el tiempo y los medios para preparar adecuadamente la defensa.
- Comunicación libre y privada entre el defensor y la persona asistida.

- Contraexaminar a los testigos de cargo, y ofrecer testigos en favor de la postura defensiva.
- Conocimiento tempestivo de los elementos de cargo (deber de revelar), y no ocultamiento de la evidencia favorable al imputado (doctrina *Brady*).
- Interponer los recursos previstos en la legislación, y en particular el recurso contra la sentencia condenatoria.
- Principio de congruencia, como garantía de que el tribunal no podrá avarlar una variación sorpresiva del supuesto de hecho respecto del cual se ejerce la defensa.
- Principio acusatorio formal, como garantía de que el tribunal no podrá resolver más allá de lo postulado y solicitado por los acusadores (limitación del objeto procesal a lo planteado por las partes).
- Imparcialidad del tribunal, que además de ser una garantía autónoma funciona como presupuesto del ejercicio de la defensa en un plano de igualdad respecto de los acusadores. También se relaciona con el principio acusatorio formal, en cuanto supone la separación de las funciones requirente y decisoria.

h) Protección de la persona y de su ámbito privado

La teoría de los círculos concéntricos (Binder)

§ 64. La protección de la persona y de su ámbito privado, ya sea que se trate del imputado o de otras personas, reconoce diversos niveles de protección. Resulta esclarecedor el planteo de Binder, en cuanto propone que la Constitución Nacional conforma *círculos concéntricos cuyo punto central es la persona humana en la dimensión total de su dignidad humana*.

Estos círculos concéntricos reflejan distintos grados de protección, porque a medida que nos acercamos más inmediatamente a la persona humana, los resguardos adquieren más fuerza y hasta se tornan más estrictos. En su enunciación general, el primero de esos círculos establece las protecciones contra el ejercicio o la amenaza del poder punitivo estatal, con lo cual en él se incluyen todas las garantías que aquí se exponen.

Los tres niveles de protección

§ 65. Ya en el ámbito más específico de la protección de la persona y de su ámbito privado, podemos también distinguir distintos niveles de protección:

- Un *primer nivel* es el de los métodos absolutamente prohibidos, como la tortura, la coacción y las amenazas. Este es un nivel de limitación absoluta, que no puede ser salvado por ningún procedimiento. Incluimos también en este nivel la *incoercibilidad de la persona imputada*, cuyas proyecciones estudiaremos con la temática probatoria. Puede decirse que este primer nivel protege a la persona en su manifestación más directa e inmediata: su condición humana, su dignidad, su voluntariedad, su integridad psíquica, y constituye una derivación de la *prohibición de obligar a declarar contra sí mismo* y de la *abolición del tormento* (CN, 18).
- Un *segundo nivel* es de los actos que solamente pueden ser realizados mediando autorización judicial expresa, como los allanamientos o la intervención de comunicaciones. También incluimos aquí a los actos que están sujetos a circunstancias regladas de excepción, como el allanamiento sin orden o la requisa. Este segundo nivel protege el ámbito de despliegue inmediato de la persona, que incluye su domicilio, su intimidad y la privacidad de sus comunicaciones, por lo que se deriva de la *inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y los papeles privados* (CN, 18).
- Finalmente, un *tercer nivel* surge del respeto a la ley y a los procedimientos preestablecidos. Surge como derivación de la cláusula -ya estudiada como principio de legalidad procesal- que establece la necesidad de juicio previo *basado en ley* (CN, 18), e impide el ingreso de información al proceso por fuera medios específicamente previstos. Este nivel se relaciona con las condiciones que la propia legislación establece para la validez de determinados actos, y con los principios que dicha legislación consagra para el procedimiento (por ejemplo: intermediación, imposibilidad de fallar en base al conocimiento privado del tribunal o a información no introducida por los canales legalmente establecidos).

Las garantías procesales como reflejo de normas prohibitivas

§ 66. Como puede verse, el tema aparece presentado desde su efecto intra-procesal, fundamentando lo que serían las prohibiciones probatorias o límites al ingreso de información al proceso. Sin perjuicio de reconocer que la proyección principal de este tipo de garantías es la protección del imputado contra la obtención indebida de elementos de cargo, debe aclararse que las garantías van

más allá de este punto. Así, cuando se prohíbe la tortura, no está simplemente estableciéndose una nulidad probatoria, sino que realmente se trata de una conducta prohibida por el orden jurídico, y uno de los tantos efectos de dicho carácter es la imposibilidad de aprovechar procesalmente la confesión obtenida por tales medios.

Otro tanto puede decirse en relación a que estas garantías protegen a la persona imputada. En realidad, *la mayoría de ellas protegen a toda persona*, y sólo algunas operan con exclusividad -o al menos con orientación preferente- en favor de la persona imputada. Ocurre que, desde el punto de vista de sus efectos en el proceso, resulta particularmente útil recordar la prohibición probatoria derivada de la actividad investigativa ilícita. Pero ello no quita que sea efectivamente ilegal, por ejemplo, allanar la morada o interceptar las comunicaciones de terceras personas sin orden judicial (aunque nunca resulten imputados), o coaccionar a los testigos (aunque estén jurídicamente obligados a declarar).

i) Protección contra la persecución penal múltiple

Formulación general

§ 67. La prohibición de persecución penal múltiple surge de manera implícita del artículo 18 constitucional. Los tratados la consagran de manera expresa, disponiendo con diversas formulaciones que el inculcado que ha recibido sentencia firme no puede ser juzgado ni sancionado nuevamente por los mismos hechos (CADH, 8.4; PIDCP, 14.7). Sin embargo, ya mucho antes la garantía aparecía reconocida en términos generales en la legislación procesal, en la jurisprudencia (como derivación del derecho de defensa en juicio, del debido proceso y del sistema republicano) y hasta en las constituciones provinciales (en nuestro caso: CSFe, 9, en cuanto prohíbe reabrir procesos fenecidos salvo en favor del condenado).

Alcances

§ 68. Aunque se omita analizar en detalle cada formulación del principio, sí debe decirse que la garantía ha sido enunciada con diversos alcances. En un sentido estrictísimo, se enuncia como prohibición de penar a quien ya ha sido

absuelto o condenado en un proceso anterior. Hoy se acepta de manera unánime que la protección es más amplia, e impide no sólo la aplicación de pena sino también el inicio y desarrollo de un nuevo proceso por el mismo hecho. Es decir, se protege contra el riesgo de ser sometido a una persecución penal renovada.

Si bien la garantía ampara a quien ha recibido un pronunciamiento de absolución o condena (sentencia material), se entiende que también protege a quien ha obtenido un pronunciamiento anticipado de efecto equivalente. En nuestro caso, esto es claro en el caso del *sobreseimiento* (CPP, 306) y del *archivo jurisdiccional* (CPP, 290). En cambio, opera de manera más limitada el *archivo fiscal* (CPP, 289), que está sujeto a reapertura, recurso y conversión (CPP, 291, 293).

La operatividad de la garantía requiere que el pronunciamiento antecedente se encuentre *firme*, considerándose que existe tal situación cuando se han agotado todas las vías recursivas. De todos modos, se entiende que la garantía impide no sólo la reapertura de procesos fenecidos, sino también la formación simultánea de procesos múltiples.

Las tres identidades

§ 69. Para que exista persecución penal múltiple, deben verificarse las tres identidades respecto del proceso antecedente: identidad personal, identidad objetiva e identidad de causa.

- ***Identidad personal.*** Se requiere que sea la misma persona a la que se persigue en un nuevo proceso, no pudiendo extenderse la protección a otras personas (por ejemplo, a los copartícipes).
- ***Identidad objetiva.*** Debe tratarse del mismo hecho imputado. Mediando esta identidad, no puede volver a perseguirse bajo una calificación jurídica distinta. Cuando el mismo hecho da lugar a varios encuadres posibles, la solución legal es la acusación alternativa dentro del mismo proceso (CPP, 295, último párrafo). Por otra parte, si con posterioridad al proceso aparecen nuevas pruebas que permiten ampliar o agravar la calificación jurídica o la pena, la garantía opera totalmente impidiendo la revisión en perjuicio del imputado. En todo caso, para evitar esta situación no queda más remedio que trabajar con eficacia en la etapa investigativa. Existen casos en los que resulta complejo determinar si estamos ante el mismo hecho, tal como ocurre con los supuestos limítrofes en los que se discute si hay unidad o pluralidad delictiva, o en los cursos causales irregulares.

- *Identidad de causa*. Aunque mayoritariamente se la considera una “tercera identidad”, se trata de un conjunto de excepciones basadas en razones de orden jurídico. Esto ocurre cuando en el primer proceso media un obstáculo a la persecución penal (por ejemplo: privilegio constitucional, o falta de instancia privada en los delitos que la requieren) o a la obtención de un pronunciamiento con efecto de cosa juzgada material (la ausencia de este efecto se produce, en el CPP Santa Fe, en los casos de *desestimación* y *archivo fiscal*), o median obstáculos legales a la válida actuación del tribunal (conurrencia de delitos no acumulables por dar lugar a distintas acciones penales, anulación del primer pronunciamiento por incompetencia del tribunal). Con todo, cabe reconocer que no existe una regla unívoca para estos casos, y así la concurrencia de la llamada *tercera identidad* deja un importante margen para la casuística.

Mecanismos procesales para plantear la garantía

§ 70. El mecanismo procesal para articular una defensa de persecución múltiple dependerá de si existe pronunciamiento antecedente firme, o si concurren varios procesos abiertos simultáneamente. En el primer caso procederá la excepción de *cosa juzgada* (CPP, 34.3), mientras que en el segundo corresponderá la de *pendencia de causa penal* o *litispendencia* (CPP, 34.4).

También se prevé la excepción de *archivo por investigación penal preparatoria antecedente* (CPP, 43.5, 292), aunque debe recordarse que este supuesto está limitado por la posibilidad de reapertura, recurso y conversión.

Finalmente, también se ha planteado como lesivo de la garantía la retrotracción del proceso a etapas precluidas en perjuicio del imputado. Es decir, en este caso la garantía operaría evitando la *repetición indebida de actos cumplidos dentro del mismo proceso*, por lo que se relaciona también con el derecho a ser juzgado en un *plazo razonable*.

Recurso del acusador y persecución múltiple

§ 71. Se ha discutido si lesiona la prohibición de persecución múltiple la posibilidad de que el acusador recurra la sentencia en perjuicio de la persona imputada. Recuerda Maier que el sistema anglosajón veda totalmente el recurso contra el veredicto absolutorio del jurado (es decir, se considera que la posibilidad de un nuevo juicio viola la garantía), por lo que nuestro modelo

constitucional de proceso penal debería conducir a que el sistema recursivo sea unilateral, en beneficio únicamente del imputado (doble conforme).

Si bien esta postura no ha sido receptada en general por nuestra legislación, ya veremos que efectivamente hay algún límite al recurso del acusador: en caso de anulación y nuevo juicio, si se obtiene una nueva absolución la misma es irrecurrible (CPP, 405).

j) Plazo razonable

Formulación general

§ 72. El derecho de la persona imputada a ser juzgada dentro de un plazo razonablemente rápido surge en la jurisprudencia nacional como una derivación del derecho de defensa y del debido proceso, por lo cual se lo desprende de del artículo 18 constitucional (fallo “Mattei”, CSJN, 1968). En los tratados aparece regulado ya como garantía autónoma: derecho de toda persona a ser oída dentro de un plazo razonable (CADH, 8.1), o derecho de la persona acusada a ser juzgada sin dilaciones indebidas (PIDCP, 14.3.c).

Hay también alguna referencia al plazo razonable al momento del control de detención o al resolverse la situación cautelar, que es formulado como derecho a *ser llevado sin demora ante un tribunal* y a *ser juzgado en un plazo razonable o puesto en libertad* (CADH, 7.5-6; PIDCP, 9.3-4), expresiones que en general son tomadas ampliamente y no limitadas a un momento procesal determinado.

§ 73. Si bien la garantía no era desconocida en tiempos más remotos, puede considerársela nueva en cuanto responde a un problema contemporáneo como es la excesiva duración de los procesos penales. En este sentido, no opera sólo ante una conducta intencionalmente lesiva, sino ante un estado de cosas estructural y multicausal: la duración de los procesos penales se ve agravada por factores inmanejables, como el ambicioso programa de legislación criminal, el régimen de la acción penal, las inadecuadas estructuras judiciales, los déficits investigativos de variada índole, la creciente conflictividad social que a su vez genera una creciente judicialización de la vida...

Criterio rígido o flexible

§ 74. Esto ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a idear distintas formas de protección de la garantía, lo que incluye también definir qué puede considerarse un plazo razonable. En cuanto a este último punto, habría dos criterios básicos a seguir: el plazo puede estar *predeterminado por ley* (criterio rígido), o bien quedar sujeto a la *valoración judicial en cada caso* (criterio flexible).

La idea de establecer por ley un plazo máximo de duración del proceso es considerada por muchos autores como la opción más garantizadora, por cuanto brinda seguridad jurídica y una relativa igualdad de trato. Pero en general, esta opción no ha sido seguida en casi ninguna legislación. Entre nosotros, el criterio legal o rígido se adopta de manera limitada, en el instituto de la *cesación de la prisión preventiva* (CPP, 227) y en el *plazo para solicitar archivo fiscal previo a la instancia de archivo jurisdiccional* (CPP, 290). Pero en todo caso, se trata de una metodología que sólo se ha aplicado en situaciones que suponen una mayor causación de daño que la mera duración del proceso mismo: la privación cautelar de la libertad y la sujeción del imputado a un proceso infructuoso.

Con respecto al proceso en sí mismo, prevalece de momento la evaluación judicial, que inevitablemente debe hacerse *caso a caso*.

El criterio flexible en la jurisprudencia

§ 75. En un intento por limitar los márgenes de incerteza y arbitrariedad que esto acarrea, la jurisprudencia ha ido generando criterios orientadores para determinar si se está ante una infracción al plazo razonable.

El precedente más exhaustivo de estos criterios puede verse en el dictamen de la Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso “Wenhoff” (CEDH, 1968). En aquella ocasión, la Comisión expuso la *doctrina de los siete criterios*, que serviría de base para posteriores desarrollos. Los siete criterios serían:

- La duración de la detención en sí misma.
- Duración de la prisión preventiva en relación al delito, a la pena señalada y a la pena que debe esperarse en el caso de condena.
- Los efectos personales sobre el detenido.
- La conducta del imputado en cuanto haya podido influir en el retraso del proceso.
- La dificultad para la investigación del caso.
- La manera en que la investigación ha sido conducida.

- La conducta de las autoridades judiciales.

La doctrina de los siete criterios es sumamente flexible, lo cual la vuelve tan útil para los tribunales como inútil para los justiciables. Es cierto que parece contemplar casi todas las circunstancias imaginables que pueden justificar márgenes mayores o menores de tolerancia según el caso. Se admite algún grado de prolongación si el imputado estuvo en rebeldía, si la pena en expectativa es muy alta o si el caso es particularmente complejo. Por el contrario, permite ser más riguroso en delitos leves o de investigación simple, o cuando el imputado se encuentra privado de su libertad o gravemente enfermo o cuando las autoridades fueron negligentes en la investigación, sólo por dar algunos ejemplos. Según el caso, los jueces deberán contabilizar los factores en uno u otro sentido, y ponderar si se justifica la prolongación verificada.

Esta idea es receptada a grandes rasgos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en el caso “Stögmüller” (TEDH, 1969) sostuvo que el plazo razonable no se puede traducir en un número fijo de días, semanas, meses o años. Retoma la idea de los criterios orientadores, que reduce a tres: *la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales*. Esta línea jurisprudencial se mantendrá a grandes rasgos en fallos posteriores, tanto en el sistema europeo como en el interamericano.

En Argentina, la Corte nacional también se ha orientado hacia un criterio flexible, como se verifica en el ya citado precedente “Mattei”. De la jurisprudencia posterior, debe destacarse que en “Mozzatti” (CSJN, 1978) se considera que existe un agravante cuando el imputado se encuentra detenido. Pero en general se recuperan, combinados de distinta forma, los criterios ya expuestos.

El criterio rígido en doctrina

§ 76. En un desarrollo de la *postura rígida o legal*, el profesor Pastor plantea la necesidad de que las legislaciones reglamenten la garantía convencional, estableciendo con precisión el plazo máximo del proceso penal y las consecuencias jurídicas que resultarán de su incumplimiento. Deriva esta conclusión del conjunto de principios de garantía, y critica agudamente la tesis flexible o judicial. Para el autor citado, un plazo que no puede medirse en unidad temporal alguna (días, semanas, meses, años) es un “no plazo”. Por otra parte, la consecuencia del incumplimiento del plazo legal debería ser la clausura definitiva del procedimiento, planteada como excepción (por analogía con la prescripción).

k) Derecho al recurso

Primera etapa: postura restrictiva

§ 77. A diferencia de la mayor parte de las garantías, el derecho a recurrir el fallo no surge inicialmente como una derivación del CN, 18. El recurso contra la sentencia aparece entre nosotros directamente en la legislación común, pero sin que ello obedezca a la necesidad de materializar un principio de mayor jerarquía. De hecho, en el fallo “Hossain Abbes Kholil vs. Swift” (CSJN, 1940), la Corte sostuvo expresamente que la doble instancia judicial no es un precepto constitucional.

Aquel criterio fue mantenido durante décadas, hasta que la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1984 obligó a considerar los alcances del *derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior* (CADH, 8.2.h).

En “Jáuregui” (CSJN, 1988), se sigue sosteniendo que la doble instancia judicial no constituye por sí misma un requisito de naturaleza constitucional. Sí se reconoce que la CADH consagra el derecho del imputado a recurrir el fallo, pero se lo limita a los supuestos de la sentencia definitiva u otra resolución asimilable a ella. Finalmente, se aclara que ese derecho se satisface con el recurso extraordinario ante la propia Corte Suprema.

Segunda etapa: reconocimiento del derecho

§ 78. La postura restrictiva de “Jáuregui” sería revisada en el caso “Girolodi” (CSJN, 1995). Aquí nos ubicamos a un año de la constitucionalización de los tratados (CN, 75.22), y a cinco años de que se concediera a la Corte la facultad de rechazar recursos extraordinarios por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia, según su sana discreción (CPCCN, 280).

Estas circunstancias acarrearón dos importantes consecuencias en torno al derecho a recurrir el fallo: Primero, que ahora tiene indudablemente jerarquía constitucional (CN, 75.22; CADH, 8.2.h). Y segundo, que no puede ser debidamente satisfecho con el recurso extraordinario federal, atento a la facultad de rechazo discrecional (CPCCN, 280).

En este marco, la Corte estableció que la forma más adecuada de garantizar el derecho del imputado a recurrir el fallo, era declarando la inconstitucionalidad de los límites legales que vedaban la admisibilidad del recurso de casación

en razón del monto de la pena (en el caso, la condena a un mes de prisión condicional resultaba irrecurrible según la normativa procesal).

Más tarde, la propia Corte vendría a aclarar que el derecho a recurrir el fallo ampara únicamente al imputado y *no a la fiscalía*, sin perjuicio de que el legislador le conceda igual derecho (fallo “Arce”, CSJN, 1997).

Respecto del *querellante*, hay quienes entienden que el fallo “Santillán” (CSJN, 1998) le reconoce el derecho al recurso. En rigor, el precedente establece que el querellante, al que la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, tiene *derecho a obtener un pronunciamiento útil* relativo a sus derechos. También de manera indirecta y en el contexto de hechos particularmente graves, la Corte IDH ha establecido que *las víctimas deben tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de las investigaciones*, de conformidad con la ley interna (caso “Bulacio vs. Argentina”, Corte IDH, 2003). De esto último podría deducirse que, si la ley regula una etapa recursiva, el acusador privado tiene derecho a abrir dicha etapa y participar de la misma.

Tercera etapa: ampliación del ámbito de revisión

§ 79. Hemos visto que el derecho al recurso aparece insinuado en “Jáuregui” y consagrado con mayor claridad en “Giroldi”. Esta línea jurisprudencial es profundizada en el fallo “Casal” (CSJN, 2005), puntualmente en relación a la amplitud que debe tener el recurso para satisfacer el derecho consagrado en la CADH, 8.2.h. En el caso se problematizan los límites del recurso de casación, que en el CPP Nacional (1991) dejaba fuera de su análisis las cuestiones de hecho y prueba.

En “Casal”, la Corte establece que el tribunal de alzada debe realizar el *máximo esfuerzo en revisar todo lo que sea posible*, incluyendo las cuestiones de hecho y prueba. Es más, se cuestiona que sea posible realizar una distinción tan clara entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, aunque se acepta como no revisable lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Citando expresamente el precedente interamericano “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (Corte IDH, 2004), la corte nacional establece la necesidad de que el recurso, independientemente de su denominación, garantice una examen integral de la decisión recurrida.

Doble instancia, derecho al recurso, doble conforme

§ 80. En cuanto a la terminología, deben distinguirse tres expresiones diferentes: doble instancia, derecho al recurso y doble conforme.

- La **doble instancia** es una característica de los sistemas judiciales, que por lo general se organizan de manera vertical o piramidal (cortes o tribunales superiores, cámaras o tribunales de alzada, y tribunales o juzgados de primera instancia). En este sentido, es correctísimo decir, incluso en la actualidad, que *la doble instancia no es un requisito constitucional*.
- El **derecho al recurso** sí es una facultad de los sujetos que intervienen en el proceso. En relación a la persona imputada (y de manera más discutible, al querellante), esa facultad reviste jerarquía constitucional (CN, 75.22; CADH, 8.2.h; PIDCP, 14.5). Para la fiscalía, es simplemente una facultad que surge de la legislación común, y que por lo tanto puede ser limitada o incluso suprimida.
- Parte de la doctrina sostiene que el derecho al recurso corresponde únicamente a la persona imputada. Esta postura fue sostenida en Argentina por el profesor Maier, basado principalmente en los principios y la dinámica del modelo adversarial, en cuyo sistema el recurso contra el fallo absolutorio implica un riesgo de persecución múltiple. En este sentido, se habla de derecho al **doble conforme**, como exigencia de que la sentencia de condena sea ratificada en dos instancias consecutivas, como requisito para la válida aplicación de una pena. En nuestro sistema, el anclaje normativo de esta postura surge del PIDCP, que establece: *toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley* (PIDCP, 14.5). La cuestión es sumamente discutida, ya que por otra parte la norma análoga del sistema interamericano establece que *toda persona tiene derecho (...) de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior* (CADH, 8.2.h).

1) Garantías relativas al órgano de juzgamiento

§ 81. La jurisdicción penal está sujeta a un conjunto de reglas de garantía, que integran el estándar del debido proceso (CN, 18). Las normas constitucionales exigen que el juez o tribunal sea *independiente, imparcial y natural* (CN, 18;

CADH, 8.1), y por otra parte establecen el juicio por jurados (CN, 24, 75.12 y 118).

Independencia

§ 82. La *independencia* del juez refiere a que el magistrado no puede recibir instrucciones respecto de los casos sometidos a juzgamiento, ni debe ser colocado en una situación de vulnerabilidad frente a presiones de cualquier tipo.

La primera manifestación de este principio son las reglas de *inamovilidad* de los magistrados y de *intangibilidad* de sus remuneraciones. Esto tiende a proteger al magistrado de las amenazas o presiones que pudiera sufrir por el ejercicio de su función. Concretamente, se busca que el juez no dependa de autoridad alguna para mantener su cargo y su nivel de ingresos, o, dicho a la inversa, que ninguna autoridad pueda amenazar con removerlo, trasladarlo o disminuirle el sueldo.

En algún momento se entendió que la intangibilidad de las remuneraciones debía garantizarse exceptuando a los jueces de la obligación de pago del impuesto a las ganancias. Esta idea rigió hasta la sanción de la ley nacional 27.346, que eliminó aquel privilegio sólo para los jueces designados a partir del año 2017. La constitucionalidad de la obligación de tributar fue luego avalada por la Corte nacional (fallo “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, CSJN, 2018).

También se pone en riesgo la independencia del magistrado con la utilización abusiva de las facultades disciplinarias, con el dictado de fallos pretendidamente obligatorios (plenarios), y en general con la estructuración vertical de la jurisdicción, que recuerda al modelo de organización inquisitivo secular. En este caso, se habla de *independencia interna*, es decir frente al propio Poder Judicial.

Finalmente, la independencia también puede verse afectada por la influencia de los medios masivos de comunicación, la difusión sesgada de información sobre los casos penales y la hegemonización de los ámbitos de comunicación social por parte de discursos populistas.

Imparcialidad

§ 83. La *imparcialidad* ha sido tradicionalmente definida como la ausencia de intereses o prejuicios, por parte del juez, frente al caso que debe decidir. Este

primer concepto es complementado con la idea de que el tribunal debe dar garantías de esa imparcialidad, o mejor dicho debe evitar no ya la parcialidad, sino hasta el temor fundado de parcialidad. Este segundo sentido del término resulta mucho más amplio, ya que abarca no sólo la ausencia de interés o prejuicio (imparcialidad en sentido subjetivo), sino también la imagen de imparcialidad (imparcialidad en sentido objetivo). Estos dos aspectos no son contradictorios ni excluyentes, sino complementarios. Es decir, el tribunal debe ser efectivamente imparcial, y además debe dar la tranquilidad de que lo es.

Los sistemas tradicionales solían contener una enumeración taxativa de las causales de apartamiento, que en general estaban relacionadas al parentesco, al vínculo económico o al prejuzgamiento u opinión prematura. Además, la doctrina mayoritariamente entendía que dichas causales eran de interpretación restrictiva.

La jurisprudencia reaccionó contra este sistema en el fallo “Llerena” (CSJN, 2005), en el que trató específicamente el temor de parcialidad, dejando también aclarado que las causales legales de apartamiento no pueden interpretarse de modo que afecten el debido proceso y la defensa en juicio.

El código de Santa Fe, advertido ya por el precedente “Llerena”, obliga a los jueces a inhibirse *cuando adviertan cualquier circunstancia que pudiera considerarse que afecta su imparcialidad*. También establece que podrán ser recusados *cuando se generen dudas razonables acerca de su imparcialidad frente al caso* (CPP, 68). Ambas expresiones aluden claramente a la imparcialidad en sentido objetivo, comprensiva del llamado temor o sospecha legítima de parcialidad.

Además, el código deja expresamente aclarado que la pérdida de imparcialidad puede deberse a actos procesales legítimamente cumplidos, con lo cual recepta expresamente la doctrina “Llerena”. Así, establece que *el juez que haya resuelto la prisión preventiva o participado en la audiencia preliminar no podrá integrar el tribunal de juicio ni intervenir en segunda instancia o instancias extraordinarias, y que el juez que haya pronunciado o concurrido a pronunciar sentencias no podrá intervenir en segunda instancia o instancias extraordinarias* (CPP, 68, párrafos segundo y tercero). Estas previsiones son concordantes, a grandes rasgos, con los lineamientos establecidos en las “Reglas de Mallorca” (en particular, Reglas 2.1 y 4.2).

Sin embargo, y aún con esta amplitud en los motivos de apartamiento, debe aclararse que *no se prevé la recusación sin expresión de causa*, como existe en el proceso civil.

Juez natural

§ 84. Se entiende por *juez natural* el juez o tribunal designado conforme a la ley, antes del hecho de la causa (CN, 18; CADH, 8.1). Este principio tiende esencialmente a proteger al acusado contra:

- El juzgamiento por comisiones especiales o por tribunales creados al efecto de un caso ya ocurrido.
- El juzgamiento penal en sede administrativa o por funcionarios del Poder Ejecutivo. Sobre esta base, se declaró la inconstitucionalidad del proceso penal militar, hoy día derogado (fallo “López”, CSJN, 2007).
- La modificación retroactiva de las reglas de competencia. Cabe aclarar que se ha descartado la afectación al principio de juez natural cuando el cambio obedece a razones estructurales y no está orientado a influir sobre un proceso en particular. Así por ejemplo, no podría actualmente pretenderse la reimplantación de los viejos juzgados de instrucción y de sentencia, para juzgar un caso cometido antes de la reforma procesal penal.
- El desplazamiento del juez de la causa por fuera de los supuestos legales de apartamiento.

Juicio por jurados

§ 85. Cuando se habla -y particularmente, cuando la Constitución habla- de *juicio por jurados*, se está haciendo referencia a un particular modelo de jurado popular, proveniente de la tradición anglosajona. En este sistema, el jurado constituye un estamento colegiado, cuya función preponderante es emitir un veredicto por íntima convicción sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Este jurado popular posee una entidad autónoma respecto de la magistratura permanente: el juez, separado funcionalmente del jurado, se comunica con éste por medio de preguntas o instrucciones, y esta interacción está regulada legalmente y controlada por las partes. En caso de que el veredicto sea de condena, corresponderá al juez fijar la pena según las pautas propias de cada sistema.

Dentro de este modelo de jurado puro, hay muchísimas variantes. Así, el número de jurados puede variar según la gravedad del caso: hay jurados de doce miembros, de ocho, de seis... También varían las mayorías requeridas para un veredicto de culpabilidad, que pueden ir desde una mayoría simple o calificada, hasta la exigencia de unanimidad. El objeto de la decisión también es variable. En general, la regla es que el jurado se expide únicamente sobre la

culpabilidad del acusado. Sin embargo, hay sistemas en los que el ámbito de decisión del jurado se extiende a la calificación legal, o a la pena a imponer. También hay jurados que actúan en momentos previos al juicio, como el jurado de control de la acusación, usualmente integrado por veintitrés miembros que deciden por mayoría simple.

El modelo estándar, considerando al jurado popular como una garantía para el justiciable, y en particular para el acusado, sería un jurado de doce miembros, que decide sobre la culpabilidad del acusado por veredicto unánime. Este diseño ofrecería mayores garantías de que la decisión sea verdaderamente debatida, y asimismo el número permitiría contemplar la representación paritaria por género y la representación proporcional de las minorías o grupos socialmente subalternizados.

§ 86. El sistema mixto y su evolución hacia el acusatorio formal durante la segunda posguerra dieron cierta popularidad a los *jurados o tribunales mixtos*, compuestos por jueces permanentes y ciudadanos legos actuando en bloque. Este sistema ha recibido diversos nombres, como Tribunal de Escabinos (Alemania) o Corte de Assises (Italia, Francia). El número y proporción de jueces letrados y legos reconoce amplias variaciones.

Se observa en favor de este modelo que fomenta un cierto intercambio entre la mirada técnica de los jueces y la mirada del ciudadano común. Se le objeta que ese intercambio se produce de manera secreta, en el momento de la deliberación conjunta, y eso lo vuelve incontrolable por las partes (a diferencia del modelo puro, en el que la comunicación entre juez y jurado está mediada por las instrucciones). Según el modelo, también puede objetarse la desmedida influencia del estamento técnico en la decisión, no sólo mediante sus respectivos votos sino también mediante la fundamentación del voto lego.

En este sistema, no hay distinción formal entre veredicto y sentencia: el tribunal mixto dicta la sentencia completa, igual que la dictaría un tribunal íntegramente técnico, debiendo valorarse la prueba según el modelo de la sana crítica racional. Alguna particularidad puede presentarse en los sistemas que reservan la calificación jurídica y la determinación de la pena al estamento técnico exclusivamente.

§ 87. Las sucesivas oleadas juradistas en Argentina han arrojado como saldo la efectiva implantación de uno u otro modelo de jurado en no pocas provincias. Córdoba tiene dos modelos de tribunal mixto (uno de tres jueces y dos jurados, y otro de tres jueces y ocho jurados), según el monto de la pena y el tipo de delito. Chubut tiene tribunales mixtos y jurado puro. También provin-

cias como Neuquén y Buenos Aires han avanzado hacia la implementación de jurados populares al estilo anglosajón.

En Santa Fe, ha habido múltiples proyectos para implantar el juicio por jurados. Aunque ninguno conserva actualmente estado parlamentario, en general se han inclinado por el jurado popular de doce miembros, con mayoría calificada de diez votos para el veredicto de culpabilidad.

§ 88. El instituto del juicio por jurados ha recibido muchísimas críticas, algunas de las cuales hasta se repiten de manera cíclica. Sintéticamente, podemos mencionar:

- Las que sostienen que no es el momento oportuno, o que la ciudadanía todavía no está lista, o que hay asuntos más importantes en qué utilizar los recursos públicos. Lo curioso de esta línea argumental, que en sí no rechaza el instituto sino que más bien lo pospone, condiciona o supedita, es que se ha esgrimido a lo largo de dos siglos: tiene su origen formal en la Constitución de 1819, que ordenaba el establecimiento del juicio por jurados *en cuanto lo permitan las circunstancias* (CN 1819, 114).
- Las que parten de prejuicios sobre las capacidades intelectuales o éticas del jurado, o sobre su supuesta mayor -o menor- propensión a dictar condenas, o sobre si son más influenciables que un juez profesional.
- Finalmente, hay una serie de críticas derivadas de la incompatibilidad del juicio por jurados con otras pautas del sistema. Así por ejemplo, se ha sostenido que un veredicto dictado por íntima convicción sería violatorio del derecho al recurso y hasta del sistema republicano (!), o que la participación popular volvería irrelevante el análisis del caso desde la dogmática penal.

m) Otras proyecciones del orden jurídico internacional

§ 89. La constitucionalización de los tratados fue dando lugar a la *recepción de reglas y principios provenientes del orden jurídico internacional*, en particular de la jurisprudencia interamericana. Si bien estos principios no constituyen garantías o bases constitucionales en el sentido tradicionalmente dado a estas expresiones, parece indudable que constituyen mandatos con directa incidencia en el ámbito del proceso penal.

De los múltiples principios y reglas que se desprenden de este orden normativo, mencionaremos particularmente la *protección de la víctima*, los *delitos priorizados* y la *perspectiva de género*.

Protección de la víctima

§ 90. El hecho de que las garantías penales y procesales constituyan en su origen límites al poder punitivo estatal, ha hecho dudar acerca de si puede ampararse en ellas quien ha sido víctima de un hecho delictivo. Esta posibilidad es contemplada con preocupación desde el garantismo penal, en cuanto ofrece nuevas posibilidades de legitimación y de ampliación del poder punitivo.

La jurisprudencia interamericana ha reconocido a las víctimas como sujetos del sistema de protección, particularmente tratándose de delitos cometidos por el propio Estado, o en delitos graves en los cuales no se haya actuado con debida diligencia para su esclarecimiento (ver, ejemplificativamente, caso “Bulacio vs. Argentina”, Corte IDH, 2003). Con todo, no estamos ante una bilateralización del sistema de garantías, sino del reconocimiento del hecho básico de que las violaciones a los derechos humanos pueden provenir tanto de los avances investigativos sobre la persona imputada como de la desidia investigativa en perjuicio de las víctimas y sus familiares.

Delitos priorizados

§ 91. Por otra parte, hay convenciones que *obligan a los estados parte a perseguir y sancionar determinados segmentos de criminalidad*. En particular, se consideran delitos priorizados los *actos de tortura* (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 4) y los *hechos de corrupción* (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 30). Otro tanto ocurre con los *hechos de violencia contra la mujer* (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer [“Convención de Belém do Pará”], 7), aunque se debate el alcance de este mandato (ver, al respecto: fallo “Góngora”, CSJN, 2013).

La jurisprudencia interamericana, por su parte, ha considerado que existe en general un deber de investigar y juzgar las *graves violaciones a los Derechos Humanos*, como derivación de las *garantías judiciales* y del *derecho al recurso judicial efectivo* (CADH, 8 y 25, respectivamente; caso “Barrios Altos vs. Perú”, Corte IDH, 2001).

Perspectiva de género

§ 92. La incorporación de la *perspectiva de género* en las prácticas judiciales constituye un mandato cuyo cumplimiento viene algo retrasado. Los avances registrados hasta el momento pueden atribuirse principalmente a los movimientos sociales feministas y de diversidad sexual.

Desde el campo teórico, los estudios de género constituyen un punto de partida para visibilizar y abordar manifestaciones de violencia y discriminación hacia las mujeres y otros grupos históricamente subalternizados. En particular, desde la jurisprudencia interamericana se ha advertido el sesgo patriarcal de los actuales sistemas de justicia y la carga de prejuicios y estereotipos involucrados en su funcionamiento.

Algunas manifestaciones de este sesgo de género son las siguientes:

- La falta de diligencia en la investigación de hechos de violencia sexual o de género, fenómeno usualmente asociado a hipótesis alternativas estereotipadas: que la adolescente desaparecida se habrá ido con su novio, que la denunciante dio lugar con su conducta previa a la supuesta violación (ver, ejemplificativamente, caso “González y otras [Campo Algodonero] vs. México”, Corte IDH, 2009).
- La tendencia a indagar en la conducta y la moralidad de la mujer víctima, más que a esclarecer el caso e identificar a los autores (ver, en particular, caso “Véliz Franco y otros vs. Guatemala”, Corte IDH, 2014).
- La victimización secundaria, provocada por el contacto de la mujer víctima con el sistema de justicia (declaraciones repetidas, estigmatización).
- La concurrencia de la discriminación por género con otros factores de desigualdad (raza, situación socioeconómica, prisionización). A modo de ejemplo, puede decirse que en Estados Unidos se ha verificado que las condenas por violación son significativamente más bajas en promedio cuando la víctima es latina, y aún más bajas cuando es afrodescendiente.

El hecho de que la jurisprudencia interamericana haya incorporado un enfoque de género es sumamente relevante, ya que el control de convencionalidad de las normas y prácticas internas debe guiarse por la interpretación que la Corte IDH realice de los tratados.

Síntesis del capítulo

1. *Constitución y proceso penal.*
 - a. *Un primer nivel de desarrollo es la idea de que la Constitución Nacional contiene garantías, que operan principalmente como límites al poder punitivo.*
 - b. *Un segundo nivel de desarrollo, más actual, extrae también de la Constitución la opción por un modelo determinado de proceso. Formulaciones: paradigma constitucional, diseño constitucional del proceso penal.*
2. *Legalidad.*
 - a. *Como proyección al ámbito del proceso del principio de legalidad sustantivo: proscripción de todo avance procedimental por hechos sin apariencia delictiva.*
 - b. *Como sujeción del proceso a la ley (principio de legalidad procesal).*
3. *Juicio previo.*
 - a. *Formulación general: prohibición de aplicar penas sin atravesar por el procedimiento establecido en la ley, y sin dar al acusado la posibilidad de una etapa contradictoria.*
 - b. *Postura de Maier: juicio como razonamiento contenido en la sentencia.*
4. *Inocencia.*
 - a. *Formulación como presunción o como estado. En general, hoy se reconoce como una situación jurídica, y predomina la idea de trato de inocente.*
 - b. *Proyecciones: ausencia de cargas probatorias en cabeza de la persona imputada, beneficio de la duda (que opera de manera distinta según el momento procesal), estado de libertad como regla.*
5. *Debido proceso. En general, predomina la idea de que es un estándar de respeto a la totalidad de las garantías individuales. Habría una formulación clásica como debido proceso legal, y una más moderna como debido proceso constitucional.*
6. *Defensa.*
 - a. *Defensa material, corresponde al propio imputado como derivación del derecho a ser oído.*
 - b. *Defensa técnica, derecho a contar con asistencia letrada. Defensa necesaria, con un estándar mínimo de efectividad para la validez del proceso.*
7. *Protección de la persona y de su ámbito privado.*

- a. *Distintos niveles de protección. Idea de los círculos concéntricos (Binder).*
 - b. *Niveles: de protección absoluta, de requerimiento de permiso judicial para excepcionar la protección, de respeto a los procedimientos legalmente establecidos.*
 - c. *En general son reflejo de normas extraprocesales, cuya violación impacta en el proceso.*
8. *Protección contra la persecución penal múltiple.*
- a. *Formulaciones restringidas y amplias: prohibición de penar o condenar, o de perseguir.*
 - b. *Identidad personal, objetiva y de causa, como requisitos para la operatividad de la garantía.*
 - c. *Puede plantearse por distintos medios según el caso: cosa juzgada, litispendencia, archivo.*
 - d. *Se problematiza si no viola esta garantía la concesión al acusador de un recurso contra la sentencia absolutoria.*
9. *Plazo razonable.*
- a. *Nace de los tratados, con distintas formulaciones, algunas más o menos acotadas.*
 - b. *La jurisprudencia mayormente ha receptado un criterio flexible, es decir, la idea de que el plazo razonable se determina en concreto y según ciertos parámetros.*
 - c. *Alguna doctrina propone avanzar hacia un criterio rígido, con el establecimiento de un plazo máximo legal.*
10. *Derecho al recurso.*
- a. *La jurisprudencia nacional ha ido reconociendo el derecho muy paulatinamente, a partir de la ratificación de las convenciones.*
 - b. *Temáticas: si existe el derecho, quién es el titular del mismo, qué alcance debe otorgarse al recurso para satisfacer las exigencias de las convenciones.*
 - c. *Distinción entre doble instancia (cuestión de organización judicial, sin base constitucional), derecho al recurso (según las convenciones) y doble conforme (postura en favor de un sistema recursivo unilateral).*
11. *Garantías relativas al órgano de juzgamiento.*

- a. *Independencia judicial, como no sujeción del juez a autoridad o poder alguno. Expresada en un conjunto de protecciones y estabilidades funcionales.*
 - b. *Imparcialidad, como ajenidad al caso. En sentido subjetivo, como ausencia de interés o prejuicio. En sentido objetivo, como deber de apartarse cuando exista sospecha de parcialidad.*
 - c. *Juez natural. Prohibición de juzgamiento por tribunales creados con posterioridad y específicamente para el caso. Presenta complejidades ante escenarios de reforma estructural.*
 - d. *Juicio por jurados. Opción constitucional por el modelo anglosajón. Actualmente se debate si otros modelos, como el tribunal mixto de origen continental, satisfacen la garantía.*
12. *Existen otras proyecciones del orden jurídico internacional, que se van dando gradualmente a través de la jurisprudencia de los organismos de protección. Así, la jurisprudencia interamericana fue incorporando la perspectiva de género como pauta interpretativa de la Convención. También se prioriza a ese nivel la investigación y juzgamiento de hechos particularmente graves, y se enfatiza la protección debida a la víctima de un hecho delictual.*

Capítulo 4. Estructura del proceso penal

a) El juicio como etapa y como hipótesis

La centralidad del juicio

§ 93. La idea de que nadie puede ser penado sin juicio previo (CN, 18) le otorga una particular relevancia al juicio propiamente dicho, como etapa fundamental del proceso penal. Es justamente en el juicio oral donde se marcan con mayor nitidez los rasgos de contradicción y bilateralidad propios del sistema, mediante el despliegue de la actividad acusatoria, el ejercicio pleno del derecho de defensa y la imparcialidad del tribunal.

La doctrina suele aludir al juicio oral como la *etapa esencial* del proceso, denotando así que las otras etapas son meramente preparatorias (investigación, etapa intermedia) o eventuales (impugnación, ejecución). El juicio se nos presenta como *la etapa procesal que no puede ser suprimida sin quitar validez constitucional al proceso mismo*.

La comparación con las otras etapas parece reafirmar esta idea:

- La *investigación penal preparatoria* puede verse notoriamente reducida, tal como sucede en el *procedimiento por flagrancia* (CPP, 379 bis a 379 quinque), o prácticamente suprimida, como en el *procedimiento por delito de acción privada* (355).
- Parte de la doctrina admite que por acuerdo de partes pueda prescindirse de la *audiencia preliminar* (CPP, 296), reduciéndose de este modo el contenido del *procedimiento intermedio*.
- La llamada *etapa de impugnación* sólo se abre mediante la interposición de un recurso por parte de un sujeto legitimado (CPP, 380).
- La *etapa de ejecución* sólo se abre una vez firme la sentencia que ordenara cumplir efectivamente pena privativa de libertad (CPP, 421).

El juicio ante los mecanismos negociales

§ 94. Es indudable que esta concepción del juicio oral como etapa esencial del proceso parece haberse relativizado con la introducción de mecanismos negociales en el proceso penal. En particular, la posibilidad de basar una sentencia condenatoria en el acuerdo de partes mediante el procedimiento abreviado ha sido criticada, justamente, porque suprime la instancia garantizadora del juicio oral. Este mecanismo, junto con las restantes alternativas que el nuevo sistema permite, dan más bien la idea contraria: que la celebración de un juicio oral es una ocasión poco frecuente en la práctica del sistema penal.

Frente a esta posible objeción, es necesario aclarar que los sistemas reformados otorgan una enorme importancia a la instancia del juicio oral, pero partiendo de una base diferente: de la concepción del proceso penal, no como una concatenación de etapas -según reza la idea tradicional- sino como un escenario abierto a las distintas formas resolutivas que los litigantes tienen a disposición.

Función alternativa del juicio

Dicho de otra manera, en nuestro sistema el juicio no es simplemente una etapa en el devenir del proceso, sino que funciona como una variable de negociación, como hipótesis de lo que podría ocurrir si no se resuelve una salida negociada. Aunque finalmente no se concrete, la instancia de juicio oral estará siempre como una posibilidad, como un horizonte con el cual debe cotejarse cualquier salida inmediata que dependa del acuerdo de partes. Sin que ello quite, además, que el imputado puede legítimamente rehusar cualquier tipo de salida alternativa que implique para él alguna consecuencia jurídica disvaliosa, y ejercer su derecho a defenderse en juicio oral y público.

Esta *función alternativa* del juicio oral está sujeta a múltiples factores que influyen sobre la consideración que las partes tienen sobre su posición estratégica y sobre la de su adversario. Por ejemplo, la defensa valorará la diferencia entre la pena acordada y la pena que posiblemente pueda aplicarse en juicio, y en qué medida ese margen resulta beneficioso o aceptable dadas las circunstancias. La fiscalía, ante ese mismo factor, tendrá en cuenta las probabilidades de éxito, y en qué medida aceptar una pena de menor cuantía resulta aceptable para, al menos, evitar que el caso quede impune. Además, las partes probablemente estarán sometidas a la necesidad de gestionar eficientemente su propia carga de trabajo, evitando en lo posible la saturación de su agenda con un nuevo juicio oral. Hay también otros factores, como el grado de avance de

la investigación, la contundencia de la prueba recolectada, el interés que manifieste la víctima o la presión de otros actores (medios de comunicación, organismos directivos de la fiscalía).

La negociación en materia penal no es algo fácil ni simple: es una actividad de toma de decisión que pone en consideración múltiples factores, de acuerdo a la información disponible. Ahora bien, la primera información que debe estar disponible es: ¿qué podría pasar si este caso llega a juicio oral? Poder evaluar correctamente los posibles escenarios de litigación resulta esencial, incluso para poder evitar la litigación misma.

b) Etapas del proceso: síntesis

Presentación esquemática

§ 95. A pesar de haberse erosionado la idea del proceso como mera concatenación de actos, pedagógicamente resulta útil exponer las etapas procesales en su tránsito secuencial. Ello a condición de tener presente, en todo momento, que esta es la estructura que se pone en juego para el supuesto de que fracasen todos los intentos de aplicar mecanismos resolutivos consensuales.



Investigación penal preparatoria

§ 96. La *investigación penal preparatoria* (IPP) está a cargo de la fiscalía, bajo el control de las demás partes y del juez.

En esta etapa, se buscará identificar a los autores o partícipes del hecho considerado delictivo y recolectar la prueba que habrá de producirse durante el juicio oral. También es posible que, a la luz de la evidencia recolectada, las partes arriben a alguna forma alternativa de resolución.

Agotada la investigación sin haberse llegado a ninguna resolución alternativa, la fiscalía podrá formular *acusación*, lo que dará paso a la siguiente etapa.

Procedimiento intermedio

§ 97. El código regula un *procedimiento intermedio*, una especie de bisagra entre la etapa investigativa y el plenario. El núcleo de esta etapa es la *audiencia preliminar*.

En esta audiencia, el juez puede asumir un rol más proactivo e instar a los litigantes a que consideren alguna forma de resolución alternativa. Esto abona una primera finalidad de la etapa intermedia, que es *evitar los juicios orales innecesarios*.

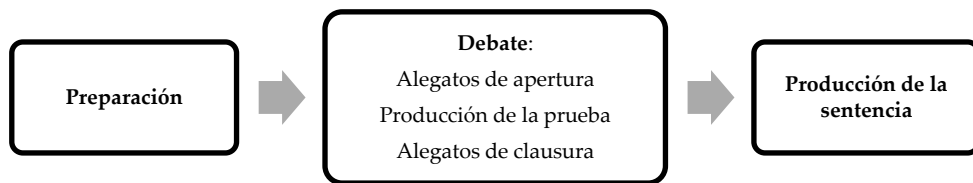
Si no se llega a una solución consensuada que evite el juicio oral, la audiencia preliminar será el ámbito propicio para eliminar la prueba innecesaria, declarar nulidades, resolver cuestiones previas y, en general, *preparar el juicio oral*. Esto dará como resultado un juicio más breve y ordenado, lo cual también contribuye a una mejor utilización de los recursos del sistema judicial.

Juicio oral

§ 98. El *juicio oral* es la etapa central del proceso penal, cuyo núcleo es el debate oral, público y contradictorio entre las partes, ante un tribunal absolutamente neutral.

El rol del tribunal durante el juicio se encuentra limitado a dirigir el debate, resolver las incidencias que se planteen y dictar la sentencia. En esta etapa los magistrados deben sujetarse estrictamente a estas funciones, evitando cualquier extralimitación que pueda verse como una pérdida de objetividad.

A su vez, la etapa de juicio oral tiene tres momentos bien diferenciados: *preparación, debate y producción de la sentencia*. Durante el debate tendrán lugar, secuencialmente, los *alegatos de apertura*, la *producción de la prueba* y los *alegatos de clausura*.



Etapa recursiva

§ 99. Suele denominarse *etapa recursiva* a la impugnación de la sentencia. Esto no es incorrecto desde un punto de vista secuencial, ya que lógicamente viene primero la sentencia, luego la posibilidad de su impugnación y finalmente la ejecución. En este sentido, se trataría de una etapa eventual del proceso penal, ya que tiene lugar únicamente ante la interposición de un recurso por parte de un sujeto legitimado para hacerlo.

No obstante, la legislación permite recurrir resoluciones judiciales distintas de la sentencia, y de hecho el nuevo sistema permite impugnar no sólo los actos del tribunal sino también algunos actos de la fiscalía, lo que seguramente obligará a revisar la teoría de los recursos en el proceso.

Etapa ejecutiva

§ 100. Finalmente, la *etapa de ejecución* se abre al adquirir firmeza la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo (regulada en nuestro país por ley 24.660), aunque también dan lugar a ejecución las resoluciones que imponen medidas de seguridad, prisión preventiva, penas o medidas no privativas de libertad o sanciones pecuniarias.

c) Principios políticos o de actuación

Nociones generales

§ 101. Hemos visto que cuando se habla de “principios” se hace referencia, en primer lugar, a los principios de fuente constitucional que cumplen una función de garantía o que actúan como límites al ejercicio arbitrario del poder punitivo.

Por esta razón, algunos autores prefieren denominar *principios políticos* o *principios de actuación* a aquellos que, en conjunto con los primeros, estructuran e informan un sistema determinado.

No obstante, esta distinción es siempre relativa, ya que es frecuente que la doctrina le reconozca a estos principios algún arraigo constitucional, con lo cual siempre estará la posibilidad de argumentar que son principios fundamentales o de garantía y no principios políticos.

La consecuencia principal de considerar a un principio como político y no como de garantía, es que no resultan obligatorios para el legislador común. Es decir, son principios que surgen de un determinado sistema, no que condicionan al legislador respecto de qué sistema elegir. También está en manos del legislador -y del intérprete- determinar cuál de estos principios tendrá más peso en desmedro del otro en el contexto de un sistema determinado: ello será aún más relevante en un sistema híbrido como el nuestro.

Principio de oficialidad

§ 102. El *principio de oficialidad* refiere al carácter estatal de la persecución penal, rasgo heredado del modelo inquisitivo. La evolución posterior del sistema acarrió la separación entre las facultades requirente y decisoria, pero ambas siguieron estando como regla a cargo de funcionarios estatales.

Este principio, vigente en los sistemas continentales europeos, comienza a perder parte de su fortaleza con la potenciación del rol del querellante privado, que según el caso puede acompañar al acusador público o directamente suplantarle.

Principio acusatorio formal

§ 103. El *principio acusatorio en sentido formal* alude a división de roles al interior del proceso, fenómeno que suele relacionarse con el principio republicano de división de poderes. En particular, hace referencia a la separación entre las funciones requirente y decisoria, aunque ambas puedan estar a cargo de funcionarios estatales por imperio del principio de oficialidad.

La estructuración formalmente acusatoria del proceso penal permite salvaguardar el derecho de defensa del imputado (limita el objeto procesal a lo planteado por el acusador), como también la imparcialidad del tribunal (tercer ajen a éxito de la pretensión punitiva).

La manifestación más clásica del principio acusatorio es la prohibición, para el tribunal, de aplicar penas más graves que las peticionadas (CPP, 335). Por extensión, limita la función de los jueces a resolver las peticiones de las partes (ley 13.018, 1 y 7), y en general veda la actuación o el impulso de oficio (por ejemplo: CPP, 169, 171, 205, 206, 208 bis, 220, 325). Por excepción, se permite actuar de oficio en favor del imputado, lo cual resulta problemático en algunos casos (particularmente, CPP, 219 y 222).

Principio acusatorio material

§ 104. El *principio acusatorio en sentido material*, derivado remotamente del antiguo sistema de los pueblos germanos, reivindica la función pacificadora del proceso penal. Atiende principalmente a los conflictos sociales o interpersonales que subyacen al fenómeno de la criminalidad, favoreciendo la incorporación de mecanismos compositivos como la reparación del daño o la conciliación. En cierta medida, se postula la revalorización de los protagonistas originarios del conflicto, desplazados del proceso penal con el advenimiento del sistema inquisitivo. Institutos como la suspensión del procedimiento a prueba o los criterios de oportunidad adscriben claramente a esta idea.

La posibilidad de canalizar los conflictos de manera compositiva no excluye que el interés de la víctima pueda enfocarse en lograr el castigo penal del ofensor. En este segundo sentido, la potenciación del rol de la víctima y la posibilidad de impulsar el proceso actuando como querellante particular pueden derivarse también del principio acusatorio material, en cuanto ambos fenómenos rememoran un momento previo a la apropiación estatal de la persecución penal.

En el marco de los sistemas de cuño europeo continental, el principio acusatorio material viene a rivalizar con el *principio de oficialidad*, en cuanto fundamenta institutos que excepcionan o al menos debilitan el carácter estatal de la persecución penal.

Principio adversarial

§ 105. El *principio adversarial*, propio de la tradición anglosajona, reconoce a las partes plenas facultades para disponer de sus pretensiones e intereses. Esto implica que el tribunal en modo alguno puede inmiscuirse ni interferir con la estrategia propia de cada litigante.

Si bien se repara, el principio acusatorio formal es una versión más modesta del principio adversarial, en cuanto no llega a concebir enteramente al proceso penal como un proceso de partes, y siempre tiene como telón de fondo el interés público en la persecución del delito. El modelo adversarial, históricamente, se corresponde con un curso evolutivo no mediado por el fenómeno de la inquisición.

El principio adversarial tiene múltiples manifestaciones, dentro de las cuales debe destacarse la autonomía de las partes para disponer negocialmente de sus pretensiones, la renunciabilidad de los derechos y potestades que surgen del proceso, y la mecánica probatoria del interrogatorio cruzado. Resulta curioso verificar que estos caracteres no han sido modificados por la incorporación del acusador público en el mundo anglosajón.

Si bien nuestro sistema puede caracterizarse en términos generales como acusatorio formal, es clara la presencia de rasgos adversariales en la regulación del procedimiento abreviado, en el interrogatorio de testigos y hasta en la amplitud con la que se regulan las salidas alternativas.

Principio de instrucción

§ 106. El *principio de instrucción* tiene su origen durante la Inquisición, para significar que el investigador debía obtener a toda costa la confesión del imputado, única prueba cuya fortaleza permitiría superar el vacío generado con la prohibición de las ordalías. La averiguación de la verdad pasa a ser una finalidad esencial del proceso penal, a punto tal que los sistemas posteriores -mixto y, en menor medida, acusatorio formal- no lograron erradicar del todo la idea de que el propio juez debe averiguar la verdad de los hechos, sin conformarse

con lo que las partes postulen o le soliciten. Bajo este principio, se construye la idea de que en el proceso penal se persigue la averiguación de la verdad real o material, en contraposición a la verdad formal propia del proceso civil y anclada en la actividad de las partes.

Los sistemas de tipo europeo continental (acusatorio formal) conservan en alguna medida este principio, manifestado principalmente en la posibilidad de que el tribunal formule preguntas aclaratorias a los testigos, ordene diligencias complementarias, rechace u observe los acuerdos de parte, o imponga penas más elevadas que las solicitadas por el acusador.

Entre nosotros, la incorporación de rasgos adversariales ha disminuido el impacto del principio de instrucción. Como resultado de esta mixtura, muchos de los sistemas reformados de América Latina son más claramente acusatorios -aún en sentido formal- que sus fuentes europeas. Al menos en Santa Fe, parece bastante indiscutible que el tribunal carece de iniciativa probatoria, de impulso procesal y de atribuciones para suplir la actividad de las partes. Sí se observan algunos efectos residuales menores del principio de instrucción, principalmente en la etapa de ejecución, imbuida aún de cierto paternalismo (ver: CPP, 419.2, 420).

Principio de oralidad

§ 107. El *principio de oralidad* se erige en primer lugar como una opción técnica en cuanto al soporte material del proceso, que regula cómo deben exteriorizarse los planteos de las partes y las decisiones del tribunal. La práctica de alegar oralmente, de interrogar a los testigos frente al tribunal o jurado y de pronunciar verbalmente el veredicto, es connatural al sistema acusatorio en cualquiera de sus versiones. No fue sino hasta la irrupción del sistema inquisitivo que se adoptó la mecánica actuarial o escriturista, como medio para permitir el control jerárquico de las resoluciones.

Los sistemas reformados consagran la oralidad como regla, aunque ello no impide que ciertos actos deban materializarse por escrito. Esto obedece en general a necesidades prácticas atento a la complejidad que ha adquirido el sistema, aunque en muchos casos la imposición de la forma escrita puede atribuirse más que nada al peso de la tradición (por ejemplo: CPP, 72). En términos muy generales, puede decirse que las solicitudes se formulan inicialmente por escrito y se debaten oralmente.

Síntesis del capítulo

1. *El juicio oral, en el contexto de un sistema que admite salidas alternativas predominantemente negociales, no sólo es una etapa procesal. También funciona como hipótesis de trabajo, que los litigantes tienen en mente al analizar otras posibles resoluciones (función alternativa del juicio).*
2. *El código de Santa Fe estructura el proceso en tres etapas (investigación, etapa intermedia y juicio oral), que pasan a ser cinco si se considera como etapas a la impugnación y a la ejecución.*
3. *A la par de los principios constitucionales que rigen el proceso penal, existen principios políticos que surgen del propio sistema. En el caso de Santa Fe, coexisten principios políticos provenientes de distintas tradiciones jurídicas.*
 - a. *Principio de oficialidad: carácter público del derecho penal y de la facultad de perseguir penalmente.*
 - b. *Principio acusatorio formal: necesidad de que las funciones de acusar-investigar y juzgar estén a cargo de sujetos diferenciados, aun siendo ambos organismos estatales.*
 - c. *Principio acusatorio material: intervención directa de la víctima y atención al conflicto subyacente al caso penal.*
 - d. *Principio adversarial: idea de proceso de partes, que deriva en la actuación prescindente del tribunal como tercero imparcial.*
 - e. *Principio de instrucción: Averiguación de la verdad como función del tribunal, que se manifiesta en los sistemas continentales en las preguntas aclaratorias o en las medidas para mejor proveer, y entre nosotros tiene una consagración muy limitada (etapa de ejecución).*
 - f. *Principio de oralidad: mecánica inherente al sistema acusatorio, en ocasiones excepcionada al admitirse cierta escriturización.*

Capítulo 5. Sujetos

a) Sujetos y sistemas procesales

§ 108. Los múltiples sujetos que intervienen en el proceso penal han sido objeto de distintas clasificaciones según su participación se considere más o menos importante, y esto obviamente depende del sistema procesal que se presupone como marco conceptual. Así, en el sistema inquisitivo el rol preponderante lo tiene el juez o tribunal, y en el acusatorio el protagonismo es de las partes en litigio. El acusatorio material, en particular, otorga mayor relevancia a los protagonistas del conflicto subyacente (víctima y acusado), mientras que otros modelos acentúan el estudio de las estructuras con rasgos más burocráticos, como los juzgados y la policía.

En lo que aquí interesa, y teniendo como marco el modelo acusatorio heterodoxo vigente en Santa Fe, estudiaremos en primer lugar a la víctima y a los sujetos encargados de promover la investigación y la persecución de los delitos; en segundo lugar, al imputado y a la defensa técnica, y en tercer lugar, a los tribunales y a la organización que suponen.

Existen otros intervinientes, de los que se dará una breve noticia en lugares específicos.

b) La víctima

Caracterización general

§ 109. La reivindicación del rol de la víctima en el proceso penal es una conquista de los actuales procesos de reforma. Implica, en cierta medida, recu-

perar el lugar del que fuera desplazada con el advenimiento del sistema inquisitivo.

La situación de víctima de un delito no refiere directamente a un rol como sujeto procesal, sino ante todo a una circunstancia desafortunada o hasta trágica en la vida de una persona. Para poder operativizar los derechos que surgen de dicha situación, el código se refiere a *quienes aparezcan como víctimas u ofendidos penalmente por el delito* (CPP, 80), o a *quien invoque verosímilmente su calidad de víctima* (CPP, 81). Estas expresiones elípticas obedecen a que no sería correcto pronunciarse sobre el carácter del víctima de una persona, porque ello podría interpretarse como un adelantamiento de opinión respecto de la culpabilidad del imputado. Particularmente en los primeros momentos de la investigación, a quien parece ser la víctima se lo trata como tal.

No es necesario formalizar ningún trámite de “constitución como víctima” para ejercer los derechos que correspondan. Son las autoridades judiciales - particularmente, de la fiscalía- quienes deben ir a buscar a la víctima, no a la inversa. No obstante, siempre que sea posible será conveniente alguna presentación formal, que advierta a la fiscalía para que no omita ninguna comunicación pertinente.

Derechos de la víctima

§ 110. La víctima como tal, sin más trámite que su identificación, tiene los siguientes derechos:

- En primer lugar, a contar con *asistencia estatal*, no sólo desde el punto de vista humano (CPP, 81), sino también desde la apoyatura técnica que se necesita para ejercer efectivamente sus derechos (CPP, 80.10, 82).
- Se consagran *derechos básicos en cuanto a su situación vital*, como recibir un trato digno (CPP, 80.1), e información y documentación sobre la marcha del proceso (CPP, 80.2-3). También a no ser revictimizada a causa del proceso mismo: minimización de las molestias (CPP, 80.4), protección de su intimidad (CPP, 80.5) y de su seguridad (CPP, 80.6).
- Se le reconocen diversos derechos que hacen a su *participación en el proceso*, como a ser oída (CPP, 80.10), a requerir medidas urgentes (CPP, 80.7), a que su situación se tenga efectivamente en cuenta al momento de tomar ciertas decisiones en relación al imputado (CPP, 83), a reclamar por el avance de la investigación (CPP, 80.8), a recurrir las salidas desincriminatorias dispuestas por la fiscalía (CPP, 80.8), y finalmente a participar como querellante (CPP, 80.9).

§ 111. El código santafesino ha avanzado en reconocer a la víctima, no sólo como una persona vulnerable a la que hay que asistir y acompañar, sino como un auténtico sujeto procesal con potestades para influir en el resultado del litigio y en la situación del imputado, en una clara concesión al principio acusatorio material.

A tal punto el rol de la víctima se ha amplificado en nuestro sistema procesal, que no faltan ocasiones en las que esta participación tensiona con derechos básicos del imputado. Estas situaciones derivan principalmente de la coexistencia entre la víctima y el acusador público, que vienen a formar un litisconsorcio irregular plagado de interacciones poco claras.

c) La fiscalía

El modelo burocrático-judicial (derecho continental)

§ 112. La figura del fiscal está ligada en su origen al sistema inquisitivo secular. En este modelo de proceso, el fiscal o procurador del rey intervenía representando principalmente el interés de la corona como beneficiaria de las penas pecuniarias (confiscación de bienes). Progresivamente la actuación del fiscal fue extendiendo su alcance, llegando a tomar intervención en la mayoría de los casos como una especie de asesor del magistrado, con la misión de brindar su dictamen u opinión oficial sobre la pena a imponerse.

La evolución posterior del proceso penal europeo continental iría perfilando a la fiscalía como el órgano regular de la acción pública. No obstante, su rol siempre estuvo teñido de cierto carácter accesorio respecto de la figura del juez, quien podía actuar de oficio en la mayoría de los casos. La acumulación de funciones en la figura del magistrado volvía prácticamente irrelevante la actuación del fiscal, a punto tal que, incluso en la mayoría de los modelos mixtos, el tribunal podía condenar aún ante el requerimiento absolutorio del fiscal. En este modelo, la fiscalía no es otra cosa que un *organismo auxiliar del tribunal*, que tiene por misión velar por la legalidad del proceso.

El modelo político-criminal (derecho norteamericano)

§ 113. Este rasgo burocrático y ciertamente opacado de la fiscalía -que en la Europa continental duraría hasta la segunda mitad del siglo XX-, contrasta con

la evolución del instituto en el modelo norteamericano. Allí el fiscal no es un auxiliar del juez, sino un órgano político en la mayoría de los casos, que goza de importantes márgenes de discrecionalidad para orientar la persecución penal según criterios de utilidad social.

En algunos modelos más centralizados (como el sistema federal estadounidense), los rasgos más marcadamente políticos corresponden a las figuras directivas de la fiscalía. En modelos más descentralizados, los propios fiscales de distrito son electivos, con lo cual tienen una legitimación directa de base comunitaria.

En este sistema (en cualquiera de sus versiones), al fiscal no se lo evalúa por el cumplimiento de reglas formales, sino por los resultados concretos que obtenga (reducción de los indicadores delictuales, desactivación de focos de conflicto, aplicación de sanciones severas en hechos de gran notoriedad social). La fiscalía no es aquí un organismo auxiliar del tribunal, sino una *agencia de control de la criminalidad*.

La cuestión en Santa Fe: caracterización del MPA

§ 114. En Santa Fe, la reforma procesal penal fue acompañada de una reestructuración de todos los organismos que intervienen en el sistema. Respecto de la fiscalía, la ley 13.013 regula el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como un organismo autónomo dentro del Poder Judicial (art. 2). Se trata de una autonomía relativa, que por el momento no está afianzada por mandas constitucionales a nivel local (a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional; ver CN, 120). En este punto, en el proceso de reforma se optó por crear directamente un organismo nuevo, manteniéndose la intervención del viejo Ministerio Público sólo para las cuestiones no penales.

El MPA rescata de la tradición norteamericana la impronta política de sus cuadros directivos, como también su estructura dinámica y enfocada al trabajo por objetivos. Este diseño moderno ha permitido que la fiscalía se constituya como un actor central en la implementación del nuevo sistema, a pesar de la notoria inconsistencia que implica su dependencia del Poder Judicial. Con todo, se trata de un organismo de naturaleza híbrida, que en su organización interna aún conserva rasgos típicos de las burocracias judiciales.

Misión, funciones y perfil institucional

§ 115. El MPA tiene por misión el ejercicio de la persecución penal pública procurando la resolución pacífica de los conflictos penales (ley 13.013, 1). Esta misión genérica se descompone en tres funciones centrales:

- Promover y ejercer la acción penal.
- Dirigir a los organismos investigativos.
- Ser responsable de la iniciativa probatoria.

La ley establece también un conjunto de principios de actuación (art. 3), dentro de los cuales deben destacarse la orientación a satisfacer los intereses de las víctimas, la gestión de los conflictos que subyacen a los casos penales, la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia y desformalización, y la unidad de actuación.

En el marco de nuestro sistema procesal, la fiscalía detenta claramente el *rol de parte*. Esto no quita que deba actuar con objetividad -por ejemplo, si encuentra una pista posiblemente desincriminatoria tiene el deber de investigarla-, pero esto no equivale a imparcialidad. El principio de objetividad conlleva que el fiscal no deba actuar de manera arbitraria o con mala fe, pero no quita que cuando el caso se vuelva litigioso pueda (¡y deba!) actuar estratégicamente, y hasta con un grado aceptable de astucia, para que sus planteos prevalezcan por sobre los de su contraparte. En modo alguno la ley exige que el fiscal sea un torpe o un quedado: debe pelear por los intereses de la víctima -en la medida en que esto sea compatible con un esquema general de política criminal- con el mismo ímpetu con el que un buen defensor pelearía por el interés del imputado. Es por eso mismo que el fiscal *debe ser objetivo, pero nunca podrá ser imparcial*.

Estructura orgánica

§ 116. El MPA está integrado por órganos de dirección, órganos fiscales, órganos de apoyo a la gestión y órganos disciplinarios.

Dentro de los *órganos de dirección*, están el Fiscal General y los cinco Fiscales Regionales (uno por circunscripción). Todos ellos acceden por concurso a un mandato de duración limitada (seis años), que en el caso del Fiscal General no es reelegible por otro período consecutivo. Para su destitución, la ley regula un procedimiento similar al del juicio político.

Los organismos de dirección tienen múltiples funciones, en general de carácter organizativo, conformando una estructura piramidal que en su nivel regional pretende adecuarse a las particularidades del fenómeno delictual en cada territorio. Debe destacarse que el Fiscal General puede dictar instrucciones generales para orientar la persecución penal, mientras que los Fiscales Regionales pueden dictar tanto instrucciones generales como particulares, es decir, pueden dar indicaciones en un caso concreto. Las últimas reformas, en general, han amplificado la intervención de los directivos en la labor de los fiscales y fiscales adjuntos, llegándose a imponer la necesidad de venia para ciertas decisiones, como también la posibilidad de recurrirlas internamente ante el superior.

Más allá de las particularidades de su regulación, está claro que la ley tiende a que los directivos de la fiscalía ejerzan un liderazgo activo y dinámico. Esto contrasta con la superioridad formal de los fiscales de cámara del viejo sistema, cuya función principal no era de conducción sino recursiva (intervénían en el trámite de las apelaciones).

Los *Fiscales* y *Fiscales Adjuntos* guardan entre sí una relación formalmente jerárquica, que en la práctica apenas resulta visible más allá de lo salarial. Las facultades organizativas de los Fiscales Regionales hacen que la división del trabajo entre los fiscales se dé de manera dinámica, pudiendo organizarse los grupos de trabajo según requerimientos de política criminal. Algunos criterios organizativos básicos son:

- Actuación *por turnos*, siguiendo el esquema tradicional. Éste es un criterio en general superado, salvo para la actuación en caso de urgencia.
- Criterio *territorial*, según el cual se dispone de los fiscales para cubrir diversos puntos del territorio (por ejemplo, al establecerse un mínimo de un fiscal por departamento).
- Según la *complejidad sociodemográfica del territorio a abordar*, puede haber fiscalías de estructura más simple en el interior, y una organización más robusta y con mayores subdivisiones para las grandes áreas metropolitanas.
- Suele ser común la creación de *unidades especializadas según el tipo de delito*. En general, esto se entiende recomendable ante fenómenos delictuales muy específicos, no sólo en cuanto a su tipicidad penal sino más bien en cuanto a su abordaje institucional e investigativo (por ejemplo, delitos económicos o fenómenos de criminalidad organizada). No debe abusarse de este criterio creando una fiscalía para cada artículo del Código Penal.

- Los modernos procesos de reforma han incorporado métodos de trabajo *por flujo de casos*, según el cual las unidades fiscales se organizan funcionalmente para brindar una respuesta escalonada según el caso lo requiera. Esto presupone una primera instancia que recibe y clasifica el caso en base a diversos factores (viabilidad jurídica y fáctica, complejidad de la investigación, gravedad del hecho, situación de la víctima), y eventualmente activa un protocolo de primeras diligencias para cumplir con las medidas más urgentes. Luego el caso puede desestimarse, ser derivado a una oficina de salidas alternativas (que negocia la aplicación de criterios de oportunidad, suspensión a prueba y en algunos casos juicio abreviado), o ser remitido a una unidad que procede investigativamente y formula acusación. Este sistema tiene la ventaja de agilizar la aplicación de respuestas tempranas, y de destinar mayores esfuerzos a los casos que en principio lo ameritan. Obviamente, su aplicación está destinada casi con exclusividad a áreas metropolitanas o de alta concentración poblacional.

Los Fiscales Regionales pueden organizar sus equipos de trabajo con márgenes importantes de discrecionalidad (por excepción, hay limitaciones), para lo cual pueden echar mano de uno o varios de estos criterios. No incumbe al Fiscal General interferir en esta organización, aunque sí puede instar la creación de sus propias unidades especiales, destinadas a actuar en más de una circunscripción.

Los Fiscales y Fiscales Adjuntos son, en definitiva, quienes cumplen directamente con la misión institucional del MPA. Son quienes dirigen la investigación penal, tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal pública y son los responsables de la iniciativa probatoria. Si bien son funcionarios comprendidos en un régimen de carrera, la actual legislación tiende a acentuar su carácter político. En particular, están sujetos a un mecanismo de destitución de carácter parlamentario, pensado originariamente para los organismos directivos.

Los *órganos de apoyo a la gestión* y los *órganos disciplinarios* cumplen roles fundamentales, relacionados con la aplicación de sanciones disciplinarias, la administración financiera de la fiscalía y la capacitación de los operadores. En particular, la Junta de Fiscales constituye un mecanismo de limitación y control recíproco entre el Fiscal General y los Fiscales Regionales.

d) Los organismos investigativos

La policía en función de investigación

§ 117. Si bien corresponde a la fiscalía la dirección de la IPP, ello no quita la necesaria colaboración técnica de funcionarios con formación específica en investigación y criminalística. Esto en modo alguno implica que la fiscalía pueda delegar totalmente esta actividad, sino que deben establecerse mecánicas de trabajo en conjunto para lograr el esclarecimiento de los delitos y la recolección de la evidencia.

Los organismos investigativos pueden recibir genéricamente la denominación de *policía*, aunque este término suele llevar a equívocos. Aclaremos inicialmente que la tarea policial tiene dos manifestaciones principales -junto con muchas otras accesorias-, que son la *prevención* y la *investigación*. La prevención es el conjunto de actividades y procedimientos que se despliegan con el objetivo de reducir la cantidad y la intensidad de los fenómenos delictuales. Esta tarea está a cargo de las agencias policiales y ejecutivas, y usualmente se exterioriza de manera proactiva con presencia policial en calle (patrullaje, puestos fijos de control, operativos especiales ante eventos de gran magnitud), lo cual puede darse de manera más o menos planificada según se cuente o no con recursos provenientes del análisis criminal.

La investigación criminal, en cambio, es una actividad esencialmente reactiva, puesto que pretende esclarecer el delito ya ocurrido. No apunta a un fenómeno general, sino a un caso concreto, aunque también es posible abordar en conjunto un determinado contexto delictual (por ejemplo, a partir de un conjunto de casos de robo de automóviles, puede construirse un caso más complejo que permita desbaratar una red de tráfico de autopartes). Esta actividad también está a cargo de organismos policiales, pero de otro tipo. Y bajo la dirección, en nuestro caso, de la fiscalía.

Niveles de especialización

§ 118. La relación entre las actividades preventiva e investigativa depende fundamentalmente del grado de desarrollo de cada una de ellas, según criterios de especialización funcional:

- En un nivel básico, *ambas funciones se cumplen de manera indistinta*. No sólo se cumplen en un mismo organismo, sino que las cumplen las mismas

personas. Este sistema actualmente carece de vigencia práctica en su estado puro, aunque tiene alguna presencia residual en localidades pequeñas, siempre que la gravedad del delito no dé lugar a una intervención de otro tipo.

- Un segundo nivel de desarrollo es la *creación de áreas especializadas dentro de la policía común*. Este sistema es el más frecuente en nuestro medio, y abarca desde las organizaciones más tradicionales (por ejemplo, las antiguas brigadas investigativas de cada unidad regional) hasta la organización de todas las ramas investigativas bajo un mando común, conformando *una policía con dos ramas funcionalmente autónomas*. Ejemplo de este fenómeno es la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, creada en el año 2013, que en 2017 pasó a concentrar todas las áreas investigativas de la provincia. En 2019, esta policía especializada pasó a denominarse Agencia de Investigaciones Criminales (AIC). También las áreas investigativas de las fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) responden en alguna medida a este modelo.
- El tercer nivel de desarrollo es la *conformación de una policía investigativa institucionalmente separada de la policía preventiva o de seguridad*. Este es el modelo de la Policía de Investigaciones chilena, o de agencias como el FBI. En general estas instituciones presuponen una instancia formativa especializada, un perfil profesional no militarizado y una estructura de mando civil. En Santa Fe, este sería el modelo del Organismo de Investigaciones dependiente del MPA, cuya competencia está limitada a unos pocos supuestos (ley 13.459, 3). Este tipo de organización en general se dedica sólo a investigaciones de cierto nivel de complejidad, por lo cual es inevitable que los demás casos sean investigados por la policía común o por su rama especializada.

En Santa Fe se da el curioso fenómeno de que estos tres niveles actúan de manera combinada. Ante un caso concreto, la fiscalía tiene en principio la potestad de especificar con qué agencia continuará la investigación. Según el grado de complejidad, esta tarea puede recaer en la AIC o en alguna de las divisiones de la policía común. Respecto del Organismo de Investigaciones -aún en formación-, su intervención está regida en principio por las directivas de la Fiscalía General. Tampoco faltan casos en los que la fiscalía solicita la colaboración de las fuerzas federales.

§ 119. Más allá de que la opción de qué policía asignar a cada caso corresponde a la fiscalía, las situaciones de urgencia usualmente dan lugar a una primera intervención de la policía común. Esto resulta prácticamente inevita-

ble, debido al mayor despliegue territorial de la policía de seguridad en comparación a las áreas investigativas, que normalmente se organizan de manera concentrada para un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos.

Por lo tanto, la ley establece una serie de deberes y atribuciones (CPP, 268) que pesan de manera indistinta sobre cualquier personal policial, y que tienen que ver con la recepción de denuncias, la adopción de medidas urgentes y la comunicación al fiscal. En general, resulta conveniente especificar esta manda legal mediante *protocolos de primeras diligencias* emanados de la propia fiscalía.

e) El querellante

Nociones generales

§ 120. Hemos visto que nuestro sistema ha amplificado notablemente la intervención de la víctima en el proceso penal. Una manifestación de esta intervención es la posibilidad de constituirse como querellante particular, actuando en forma conjunta con la fiscalía en los delitos de acción pública. Además de la intervención exclusiva que ya le acordaban las leyes de fondo en relación a los delitos de acción privada (CP, 73).

Si bien es inicialmente correcto referirnos -como lo hace el propio código- al querellante como un rol que puede asumir la víctima del delito, es necesario precisar y ampliar este concepto. La figura del querellante constituye, en primer lugar, la forma procesal a través de la cual se concede a los particulares la posibilidad de accionar penalmente. Es decir, se trata de un instituto que excepciona el carácter estatal de la persecución penal (rasgo heredado del sistema inquisitivo), por lo cual cabe considerarlo una importante concesión al principio acusatorio material.

Tipología según su legitimación

§ 121. En cuanto a su legitimación, la ley prevé dos tipos de querellante: el particular y el popular (CPP, 93).

- Las leyes suelen legitimar al *ofendido* por el delito a intervenir como *querellante particular*. En este caso, el término “ofendido” se usa en sentido amplio, y comprende no sólo al portador del bien jurídico lesionado o

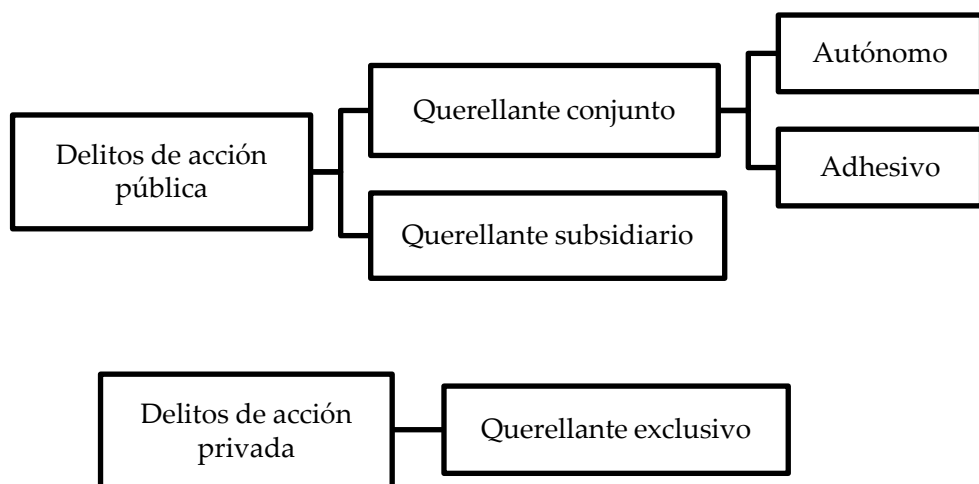
puesto en peligro (según la ubicación sistemática del delito en el Código Penal; por ejemplo, cuando se dice “delitos contra la propiedad”), sino también a quien ha sido directamente afectado en un bien jurídico individual. Por extensión, la ley también otorga legitimación a algunos *causahabientes*. Un tema discutido es si corresponde otorgar legitimación como querellante *al propio Estado* cuando se considera ofendido por un hecho delictivo (por ejemplo, en delitos tributarios o contra la administración pública; ver particularmente ley 24.769, 23).

- En algunos sistemas se habilita a cualquier persona a intervenir como *querellante popular*, cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos. Nuestro código prevé esta posibilidad, aunque *limitándola a la persona jurídica cuyo objeto fuera el bien tutelado en la figura penal* (por ejemplo: delitos ecológicos, hechos de corrupción estatal, delitos contra la salud pública).

Tipología según su forma de actuación

§ 122. La tipología del querellante según el formato de su actuación procesal no es uniforme en doctrina. Una clasificación básica debería partir de distinguir si estamos en el marco de los delitos de acción pública o de acción privada a tenor de la ley penal:

- El *querellante exclusivo* interviene en los delitos de acción privada, en los que la fiscalía directamente carece de participación.
- El *querellante conjunto* interviene en los delitos de acción pública, a la par de la fiscalía. Se le agrega el calificativo de *autónomo* cuando la ley le reconoce facultades suficientes para impulsar el proceso y realizar peticiones que vinculen al tribunal, mientras que se lo denomina *adhesivo* cuando su intervención se limita a acompañar o adherir a la actividad de la fiscalía.
- Finalmente, el *querellante subsidiario* es el que está facultado a ingresar al proceso, en los delitos de acción pública, ante el desistimiento por parte de la fiscalía.



El querellante en el Código de Santa Fe

§ 123. El código de Santa Fe regula la intervención del *querellante exclusivo* en el procedimiento especial para delitos de acción privada (CPP, 347-363). Si bien se le reconocen al querellante similares facultades y obligaciones que las correspondientes a la fiscalía en los delitos de acción pública (CPP, 363), es claro que esta cláusula de equiparación reconoce límites. Primero, porque obviamente el querellante particular carece de las facultades coercitivas que caracterizan al actor público. Y segundo, porque la acción penal privada se rige por el principio de disponibilidad, siendo incluso pasible de desistimiento (CPP, 351 y 352). Más exacto hubiera sido decir que el querellante exclusivo puede litigar como lo haría un fiscal, pero disponiendo de su pretensión como lo haría un demandante en el fuero civil y comercial.

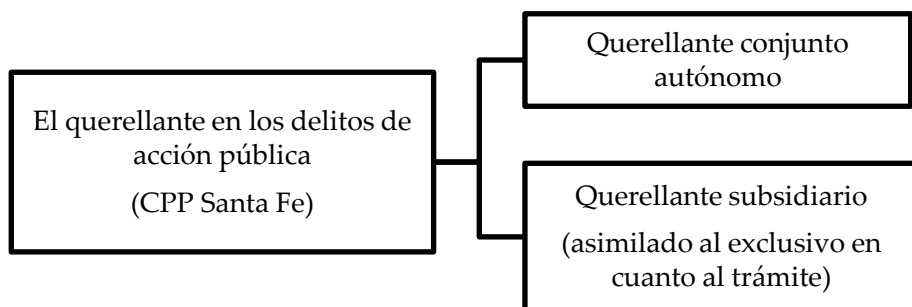
§ 124. En los delitos de acción pública, el código se inclina decididamente por el *querellante conjunto autónomo*. Esta caracterización se reafirma por la negativa, al establecerse que *en ningún caso su actividad estará subordinada a directivas o conclusiones del fiscal* (CPP, 97, último párrafo). Es decir, no sólo se consagra el querellante conjunto autónomo, sino que además se rechaza expresamente el formato conjunto adhesivo vigente en otros sistemas de la región.

En determinados casos, el desistimiento por parte de la fiscalía habilita al querellante a instar la *conversión de la acción penal*. Esta posibilidad se regula ante la aplicación de un *criterio de oportunidad* no aceptado por la víctima (CPP,

21, 22), y en caso de *desestimación* o *archivo fiscal*, una vez agotada la vía recursiva en sede fiscal (CPP, 291). En cualquiera de estos casos, la víctima podrá presentar la querella en el plazo de sesenta días hábiles, y el proceso pasará a regirse por las normas del juicio por delito de acción privada.

Si bien el propio código se refiere lateralmente a quien insta la conversión de la acción penal como *querellante exclusivo* (CPP, 21), sería más correcto caracterizarlo como *querellante subsidiario* según la tipología que ofrece el derecho comparado. Ello principalmente porque no actúa con una legitimación exclusiva originaria, sino acudiendo ante el desistimiento del actor público. Dicho de otra manera, se le aplican las reglas del juicio por delito de acción privada por una cuestión práctica, ya que el querellante carece de la estructura y facultades que le requerirían llevar adelante una investigación preparatoria comparable a la del fiscal. Por ende, la solución legal ha sido que el proceso inicie directamente con la querella (acusación privada), con lo cual *hay una similitud con la actuación del querellante exclusivo, pero sólo en cuanto al trámite, no en cuanto a su legitimación*.

Como conclusión, puede decirse que en los delitos de acción pública se regula el querellante conjunto autónomo, con posibilidad de actuar como querellante subsidiario ante el desistimiento del fiscal.



§ 125. La intervención como querellante conjunto requiere de una instancia de constitución. Es el único tipo de querellante que exige esta formalidad, ya que en los otros dos casos (exclusivo y subsidiario) se procede directamente con la presentación de la querella. Con lo que la instancia formal de constitución permite el ingreso como acusador privado a una IPP en curso, aceptándose incluso el planteo durante la etapa intermedia (CPP, 95).

Procedimiento de constitución como querellante

§ 126. El procedimiento de constitución como querellante tiene dos momentos bien diferenciados:

- La *instancia de constitución* (CPP, 94, 96) debe presentarse por escrito, con representación o patrocinio, ante el fiscal interviniente. Deberá contener los datos del presentante, el relato sucinto del hecho y el carácter que se invoca, los datos de los imputados si los conociera, la petición de ser tenido como querellante y la firma. La ley exige que la instancia sea presentada con copia para cada querellado, lo cual es inexplicable atento a que el presentante puede no saber qué personas se encuentran imputadas. Nada impide, por ejemplo, presentarse como querellante en una causa sin imputados individualizados (vulgarmente, causa NN), justamente con el propósito de impulsar la investigación y hallar a los autores.
- El *trámite* es totalmente escrito o parcialmente oral, dependiendo de la postura asumida por las partes. El fiscal deberá remitir a la OGJ la instancia, expresando su propia postura al respecto. Notificados todos los interesados, *el código regula dos posibles variantes*. Si no hay oposición, el juez puede resolver directamente sin audiencia. En caso de controversia (entre distintos pretensos querellantes, entre querellante y querellados, o ante la opinión negativa del fiscal), resolverá previa audiencia.

Facultades y deberes

§ 127. El querellante, una vez admitido como tal, pasará a tener las facultades y deberes establecidos en el código (CPP, 97). Genéricamente, y con las salvedades que se han hecho, rige la cláusula de equiparación: el querellante puede hacer, en principio, lo mismo que el fiscal.

Un importante efecto de la participación como querellante es que este rol habilita a la víctima a reclamar contra el condenado la *reparación del daño*, mediante el procedimiento especial que el propio código establece (CPP, 99, 364-369).

La intervención como querellante *puede ser desistida expresa o tácitamente* (CPP, 98), lo cual en el formato conjunto no implica disponer de la pretensión punitiva, que continuará a cargo de la fiscalía.

f) La persona imputada

Nociones generales

§ 128. La persona penalmente perseguida recibe el nombre genérico de imputado. Otras denominaciones más específicas aluden a ciertas etapas del proceso (por ejemplo, acusado), cuando no derivan directamente de institutos o hasta de prácticas basadas en normas derogadas (procesado, encartado, reo).

La posición del imputado en el proceso penal ha estado sujeta a la lógica general de cada sistema. Así, el sistema inquisitivo no concebía la figura del imputado como sujeto procesal, sino como *objeto de indagación*. La actividad oficiosa del juez estaba encaminada principalmente a obtener la *confesión*, para lo cual se recurría originariamente a la *tortura*, y en un momento evolutivo posterior al *interrogatorio inquisitivo* (indagatoria). Esta actividad presuponía además el *encarcelamiento preventivo*, al menos como regla general. La situación del imputado en el derecho continental recién se atenuaría con la implantación del sistema mixto, a principios del siglo XIX.

El modelo acusatorio, en sus distintas versiones, fue en general mucho más proclive a reconocer al imputado como sujeto procesal, en una situación de relativa igualdad con el acusador. El principio de inocencia, el beneficio de la duda, el estado de libertad ambulatoria como regla, son consecuencias lógicas de esta concepción. En este sistema, el imputado es una parte procesal, y como tal detenta una serie de potestades tendientes a confrontar y contradecir los planteos acusatorios.

Comienzo y fin de la calidad de imputado

§ 129. El código de Santa Fe, siguiendo un criterio muy extendido, no aborda el concepto de imputado con una definición, sino con una atribución de derechos. No dice quién o qué es el imputado; dice que *los derechos que acuerda al imputado, podrá hacerlos valer la persona que fuera detenida o indicada como autor o partícipe de un hecho delictuoso* (CPP, 100). Esta indicación, materializada en un acto procesal de carácter persecutorio, basta para que la persona aludida pueda ejercer los derechos correspondientes.

La referencia a la *detención* es porque dicha medida, además de constituir un claro señalamiento, genera un estado de vulnerabilidad tal que amerita activar ciertas protecciones básicas (por ejemplo, hábeas corpus por vencimien-

to de plazos, control de legalidad de la detención). Ello no excluye que la *indicación* pueda producirse con otros actos procesales, siempre y cuando tengan un claro contenido persecutorio. Por ejemplo: la denuncia en sede policial o fiscal, la intervención de comunicaciones o el allanamiento de morada. Alguna duda puede presentarse con la llamada *denuncia pública* (en medios masivos o en redes sociales), aunque la tendencia es a reconocer preventivamente idéntico ejercicio de derechos. Por ejemplo, para permitir la presentación espontánea ante la fiscalía.

La calidad de imputado -y con ella, la posibilidad de ejercer los derechos que la ley acuerda- se extiende durante todo el proceso, hasta su finalización por sentencia firme u otra resolución de efecto análogo. Se considera que una resolución está firme cuando se han agotado todas las instancias recursivas o cuando ha vencido el plazo para interponer el recurso pertinente. En caso de recaer condena firme, la extinción de la calidad de imputado no obsta a que algunas manifestaciones defensivas se proyecten durante la etapa de ejecución o al ámbito del recurso de revisión.

Comunicación de derechos

§ 130. El código regula una instancia de *comunicación de derechos* (CPP, 101), que debe efectivizarse ni bien el señalamiento como imputado sea ostensible. En esta instancia, se le debe comunicar:

- La existencia de una causa seguida en su contra con los datos necesarios para individualizarla.
- El hecho que se le atribuye y la calificación legal que provisionalmente corresponda.
- Los derechos referidos a su defensa técnica.
- Que podrá solicitar audiencia a fin de prestar declaración cuando lo estime conveniente, presumiéndose mientras tanto que ejerce el derecho de abstenerse a declarar sin que ello signifique ninguna presunción en su contra.

Esta comunicación está a cargo del fiscal como director de la IPP, siendo posible su delegación en la autoridad policial. Es un acto declarativo, dado que la condición de imputado es previa y no requiere de ninguna investidura formal. Sin embargo, reviste una gran importancia en cuanto se orienta a prevenir abusos en la actividad investigativa. De alguna manera, consagra legalmente la doctrina del precedente estadounidense “Miranda contra Arizona” (USSC, 1966) y del argentino “Montenegro” (CSJN, 1981).

g) La defensa técnica

Generalidades de la defensa en materia penal

§ 131. Como regla general, el rol defensivo requiere de la actuación letrada, siendo excepcionales los casos en que el imputado puede intervenir por derecho propio. En materia penal, se habla por ello de una *defensa técnica necesaria*, que en el caso concreto puede recaer en el defensor de confianza del imputado, o en la defensa pública.

- El imputado puede designar un abogado matriculado para que actúe como su *defensor de confianza*. Puede inclusive designar varios abogados defensores, aunque no podrán actuar más de dos en las audiencias o en el mismo acto (CPP, 116).
- La *defensa pública* interviene ante la falta de designación de un defensor de confianza, ya sea por cuestiones económicas o por cualquier otro motivo.

La defensa en el viejo sistema y en el modelo anglosajón

§ 132. En Santa Fe, el viejo sistema proveía la defensa pública mediante un cuerpo de defensores oficiales organizados jerárquicamente -según actuaran ante los tribunales de primera o segunda instancia- y dependientes del Procurador General de la Corte Suprema. Esta estructura, tomada de los modelos continentales, resultaba sumamente burocrática y rígida, en función del proceso escriturista imperante, y en general su intervención se limitaba a los pocos actos de defensa considerados ineludibles.

El mundo anglosajón tampoco resultaba demasiado inspirador. Hacia mediados del siglo XX, en la mayoría de los estados norteamericanos el derecho a contar con un defensor se consideraba satisfecho con la posibilidad de que el juez nombrara compulsivamente a cualquier abogado presente en la audiencia. Con lo cual no faltaban candidatos que tomaran estos casos para forjar experiencia profesional, o como una cuestión de beneficencia. Este sistema de hecho subsiste, aunque en combinación con alguna mínima defensa oficial.

La defensa penal en el nuevo sistema: caracterización del SPPDP

§ 133. La reforma procesal penal en Santa Fe se inclinó por un sistema de defensa pública estatal, con posibilidad de participación privada. La ley 13.014 regula el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) como un organismo autónomo dentro del Poder Judicial, con una estructura prácticamente refleja a la del MPA. Está integrado por el Defensor Provincial, cinco Defensores Regionales, el cuerpo de Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos, y los organismos de gobierno, administrativos y disciplinarios previstos en la ley. En general, las condiciones de acceso, la duración de los cargos de gestión, los mecanismos de designación y remoción, y hasta las remuneraciones, son prácticamente idénticos a los regulados para la fiscalía.

La ley también prevé un mecanismo para proveer a la defensa de personas con capacidad económica limitada, mediante la participación de los Colegios de Abogados (ley 13.014, 32).

§ 134. El SPPDP tiene por misión proporcionar servicios de defensa penal técnica a toda persona sometida a un proceso penal, a las personas condenadas hasta la extinción de la pena y a las personas sometidas a proceso, trato o condición en los que el Estado ponga en peligro su libertad o su indemnidad física; siempre que se niegue a designar un defensor de su confianza o que, por carecer de recursos económicos o porque otras circunstancias se lo impidan, no pueda contratar a un defensor de su confianza o que no haya optado por ejercer su propia defensa, en los casos y bajo las circunstancias en que la ley así lo dispone (ley 13.014, 10), con lo cual la defensa pública es subsidiaria respecto de la designación de un defensor de confianza. Sus prestaciones son gratuitas para quienes carezcan de medios económicos, pudiendo ser cobradas al condenado en costas en el resto de los casos (art. 11).

También se regula un conjunto de principios de actuación, tales como el respeto al interés y voluntad de la persona defendida, autonomía funcional, sujeción al marco constitucional y defensa de los Derechos Humanos, actuación estratégica como conjunto, eficiencia, trabajo por objetivos, transparencia y calidad del servicio (art. 13).

Un muy importante principio de la defensa pública es la *orientación a garantizar efectiva y eficientemente el derecho de defensa a las personas más vulnerables social y económicamente* (art. 1, tercer párrafo). Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras y dependiendo del contexto local, *la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migra-*

ción y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad (Reglas de Brasilia, 3-21).

h) El tribunal

Nociones generales

§ 135. Un rasgo de origen inquisitivo, pero común a todos los sistemas procesales contemporáneos, es la existencia de una *magistratura técnica permanente*. El hecho de que la administración de justicia esté integrada por funcionarios estatales con versación jurídica constituye hoy un estándar, aún en los modelos con participación de jurados populares.

La reforma procesal penal en Santa Fe ha implicado, en relación a los jueces, tres grandes transformaciones:

- La estructuración formalmente acusatoria del proceso penal implica que las funciones de investigación y juzgamiento sean cumplidas por diferentes estamentos. Con lo cual, y como primer orden de transformaciones, se les quita a los jueces las facultades instructorias o que impliquen cualquier tipo de iniciativa probatoria, y se limita la función judicial a resolver las peticiones de las partes (ley 13.018, 1).
- La división del trabajo entre los jueces penales se ha dispuesto mediante un sistema flexible, que permite resolver la asignación de casos de manera dinámica y según la necesidad. El viejo sistema de división de competencias por función, materia y turnos ha sido reemplazado por un sistema de Colegio de Jueces, en el que todos los jueces penales de idéntica competencia territorial pueden ser asignados de manera rotativa a casi cualquier función (ley 13.018, 2, primer párrafo). Sí se ha conservado la competencia funcional separada de las Cámaras de Apelaciones, aunque también los jueces de cámara se organizan colegiadamente y no por salas de conformación fija. Es decir, tanto en primera como en segunda instancia se asigna a cada caso, y en forma aleatoria, la cantidad de jueces que corresponda.
- Finalmente, la reforma también ha establecido una separación tajante entre actividad jurisdiccional y actividad administrativa. Corresponde a los jueces penales dedicarse exclusivamente a cumplir las funciones jurisdiccionales para las que fueron designados, quedando las funciones admi-

nistrativas en manos de un organismo específico: la Oficina de Gestión Judicial (ley 13.018, 2, segundo párrafo, y 12). Por lo que desaparece, al menos en materia penal, el juzgado como unidad administrativa a cargo del juez.

La competencia penal

§ 136. La determinación del órgano jurisdiccional para intervenir en un caso concreto se rige por las normas sobre *competencia*. Estas normas son, en su origen, un conjunto de pautas de división del trabajo entre los propios jueces. La evolución posterior hizo de este entramado de reglas un sistema para determinar de antemano a qué magistrado tocará intervenir en un caso concreto, con lo cual hoy las reglas de competencia admiten ser consideradas desde dos puntos de vista: como un mecanismo para dividir la carga de trabajo entre los distintos órganos jurisdiccionales (aspecto interno), y como un mecanismo para garantizar a las partes que la intervención de un magistrado tiene lugar en función de reglas preestablecidas (aspecto externo). La tendencia de los actuales procesos de reforma es hacia la eliminación del aspecto interno como regla de competencia en sentido propio, conservándose a lo sumo una regulación administrativa de división del trabajo, que evite la asignación intencional del magistrado interviniente.

La competencia en materia penal es considerada *absoluta* o *de orden público*, en cuanto no admite ser prorrogada por acuerdo de partes (improrrogabilidad), y una vez fijada no es susceptible de modificaciones por hechos ulteriores (inalterabilidad).

Criterios para determinar la competencia

Las reglas de determinación de la competencia pueden clasificarse en *criterios comunes* y *cláusulas de excepción*.

Los criterios comunes son la *materia*, la *función* y el *territorio*.

- La *competencia material* comprende la *especialización de la magistratura penal*, que hoy es la regla excepto en instancias extraordinarias. Dentro de la materia penal, hay una especialización también material en lo *penal juvenil* y en lo *contravencional*. Otros sistemas mantienen criterios más tradicionales, como los tribunales para delitos de menor gravedad (correc-

cionales) o para determinado tipo de delitos (narcotráfico, criminalidad económica).

- La *competencia funcional* diferenciada es tal vez el más claro signo de verticalidad de una magistratura. Refiere a la intervención de un órgano judicial específico en función de la etapa procesal. Actualmente, la única competencia funcional rígida es la de las instancias revisoras (Cámaras de Apelaciones y Corte Suprema). Respecto de las distintas intervenciones judiciales que se suceden en primera instancia (durante la investigación, el juicio y la ejecución), la reforma procesal ha optado por considerarlas meras divisiones internas del trabajo, que en principio se cumplen de manera rotativa (ley 13.018, 22, 23).
- La *competencia territorial* se determina tomando como punto de referencia el lugar donde se afirma cometido el hecho con apariencia delictiva, y en caso de delito continuado o permanente, el lugar en que cesó la continuación o permanencia (CPP, 50). Determinado el punto de referencia territorial, el mismo debe ser contrastado con los distritos o circunscripciones del mapa judicial, según se trate de primera o segunda instancia (ley 13.018, 13; LOPJ, 5, 6).

Las *cláusulas de excepción* son las que regulan la *competencia federal*, la *competencia por conexidad* y la *competencia por unificación de penas*. La primera es una *competencia especial* (actualmente la única, desde la abolición del fuero penal militar), la segunda es una *cláusula de alteración de la competencia ordinaria* y la tercera es una *regla subsidiaria*.

- La *competencia federal* surge de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales que la reglamentan (CN, 116; ley 48, 1-3). Es *excepcional* frente a la competencia ordinaria de las provincias (CN, 75.12), y *limitada*, en cuanto se extiende únicamente a los casos establecidos en la citada cláusula constitucional o en las leyes reglamentarias. Los puntos de conexión para deslindar la competencia federal de la provincial son el *territorio* (lugares de absoluta y exclusiva jurisdicción nacional, alta mar, aguas territoriales, ríos interprovinciales, espacio aéreo y exterior), la *materia* (puntos especialmente regidos por la Constitución o por tratados con naciones extranjeras, delitos que lesionan o ponen en peligro un interés federal) y las *personas* (causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros). No obstante lo señalado, hay una cierta tendencia a extender la competencia federal más allá de lo que constitucionalmente se justifica. En estos casos, la competencia federal debe ser cuestionada legalmente, especialmente cuando se federalizan delitos en abstracto (por ej.: lavado de dinero, estupefacientes), sin reparar en la

existencia o no de un interés nacional realmente lesionado o amenazado en el caso concreto.

- La *competencia por conexidad* es una cláusula que amplifica la competencia territorial natural del tribunal de juicio, permitiéndole abarcar hechos que se afirman cometidos en otros lugares de la provincia. Es decir, es una regla que permite a las partes acumular varios procesos conexos de distintas competencias territoriales ante un solo tribunal. La conexidad puede ser *subjetiva*, por imputarse a una persona más de un delito (CPP, 55.1), u *objetiva*, en caso de haber un vínculo o un acuerdo previo entre los distintos hechos delictivos (CPP, 55.2-3).
- La *competencia por unificación de penas* rige cuando se hubieran dictado dos o más sentencias condenatorias en violación a las reglas del concurso real. En estos casos, *corresponderá dictar la pena única al tribunal que haya impuesto la pena mayor* (CP, 58). Se trata de una norma procesal contenida en la legislación de fondo, que ha dado lugar a múltiples debates. Hoy es considerada una regla subsidiaria, tendiente a evitar que el condenado se vea perjudicado por un conflicto negativo de competencia.

Integración unipersonal o pluripersonal del tribunal

§ 137. Como novedad de la reforma santafesina, el tribunal puede integrarse *de manera unipersonal o pluripersonal* según el caso concreto lo requiera. La regla es siempre la integración unipersonal, lo que obedece a un criterio básico de racionalidad en la utilización de los recursos.

Las circunstancias que determinan la integración pluripersonal del tribunal son las siguientes:

- En primera instancia: cuando el monto de la pena solicitada fuera de doce años o más, o cuando razones excepcionales o la complejidad del asunto así lo aconsejen (CPP, 43). Los planteos sobre integración unipersonal o pluripersonal del tribunal deben formularse y ser resueltos en la audiencia preliminar (CPP, 299, 304.1).
- En segunda instancia: para la impugnación de sentencias dictadas en juicio oral (ley 13.018, 21).

Cuando se solicita la integración plural en primera instancia invocando razones excepcionales o la complejidad del asunto, entendemos que dichas circunstancias deben ser valoradas con criterio absolutamente restrictivo. Nuestra postura se deriva del hecho de que, hacia la época de sanción del código, los recursos tecnológicos aún no permitían suplir por completo el valor

garantizador de la integración plural del tribunal. Debe recordarse que apenas dos años antes de la sanción del código santafesino, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación observaba la dificultad de revisar en alzada las cuestiones percibidas directamente en inmediación (caso “Casal”, CSJN, 2005). De ahí que el legislador haya previsto la posibilidad de filmar la audiencia de juicio, a pedido de la defensa, cuando se hubiera negado la integración plural (CPP, 143).

Hoy en día la totalidad de las audiencias se realizan con registro digital de audio y video. Por ende, el resguardo adicional de la integración plural puede considerarse obsoleto, al menos en lo que hace a garantizar una mejor valoración de la prueba considerada inaccesible por el tribunal de alzada (en su origen, la colegiación se corresponde con el juzgamiento en instancia única en cuanto a los hechos, rasgo típico del sistema mixto). Ello no quiere decir tampoco que no corresponda la integración plural cuando la ley así lo establece, pero la existencia de un recurso amplio y con audiencias filmadas debería llevarnos a exigir que el pedido de integración plural vaya munido de razones verdaderamente excepcionales (en contra de esta postura, Erbetta, Orso, Franceschetti y Chiara Díaz sostienen que resulta más garantizador estar a la integración plural ante la duda).

i) Noticia de otros intervinientes

La Oficina de Gestión Judicial

§ 138. Un componente central en los procesos de reforma es la creación de organismos especializados en gestionar los aspectos administrativos de la justicia penal. Funciones tales como el agendamiento de audiencias, la atención al público, las citaciones o las tramitaciones escritas, son cumplidas por la *Oficina de Gestión Judicial* (OGJ). En el viejo sistema estas funciones eran desarrolladas por cada juzgado de manera aislada, sin aprovechamiento de técnicas de gestión y usualmente sin preparación específica por parte de los funcionarios.

La OGJ se organiza como una entidad paralela a cada Colegio de Jueces, es decir que hay una OGJ de primera instancia y otra que corresponde al Colegio de Cámara. Cada OGJ está a cargo de un Director con versación en administración. No es propiamente un organismo auxiliar de la judicatura, sino que la

relación entre ambos estamentos es más compleja, y se caracteriza por una dinámica que tiene aspectos colaborativos y momentos de tensión. Concretamente, una OGJ correctamente posicionada debería poder plantear ciertos estándares de productividad y calidad de servicio, también en relación a la actividad de los jueces. Por ejemplo, el agendamiento de audiencias implica poder anticipar ciertas pautas temporales, como la duración de cada tipo de audiencia y hasta la puntualidad de los intervinientes. La relación entre la OGJ y los jueces es uno de los aspectos centrales en los actuales procesos de reforma, y en cierta medida las tensiones en esta relación reflejan la profundidad del cambio de paradigma: expresan, en cierto sentido, el cambio cultural que implica dejar atrás una organización tribunalicia de tipo feudal.

Noticia sobre las partes civiles en otros sistemas

§ 139. Los antiguos sistemas -junto a muchos actuales- regulaban la intervención del *actor civil en el proceso penal*. Se entendía que este rol procesal tutelaba en cierta medida el interés de la víctima del delito, como un sucedáneo de la figura del querellante, aunque restringiendo su participación a lo atinente a la indemnización de daños.

Esta idea de introducir la pretensión indemnizatoria en el proceso penal daba lugar a complejidades adicionales, ya que también podía participar un tercero ajeno al hecho presuntamente delictivo como *civilmente demandado* (por ejemplo, el dueño del automóvil implicado en un caso de homicidio o lesiones por imprudencia), y hasta el *citado en garantía* (usualmente, la compañía aseguradora).

La reforma ha eliminado todos estos intervinientes. En cambio, otorga al querellante la posibilidad de activar un procedimiento para la reparación del daño, exclusivamente contra el condenado (CPP, 364-369).

Síntesis del capítulo

1. *Los procesos de reforma en América Latina traen en general una revalorización del rol de la víctima. En Santa Fe, se le reconoce a la víctima como tal un conjunto de derechos, entre ellos la posibilidad de constituirse como querellante.*
2. *La fiscalía se ha organizado en Santa Fe respondiendo a un modelo híbrido, que combina rasgos de los sistemas continental y americano. Es un organismo autónomo dentro del Poder Judicial, pero acusa caracteres que le imprimen una cierta naturaleza política, especialmente en los organismos directivos. Desarrolla su actividad investigativa con el apoyo de organismos policiales cuyo nivel de especialización es variable.*
3. *El código de Santa Fe consagra la figura del querellante autónomo para los delitos de acción pública, y mantiene el querellante exclusivo para los delitos de acción privada. Prevé también la conversión de la acción penal, ante la aplicación de institutos que implican un desistimiento de la acción penal.*
4. *Se define al imputado de manera amplia, en una atribución de derechos que se extiende desde el primer señalamiento hasta el agotamiento del proceso, subsistiendo manifestaciones defensivas también en la etapa de ejecución. Se prevé una instancia de comunicación de derechos.*
5. *En materia penal la defensa es necesaria, pudiendo estar a cargo de defensores particulares u oficiales. La defensa pública en Santa Fe se brinda mediante una estructura autónoma, cuya organización es prácticamente refleja a la de la fiscalía.*
6. *El nuevo sistema ha separado las funciones jurisdiccionales y administrativas, atribuyendo estas últimas a la oficina de gestión judicial. Las funciones jurisdiccionales se cumplen mediante una estructuración flexible, mediante Colegios de Jueces (con separación en primera y segunda instancia). La organización judicial se rige por las normas de competencia, y por mecanismos internos de división del trabajo. También hay normas que determinan la integración unipersonal o pluripersonal del tribunal en el caso concreto.*

Capítulo 6. Acción penal

a) Acción penal y sistemas procesales

Sistemas acusatorios: principio de disponibilidad

§ 140. A grandes rasgos, los sistemas procesales que podríamos considerar puros no presentaban ambigüedad alguna en cuanto al régimen de la acción penal. En los modelos acusatorios clásico, material y adversarial, era muy claro que el ejercicio de la acción privada (a cargo del ofendido) o popular (a cargo de cualquier ciudadano, en delitos que afectaban intereses públicos) se regía por el principio de disponibilidad, a punto tal que ni siquiera hacía falta aclarar esta regla: nadie en su sano juicio hubiera postulado la existencia de un deber legal de acusar.

El principio fue luego receptado por los sistemas adversariales como un componente central de este modelo, a punto tal que siguió vigente incluso con la posterior incorporación del actor público (primero en Estados Unidos, y más tardíamente en Inglaterra). Como hemos adelantado, con algo de exageración podría decirse que el fiscal norteamericano posee sobre la acción penal pública casi el mismo poder de disposición que entre nosotros se concede a la acción privada.

Sistema inquisitivo: principio de obligatoriedad

§ 141. El advenimiento, consolidación y posterior evolución del sistema inquisitivo dará lugar a la creación de un funcionariado estatal con facultades de persecución de oficio (tribunales y fiscalía). Este funcionariado, jerárquicamente dependiente de la Corona, actuará regido por una pauta diametralmente opuesta a la disponibilidad típica del modelo acusatorio: el *principio de obligato-*

riedad de la acción penal. La doctrina posteriormente dará a este principio una nueva y confusa denominación: *principio de legalidad procesal*.

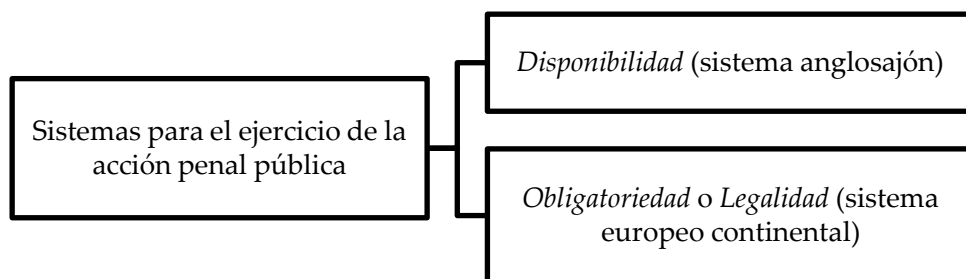
En su formulación inquisitivo-mixta propia de los modelos europeos continentales, el principio de obligatoriedad de la acción penal tiene los siguientes corolarios:

- *Oficialidad*. Como regla, el ejercicio de la acción penal es una facultad de los organismos estatales.
- *Inevitabilidad*. La acción penal debe ejercerse siempre que se tenga noticia de un delito de acción pública, no pudiendo omitirse en ningún caso.
- *Oficiosidad*. Como regla, el ejercicio de la acción penal no requiere ser instado o solicitado por los particulares, sino que se produce *de oficio*.
- *Indivisibilidad*. La acción penal debe dirigirse contra todos los autores o partícipes de un hecho delictivo (indivisibilidad en sentido subjetivo), y debe extenderse a todas las conductas con apariencia delictiva (indivisibilidad en sentido objetivo).
- *Irretractabilidad*. Una vez promovida la acción penal, la misma no puede retractarse o retirarse, debiendo ser sostenida hasta la culminación del proceso.

La fuerza simbólica del llamado *principio de legalidad procesal* reside principalmente en cierta vinculación que se le atribuye con las teorías absolutas de la pena: vendría a realizar en el ámbito del proceso la idea de que *a todo delito corresponde una pena*. Más contemporáneamente, se lo ha relacionado con la necesidad de dar un marco objetivo a la aplicación de la ley y de evitar así que el castigo de los delitos quede sujeto a la arbitrariedad de los funcionarios. Así, Hassemer vincula al principio de legalidad con la igualdad de trato, la vigencia de las normas, la división de poderes y la centralidad del juicio como instancia de decisión pública.

Disponibilidad y obligatoriedad como modelos opuestos

§ 142. Sintetizando lo expuesto, puede decirse que en los modelos anglosajones el ejercicio de la acción penal pública se rige por el *principio de disponibilidad*, mientras que en los sistemas continentales se rige por su opuesto, el *principio de obligatoriedad* o de *legalidad procesal*.



Las excepciones en ambos modelos

§ 143. En su desarrollo posterior, tanto el sistema anglosajón como el continental fueron admitiendo atenuaciones o excepciones.

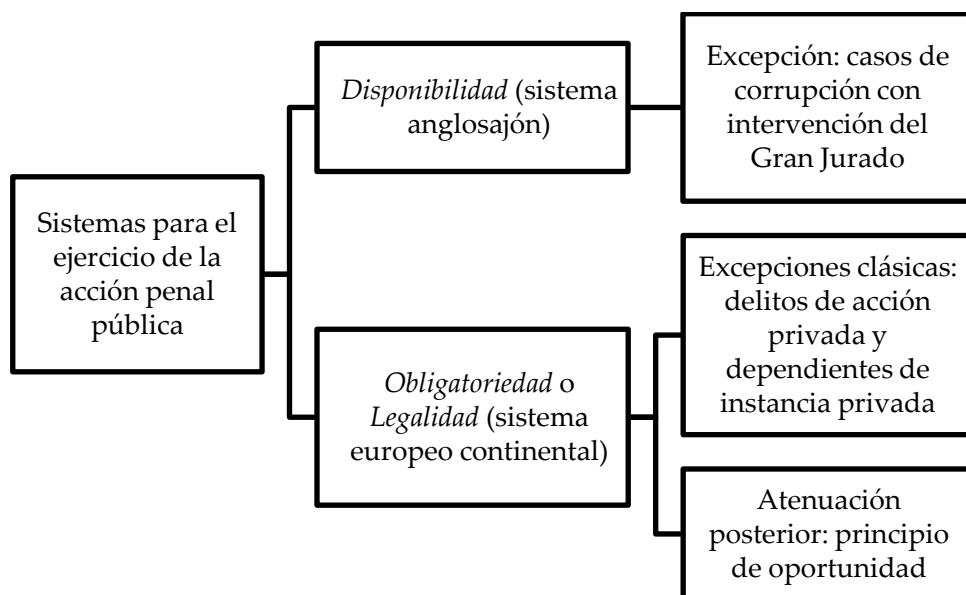
En Estados Unidos, existen casos (como los hechos de corrupción) en los que el desistimiento de la acción penal está sujeto a la aprobación de un *gran jurado*. En estos casos, un veredicto acusatorio implica que ese caso debe obligatoriamente llevarse a juicio, para lo cual es frecuente la designación de fiscales especiales.

En los sistemas continentales, prácticamente desde siempre han existido institutos que excepcionan el principio de obligatoriedad de la acción penal o alguno de sus corolarios. Piénsese, por ejemplo en los *delitos de acción privada*, cuya persecución queda librada a la discrecionalidad de la persona ofendida (excepción a la oficialidad), quien tiene facultades para renunciar a su ejercicio (excepción a la irretractabilidad). También, en los *delitos dependientes de instancia privada*, en los que el inicio del procedimiento se condiciona a la formulación de instancia privada por parte del ofendido (excepción a la oficiosidad).

El principio de oportunidad

Durante el siglo XX, las legislaciones continentales fueron dando paso gradualmente al *principio de oportunidad*, a través de institutos como los *criterios de oportunidad*, la *suspensión del procedimiento a prueba* y el *procedimiento abreviado*. En el marco de estos sistemas (usualmente mixtos o acusatorios formales), el principio de oportunidad fundamenta institutos de atenuación del principio de legalidad procesal, algunos de los cuales hoy englobamos como *alternativas al juicio contencioso* (ver Capítulo 9). No parece resultar inteligible como principio

autónomo, sino como *principio parasitario* (la expresión pertenece al profesor Oliva) respecto del principio de legalidad procesal. Viene a ser un principio dependiente de otro principio.



Oportunidad: fundamentos

La incorporación del principio de oportunidad suele fundamentarse de distintas maneras:

- Desde un punto de vista *pragmático*, constituye la respuesta a la imposibilidad de perseguir efectivamente todos los delitos, especialmente en contextos de creciente conflictividad social, en los que además cada vez más cuestiones son abarcadas por normas penales. Con todo, es una respuesta compatible con los principios del modelo continental, que no desecha totalmente la sujeción de la fiscalía a reglas objetivas, sino que a lo sumo flexibiliza dichas reglas para que resulten aplicables. Es decir, permiten incorporar herramientas de gestión, sin renegar del interés público en la persecución del delito, y sin derogar expresamente la regla de obligatoriedad de la acción.
- Desde la *política criminal*, permiten dosificar la respuesta estatal frente al delito, evitando directamente el ingreso de infractores leves al sistema

penal (sistema que en sí tiene efectos criminógenos), o privilegiando la composición pacífica de los conflictos con el menor desgaste posible. En un sentido más amplio, cumplirían una función reductora del poder punitivo.

- En el marco de los modernos procesos de reforma, brindan a la fiscalía un conjunto de herramientas de negociación, que le permiten posicionarse como actor de pacificación social.
- Finalmente, se discute si algunos institutos vinculados al principio de oportunidad no deben empezar a ser considerados verdaderos *derechos de la persona imputada* (ver, en relación a la suspensión del procedimiento a prueba, fallo “Acosta”, CSJN, 2008).

§ 144. Conceptualmente, el principio de oportunidad amerita algunas consideraciones:

- Como se trata de un principio típico de las legislaciones continentales reformadas, su aplicación no corresponde a la fiscalía de manera exclusiva, sino que involucra una serie de interacciones y controles con otros sujetos. En términos generales, en este modelo el régimen de la acción penal sigue siendo reglado, por lo que en mayor o menor medida el fiscal se encuentra sujeto a un conjunto de controles.
- Alguna doctrina expone los principios de *legalidad* y *oportunidad* como correspondientes a sistemas opuestos, distinguiendo dentro del segundo entre “oportunidad libre” (modelo anglosajón) y “oportunidad reglada” (modelo continental). Esta propuesta tiene el inconveniente de su extrema abstracción, a punto tal que inventa un inexistente tronco común entre sistemas absolutamente disímiles.
- Si bien puede resultar algo confuso distinguir entre *principio de oportunidad* y *criterios de oportunidad*, es ésta la terminología más utilizada en la doctrina de los sistemas acusatorios formales. Otros enfoques se refieren al principio de oportunidad como “reglas de disponibilidad” (por ejemplo, CPP Federal, 30), lo cual no parece correcto ya que esta expresión sugiere un grado mayor de desregulación de la acción penal.

b) Marco normativo de la acción penal

El Código Penal como ley marco

§ 145. El Código Penal, en su redacción original, mandaba iniciar de oficio todas las acciones, con excepción de las que dependieran de instancia privada y de las acciones privadas (CP 1921, 71). La norma provenía del Proyecto de 1881, en cuyos fundamentos se alude a la necesidad de que la autoridad central impida el desorden en la aplicación de la ley sustantiva. El desorden al que se alude es ni más ni menos que la pluralidad de legislaciones subnacionales, fenómeno inevitable en una organización estatal federal.

Las provincias acataron en lo sustancial este marco legal unificador, y reglamentaron el ejercicio de la acción penal según este esquema. Centralmente, lo que se impone como una suerte de “ley marco” es el *carácter público de la acción penal* (regla de oficialidad) y el *deber de iniciación de oficio* (regla de oficiosidad). Como hemos visto, se trata de dos notas centrales del llamado *principio de legalidad procesal* o de *obligatoriedad de la acción penal*.

Las regulaciones locales y la postura compatibilista

§ 146. La facultad para legislar sobre la acción penal no fue seriamente reivindicada por las provincias sino hasta la década de 1990, cuando de manera progresiva comienza a ganar terreno el principio de oportunidad con la consagración de institutos como el procedimiento abreviado y los criterios de oportunidad.

De todos modos, esta tendencia reivindicadora no llega a cuestionar del todo el principio de legalidad procesal, ya que en rigor el principio de oportunidad no lo deroga sino que lo complementa o limita. De hecho, las posturas que legitiman estos avances a nivel local no se basan tanto en el reparto constitucional de facultades legiferantes, sino en la idea de conciliación o complementación entre la legislación local y la nacional (ver por ejemplo, fallo “Sosa Morán”, SCJ Mendoza, Sala Segunda, 19-9-2005).

La acción penal en el Código de Santa Fe

§ 147. El código de Santa Fe se inscribe parcialmente en esta tendencia compatibilista, aunque es considerablemente más innovador que los códigos

de la época (recordemos que fue sancionado en el año 2007). Así, establece que el ejercicio de la acción penal pública corresponde al MPA, quien podrá actuar de oficio (CPP, 16). La expresión “podrá” (en lugar del “deberá” del CP, 71) sugiere una mayor recepción del principio de oportunidad, que luego plasma en institutos como los criterios de oportunidad (CPP, 19), la suspensión del procedimiento a prueba (CPP, 24) y el procedimiento abreviado (CPP, 339). En particular, la regulación de la suspensión del procedimiento a prueba, si bien remite al Código Penal, se inclina decididamente por la tesis amplia, determinando la aplicabilidad del instituto cuando fuera procedente la condena condicional (CPP, 24). Otro tanto ocurre con el procedimiento abreviado, que aparece regulado en un formato marcadamente adversarial, en contraste con lo que ocurre en el resto de las provincias argentinas.

Además, en los delitos de acción pública habilita la intervención del ofendido como querellante conjunto autónomo (CPP, 97), con posibilidad de instar la conversión de la acción penal pública en privada en los supuestos de desestimación, archivo fiscal o aplicación de un criterio de oportunidad (CPP, 22, 291). Aquí sí se advierte una mayor autonomización respecto del régimen del Código Penal, que limita la acción privada a los pocos delitos enumerados en su artículo 73.

La reforma del Código Penal

§ 148. Finalmente, el Código Penal fue modificado para concordarlo con el nuevo CPP Federal. En su redacción actual, el deber de iniciar de oficio todas las acciones penales se establece *sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal* (CP, 71). Como hemos visto, las reglas de disponibilidad a las que refiere la norma son los criterios de oportunidad, la conversión de la acción, la conciliación y la suspensión del proceso a prueba (CPP Federal, 30), institutos cuya regulación local ahora cuenta con un aval más explícito.

Por supuesto, esto no pone fin a la discusión sobre las competencias legiferantes. Hoy en día hay una cierta paz doctrinaria, producto de una extrema gradualidad en las reformas legislativas. La disonancia podrá surgir tan pronto como alguna provincia adopte el principio de *disponibilidad* de la acción pública, lo cual no parece improbable según el curso actual de las reformas procesales.

c) Régimen vigente

§ 149. Hemos visto que la acción penal es una temática atravesada por múltiples complejidades, que van desde su discutible naturaleza jurídica hasta los distintos momentos de tensión y complementación entre la legislación nacional y provincial.

A partir de este ensamblaje normativo, intentaremos a continuación explicar sintéticamente el régimen de la acción penal vigente en Santa Fe.

§ 150. En el esquema del Código Penal, la acción penal puede ser pública o privada, y a su vez la acción pública puede ser promovible de oficio o dependiente de instancia privada. Por imperio de la normativa procesal, habría que agregar que la acción privada puede ser exclusiva o conjunta, y dentro de esta última puede ser particular o popular.

La *acción pública* es la norma general de nuestro sistema (CP, 71), y su ejercicio está regido por el *principio de legalidad procesal*, atenuado por el *principio de oportunidad* en sus distintas manifestaciones.

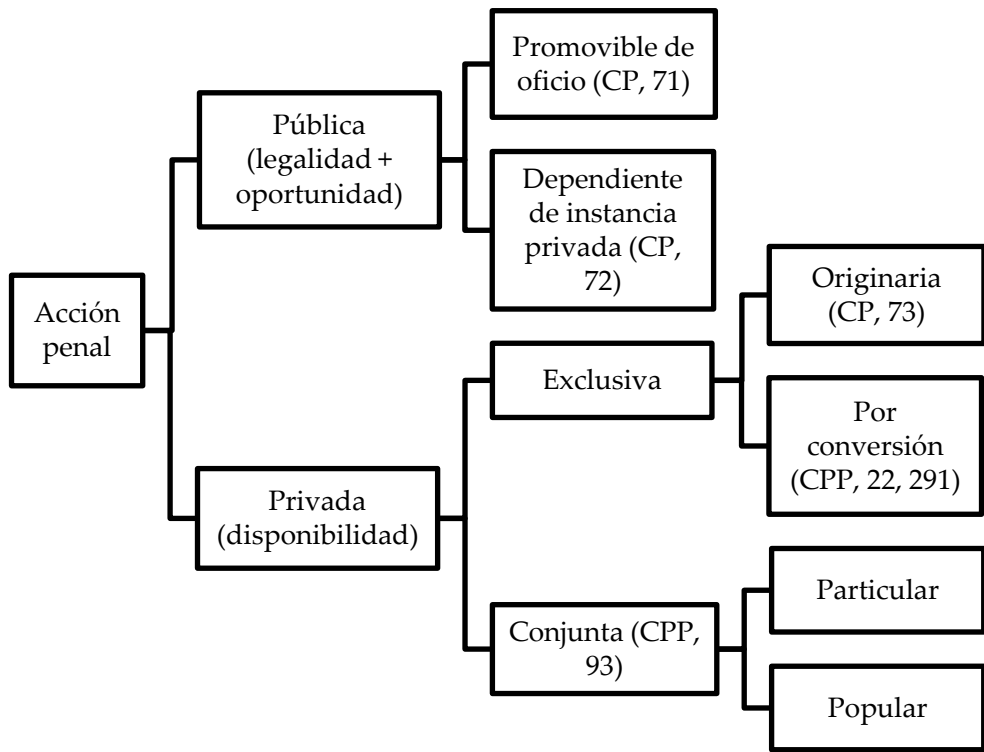
- Como regla, la acción pública es *promovible de oficio*, no resultando necesario acto promotor alguno por parte de los particulares.
- Son *dependientes de instancia privada* las acciones por ciertos *delitos sexuales* (CP, 119, 120, 130, sin resultado de muerte o lesiones gravísimas), *lesiones leves* e *impedimento de contacto filial* (CP, 72). En estos casos, una vez que el agraviado o sus representantes legales manifiestan su interés en la persecución, la acción pasa a tener el mismo régimen que la acción promovible de oficio y *la instancia privada no es susceptible de retractación*. A tal punto la promoción de oficio es la regla general, que la necesidad de instancia privada reconoce múltiples excepciones, vinculadas a la minoridad de la víctima, a la falta de representantes o al conflicto de intereses entre éstos y la víctima menor, o a razones de interés público (CP, 72.a-b-c).

§ 151. La acción privada fue históricamente regulada para delitos cuya persecución despertaba un menor interés estatal: típicamente los delitos contra el honor, a lo que ahora se agregan algunos casos de violación de secretos, concurrencia desleal e incumplimiento alimentario contra el cónyuge (CP, 73.1-2-3-4). En estos casos hablamos de *acción privada exclusiva*, ya que corresponde únicamente al ofendido y a sus representantes legales (y en algunos casos, a sus causahabientes), pero en ningún caso permiten la intervención del actor público.

La introducción del querellante particular en los delitos de acción pública (CPP, 93) da lugar a la *acción privada conjunta*, que puede desarrollarse en paralelo a la acción pública promovida por la fiscalía. En nuestro sistema, se admite tanto la *acción privada particular* a cargo del ofendido, como la *acción popular*, que puede ejercer la persona jurídica cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal, cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos. Si bien la acción popular históricamente constituye una categoría independiente, en nuestro sistema está sujeta al régimen de la querrela privada, por lo cual debe considerársela una subespecie de ésta.

La intervención del querellante en los delitos de acción pública permite instar la *conversión* de la acción penal en los supuestos de desestimación, archivo fiscal o aplicación de un criterio de oportunidad, debiendo presentarse la querrela dentro de los sesenta días hábiles desde la resolución respectiva, una vez agotadas las instancias de revisión (CPP, 22, 291). En estos casos, la acción se registrará por el procedimiento para delitos de acción privada (CPP, 347-353), con lo que el querellante (ya sea particular o popular) pasa a quedar en ese rol en carácter *exclusivo*.

§ 152. En cualquiera de sus modalidades, la acción privada se rige por el *principio de disponibilidad*: su promoción queda librada por entero a la voluntad de la persona legitimada, quien puede desistir de la persecución en cualquier momento (CPP, 351-352). En el caso de la acción privada exclusiva (ya sea originariamente exclusiva o por conversión), el desistimiento acarrea el sobreseimiento de las personas querelladas (CPP, 353; aunque la norma impone el archivo en caso de desistimiento tácito, lo cual despierta fundadas críticas constitucionales).



Síntesis del capítulo

1. El régimen de la acción penal es de naturaleza discutida, predominando actualmente una postura que compatibiliza las normas del Código Penal con las de los códigos procesales.
2. Para el ejercicio de la acción pública existen dos grandes sistemas: disponibilidad y obligatoriedad. Los modelos continentales dieron lugar al principio de oportunidad, que en términos generales excepciona o atenúa el principio de obligatoriedad.
3. Se regula también la acción privada, de aplicación residual y en una limitada cantidad de delitos.

Capítulo 7. Prueba

a) La prueba y su tratamiento legal

§ 153. La regulación de la prueba en el código santafesino se encuentra dividida en *dos bloques normativos claramente diferenciados*. En el Libro II, Título II, artículos a 159 a 204, se prevén los principios generales de la prueba en el proceso penal, y se prevén los medios de prueba en particular: inspección y reconstrucción, testigos, peritos y reconocimientos y careos (y algunos más incluidos dentro de éstos).

Este *primer conjunto de normas*, que mayormente sigue vigente con algunas modificaciones, contrasta con el carácter acusatorio asignado al nuevo sistema procesal penal. Algunas previsiones son sumamente ambiguas en cuanto al modo en que se desarrolla la actividad probatoria, particularmente por la utilización de expresiones impersonales: cuando se dice que el testigo *deberá declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado* (CPP, 173), no se aclara quién está facultado a realizarle preguntas, ni en qué orden. Más allá de que en lugares puntuales se menciona el pedido de parte, en general esta regulación de los medios de prueba parece apuntar más al momento investigativo que al momento de su producción en juicio oral (por ejemplo, la inspección es más una medida de obtención de evidencia que un medio de prueba en sí). De ahí que incluso se regulen medidas coercitivas o de obtención de evidencia (por ejemplo, CPP, 169), en forma un tanto mezclada con los medios de prueba en particular.

Ahora bien, en el Libro IV, Título I, un *segundo conjunto de normas* prevé el interrogatorio cruzado (CPP, 325), la utilización de declaraciones previas (CPP, 325 bis) y la introducción de evidencia material a través de testigos (CPP, 326). Estas normas, producto de una reforma al texto original del código, introducen en nuestro sistema una mecánica probatoria de claro corte adversarial.

§ 154. Estos dos conjuntos de normas que regulan el fenómeno probatorio resultan escasamente compatibles entre sí. Para explicar esta contradicción, tal vez convenga recordar que entre la sanción del código y su entrada en vigencia pasaron más de seis años, y los contextos políticos e institucionales ya no eran exactamente los mismos. También debe tenerse en cuenta que la implementación del nuevo sistema fue acompañada por acciones de capacitación, inicialmente centradas en las técnicas de litigación adversarial. Con lo cual ya había cierta instalación cultural del modelo anglosajón, mucho antes de la reforma.

Pese a esta innegable disparidad regulatoria, sí queda claro que la mecánica del interrogatorio cruzado y la introducción de evidencia material por testigos es específica de la etapa del juicio oral. Esto refuerza la idea de que las audiencias previas al juicio (APJ) son preponderantemente argumentativas, y que en ellas se permite la introducción de evidencia por simple enumeración o exhibición. Esta distinción entre la mecánica probatoria del juicio oral y la de las APJ es básica para comprender cómo funcionan éstas últimas, y para evitar el adelantamiento a las APJ de cuestiones que son propias de la etapa de juicio.

Como veremos, ambos mecanismos se excepcionan mutuamente. Es posible que determinadas evidencias materiales ingresen válidamente al juicio oral sin ser introducidas por testigos. También es posible, a la inversa, que en casos puntuales deba procederse por interrogatorio cruzado en una APJ. Más adelante veremos algunos de estos casos de excepción.

b) Conceptos fundamentales del fenómeno probatorio

Nociones generales

§ 155. Partiendo de esta regulación legal en apariencia contradictoria, deben establecerse algunos conceptos fundamentales:

- *Objeto de prueba* son los hechos que deben probarse. Típicamente, las proposiciones fácticas que integran la teoría del caso de cada litigante.
- *Órgano de prueba* es el sujeto que transmite información al proceso: el testigo, el perito, el imputado.
- *Evidencia material* son los objetos, documentos, rastros, huellas, marcas, señales o vestigios, susceptibles de ser introducidos *como prueba* al proceso.

- *Medio de prueba* es la forma legalmente establecida para el ingreso de información al proceso (documental, pericial, informativa, testimonial, etc.).
- *Forma de introducción* es el procedimiento por el cual cada medio de prueba ingresa en el ámbito de conocimiento del tribunal a efectos de su valoración (enumeración, exhibición, introducción por testigos).

A su vez, el fenómeno probatorio -en su máximo despliegue y extensión- reconoce los siguientes momentos: *hallazgo, formalización, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, producción, introducción y valoración*. Esta es la formulación más extensa, propia de la producción estándar en juicio oral, aclarándose que no todos los medios de prueba atraviesan por la totalidad de estos momentos. Sobre este punto volveremos más adelante.

Objeto de prueba

§ 156. Hemos dicho que se denomina *objeto de prueba* a los hechos que deben probarse, específicamente a las proposiciones fácticas que integran la teoría del caso de cada litigante. Esta idea merece algunas aclaraciones y especificaciones.

Como corolario del *principio de inocencia* (CN, 18; CADH, 8.2; PIDCP, 14.2), asiste al imputado el *beneficio de la duda* (específicamente: Reglas de Mallorca, 33.1), que opera en cualquier grado e instancia del proceso (CPP, 7). Para decirlo con otras palabras, el tribunal deberá pronunciarse a favor del imputado cada vez que no se verifique el grado mínimo de conocimiento exigible para la decisión de que se trate (por ejemplo: *probabilidad* para restringir la libertad del imputado, *certeza* para dictar sentencia condenatoria). Esto tiene un impacto directo en la teoría del caso de los litigantes (y por ende en la delimitación del objeto de prueba), ya que *los hechos constitutivos de cualquier pretensión esgrimida contra el imputado deberán ser acreditados por los acusadores*, constituyendo en el caso de los fiscales un deber funcional procurar esta prueba. Esta carga-deber es *asimétrica*, ya que no pesa deber probatorio alguno en cabeza del imputado o de su defensa técnica. De hecho, es perfectamente posible (aunque no necesariamente es recomendable) que la defensa no tenga teoría del caso propia, y simplemente postule la insuficiencia de la prueba presentada por la acusación. Por supuesto, la defensa también tiene derecho a postular su propia teoría del caso, y si lo hace oportunamente esto genera para la fiscalía el deber adicional de investigar las postulaciones defensivas.

El objeto de prueba sirve para definir la *pertinencia* de una determinada prueba. Será considerada pertinente la prueba que se ofrezca para acreditar las proposiciones fácticas de la propia teoría del caso, o para desacreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso de la contraparte. Si no se verifica esa mínima vinculación, la prueba deberá ser rechazada por impertinente (aunque con otra formulación: CPP, 159, segundo párrafo).

Debe tenerse presente que nuestro sistema permite acordar *reglas particulares de actuación* (CPP, 13), lo cual hace posible que las partes planteen *acuerdos probatorios parciales* sobre determinados aspectos de sus respectivas teorías del caso. Si bien esto está expresamente previsto sólo para los hechos que se postulan *notorios* (CPP, 159, tercer párrafo), no hay inconveniente en reproducir este mecanismo para los hechos que las partes no controvierten (después de todo, la admisión de culpabilidad exigida por el CPP, 339.4 para el procedimiento abreviado vendría a funcionar como una especie de *acuerdo probatorio total*). Los acuerdos probatorios parciales resultan particularmente útiles cuando se plantea una *defensa positiva*, que reconoce buena parte del núcleo de la imputación: por ejemplo, cuando en un caso de homicidio se postula la *legítima defensa* (CP, 34.6), en general se estará admitiendo la materialidad de buena parte del hecho de haber matado a otro, y sólo quedará para debatir si concurren o no los presupuestos de dicha causal. Y sin llegar a casos de acuerdos tan extensos, también es posible que un litigante admita determinado hecho puntual para quitar pertinencia a las preguntas formuladas por su contraparte (“- señor juez, damos por acreditado que el automóvil era rojo tal como sostiene la fiscalía”, es una frase que debería llevar al fiscal a dejar de hacer preguntas sobre el color del auto).

Órgano de prueba

§ 157. El modelo adversarial trabaja sobre un *concepto amplio de testigo*, comprensivo de lo que aquí llamamos testigos, peritos, imputados, etc., es decir de todos los órganos de prueba. Este concepto amplio es el que toma nuestro código en la etapa de juicio oral, por ejemplo cuando habla de la introducción de evidencia material mediante testigos y peritos (CPP, 326).

Comencemos por decir que el órgano de prueba puede actuar como *medio directo de prueba*. En este caso, no habrá diferencia entre medio de prueba y forma de introducción: la prueba testimonial nace como prueba en el momento en que es producida en juicio. Las declaraciones previas prestadas durante la investigación carecen de entidad probatoria autónoma (no constituyen eviden-

cia material), por lo cual no son *introducidas* sino *utilizadas* para los limitados fines previstos legalmente: *refrescar la memoria del testigo* y *señalar contradicciones*.

§ 158. A pesar de este valor prototípico de la figura del testigo -como equivalente del término genérico *órgano de prueba*-, existen distinciones entre los distintos órganos de prueba en particular, como existen también reglas especiales para determinado tipo de testimonios.

En cuanto al primer orden de distinciones, debe distinguirse entre los siguientes órganos de prueba:

- *Testigo*, en un sentido estricto, es la persona que declara en un proceso del que no es parte, sobre hechos percibidos a través de sus sentidos.
- *Perito* es quien dictamina acerca de determinados hechos, por encargo judicial, sobre la base de conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Las diferencias más importantes con la figura del testigo son el encargo judicial previo y la producción de un dictamen.
- Si el testigo declara sobre hechos que pudo percibir sin encargo previo pero en virtud de sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos, a instancia de parte -y previa acreditación en caso de ser necesario- puede ser tratado como *testigo experto*. En este caso, podrá incluir en su declaración opiniones o valoraciones de contenido técnico, que de otro modo serían pasibles de objeción (por ejemplo: el mecánico que al presenciar una colisión vehicular reconoce el sonido típico de determinada falla en el motor; el experto en artes que advierte la sustitución de un cuadro por una falsificación). Más polémica es la atribución de carácter de experto al policía testigo, que declara sobre actitudes sospechosas del imputado al momento de ser aprehendido (en algunos casos, estas supuestas actitudes resultan no ser otra cosa que caracteres estereotípicos, como la vestimenta o cierto rasgo sociocultural o étnico).
- La *declaración del imputado* se regula de manera ambigua. Además de las distinciones de contenido garantizador (como la facultad de abstenerse sin que ello implique presunción en su contra, o la necesaria presencia de su defensor técnico), se prevén una serie de tutelas que con algo de exageración lo sustraen de la lógica general de la prueba testimonial: puede declarar de manera espontánea antes de que se le formulen preguntas (CPP, 111-113), puede ser oído y hacer declaraciones en cualquier momento del debate (CPP, 318, 320), está exento de prestar juramento o promesa de decir verdad (CPP, 318) y está excluido de la mecánica del interrogatorio cruzado, que sólo aplica a peritos, asesores técnicos, testi-

gos e intérpretes (CPP, 325). Es decir, se ha enfatizado tanto la concepción de la declaración del imputado como instancia defensiva (en contraposición al sistema inquisitivo, en el que el interrogatorio perseguía obtener la confesión), que termina desmereciéndose el valor probatorio que podría surgir de dicha declaración si la misma estuviera sujeta a controles de calidad más exigentes. La verdad es que poco puede convencer un imputado que opta por hablar pero sin contestar preguntas, y a quien asiste el derecho a mentir sin consecuencias (no puede ser perseguido por falso testimonio). Por lo que consideramos admisible que, a instancias de la defensa, se permita ofrecer al imputado como testigo, posibilidad que el código no contempla expresamente pero tampoco prohíbe. Si el caso lo requiere y se trata de una decisión estratégica consciente (por ejemplo, si no hay testigos adicionales y la cuestión queda *palabra contra palabra*), debería ofrecerse al imputado la posibilidad de brindar una declaración más robusta, sin rueditas de apoyo, tal como ocurre en el modelo adversarial.

El segundo orden de distinciones refiere a los medios que regulan formas especiales de actuación o declaración de órganos de prueba: declaración de menores (CPP, 160), reconstrucción del hecho (CPP, 166), tratamiento especial para autoridades (CPP, 175, 176), formación de cuerpo de escritura, grabación u otra declaración de cotejo (CPP, 191), reconocimiento de personas (CPP, 194 y siguientes), careo (CPP, 203, 204). Aunque algunas de estas modalidades puedan considerarse medios de prueba autónomos o mixtos.

§ 159. Los documentos, dictámenes periciales, actas o cualquier otro soporte técnico en el que se hayan registrado actos o manifestaciones de los órganos de prueba con anterioridad al juicio se consideran *declaraciones previas* (CPP, 326, segundo párrafo). Existen dos tipos de declaraciones previas:

- **Intraprocesales:** Las actas o registros de cualquier tipo (por ejemplo, audiovisuales) de las declaraciones prestadas en el marco de la investigación, incluyendo los dictámenes que hubieran producido los peritos (aunque para alguna doctrina constituyen *evidencia material*) y las actas de procedimiento (de allanamiento, secuestro, detención).
- **Extraprocesales:** Las manifestaciones realizadas fuera del marco del proceso, tales como notas periodísticas, publicaciones, mensajes o audios enviados a otra persona o declaraciones en otro proceso.

La principal característica de estas declaraciones es que *no constituyen evidencia autónoma*, por lo cual no podrán ingresar como prueba al proceso. Su utilización está restringida a servir de *auxilio al interrogatorio*, en caso de que un

testigo, perito o intérprete (se omite mencionar al imputado) olvide información relevante (refrescar la memoria), o para confrontarlas con su declaración actual (señalar contradicciones).

§ 160. Es común en doctrina que se utilice el término *evidencia*, para referirse a los elementos de convicción que aún no han sido válidamente introducidos en el ámbito de conocimiento del tribunal. En este sentido, el concepto engloba tanto a la evidencia material como a las declaraciones previas de los órganos de prueba.

La utilidad de esta denominación es que parece distinguir los elementos de convicción contenidos en el legajo investigativo, de aquellos que efectivamente se producen frente al tribunal y así adquieren la categoría de prueba. Los primeros son relevantes en cuanto se impone su revelación a la contraparte (por ejemplo, en ocasión de la audiencia imputativa: CPP, 275.2), pero no serán *prueba* hasta que no sean debidamente producidos o introducidos.

Sin perjuicio de reconocer alguna utilidad a esta formulación, debe señalarse que un concepto amplísimo de evidencia lleva a borrar la distinción entre evidencia material y declaraciones previas, dando a estas últimas una apariencia de mayor legitimidad. Esto no pasaría de ser una inofensiva cuestión terminológica, si no fuera porque de hecho se ha admitido como evidencia la declaración previa del propio imputado (fallo “Mariaux”, CSJSFe, 2017).

Por ello, encontramos preferible una utilización restringida del término “evidencia” (como evidencia material únicamente), dejando así en claro que las declaraciones previas sólo pueden utilizarse en los términos del CPP, 326.

Evidencia material

§ 161. El concepto de *evidencia material* surge casi por descarte: son los elementos de convicción no basados en la declaración de una persona (órgano de prueba), sino en una materialidad objetiva. Concretamente, el código refiere a *objetos, documentos o cualquier otro soporte técnico* (CPP, 326, tercer párrafo).

Algunas manifestaciones de evidencia material son las siguientes:

- Documentos públicos (escritura, carné de conductor) o privados (contrato, testamento ológrafo, factura, recibo, cuaderno de anotaciones, correo electrónico, mensaje de texto), incluyendo los registros de imagen, audio, video o de otro tipo.
- Informes de organismos públicos (certificado de antecedentes penales, partida de nacimiento) o privados (estados bancarios, informe de con-

sumos de tarjeta de crédito, historia clínica, registro de llamadas telefónicas), emitidos a requerimiento y en el marco del proceso.

- Objetos secuestrados o entregados en el marco del proceso, siempre que pudieran ser exhibidos directamente en audiencia (respecto de los *lugares*, habrá que estar a las actas de inspección).

§ 162. La evidencia material debe introducirse en juicio mediante testigos y peritos, aunque veremos que esta regla admite excepciones. En cualquier caso, se trata de *medios de prueba autónomos* hasta el momento de su introducción en juicio, por lo que durante las audiencias previas pueden ser utilizados mediante su simple exhibición, o acompañándolos a la presentación respectiva.

A pesar de su autonomía, funcionalmente también operan como auxilio al interrogatorio, tanto para refrescar la memoria como para señalar contradicciones. Es decir, también pueden ser utilizados *como si fueran declaraciones previas*.

Medio de prueba

§ 163. Nuestro sistema consagra el *principio de libertad probatoria*, según el cual los hechos pueden ser probados por cualquier medio, salvo las excepciones previstas por las leyes (CPP, 159). De este principio se siguen dos reglas:

- En principio, no hay hechos que necesariamente deban ser acreditados por un medio de prueba en particular (no imprescindibilidad del medio de prueba).
- La regulación legal de los medios de prueba no es exhaustiva, sino que se limita a establecer garantías contra la incorporación de información manipulada, sesgada o de baja calidad, y contra el abuso del proceso en perjuicio del órgano de prueba (carácter garantizador del régimen de la prueba).

§ 164. En cuanto a la *primera regla*, está claro que en algunos casos un determinado medio de prueba puede resultar más creíble o más idóneo en relación a un hecho determinado (por ejemplo, la causa de la muerte debería ordinariamente ser acreditada mediante autopsia), no hay impedimento legal para prescindir de ese medio y proponer otro. En todo caso, será un problema de quien ofrece el medio probatorio alternativo explicar por qué prescindió de aquella prueba considerada esencial (siguiendo con el ejemplo de la autopsia, la falta de hallazgo del cadáver sería una razón atendible).

Hay casos puntuales en los que la propia ley impone que un hecho deba ser acreditado a través de un medio de prueba específico. Así ocurre con los *antecedentes penales de las personas*, que se acreditan de manera ineludible con el informe del Registro Nacional de Reincidencia (ley 22.117, 5, 9). Más discutibles son los casos del *nacimiento*, la *edad*, el *sexo* y la *filiación* de las personas, que se prueban con las partidas del Registro Civil (CCC, 96), y del *matrimonio*, que se prueba con el acta respectiva o con la libreta de familia (CCC, 423); en estos casos, se debate en doctrina si corresponde atenerse o no a las reglas limitativas impuestas en el ámbito del derecho privado.

§ 165. La *segunda regla*, además de posibilitar la adopción de medios probatorios no previstos expresamente, funciona como pauta interpretativa respecto de la totalidad del régimen de la prueba: el objetivo central de todas las regulaciones probatorias en particular, es evitar la introducción al proceso de información sesgada, manipulada o de baja calidad. También persigue, adicionalmente, reducir los daños que el mismo proceso penal ocasiona a las personas que intervienen como órgano de prueba.

Veamos algunos ejemplos:

- La llamada *Cámara Gesell*, que constituye un medio de prueba autónomo, no regulado expresamente (aunque se fundamenta indirectamente en el CPP, 160), pensado para brindar un marco de protección a la declaración de personas en especial situación de vulnerabilidad, ya sea por edad, género, condición física o mental, condición de víctima o privación de libertad, entre otros factores (ver Reglas de Brasilia, 3-21), y fundamentalmente como estrategia para minimizar los efectos de la *victimización secundaria*, producto no ya del delito mismo sino del contacto posterior de la víctima con el sistema de justicia.
- La regulación de la *inspección judicial* (CPP, 163) no pasaría de ser un conjunto de meras sugerencias sobre cómo llevar a cabo la medida, de no ser porque en su párrafo final establece que la diligencia debe ser realizada *de tal modo que no se afecte la dignidad o la salud de la personas*. Con lo cual constituye una regla de protección, en favor de todos los intervinientes.
- En la *reconstrucción del hecho* (CPP, 166), la única parte con verdadero contenido normativo es la que exige la previa conformidad del imputado cuando fuera necesaria su participación activa, como derivación del principio de incoercibilidad.
- La regulación del *reconocimiento de personas* (CPP, 194-196) tiende, fundamentalmente, a evitar que quien identifica lo haga inducido o sugestionado por los investigadores, y a disminuir el riesgo de falsos positi-

vos. Para ello, se imponen limitaciones objetivas, tales como el número mínimo de personas en fila o el interrogatorio previo, que funcionan como garantía para quien es objeto de la medida.

Con lo cual el carácter enunciativo de los medios de prueba no implica que la regulación de los medios en particular sea una tarea inútil. Sí debe entenderse que estas reglas deben ser interpretadas de acuerdo a su función de garantía hacia el imputado y de protección hacia las personas que intervienen en el proceso, y no como pautas a aplicar mecánicamente.

Forma de introducción

§ 166. La *forma de introducción de la prueba* en el ámbito de conocimiento del tribunal depende centralmente de si se trata de órganos de prueba o de evidencia material. En ambos casos, está sujeta a variaciones en función del momento procesal, el grado de controversia y la concurrencia de circunstancias especiales.

§ 167. La *declaración de los órganos de prueba* se introduce, como regla general, practicando el interrogatorio cruzado en presencia del tribunal. Es decir, la prueba es producida directamente frente al tribunal que habrá de valorarla. Esta mecánica admite algunas excepciones:

- El código permite introducir en juicio los registros de una declaración previa, cuando ésta fue formalizada como *anticipo jurisdiccional de prueba* (CPP, 298). Esta posibilidad se prevé para casos excepcionales en los que se considere que la declaración no podrá efectivizarse en el momento del juicio oral (por ejemplo, cuando el testigo padece una enfermedad terminal, o tiene previsto viajar al exterior, o se ve amenazado por una situación de riesgo personal), por lo cual no corresponde la introducción de los registros si finalmente la concurrencia al juicio resulta posible. Al momento de la medida, deben observarse las reglas del interrogatorio cruzado (CPP, 325-326), correspondiendo al tribunal de la IPP dirigir la audiencia como si se tratara del tribunal de juicio.
- Más debatida es la posibilidad de recibir testimonios en carácter de *actos definitivos* (CPP, 260, 282, 283), ya que en este caso se estaría reemplazando la intervención judicial al momento de la declaración por una mera notificación a las partes. De admitirse esta alternativa, está claro que el control judicial posterior debería ser más riguroso que en el caso del CPP 298, considerándose si verdaderamente se estuvo ante una situación de extrema urgencia que imposibilitó formalizar la medida como anticipo

jurisdiccional (pensamos en casos verdaderamente excepcionales, como el del testigo que se encuentra internado con riesgo de vida inminente). Sin embargo, no parece correcto acudir a este mecanismo *no habiendo sido adjudicada la calidad de imputado* (CPP, 282) o *invocando razones de urgencia* (CPP, 283). En cualquiera de estos casos, se estaría validando como prueba un testimonio incontrolable para la defensa, y que por ello no pasaría de ser una mera *declaración previa*.

- En el ámbito de las audiencias previas al juicio (APJ), el interrogatorio cruzado debería considerarse de absoluta excepción, ya que esto implicaría adelantar debates propios de la etapa de juicio. La norma en este tipo de audiencias es que funcionen de manera *argumentativa* (sin producción probatoria), pudiendo aumentarse el nivel de acreditación según el grado de controversia: primero *enumerando* la prueba (- “*hay tres testigos presenciales del hecho*”), luego *relacionando sucintamente* su contenido (- “*los testigos Gutiérrez y García declaran haber visto que el imputado tenía un cuchillo*”), y eventualmente hasta *ostentar la prueba*, señalando que se está en condiciones de producir la declaración (- “*la víctima, el señor Pérez, se encuentra aquí en la sala dispuesto a declarar de ser necesario*”; para decirlo vulgarmente, puede *amagarse* con producir la declaración si la contraparte insiste en controvertir los hechos alegados). Con lo cual, en el marco de las APJ, el orden ideal sería el siguiente: *argumentación, enumeración, relación, ostentación e interrogatorio cruzado*.

§ 168. La *evidencia material* debe ser introducida mediante órganos de prueba, con lo que indirectamente también ingresan mediante interrogatorio cruzado. Sin embargo, esta regla es menos estricta que la referente a las declaraciones propiamente dichas. Esta mayor flexibilidad se debe a que la evidencia material *existe como evidencia ya antes de su introducción*, si bien requiere ser *acreditada* para poder ingresar al ámbito de conocimiento del tribunal. Aquí las excepciones son más amplias:

- Desde ya que en las APJ debería considerarse prácticamente vedado recurrir a la introducción por testigos. Aquí también hay un orden creciente en el grado de acreditación, que abarca la *mera argumentación*, la *enumeración* (- “*contamos con veinte correos amenazantes enviados por el señor Juárez*”), la *relación* (- “*en uno de ellos, dice textualmente: te voy a matar*”), la *ostentación* (- *contamos con los audios de contenido amenazante enviados por el señor Juárez, que si es preciso podemos reproducir*), la *exhibición* (mostrar el objeto o documento; si se trata de documentos, se considera de buena práctica mostrárselo previamente a la contraparte), la *reproducción* (de contenidos de audio, video, imágenes o de otro tipo; es una especie de

exhibición, pero más costosa en cuanto al tiempo que insume) y la *entrega al tribunal* (es decir, acompañarlo como si se tratara de un incidente escrito, para que el tribunal pueda luego examinarlo con más detenimiento).

- Ya en el ámbito del juicio oral, pueden introducirse directamente los *documentos públicos que no requieran acreditación*, tales como escrituras o informes registrales, siempre que no haya sido puesta en duda su autenticidad. Sería una actividad inútil, por ejemplo, citar en cada caso al Director del Registro Nacional de Reincidencia para acreditar los informes sobre antecedentes penales, al Ministro del Interior para acreditar los documentos de identidad, o al Director del Registro Civil para acreditar las partidas de nacimiento.
- También puede obviarse la introducción por testigos cuando la evidencia material refiere a *hechos circunstanciales, accesorios o no controvertidos* (aun sin mediar acuerdo probatorio entre las partes). Sin embargo, esto debe ser estratégicamente decidido por la parte que ofrece la prueba, en función del grado de centralidad o controversia que ese hecho puntual puede suscitar. Si esto no se considera, existe el riesgo de que la evidencia así introducida sea percibida con algo de frialdad, perdiendo así parte de su eficacia persuasiva. Por ejemplo, si bien podrían introducirse directamente las fotografías del automóvil chocado, siempre será más convincente que sea la propia víctima quien introduzca esas imágenes y cuente cómo tuvo que escurrirse entre esas chapas estrujadas para salvar su vida.
- Respecto de la introducción directa de documental en el juicio oral, hay posturas que la admiten limitadamente, valorando de forma integral algunas de las circunstancias que para nosotros constituyen casos autónomos. Así, se ha considerado si se trata de un instrumento público o asimilable, la relevancia de la información y su relación con el objeto procesal, y el grado de controversia respecto de esta forma de introducción (fallo “Argañaraz”, Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rafaela, 2020).
- Finalmente, en algunos casos puede resultar poco práctico introducir por testigos los *registros de audio y de video* (particularmente cuando son muy prolongados), por lo cual se admite que ingresen directamente mediante su reproducción. La acreditación por testigos tiene lugar en un momento posterior, pudiendo acudir a citas o desgrabaciones para no entorpecer el interrogatorio con continuas repeticiones del material ya proyectado. En este caso no estamos ante una verdadera excepción, ya que en definitiva la evidencia tiene una relativa autonomía sólo al momento de su ingreso, y no exime de su posterior acreditación.

c) Aspectos técnicos del interrogatorio cruzado

Nociones generales

§ 169. Hemos visto que el interrogatorio cruzado de testigos constituye, pese a sus muchas excepciones, la mecánica de producción y de introducción de prueba prototípica del modelo adversarial. Comparativamente, es el modo de probar que más se apega al principio de oralidad, a punto tal que incluso las evidencias documentales deben ser oralizadas para ingresar al ámbito de conocimiento del tribunal.

Surgido en el marco del sistema adversarial inglés, el interrogatorio cruzado materializa un momento en el que el proceso penal funciona enteramente como un *proceso de partes*, sin intervenciones auxiliadoras de ningún tipo por parte del tribunal de juicio. Por ello, su mecánica se estructura en torno a los principios de *contradicción* entre partes y *neutralidad* del juzgador.

Esquemáticamente, el interrogatorio cruzado se rige por las siguientes pautas:

- El juez debe interrogar al testigo sobre su identidad. Cumplida esta actividad, no podrá hacer más preguntas (ni siquiera para aclarar dudas), y el testigo quedará a disposición de las partes.
- El testigo es interrogado en primer término por la parte que lo ofrece (esto se denomina *examen directo*), y luego por la contraria (*contraexamen*). Excepcionalmente, puede haber réplica de ambas actividades.
- Formulada una pregunta y antes de que fuera contestada, la parte contraria puede formular *objeción*. Las objeciones son resueltas por el tribunal, luego de oír a las demás partes.
- En el interrogatorio pueden utilizarse, con fines específicos, las *declaraciones previas del testigo*.
- Como hemos visto, el interrogatorio cruzado es la forma estándar de *introducir en juicio la evidencia material*, para lo cual hay un procedimiento específico.

El desarrollo de estas temáticas a nivel local ha ido de la mano de la difusión de las *técnicas de litigación adversarial*, ya sea directamente (a partir de las fuentes inglesas o estadounidenses) o por contacto con otros sistemas reformados (en nuestro caso, se ha observado principalmente el modelo chileno).

Examen directo

§ 170. Se denomina *examen directo* al interrogatorio conducido por la parte que ofrece una declaración (testimonial, pericial o de otro tipo). Mediante el examen directo, el litigante buscará crear un relato o narración de los hechos que permita acreditar las proposiciones fácticas de su teoría del caso. Más allá de este objetivo de acreditación puntual, está claro que la característica distintiva del examen directo es que pretende que el propio testigo cuente su historia, con sus propias palabras, lo cual incidirá en algunos aspectos técnicos de esta modalidad.

Además de este objetivo que podríamos considerar *principal* (acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso), el examen directo puede cumplir otros objetivos secundarios o accesorios, como *introducir y acreditar evidencia material* (objetos o documentos) o *acreditar otro medio de prueba* (por ejemplo, señalar que otro testigo estaba presente en el lugar).

Hay además un objetivo indirecto o mediato (ya que posibilita el cumplimiento de los otros), que es *fortalecer la credibilidad del propio testigo*. Este objetivo normalmente se aborda en primer término, mediante las llamadas *preguntas de acreditación*.

§ 171. El examen directo tiene ordinariamente dos partes bien diferenciadas: la *acreditación* y las *preguntas sobre el hecho*.

La *acreditación del testigo* debe trabajarse de manera específica para cada caso. No existen en nuestro sistema las *generales de la ley* ni la *prueba de tachas*, por lo cual la credibilidad debe construirse a partir de la situación particular de cada testigo. No se trata de ensalzar al testigo desde una perspectiva moral, sino de establecer que estuvo en condiciones de percibir lo que dice haber percibido y de situarlo en tiempo y lugar en relación al hecho que va a relatar. Por ejemplo, si presencié un choque en una esquina, habrá que contar que estaba en ese lugar porque esperaba el colectivo. Si vio un robo a las cuatro de la mañana, tal vez sea útil mencionar que es enfermero y a esa hora sale de su turno en el hospital. Si se trata de un adulto mayor, a veces conviene señalar que su mente y sus sentidos funcionan razonablemente bien a pesar de la edad.

También en ese marco, el litigante puede adelantarse a plantear de manera matizada posibles debilidades del testimonio, antes de que sea la contraparte quien los deje en evidencia (por ejemplo, señalando que si bien era de noche, pudo ver bien porque había iluminación artificial).

Las *preguntas sobre el hecho* constituyen el objeto central del examen directo. A través de ellas, el litigante intentará cumplir con sus objetivos directos (acreditar su teoría del caso, introducir evidencia material o acreditar otra prueba). Como regla, el relato del testigo se construye de manera cronológica, guiándolo en su discurso a través de la formulación de preguntas abiertas y transiciones. Sin embargo, esto no es una regla absoluta, y efectivamente puede recurrirse a los saltos temporales -hacia adelante y hacia atrás-, para enfatizar determinados hechos o la relación causal entre ellos (por ejemplo, después de relatar una colisión vehicular en apariencia fortuita, puede volverse a los momentos previos para señalar que el conductor había bebido en exceso; o después de un disparo supuestamente accidental, puede volverse a los momentos previos, en los que el acusado amenazó con matar a su suegra).

§ 172. Como regla, el examen directo se practica sobre un testimonio que es *amigable*, en un doble sentido:

- En un sentido *objetivo*, porque su narrativa se ha evaluado compatible con la teoría del caso de quien lo ofrece (como regla, uno no ofrecería un testimonio que sabe desfavorable), e incluso es probable que haya existido contacto previo entre el testigo y el litigante, en la etapa de preparación del caso.
- En un sentido *subjetivo*, porque el testigo supone valorizado su relato por parte del litigante que lo ofrece. Esto incluso puede generar un grado de identificación tal que lleve al testigo a adaptar el relato -aun de manera no consciente- a lo que se supone son las necesidades de la parte que lo ofrece.

§ 173. La metodología del examen directo pretende mantener al testigo como protagonista del relato, limitando también los efectos de una posible identificación subjetiva del testigo con la posición del litigante (o directamente, de una posible manipulación).

Por ello, y más allá de los límites comunes a todo interrogatorio (preguntas capciosas, compuestas, vagas, ambiguas, confusas, repetitivas), en el examen directo resultan específicamente objetables las *preguntas sugestivas*. Se considera que una pregunta es sugestiva cuando conduce al testigo a avalar una respuesta dada o sugerida (“- entonces, ¿el auto era rojo?”). De hecho, es posible que ni siquiera se formule como interrogación, sino como una petición de que el testigo consienta la afirmación (- “así que el auto era rojo”).

Por el contrario, en el examen directo se considera recomendable utilizar preferentemente *preguntas abiertas*, posibilitando así que el testigo construya el relato con sus propias palabras. Ordinariamente, esto debería no sólo favorecer

su propia credibilidad, sino también aumentar la calidad de la información que ingresa al proceso. Después de todo, poco habrá aportado un testigo que sólo dijo *ajá* con la cabeza a cada proposición del litigante. La idea es que el litigante vaya guiando al testigo para que cuente su propia historia, de manera tal que el tribunal pueda ir *haciéndose la película* a medida que transcurre el relato.

§ 174. Aún en el examen directo, hay casos de excepción en los que se permite la utilización de preguntas sugestivas:

- Cuando se está ante un *testigo hostil*, ya sea porque hubo necesidad de citar a un testigo que se sabía no amigable con nuestra teoría del caso, o bien porque sorpresivamente el testigo comienza a responder con evasivas. En cualquier caso, el tratamiento de testigo hostil debe ser autorizado por el tribunal, exigiéndose como regla que el litigante formule previamente *preguntas de testeo*.
- Las *preguntas preliminares o de acreditación* también pueden formularse sugestivamente por motivos de simplicidad, especialmente cuando se abordan puntos no controvertidos (por ejemplo, da lo mismo preguntar “¿a qué se dedica usted?” que “usted es podólogo, ¿verdad?”).
- Las *transiciones* de un tema a otro, o de un momento del relato a otro (incluso en retrospectiva), pueden dar lugar a preguntas sugestivas que eviten reiteraciones y pérdida de tiempo (“- Señora Castiglione, usted anteriormente dijo que esperaba el colectivo, ¿verdad?, entonces, ¿qué hora era?”). Esto es especialmente útil cuando el testigo se va por las ramas y es necesario volver a encarrilar el relato.
- Se admite la pregunta sugestiva *por la negativa*, cuando en determinado contexto es evidente que el litigante no busca introducir sus propias afirmaciones, sino dar pie para que el testigo enfatice algún aspecto puntual de su relato. Por ejemplo, si sabemos que el testigo estaba con otra persona al momento del hecho, le preguntamos: “- usted, ¿estaba solo?”. O si las amenazas fueron reiteradas, preguntamos: “y ese mensaje de texto, ¿fue el primero que le envió el señor Benavídez?”.
- En general, se considera permitida la *pregunta sugestiva inocua*, aquella que no causa perjuicio alguno o que no persigue deformar el relato ni poner palabras en boca del testigo. Después de todo, tampoco se trata de objetar por objetar.
- Finalmente, a veces es sencillamente imposible, o al menos muy engorroso, preguntar algo de manera no sugestiva. Imaginemos que la víctima, en su declaración previa, dijo que al atacante le faltaba un brazo: no tiene sentido preguntar “- ¿notó usted algo raro en cuanto al número de extremidades de su agresor?”. Le preguntamos si le faltaba un brazo, y se acabó. De

la misma forma, puede preguntarse si tenía un tatuaje, si tenía acento, si era alto, si era de noche, si había olor a nafta, si vio que tenía un cuchillo... Pero sin abusarse: una vez que entramos en tema, habrá que continuar mediante preguntas abiertas.

Contraexamen

§ 175. Se denomina *contraexamen* al interrogatorio conducido por la parte contraria a quien ofrece el testigo y que tiene lugar a continuación del examen directo. El contraexamen tiene por objetivo primario desacreditar al testigo o a su declaración, aunque secundariamente puede perseguir en alguna medida los objetivos propios del examen directo (acreditación del caso, de evidencia material o de otra prueba).

Aunque la facultad de contraexaminar es bilateral, cuando es ejercida por la defensa materializa la llamada *cláusula de confrontación*, expresada normativamente en el derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo (CADH, 8.2.f). Y en términos más generales, en el marco del modelo adversarial se reconoce en el contraexamen un medio idóneo para mejorar la calidad de la información que se produce en el proceso. También proporciona información adicional para valorar la credibilidad intrínseca de un testimonio, funcionando como un control de calidad que, en caso de ser superado, vuelve más robusta la declaración (y en caso contrario, permite al tribunal argumentar la pérdida de credibilidad).

§ 176. La realización de un contraexamen presupone que ya ha tenido lugar el examen directo, por lo cual no cabe aquí atenerse a una estructura narrativa cronológica. Más bien, el abordaje sugerido es de carácter *temático*, pudiendo abordarse separadamente las principales debilidades de la declaración. Aquí no se trata de que el testigo diga que *primero pasó esto, y después pasó lo otro*, sino de generar situaciones que atenúen la credibilidad personal del testigo o de su declaración. Ejemplificativamente, una estructura posible sería:

- Tema 1: Condiciones de percepción. Preguntas tendientes a demostrar que el lugar estaba oscuro, que el testigo no traía puestos sus lentes recetados, que el supuesto agresor pasó corriendo y no pudo verle el rostro.
- Tema 2: Momentos previos. Preguntas sobre qué estaba haciendo antes, de dónde venía, si había tomado alcohol, si estaba distraído en otra cosa.
- Tema 3: Conducta previa. Preguntas sobre situaciones previas del testigo que evidencian o sugieren mendacidad, como condenas por falso testimonio, infidelidades en su vida privada, inconductas laborales.

Debe tenerse presente que si se utiliza el contraexamen para desacreditar al testigo o a su declaración, nuestros propios objetivos secundarios también pueden verse salpicados. Es decir, aun tratándose de un testigo de la contraparte, a veces conviene no desacreditarlo tanto cuando se lo pretende utilizar para introducir evidencia o para acreditar algún aspecto de nuestra propia teoría del caso. Esta es una cuestión de riesgo-beneficio, que debe ser ponderada con un sentido estratégico en el caso concreto.

§ 177. El contraexamen se practica sobre un testimonio que se supone *hostil*, por lo cual se da la situación inversa al carácter amigable del examen directo:

- En un sentido *objetivo*, porque la contraparte ha considerado que la narrativa del testigo resulta compatible con su propia teoría del caso. Y porque además del contacto previo que pudo existir, acaba de tener lugar el examen directo, que por hipótesis (a menos que haya ocurrido un sorpresivo cambio de versión) habrá reafirmado esa compatibilidad.
- En un sentido *subjetivo*, a raíz de la posible identificación del testigo con la posición de la parte que lo ofrece, y además porque supone (en general con gran acierto) que el contraexaminador pretende poner en duda su relato, cuando no busca directamente tratarlo de mentiroso o de poco confiable. Y a la inversa de la identificación positiva que suele tener lugar con quien ofrece el testimonio, aquí el testigo puede adoptar una actitud remisa o evasiva, poniéndose a la defensiva o dando respuestas cortantes. Esto es especialmente relevante cuando quien se presenta como víctima es contraexaminada por quien defiende a su supuesto agresor, situación que debe ser manejada con suma prudencia para minimizar el impacto revictimizante de la confrontación.

§ 178. Se ha discutido si debe permitirse interrogar a los testigos ofrecidos por la contraparte y luego desistidos (algo así como un “contraexamen directo”). Estamos hablando de testigos no ofrecidos por la parte que pretende interrogar, ya que de mediar ofrecimiento propio la facultad de examinación es indiscutible. La cuestión es compleja y se relaciona en principio con los modelos de proceso. Como regla, se entiende que en un proceso con juicio de tipo adversarial la prueba pertenece a la parte que la ofrece, no habiendo posibilidad de que la contraria aproveche una prueba desistida (es decir, no habría *comunidad de prueba*). La jurisprudencia ha admitido alguna excepción, mediando solicitud fundada y sólo en favor de la defensa (en el ya citado precedente “Argañaraz”, Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rafaela, 2020).

§ 179. La metodología del contraexamen pretende mantener un estricto control de la información que el testigo emite. Después de todo, él ya ha decla-

rado en términos más amigables en el marco del examen directo. Ahora no podemos reeditar toda su declaración, sino que hay que hacer foco en aquellos puntos que interesan a la contraparte. Aquí hay un desplazamiento de la centralidad discursiva, de la persona del testigo hacia la figura del propio litigante que conduce el contraexamen.

La herramienta fundamental de este abordaje metodológico es la *pregunta sugestiva* (de hecho, hay autores que sostienen que en el contraexamen *sólo* deberían formularse este tipo de preguntas). Aquí estamos ante un testigo que de antemano suponemos hostil (en el doble sentido antes señalado), y se lo puede tratar como tal sin necesidad de formular preguntas de testeo.

No obstante, ocasionalmente se sugiere ir intercalando distintos tipos de preguntas, para evitar que el contraexamen se vuelva tedioso. La regla sería *abordar mediante preguntas sugestivas las temáticas de desacreditación y los aspectos más controvertidos de nuestro caso*. Por el contrario, las *zonas seguras*, aquellas que no dan lugar a controversia, en las que ninguna respuesta podría afectar nuestra teoría del caso, o en las que se cuenta con evidencia de respaldo, pueden abordarse mediante preguntas abiertas. Estratégicamente, esto puede ser una buena herramienta para correr al testigo de su lugar de hostilidad, dándole una ocasión -muy limitada y controlada- para que sienta valorizado su relato y esté mejor predispuesto a contestar nuestras preguntas.

Réplicas

§ 180. Como regla, tanto el examen directo como el contraexamen deben ser exhaustivos, es decir que deben agotar las preguntas en relación a ese testigo o perito, no permitiéndose una nueva ronda de preguntas a cargo del litigante que ya tuvo ocasión de examinar.

Sin embargo, excepcionalmente se permiten las *réplicas* (de ambos interrogatorios) cuando resulta necesario refutar o aclarar algún punto sacado a la luz por la contraparte. Así por ejemplo, si en el contraexamen se problematiza la capacidad de percepción del testigo porque no traía puestos sus lentes recetados, puede replicarse el examen directo para tocar específicamente este tema.

Las réplicas son excepcionales, y desde ya que no deben autorizarse para realizar preguntas que bien pudieron hacerse antes sobre la base de la información disponible. Mucho menos debe permitirse que los litigantes agreguen preguntas que debieron formular a su tiempo, pero sencillamente se olvidaron de hacerlo o especularon con dejarlas para último momento. El concepto gene-

ral es que las réplicas están limitadas a un ámbito específico de refutación, y no pueden ser utilizadas para suplir la negligencia de los litigantes.

Uso de declaraciones previas

§ 181. El uso de *declaraciones previas* está limitado a los casos en que sea necesario refrescar la memoria (cuando el testigo olvida un dato esencial), o para señalar contradicciones entre la declaración previa y la actual. Como regla, puede pensarse que en el examen directo se buscará refrescar la memoria y en el contraexamen señalar contradicciones, aunque según el caso las dos funciones son viables en ambas formas de interrogatorio.

§ 182. En cualquier caso, antes de acercarse al testigo con la declaración previa deben agotarse los medios para obtener la información que se busca mediante preguntas bien formuladas, incluyendo las preguntas sugestivas. Agotado este paso, corresponde pedir permiso al tribunal para hacer uso de la declaración previa. Como estas declaraciones ya habrán estado disponibles para las partes, no es necesario que estén ofrecidas como prueba (aunque en algunos casos la evidencia material puede ser utilizada como declaración previa). Sí se considera de buen tono exhibir a la contraparte la declaración antes de abordar al testigo.

Cumplidas las formas previas (agotar las posibles preguntas, solicitar permiso al tribunal y exhibir la declaración a la contraparte), puede abordarse al testigo. Debe recordarse que la declaración previa no posee valor probatorio autónomo, por lo cual debe lograrse que el propio testigo, una vez impuesto de su contenido, exprese el dato olvidado o aclare la contradicción.

Introducción y acreditación de evidencia material

§ 183. Hemos visto que como regla la *evidencia material* debe introducirse a través de testigos y peritos. Esto requiere analizar estratégicamente qué evidencia introducir y a través de qué testigos. Además, una vez introducida una evidencia, puede ser necesario acreditarla por medios adicionales: por ejemplo, el arma homicida puede ser introducida por el policía que realizó el secuestro, pero luego habrá que acreditar la cadena de custodia y los peritajes realizados, a través del testimonio de todos los que intervinieron en ese devenir.

Antes de introducir la evidencia, debe lograrse que el testigo la mencione en su relato: en el ejemplo anterior, el policía debería mencionar que encontró un

cuchillo en la escena. Una vez que el testigo da cuenta del objeto o documento, se está en condiciones de exhibírselo para que lo reconozca. Una vez cumplidos estos pasos, la evidencia material ya ha ingresado como prueba, pudiendo utilizarse directamente en momentos posteriores y ser valorada en la sentencia.

Objeciones

§ 184. En el modelo adversarial, corresponde a los litigantes controlar la información que su contraparte pretende ingresar al proceso. En el momento de los interrogatorios en juicio, este control de parte se cumple mediante las *objeciones*. Cada tipo de objeción expresa un límite a la facultad de interrogar, y en general esos límites tienden a proteger la calidad de la prueba que se produce en el marco del proceso.

§ 185. En nuestra legislación, la facultad de objetar está expresamente consagrada (CPP, 325, segundo párrafo). Sin embargo, las objeciones en particular están reguladas de manera parcial y un tanto vaga, por lo cual nuevamente debemos recurrir a la integración normativa a partir del derecho y la práctica de otros sistemas reformados.

Una formulación posible sería la siguiente:

- **Pregunta sugestiva**, aunque como hemos visto esta objeción sólo se aplica al examen directo, y con excepciones (testigo hostil, preliminares, transiciones, por la negativa, inocua, inviabilidad de otra forma).
- **Formulación defectuosa**, cuando la pregunta es confusa (poco clara), ambigua (puede aludir a dos cuestiones distintas), vaga (demasiado amplia) o compuesta (contiene varios puntos).
- **Irrelevante**, cuando la pregunta no avala la teoría del caso de ninguno de los litigantes (a veces puede haber un margen de tolerancia para que el litigante llegue al punto).
- **Especulativa**, la pregunta que no apunta a que el testigo relate hechos sino a que especule o adivine datos que no le constan. Se permiten ciertas estimaciones básicas de experiencia común (temperatura ambiente, velocidad, distancia, altura).
- **De opinión o conclusión**, ya que la idea es que el testigo relate los hechos y sea el tribunal el que saque las conclusiones (a menos que se trate de un testigo experto).
- **Repetitiva**, la pregunta formulada nuevamente cuando ya ha sido contestada.

- *Hechos asumidos*, cuando la pregunta introduce hechos no probados o de existencia discutida, pudiendo confundirse al testigo.
- *Privilegio*, cuando existe prohibición legal de declarar.
- *Coacción ilegítima*, cuando en el interrogatorio el litigante hostiga o presiona de manera abusiva al testigo.

Hay otras objeciones que se corresponden específicamente con las reglas probatorias del modelo anglosajón, por lo cual difícilmente resulten trasladables a nuestro contexto. Tal es el caso de las objeciones de *mejor evidencia* (cuando hay otro medio más idóneo para acreditar un hecho) y *testimonio de oídas* (cuando el testigo no percibió directamente el hecho que afirma, sino que oyó a otra persona mencionarlo), que en nuestro sistema chocarían abiertamente con el principio de libertad probatoria.

§ 186. Las objeciones deben formularse de inmediato, una vez hecha la pregunta en cuestión y antes de que el testigo responda. No hay una fórmula ritual para objetar, siempre y cuando quede clara la voluntad de impugnar la pregunta (“objeción” y “protesto” son formas admitidas, aunque considerando que se trata de un planteo urgente debería admitirse incluso un “¡eh!”). Se exige fundamentar la objeción, cuestión que con la práctica debería simplificarse hasta llegar a bastar con la mera enunciación de la objeción en particular (“objeción, confusa”).

Antes de resolverse una objeción, debe darse la palabra a quien examina para que conteste el planteo. Es muy común en sistemas más aceitados que esta instancia sea sumamente ágil, e incluso que el examinador se allane a reformular o retirar la pregunta para evitar que la incidencia le haga perder ritmo al interrogatorio.

§ 187. Se ha sostenido la posibilidad de que el tribunal intervenga ante una determinada pregunta, sin mediar objeción de parte. Esta intervención de oficio parece admisible cuando no se realiza con un fin de control probatorio (en cuyo caso el tribunal se estaría extralimitando en su función), sino de protección otros valores no disponibles por las partes. En particular, debería considerarse un *deber del tribunal* llamar la atención ante una posible infracción a la prohibición de declarar (privilegio), como también debería intervenir ante situaciones de maltrato al testigo (coacción ilegítima), particularmente cuando se trata de la víctima.

d) Medios de prueba en particular

Nociones generales

§ 188. Hemos visto que la regulación de la prueba en nuestro código confunde los medios de prueba con las diligencias investigativas tendientes a recolectar evidencia (allanamiento, registro, requisa, interceptación). En cuanto a los medios de prueba en particular, también hemos realizado la distinción entre órganos de prueba y evidencia material, con la aclaración de que el ingreso en juicio de esta última se realiza como regla a través de testigos.

Con lo que restaría desagregar aquí los medios probatorios en particular, que regulan formas específicas de declaración o actuación de los órganos de prueba. Esta regulación adquiere tres formas básicas: la *declaración de testigos y otros sujetos* (testimonial, pericial, declaración del imputado), la *declaración combinada de distintos órganos de prueba* (careo, declaraciones protegidas) y la *combinación de declaraciones con otro tipo de actividades* (reconocimiento de personas, reconstrucción del hecho).

Testimonio

§ 189. En sentido estricto, *testigo* (CPP, 173-181) es quien percibe a través de sus sentidos, y de manera accidental o espontánea, hechos relevantes para el proceso. En el marco del proceso, el testigo tiene obligación de comparecer, y declara bajo juramento o promesa de decir verdad.

Normalmente se reconoce a los familiares del imputado la facultad de abstenerse de declarar en contra de éste, y obviamente se prohíbe la declaración en infracción al deber de guardar secreto.

El testimonio es la prueba prototípica del modelo adversarial, a punto tal que las declaraciones de los restantes sujetos pueden considerarse testimonios especiales. Además, ya hemos visto la importancia de los testigos en orden a la introducción de evidencia material en juicio.

§ 190. No obstante, debe mencionarse que la prueba de testigos es objeto de problematización por parte de alguna doctrina estadounidense, por su elevado margen de error en comparación con otros medios de prueba. Esto ha sido particularmente discutido en Estados Unidos en ocasión de la revisión de condenas penales (muchas de ellas a pena de muerte) con la aparición de la prueba de ADN. Los resultados han sido devastadores: cientos de condenas

han sido anuladas, aunque *muchas de ellas ya se habían ejecutado* (recién en 2013 un condenado logró salvarse de la ejecución a causa de esta nueva evidencia). De ahí que haya en aquel contexto posturas extremas, como la que propone directamente la supresión de los testimonios en materia penal.

Compártase o no esta postura, el planteo debería llevar a revisar la ligereza con la que se valora la prueba de cargo, y en particular si al menos como estándar no debe exigirse la prueba científica siempre que esté disponible.

Peritaje

§ 191. De la mano de la valorización de la prueba científica viene justamente la *prueba pericial* (CPP, 182-193). Se denomina perito a quien dictamina acerca de determinados hechos, por encargo judicial, sobre la base de conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Varios son los elementos distintivos del perito en comparación al testigo:

- El *encargo judicial previo*, en el que se le fijan los puntos de peritaje.
- La *experticia en determinado campo del conocimiento*, que lo habilita no sólo para describir hechos sino también para emitir conclusiones u opiniones calificadas.
- La elaboración de un *dictamen escrito*, previo a su declaración en juicio y puesto a disposición de las partes.

§ 192. En nuestro medio aún es frecuente que la Corte Suprema elabore listados con los profesionales de cada rubro que se postulan para actuar como perito, lo cual es una clara herencia del viejo sistema. La tendencia actual es hacia la incorporación amplia de *peritos de parte*, e incluso es posible que las partes acuerden la intervención de peritos de una institución determinada. La nota central del perito es la *idoneidad*, y esto no se relaciona con integrar una lista de nombramientos de oficio, sino con el prestigio profesional alcanzado y hasta con el respaldo institucional con el que se cuenta.

De todos modos, recuérdese que el perito también estará sometido a preguntas de acreditación, y eventualmente al intento de desacreditación de la contraparte. En el caso concreto, salir airoso de esa instancia da mucho más credibilidad que haber sido sorteado de una lista.

§ 193. La naturaleza del dictamen pericial es debatida, habiendo quien lo considera *declaración previa* (lo cual coincide con la letra del CPP, 326, segundo párrafo). Esta postura es problemática, en cuanto parece requerir el interrogatorio cruzado del perito en todo caso, aun cuando se trate de una cuestión no

controvertida o se trate de un *peritaje duro* (con poco o nada de margen de refutación, como ocurre con el cotejo dactiloscópico o la prueba de ADN). En estos casos, parece más razonable tratar al dictamen como evidencia material.

Algunas formas puntuales del peritaje han merecido una regulación específica, como la *inspección de cadáveres* (CPP, 164), la *autopsia* (CPP, 165) e, indirectamente, el *cotejo de escritura o de voz* (CPP, 191). Cuestión atribuible al peso de la tradición, más que a la necesidad técnica.

§ 194. Según la complejidad del tema y el grado de centralidad del peritaje en relación al caso, a veces resulta conveniente que las partes cuenten con *asesores técnicos* (también llamados *peritos de parte*, aunque en otros sistemas se trata de figuras distintas). El asesor técnico puede actuar junto con el perito designado en las operaciones previas a la elaboración del dictamen, y también puede actuar en juicio interrogando al perito en representación de la parte a la que asesora.

Testimonio experto

§ 195. La figura del *testigo experto* proviene de la tradición anglosajona, en cuyo sistema no existe la figura del perito oficial como nosotros la conocemos. En nuestro medio, testigo experto sería quien relata u opina sobre determinados hechos, en virtud de especiales conocimientos pero sin encargo judicial previo. En otras palabras, se trataría de un medio de prueba híbrido, entre la testimonial y la pericial.

Hay dos formas básicas de testigo experto:

- El que es citado específicamente como testigo experto, para dar su opinión técnica en relación a determinados hechos.
- Cuando, frente a la objeción de *pregunta por opinión*, el examinador responde que la opinión es relevante por tratarse de un testigo experto. En este caso, la contraparte puede pedir algún tipo de acreditación (por ejemplo, puede requerirle que exhiba sus credenciales, y puede incluso formularle preguntas de comprobación).

Declaración del imputado

§ 196. La *declaración del imputado* es una especie de tabú para los modelos reformados. Hemos visto que se ha problematizado al extremo la posibilidad de que declare como testigo y bajo juramento (aun a su propio pedido), con lo

cual debemos considerar su declaración como un medio de prueba autónomo, y sin perjuicio de que constituya asimismo un acto de defensa material.

Los principales caracteres distintivos de la declaración del imputado, analizada como medio de prueba, es que puede expresarse de manera espontánea antes de que se le formulen preguntas (CPP, 111-113), puede ser oído y hacer declaraciones en cualquier momento del debate (CPP, 318, 320), está exento de prestar juramento o promesa de decir verdad (CPP, 318) y está excluido de la mecánica del interrogatorio cruzado, que sólo aplica a peritos, asesores técnicos, testigos e intérpretes (CPP, 325). La jurisprudencia acertadamente ha aceptado la posibilidad de confrontar al imputado con sus declaraciones previas, e incluso ha admitido *como evidencia material* el registro de su declaración previa, si es que se niega a declarar (fallo “Mariaux”, CSJSFe, 2017). Esta última posibilidad resulta cuestionable, en cuanto confunde *declaración previa* (que puede utilizarse para refrescar memoria o para señalar contradicciones) con *evidencia material* (que por excepción puede introducirse de manera directa). La declaración previa del imputado es, como su nombre lo indica, una declaración previa. Y si el imputado en juicio ejerce su derecho a guardar silencio, ello impide que surja contradicción alguna que deba ser señalada acudiendo a aquella declaración.

En caso de pluralidad de imputados, las reglas expuestas aplican para todos ellos. Distinto es el caso de quien ha sido condenado por sentencia firme antes de ir a juicio sus coimputados. Esta situación puede darse porque fue juzgado por separado (por ejemplo, por hallarse en rebeldía los demás imputados) o porque se avino a celebrar un procedimiento abreviado. En este supuesto, el condenado que declara contra quienes fueron sus coimputados *debería hacerlo en calidad de testigo*, puesto que ya no corre riesgo de autoincriminarse en cuanto opera en su favor la cosa juzgada. La consecuencia lógica de esta calidad es que tendría el deber jurídico de declarar y de decir verdad, y estaría sometido al interrogatorio cruzado (en contra de este planteo, y sosteniendo que se trata de una figura híbrida entre testigo y acusado, *con obligación de declarar pero no de decir verdad*: fallo “Vera”, CSJSFe, 2020).

Careo

§ 197. El *careo* (CPP, 203-204) es un medio de prueba cuya funcionalidad está atada al sistema escriturista. Habiendo declaraciones contradictorias (entre testigos, o entre testigo e imputado), el magistrado debía carear a los declaran-

tes en una instancia común tendiente a exponer y aclarar los puntos controvertidos. Con la salvedad de que el imputado no puede ser obligado a carearse.

La incorporación de la mecánica del interrogatorio cruzado ha vuelto obsoleta esta medida, ya que ahora son las mismas partes las que tienen la atribución de confrontar al testigo, con sus propios dichos y con los de otros sujetos.

Testimonio de personas en especial situación de vulnerabilidad

§ 198. La necesidad de reducir los daños que el propio sistema judicial ocasiona a la víctima (victimización secundaria) ha dado lugar a dispositivos como la Cámara Gesell. Nuestro código no establece este medio probatorio de manera rígida, sino que prevé un *régimen especial para la intervención de menores de edad* (CPP, 160), cuya aplicación debe extenderse a *toda persona en especial situación de vulnerabilidad*. Pueden considerarse causas de vulnerabilidad, entre otras circunstancias, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad (Reglas de Brasilia, 3-21).

§ 199. El régimen especial prevé la intervención de un equipo multidisciplinario, que aconsejará sobre la forma de producción de la medida y actuará en la misma, emitiendo opinión acerca de su valoración. Algunas necesarias aclaraciones:

- Tratándose de menores (en lenguaje más contemporáneo, NNA: niños, niñas y adolescentes), esta intervención viene impuesta de pleno derecho por la norma, a punto tal que el tribunal debería negar la participación del NNA en cualquier tipo de medida por fuera del régimen especial.
- Fuera del caso de los NNA, incumbe a las partes detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y evaluar la necesidad de solicitar el régimen especial. Por cuestiones estratégicas, y con el consentimiento informado de la persona afectada, puede incluso optarse por la intervención estándar (por ejemplo, por el efecto catártico de la declaración en juicio oral, o porque se considera más conveniente someterse al interrogatorio cruzado para ofrecer un testimonio más creíble).
- Como la propia norma en su párrafo final lo expresa, las modalidades del acto están sujetas a los conocimientos técnicos disponibles. Con lo cual el medio utilizado dependerá del estado actual del conocimiento científico -que es esencialmente dinámico- y hasta de la particular orientación disciplinar de los profesionales intervinientes. De acuerdo a estas

variables, y según las particularidades del caso, podrá recomendarse la Cámara Gesell, la entrevista en profundidad, la realización de test psicotécnicos, la declaración asistida, la realización de dibujos, la utilización de muñecos... Para tomar esta definición, no es menor la importancia de factores como la edad (no es lo mismo un niño de dos años que uno de diecisiete años), el género y hasta la índole de la experiencia sufrida (en casos verdaderamente extremos, hasta podría recomendarse que directamente la persona no declare sin antes recibir asistencia terapéutica).

§ 200. Como se trata de un medio cuyo uso es estandarizado en cierto tipo de delitos (particularmente, delitos sexuales y hechos de violencia de género), conviene hacer aunque sea una mínima referencia a la específica modalidad de la Cámara Gesell.

Se trata básicamente de una habitación con dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, equipada con dispositivos de grabación de audio y video. La idea general es que en el ambiente observado tiene lugar determinada actividad, que se desarrolla sin poder percibir lo que ocurre en el ambiente de los observadores. En este último se encuentran normalmente el juez y los abogados, que pueden interactuar de manera remota con la persona que conduce la actividad del otro lado.

En el caso específico de declaración de personas en situación de vulnerabilidad, en el ambiente observado tiene lugar la entrevista conducida por los profesionales del equipo interdisciplinario. Ocasionalmente, los profesionales pueden pausar la entrevista y pasar al otro ambiente para recibir los comentarios y preguntas de los litigantes. Técnicamente no se trata de un interrogatorio, sino que los temas o preguntas se van abordando de manera contextualizada y en el marco de una interacción que se plantea en función de la edad y las características de la persona entrevistada.

Los registros de la medida pueden ser reproducidos en juicio como evidencia material. Además, los profesionales elaboran un dictamen y pueden declarar en calidad de peritos. Con lo que se trata de un *medio probatorio híbrido o compuesto*, en el que interactúan distintos órganos de prueba en un entorno dispuesto a tal fin.

Reconocimiento de personas

§ 201. El *reconocimiento de personas* (CPP, 194-201) constituye una forma específica de la prueba testimonial, consistente en exhibir al declarante una determinada cantidad de personas formadas en línea para que diga si reconoce

entre ellas a la que ha mencionado o aludido en su declaración. Cuando el propio imputado actúa como declarante, está amparado por la facultad de abstención y no presta juramento de decir verdad. Sí está obligado a intervenir cuando actúa como integrante de la fila.

§ 202. El reconocimiento está rodeado de una serie de previsiones tendientes a evitar la manipulación de la medida, y fundamentalmente a prevenir los falsos positivos o las identificaciones dudosas. Algunas de estas previsiones son:

- Antes del reconocimiento, se interroga al testigo para que describa a la persona que dice haber visto.
- A continuación, se forma una fila con la persona que se pretende reconocer, junto a otras tres que tengan similares características físicas externas, aunque no necesariamente biológicas (caso de *fila de cuatro*). Cuando se trata de individualizar a una persona como perteneciente a un grupo determinado (expresión poco clara que usualmente alude a caracteres distintivos o particulares), podrán formarse filas con no menos de cuatro integrantes (la curiosa forma de redacción hace que también en este caso estemos ante una *fila de cuatro*, que aquí opera como número mínimo). En cualquiera de estos casos, la persona a ser reconocida puede elegir su lugar en la fila. Durante el acto, quienes integran la fila deben guardar silencio y seguir las indicaciones que se le impartan (por ejemplo, girar hacia un lado, acercarse, hablar).
- A continuación, se invita al declarante a que señale si reconoce a alguna persona entre las que integran la fila.

La diligencia se formaliza mediante acta y por registro audiovisual, que en principio tienen carácter de *declaración previa* (a menos que la diligencia se cumpla mediante *anticipo jurisdiccional de prueba*, CPP, 298).

Se prevé también el reconocimiento por fotografías o imagen de video (CPP, 198), imponiéndose en este caso un mínimo de siete personas exhibidas (*fila de siete*).

§ 203. Con todo, el reconocimiento de personas es un medio de prueba sumamente criticado. Además de los problemas asociados a los testimonios en general, se ha visto con frecuencia que cuando el testigo no está totalmente seguro de la identificación, señala aunque sea por aproximación al que más se parece a su recuerdo, y rara vez admite no poder reconocer a nadie en la fila. Además, en la mayoría de los casos al testigo se le exhiben previamente *álbumes de sospechosos*. Esta actividad previa es cumplida muchas veces de manera no oficial, y en la práctica resulta de casi imposible comprobación.

Frente a estas deficiencias, se han formulado propuestas extremas como directamente suprimir este medio de prueba. Otros optan por exigir reglas más estrictas (por ejemplo, aumentar el número de personas en fila, o exhibir de manera no anunciada *filas placebo*, en las que no se encuentre la persona a reconocer), y hay quienes proponen permitir la medida sólo con fines investigativos, pero prohibiendo su utilización en juicio. Finalmente, algunos proponen que pueda ser introducida sólo como prueba de descargo, en caso de identificación negativa (la validez asimétrica vendría a compensar la supuesta mayor tendencia a los falsos positivos).

Reconstrucción del hecho

§ 204. La *reconstrucción del hecho* (CPP, 166) es un medio de prueba típico del viejo sistema, al igual que el careo. Pero a diferencia de éste, ha logrado cierta aplicación práctica en el sistema reformado.

Consiste en la realización de actividades materiales o físicas, de manera dirigida, controlada y hasta escenificada, que suponen reproducir la mecánica original de los hechos investigados. Es una especie de experimentación, tendiente a comprobar si fácticamente las cosas pudieron ocurrir tal como se relatan.

Es un medio de prueba derivado de la testimonial, por cuanto supone que ya se han brindado declaraciones. Respecto del imputado, rige la facultad de abstención.

e) Momentos del fenómeno probatorio

Nociones generales

§ 205. Hemos adelantado que la actividad probatoria transcurre por determinados momentos, actividades o etapas: hallazgo, formalización, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, producción, introducción y valoración. Hemos visto también que estos conceptos a veces aparecen superpuestos o entremezclados (por ejemplo, en el caso de la prueba testimonial en juicio, producción e introducción son momentos coincidentes, porque el testimonio como tal nace en el momento de su presentación mediante el interrogatorio cruzado), y que no todas estas actividades necesariamente se cumplen en todo caso.

Algunas de estas actividades son relativamente sencillas de explicar, o de alguna manera ya han sido tratadas. De manera esquemática, puede decirse que:

- El *hallazgo* de evidencia se produce en el momento investigativo, ya sea de manera casual o intencional.
- La *formalización* es el medio de resguardar la evidencia o el testimonio, para su posterior utilización. En general las formalidades son más exigentes cuando se trata de *actos definitivos*, considerándose tales aquellos no susceptibles de ser realizado nuevamente en las mismas condiciones (CPP, 260).
- El *descubrimiento* de la prueba para el juicio tiene lugar durante la etapa intermedia, pesando sobre ambas partes el deber de poner en conocimiento de su contraria la evidencia material de la que propone valerse y la nómina de testigos (CPP, 296, 299).
- El *ofrecimiento* de prueba para el juicio también tiene lugar en la etapa intermedia (CPP, 299), aunque durante el juicio es posible excepcionalmente ofrecer nuevas pruebas (CPP, 324). La audiencia preliminar tiene su propia instancia de ofrecimiento (CPP, 300), mientras que en las demás audiencias previas al juicio el ofrecimiento no está regulado y puede darse de manera más inmediata.
- La *admisión* de la prueba (que también se regula con más detalle para el juicio y no para las demás etapas) es el pronunciamiento jurisdiccional que autoriza el medio propuesto, pudiendo rechazarse la prueba impertinente o sobreabundante y *debiendo* rechazarse la prueba ilícita.
- La *producción* es el momento en el cual la prueba genera información en el marco del proceso. En algunos medios probatorios, esta actividad puede ser continuada o compleja (por ejemplo, en la pericial la producción abarca desde la fijación de los puntos de peritaje hasta la presentación del dictamen y posterior examinación del perito).
- La *introducción* es la operación mediante la cual la prueba ingresa al ámbito de conocimiento del tribunal (en el caso de la prueba testimonial, producción e introducción constituyen una actividad única, mientras que la evidencia material requiere ser introducida por testigos).
- Finalmente, la *valoración* es el análisis de la información que la prueba aporta al proceso y su puesta en relación con los hechos del caso para acreditarlos o desacreditarlos.

Valoración de la prueba

§ 206. La *forma de valorar la prueba* en los distintos modelos procesales ha dado lugar a tres grandes *sistemas*:

- **Íntima convicción.** El sistema de la *íntima convicción* permite al tribunal fallar sin explicitar por qué atribuye determinado valor a las pruebas rendidas. Este sistema se corresponde con los modelos acusatorios clásico, material y adversarial y con el instituto del juicio por jurados. En el modelo anglosajón, no se prevé que el jurado tenga que explicitar los motivos de su decisión, por lo que las eventuales apelaciones se basan en las instrucciones del juez al jurado, que usualmente son elaboradas teniendo en cuenta los aportes de las partes. La viabilidad de las apelaciones en aquel sistema depende casi enteramente de la correlación entre la prueba rendida, las alegaciones de las partes, las instrucciones al jurado y finalmente el veredicto, por lo que la apelación funciona en definitiva como una instancia para plantear nulidades procesales en bloque (no se ataca directamente el contenido del decisorio, sino el procedimiento que llevó a su dictado). En algunos sistemas, hoy se admite que los litigantes incluyan preguntas concretas a los jurados sobre determinados aspectos de la prueba, lo que resulta útil para saber cómo formaron su convicción. Esto flexibiliza de algún modo el sistema, en cuanto abre la posibilidad de tomar esta incipiente forma de fundamentación como base para formular impugnaciones sobre el contenido del decisorio.
- **Prueba legal o tasada.** El sistema de las *pruebas legales*, o de la *prueba tasada*, consiste en establecer de antemano y en abstracto qué valor relativo debe asignarse a cada prueba (por ejemplo: la confesión hace plena prueba; el testimonio único es insuficiente; pesa más un testigo noble que un plebeyo; lo que no está en las actas no está en el mundo). Este sistema se corresponde históricamente con el modelo inquisitivo y con el carácter burocrático y piramidal de la judicatura.
- **Libre convicción o sana crítica.** El sistema de la *libre convicción* (no confundir con íntima convicción) o *sana crítica racional* permite al tribunal valorar la prueba con total libertad, sin estar sujeto a reglas que predefinan el valor de cada evidencia. Pero esta libertad de apreciación está unida al requisito de fundamentación de las sentencias, propio de la institución de la magistratura técnica. En cuanto a la prueba, el deber de fundamentación acarrea la necesidad de explicitar los motivos por los que se otorga determinado valor a cada testimonio o evidencia, de conformidad con las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia común.

Este método de valoración surge con el auge del sistema mixto, de la mano del desarrollo científico del Derecho Procesal.

§ 207. Nuestro código, siguiendo un criterio unánime en nuestra región, se inclina por el sistema de la *libre convicción* o *sana crítica racional* (CPP, 161). De manera concordante, la Constitución de Santa Fe impone a los tribunales el deber de *motivar las sentencias y autos* (CSFe, 95), exigencia que el código extiende a las resoluciones de la fiscalía y excepcionalmente a los decretos y providencias (CPP, 140).

A pesar de tan expresa consagración del sistema de la sana crítica, debe recordarse que el mismo sólo rige respecto de los jueces técnicos. La regla no se aplica cuando el juzgamiento está a cargo de *jurados populares*, ya que el indiscutible respaldo constitucional de este instituto (CN, 24, 75.12 y 118) obliga a aceptar el sistema de la íntima convicción que le es connatural (ver, a este respecto, el fallo “Canales”, CSJN, 2019; en particular, Considerando 19 del voto mayoritario).

f) Límites al ingreso de información al proceso

Nociones generales

§ 208. El ingreso de información al proceso está sujeto a un conjunto de reglas de garantía -de fuente legal y constitucional-, cuya infracción acarrea la invalidez de la prueba así obtenida. Estas reglas pueden operar impidiendo la actuación coactiva del imputado como órgano de prueba, o estableciendo límites a la obtención de evidencia material.

En general, también se le reconoce una función garantizadora a *la regulación de los medios de prueba en particular*, en cuanto establece condiciones mínimas de calidad para el ingreso de información al proceso (por ejemplo, si en el reconocimiento de personas no se cumple el número mínimo de personas en línea, ello privará a la diligencia de todo valor probatorio).

Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba

§ 209. La *incoercibilidad del imputado como órgano de prueba* se deriva de las cláusulas que prohíben obligar a declarar contra sí mismo o a declararse culpa-

ble, y se relaciona también con la prohibición del tormento (CN, 18; CADH, 8.2.g). Se consideran medios de coerción prohibidos no sólo los castigos físicos, lesiones o apremios (ver, al respecto, el fallo “Montenegro”, CSJN, 10-12-1981), sino también el interrogatorio inquisitivo o bajo presión, la falta de advertencia previa sobre el derecho de negarse a declarar y el interrogatorio sin presencia del defensor (ver fallo “Miranda contra Arizona”, Corte Suprema de los Estados Unidos, 13-6-1966; precedente que dio lugar a la célebre Doctrina Miranda).

El principio de incoercibilidad del imputado no sólo impide obligarlo a prestar declaración en el marco del proceso (CPP, 110), sino que se proyecta a *toda intervención del imputado como órgano de prueba*. Las intervenciones en este carácter son las que suponen la transmisión consciente de información, ya sea mediante el uso de la palabra oral o escrita (careo, reconocimiento cuando se actúa como declarante, formación de cuerpo de escritura), o mediante actos, gestos o movimientos que impliquen una colaboración voluntaria con el proceso (reconstrucción del hecho).

§ 210. A nuestro juicio, la garantía opera permitiendo -y hasta facilitando- la *mera abstención* del imputado, y no consagran el *derecho a mentir*. Por lo que no sería inconstitucional que el imputado, si voluntariamente acepta declarar, lo haga bajo juramento de decir verdad e impuesto de las penalidades por falso testimonio. Sin embargo, desde posturas más tradicionales se ha considerado que en este caso el deber de decir verdad constituye una forma de *coacción jurídica prohibida*.

Límites a la búsqueda de evidencia material

§ 211. A diferencia de lo que ocurre con la intervención del imputado como órgano de prueba, la *búsqueda de evidencia material* puede realizarse aun coactivamente, pesando en general una carga mínima de cooperación pasiva (deber de soportar). En particular, el imputado no puede negarse a participar en el reconocimiento de personas como integrante de la fila, ni tampoco a ser identificado dactiloscópicamente o a ser fotografiado, ni a someterse a examen médico o psicológico o a ser radiografiado.

Otras medidas, como la *requisa corporal* (CPP, 168, primer párrafo), requieren la concurrencia de motivos razonables para presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito. También para la *requisa vehicular* (CPP, 168, segundo párrafo) se exigen motivos razonables o la fuerte presunción de que se ocultan cosas relacionadas con un delito.

Se ha discutido hasta dónde llega este deber de soportar cuando la recolección de evidencia material requiere de intervenciones corporales sobre las personas. Así por ejemplo, se ha analizado la viabilidad de la *extracción compulsiva de sangre y tejidos corporales*, ponderándose factores tales como la necesidad de la intervención (por ejemplo, analizar si no es posible recolectar elementos orgánicos ya desprendidos del cuerpo, como pelos o restos cutáneos), la existencia de una negativa categórica (tratándose de una persona adulta), la intensidad de la coerción física que deba desplegarse (por ejemplo, si es una intervención traumatizante, o si requiere medidas de sujeción física), y hasta la índole del delito y la importancia de la prueba requerida (ver, ejemplificativamente, el fallo “Vázquez Ferrá”, CSJN, 2003). También se ha problematizado la *requisa en profundidad*, con inspección de cavidades corporales (también ejemplificativamente: fallo “Álvarez, Juanito”, Cámara Nacional en lo Penal Económico, 7-10-1988).

Aun señalando la complejidad de la temática y la enorme variedad de criterios que ofrece la casuística, puede concluirse que las diligencias tendientes a la obtención de evidencia material no requieren del consentimiento de la persona afectada, al menos como regla. Sí existen limitaciones puntuales, distintas de las que protegen al imputado contra la autoincriminación, basadas en el elemental respeto que se debe a la dignidad humana (CN, 19; CADH, 11.1).

Allanamiento

§ 212. El *allanamiento* (CPP, 169) puede ordenarse cuando resulte necesario proceder al registro de lugares habitados u otras dependencias. Se trata de una medida de coerción real que afecta la *inviolabilidad del domicilio* (CN, 18), por lo que requiere en principio de orden judicial escrita.

El código prevé dos cláusulas que podrían considerarse excepciones a la exigencia de orden judicial:

- La primera cláusula tiene que ver con la *autorización libre y previamente expresada por la persona con derecho a oponerse* (usualmente, el morador). El código trata este caso como un supuesto de mero registro sin necesidad de allanamiento (CPP, 169, primer párrafo), lo cual es problemático. La jurisprudencia ha cuestionado el carácter voluntario de esa autorización, especialmente cuando se interpreta como tal la mera ausencia de oposición expresa (fallos “Fiorentino”, CSJN, 1984; “Rayford”, CSJN, 1983; y, algo más cercano a en el tiempo, “Ventura”, CSJN, 2005).

- La segunda excepción tiene que ver con los *casos de urgencia* previstos en todos los códigos, incendio, inundación u otra causa semejante que ponga en peligro la vida o los bienes de los habitantes, ingreso de personas extrañas con indicios manifiestos de cometer un delito, ingreso de un imputado durante una persecución e indicios de que en el interior de una casa o local se estuviera cometiendo un delito, o desde ella se solicitara socorro (CPP, 170).

La orden deberá individualizar los objetos a secuestrar o las personas a detener, no admitiéndose en principio que la diligencia se extienda más allá de sus específicas finalidades. Sin embargo, se ha admitido el hallazgo de objetos adicionales (no contemplados en la orden), particularmente cuando pudieron ser detectados a simple vista.

Interceptación de comunicaciones

§ 213. El código permite disponer la *interceptación de comunicaciones*, para impedir las o conocerlas, y el secuestro de correspondencia (CPP, 171). Pueden intervenir las comunicaciones realizadas por cualquier medio técnico: correo postal, telegráfico, electrónico, mensajes de texto y de audio (vía SMS o mediante redes digitales, como WhatsApp o Telegram), mensajes a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, por qué no Tinder... aunque temo que en algún momento este listado pasará de moda), y obviamente también llamadas por línea telefónica.

La interceptación requiere ineludiblemente de orden judicial, dado que pone en juego la garantía de *inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados* (CN, 18). Desde una interpretación progresiva, se incluyen en la protección constitucional todas las formas de comunicación con expectativa de privacidad (la garantía no ampara, por ejemplo, aquellos mensajes transmitidos de forma pública: estados de WhatsApp, muro de Facebook, etc.).

La orden deberá estar debidamente fundada, y en el caso de la interceptación de comunicaciones deberá establecer el plazo de duración de la medida. No se prevé que una vez finalizada la intervención se deba notificar a la persona intervenida, como se ha planteado en algunos proyectos de reforma.

g) La salvaguarda del juego limpio en relación a la prueba

Nociones generales

§ 214. Existen determinadas situaciones que ponen en tensión no sólo límites legales y constitucionales a la obtención e introducción de la prueba, sino que también generan alguna distorsión en el equilibrio entre las partes. Esto es particularmente relevante tratándose de un modelo acusatorio formal, en el que la fiscalía, además de litigar en carácter de parte, detenta la dirección de la investigación penal y el poder directivo específico sobre la policía en el marco del caso concreto.

Esta posición de *parte investigadora* no sólo genera la necesidad de generar instancias de control sobre los actos de la fiscalía, sino que requiere también del establecimiento de elementales pautas de buena fe procesal y respeto profesional entre los litigantes. En este sentido, deben mencionarse cuatro pautas fundamentales: *Reglas Brady*, *deber de revelar evidencia*, *control de actos definitivos* y *prueba instada por la defensa*. Estas pautas, en la medida en que protegen a los litigantes del abuso del proceso por parte de su adversario, integran la garantía del *debido proceso constitucional* (CN, 18).

Las Reglas Brady

§ 215. Se conoce como *Reglas Brady* (fonética: *bréi-di*) a la doctrina generada por el fallo estadounidense “Brady contra Maryland” (Corte Suprema de los Estados Unidos, 1963). En aquel precedente, se estableció que constituye una violación al debido proceso la retención o supresión, por parte de la fiscalía o de los investigadores, de evidencia favorable al acusado. En el caso concreto, se trataba de un homicidio en ocasión de robo, y la evidencia retenida era la declaración del copartícipe en la que confesaba haber cometido el homicidio por su cuenta y sin participación de quien era imputado en este proceso.

A la luz de aquel precedente, se considera como evidencia favorable no sólo la que resulte directamente exculpatoria, sino también la que pueda servir para atenuar la pena o la que permita desacreditar a un testigo de cargo.

§ 216. Nuestro código consagra en términos generales la doctrina Brady, aunque sin el grado de detalle propio del derecho anglosajón. Concretamente, se obliga a la fiscalía a poner en conocimiento de las demás partes todos los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que se hubieran reunido o

conocido a lo largo de todo el procedimiento penal, considerándose falta grave su ocultamiento (CPP, 132, segundo párrafo). La norma se extiende incluso a los elementos no incorporados al legajo investigativo, *en tanto fueran conocidos por la fiscalía*. En correlato con esta disposición, la ley 13.013 consagra en relación a los fiscales el *principio de objetividad* (art. 3.2) y *tipifica como falta grave ocultar información en forma injustificada* (art. 52.6).

Aunque parezca una obviedad, debe aclararse que no pesa sobre la defensa un deber, correlativo al de la fiscalía, de aportar la prueba de cargo con la que pudiera contar. Dicho de otro modo, las reglas Brady funcionan de manera asimétrica o unilateral, operando como una suerte de contrapeso al hecho de que la dirección de la investigación penal esté a cargo del acusador.

El deber de revelar evidencia

§ 217. Se ha popularizado en nuestro medio la invocación de las llamadas *reglas de descubrimiento* o *discovery* (fonética: *dis-có-ve-ri*), propias de la legislación procesal civil norteamericana. En rigor, las reglas en cuestión regulan el deber de las partes de entregar, a solicitud de la contraria, documentación y deposiciones de testigos que obren en su poder. Esta actividad se cumple en un momento previo al juicio, que funciona como etapa preparatoria. De hecho, la función principal del llamado descubrimiento (que podemos traducir mejor como *deber de revelar evidencia*) es que las partes cuenten con información detallada que les permita llegar a un arreglo extrajudicial.

§ 218. En el marco del proceso penal, y específicamente en nuestro sistema, no existe este deber genérico de revelación de evidencia a la contraparte. Más lejanamente, puede verse en el *ofrecimiento de prueba para el juicio* (CPP, 299) una manifestación puntual y limitada del *discovery*, en cuanto obliga a revelar la evidencia que luego se pretenderá utilizar. Obligación que pesa sobre ambas partes (a diferencia de las reglas Brady, que operan sólo en relación a la fiscalía), aunque no necesariamente de manera simétrica: la fiscalía tiene instancias previas de revelación (la audiencia imputativa, la consulta del legajo una vez finalizada ésta y el requerimiento acusatorio), mientras que la defensa sólo debe revelar antes de la ocasión del CPP 299 si es que pretende utilizar alguna evidencia de forma adelantada (por ejemplo, para avalar una morigeración de la situación cautelar). En otras palabras, la fiscalía debe revelar su evidencia en momentos legalmente determinados, mientras que la defensa puede ir revelando selectivamente la evidencia en la medida en que necesite valerse de ella.

Régimen de los actos definitivos

§ 219. El *régimen de los actos definitivos* (CPP, 260, 282, 283) tiende a asegurar cierto grado de control sobre las diligencias consideradas irreproducibles. La imposibilidad de que el acto pueda ser realizado o reproducido con posterioridad es precisamente lo que le da el carácter de definitivo. En rigor, cualquier acto investigativo puede considerarse definitivo a estos efectos si existe el riesgo de que luego no pueda ser cumplido en las mismas condiciones (por ejemplo: autopsia, otros peritajes, reconocimiento de personas).

Las consecuencias principales de que un acto se considere definitivo son la *formalización por acta* (CPP, 260) y la *notificación a la defensa y al querellante* (CPP, 282), a fin de que ejerciten sus facultades (centralmente, presenciar el acto y, si se trata de un peritaje, designar peritos de parte). Obviamente, el deber de notificar surge una vez adjudicada la calidad de imputado (según el CPP, 100).

Sin embargo, en casos de urgencia la notificación a las partes puede ser dispensada por el tribunal (CPP, 283, primer párrafo), y si esto fuera imposible puede procederse directamente a la realización del acto, haciéndose constar en acta dicha circunstancia (CPP, 283, segundo párrafo).

Prueba instada por la defensa

§ 220. Si bien la defensa puede ofrecer prueba para el juicio (CPP, 299), esta facultad por sí sola resultaría insuficiente. Ello por varias razones:

- Primero, porque hay medios de prueba que ineludiblemente requieren algún grado de preparación (por ejemplo, para poder ofrecer la declaración de un perito, ya debe haberse desarrollado el peritaje propiamente dicho y debe haberse entregado el dictamen correspondiente).
- Segundo, porque si la defensa espera al ofrecimiento de prueba para intervenir, habrá perdido valiosas oportunidades de lograr evidencia de descargo y de inclinar el caso a su favor.
- Y tercero, porque de ordinario el resultado de las negociaciones dependerá del cúmulo de evidencias (de cargo y de descargo) con que se cuente. Por lo que es fundamental contar con evidencia defensiva antes del juicio, y precisamente para tener la opción de lograr una salida alternativa más balanceada.

Por ello, el código prevé que la defensa *pueda proponer diligencias probatorias durante la investigación* (CPP, 286). Estas solicitudes se realizan ante el fiscal a cargo de la investigación, con recurso ante la Fiscalía Regional en caso de

negativa. La norma en su redacción original establecía que el fiscal de grado superior resolvía *sin recurso alguno*. La eliminación de esta última aclaración hace pensar que, ante la negativa del Fiscal Regional, cabe recurrir ante el tribunal.

§ 221. Actualmente se está considerando insuficiente incluso este tipo de regulación. Así por ejemplo, el *Manual de Defensoría Penal Pública para América Latina y el Caribe*, elaborado por instituciones de referencia como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recomienda que las defensorías cuenten con recursos para realizar sus propias investigaciones alternativas, particularmente en casos de alta complejidad. Con la importante salvedad de que esto no debería llevar a crear una infraestructura similar a la de la fiscalía, en el ámbito de la defensa.

Más allá de esta recomendación, está claro que la defensa de hecho puede llevar adelante *actividad esencialmente investigativa*, como entrevistar testigos, o requerir informes de organismos públicos y privados. De todos modos, la cláusula del CPP, 286 resulta necesaria para dar *formalidad* a las diligencias realizadas, ya que técnicamente la única investigación oficial es la que dirige la fiscalía (CPP, 251). Además, la participación del fiscal es ineludible cuando se requiere de algún despliegue de coerción para cumplimentar la medida (CPP, 135).

h) Prueba prohibida, ilícita e irregular

Nociones generales

§ 222. La problemática de la prueba ilegal obliga a distinguir conceptualmente *prueba prohibida*, *prueba ilícita* y *prueba irregular*, aunque advirtiendo que la terminología no es uniforme en doctrina.

Con todo, hay algún grado de consenso para afirmar que la *prueba prohibida*, es decir aquella que carece de toda eficacia probatoria, es *aquella que se obtiene a partir de una vulneración de garantías constitucionales o que es consecuencia necesaria de aquella vulneración*. Es decir, toda protección constitucional (del domicilio, de las comunicaciones privadas, de la propia declaración del acusado) acarrea como consecuencia la ineficacia de la prueba obtenida a través de su vulneración.

§ 223. La singular importancia de los valores con tutela constitucional permite distinguir la prueba prohibida, de la ilícita y de la irregular:

- La *prueba ilícita* surge de un medio antijurídico, pero que no lesiona un derecho fundamental. Esto ocurre cuando determinadas prohibiciones surgen directamente de normas legales, que no pueden considerarse reglamentarias de garantías constitucionales sino que tienden a proteger otros valores (por ejemplo, las limitaciones al testimonio de ciertos parientes del imputado, o el número mínimo de integrantes de la fila en el reconocimiento de personas). En estos casos, alguna doctrina admite la posibilidad de que la prueba así obtenida pueda igualmente valorarse, según la entidad de la infracción y la importancia de la prueba.
- La *prueba irregular* es la que adolece de algún requisito formal considerado no esencial, como la firma de testigos al pie de un acta, el juramento previo de decir verdad o la constancia de que se ha dado aviso al fiscal de una determinada diligencia.

En cuanto a sus efectos, la prueba ilícita e irregular requieren de protesta previa (de lo contrario, el acto se considera tácitamente consentido), y también admiten la subsanación posterior (CPP, 246).

Regla de exclusión y efecto extensivo

§ 224. Bajo el título de *exclusiones probatorias*, el código regula de hecho los dos supuestos de prueba prohibida:

- *Regla de exclusión*: Se priva de toda eficacia a la prueba cumplida vulnerando garantías constitucionales (CPP, 162, primer párrafo). Ejemplo: confesión obtenida mediante tortura o apremios.
- *Efecto extensivo (teoría del fruto del árbol envenenado, efecto reflejo o efecto dominó)*: La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieran podido ser obtenidas la violación de garantías constitucionales y fueran consecuencia necesaria de ella (CPP, 162, segundo párrafo). Ejemplo: el allanamiento ordenado regularmente y mediante el cual se descubre evidencia material, al que se llega a partir de un dato que se obtiene mediante una confesión bajo tortura.

Como se advierte, no se trata de reglas excluyentes ni contradictorias entre sí. Más bien, la teoría del fruto del árbol envenenado opera como una extensión o complemento de la regla de exclusión en sentido estricto.

Fundamentación

§ 225. Doctrina y jurisprudencia han ensayado diversas fundamentaciones para ambas reglas:

- Con un innegable contenido *ético*, se ha sostenido que otorgar valor al resultado de un delito compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito (fallos “Montenegro” CSJN, 1981, “Fiorentino”, CSJN, 1884, y Rayford, CSJN, 1986).
- En sentido concordante, se ha dicho que *la tutela de los derechos del individuo es un valor más importante para la sociedad que el castigo del autor del delito* (fallo “Monticelli de Prozillo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 1984).
- En otro sentido, se ha considerado que la regla de exclusión *integra el estándar del debido proceso* (fallo, “Mapp contra Ohio” [fonética: o-já-io], Corte Suprema de los Estados Unidos, 1961).
- Finalmente, se ha dicho que la exclusión probatoria es un medio para *desalentar los actos policiales ilegales* (fallo “Estados Unidos contra Calandra”, Corte Suprema de los Estados Unidos, 1974).

§ 226. Por supuesto que algunos de estos argumentos han recibido críticas. Así, se ha dicho que si se quiere desalentar las malas prácticas policiales, ello puede lograrse sancionando a los funcionarios responsables, pero no haciendo que la sociedad pague por esa falla con la impunidad de un culpable. En relación a que los derechos individuales puedan tener más importancia que el castigo de los delincuentes, esto ha sido puesto en duda en delitos particularmente graves (todos hemos visto alguna escena cinematográfica, en la que se tortura a un supuesto terrorista para que diga dónde puso la bomba que seguramente matará a miles de inocentes).

Excepciones o teorías de validación

§ 227. Tanto la regla de exclusión como la teoría del fruto del árbol envenenado han dado lugar a *teorías de validación* o *casos de excepción*, cuya aplicación sigue siendo muy discutida. Más discutida aún es la correspondencia de algunas de estas excepciones con una forma particular de invalidez, ya que la mayoría de los supuestos son imaginables tanto en relación a la exclusión probatoria directa como a su efecto extensivo o reflejo.

Estos supuestos son:

- *Fuente independiente*. Cuando, aun excluyendo la prueba obtenida ilegalmente, el hecho delictivo puede acreditarse por otros medios que no tienen relación con la afectación constitucional. En este caso no estaríamos técnicamente ante una excepción, ya que la prueba obtenida legalmente y que no deriva de ninguna afectación constitucional ni siquiera está abarcada por la regla de exclusión (CPP, 162).
- *Descubrimiento inevitable*. Se da cuando la evidencia ilícitamente obtenida podría haber sido descubierta igualmente a través de un curso investigativo independiente ya iniciado. Este supuesto tiene alguna relación con el anterior (fuente independiente), pero aquí la supuesta fuente independiente no ha operado, sino que se trata de una hipótesis (ejemplo: aun prescindiendo de la confesión, de todas maneras se hubiera encontrado el cadáver, puesto que ya estaba en marcha un operativo de rastrillaje por esa zona).
- *Atenuación del nexo causal (mancha diluida)*. Este supuesto se da cuando la relación causal entre la ilegalidad primigenia y la evidencia en cuestión resulta atenuada. Para evaluar si existe atenuación del nexo causal, se ha considerado particularmente el tiempo transcurrido entre el acto ilegal y la prueba, la extensión de la cadena causal (la cantidad de actos intermedios), si existen circunstancias especiales, la gravedad e intencionalidad de la ilicitud original, la intervención de un acto libre de voluntad y la naturaleza de la evidencia derivada (se supone que el testimonio tiene más autonomía que la evidencia material). Por su propia naturaleza, esta excepción se esgrime *con exclusividad en relación al efecto reflejo* de la invalidez (frutos del árbol envenenado; por ello, no es aplicable a la regla de exclusión), ya que la pretendida atenuación del nexo causal operaría precisamente sobre los actos posteriores y no sobre el acto originariamente viciado.
- *Atenuación por hechos intervinientes*. Se da cuando a partir de un acto ilegal (por ejemplo, un registro domiciliario) se identifica a un testigo. Se ha considerado que el testigo cuenta con voluntad autónoma, por lo cual el estándar de exclusión es más exigente que con la evidencia material, considerándose particularmente si la identidad del testigo ya era conocida por la policía. También se ha tenido en cuenta la falta de relación entre el testimonio y el acto ilegal. Buena parte de la doctrina considera que estamos ante un caso específico del supuesto anterior (*atenuación del nexo causal o mancha diluida*).
- *Buena fe*. Esta excepción se relaciona principalmente con la llamada finalidad disuasiva de la regla de exclusión, y entre nosotros no suele aceptarse. Consiste en aceptar la prueba obtenida de manera ilegal, cuando

presumiblemente los funcionarios actuaron de buena fe, bajo la errónea creencia en la legalidad de su accionar. Por ejemplo, cuando se incurre en error sobre la concurrencia de los supuestos que habilitan el allanamiento sin orden, cuando se actúa en cumplimiento de una orden judicial que luego es anulada, o cuando se cree erróneamente que existe una orden de detención vigente contra una persona.

Síntesis del capítulo

1. *La prueba aparece regulada en general y en su producción en juicio. Esta última regulación introduce notas claramente adversariales, al consagrar el interrogatorio cruzado de testigos y otros sujetos.*
2. *Se distingue la prueba de testigos -en sentido amplio- de la evidencia material, y esta última de las declaraciones previas.*
3. *Los medios de prueba en general son regulaciones que garantizan estándares mínimos de calidad de la información, y evitan deformaciones en perjuicio del imputado. Pero la regla general es la libertad de los medios de prueba.*
4. *Existen límites al ingreso de información al proceso, que son el reflejo de garantías o principios constitucionales. Hay distintos niveles prohibitivos: la prohibición absoluta, el requerimiento de orden judicial o la concurrencia de especiales circunstancias, y el respeto a las formas legales.*
5. *La prueba prohibida da lugar a la exclusión probatoria directa, y a su efecto reflejo o teoría de los frutos del árbol envenenado. A su vez, existen posturas o teorías que proponen validar la prueba así obtenida en determinados casos.*
6. *Existen también reglas o pautas que tutelan el juego limpio y la relativa igualdad de partes (reglas Brady, deber de revelar evidencia, actos definitivos, prueba de la defensa), y que cobran mayor importancia en un sistema que concede a la fiscalía el poder de investigar.*

Capítulo 8. Coerción procesal

a) Nociones generales

El poder coercitivo

§ 228. Cuando se habla de *coerción* o *poder coercitivo*, se está haciendo referencia a la facultad que poseen determinados sujetos para obligar a otros a realizar o a tolerar alguna actividad sin el concurso de su libre voluntad. Esta obligación de hacer o de tolerar, se impone mediante el ejercicio de la fuerza pública directa (coerción física), o implicando la eventualidad de dicho ejercicio (coerción jurídica). El poder coercitivo descansa primariamente en el órgano jurisdiccional, aunque excepcionalmente puede ser ejercido por la autoridad fiscal o policial, e incluso por particulares.

Aunque hay una cierta aproximación entre medidas coercitivas y medidas cautelares, debe dejarse en claro que ambos conceptos no son totalmente coincidentes. A lo sumo, puede decirse que las medidas cautelares suponen algún tipo de coerción para su imposición. Pero no puede haber una identificación total, en cuanto ello implicaría adelantar posición sobre la supuesta naturaleza cautelar de ciertos institutos. Como ejemplo, puede mencionarse que se discute en doctrina el carácter cautelar de la prisión preventiva; sin embargo, su carácter coercitivo no admite duda. Asimilar coerción con cautela, como hacen erróneamente muchas legislaciones (por ejemplo: CPP, 205), parece arrojar anticipadamente un manto de legitimidad sobre toda actividad coercitiva por el solo hecho de serlo.

Clasificaciones

§ 229. La coerción procesal admite múltiples formas y modalidades. Así, se habla de *coerción personal*, en referencia a la que recae sobre las personas, y

particularmente sobre el imputado, y de *coerción real*, aquella que se despliega sobre cosas, lugares y bienes. Por otra parte, las medidas de coerción pueden perseguir el aseguramiento de la evidencia o el cumplimiento de las resoluciones judiciales, no faltando aquellas que pretenden cumplir ambas finalidades. Como novedad, la mayoría de los códigos fue incorporando medidas innovativas (no atadas, por ende, a ninguna de aquellas finalidades), como el cese del estado antijurídico y la inhabilitación provisoria para conducir.

Por razones de importancia temática y de complejidad, se expondrá separadamente y en primer término el conjunto de medidas coercitivas que afectan la libertad de la persona imputada. Luego se expondrán, de forma algo más escueta, las demás medidas.

b) Medidas de coerción que afectan la libertad de la persona imputada

La situación del imputado en los distintos modelos de proceso

§ 230. La situación del imputado durante el curso del proceso ha sido siempre un tema definitorio desde el punto de vista de los sistemas. En términos generales, puede afirmarse que el estado de libertad durante el proceso es connatural al sistema acusatorio, mientras que el sistema inquisitivo se caracteriza por el encarcelamiento preventivo del imputado. Aunque la evolución posterior de ambos modelos los ha ido acercando en la práctica, las diferencias de concepción y de método son notorias:

- En los sistemas de raigambre inquisitiva, el juicio incriminatorio en grado de probabilidad (procesamiento) trae aparejado como regla el *encarcelamiento preventivo del imputado*. Dicha medida admite ser excepcionada mediante el instituto de la *excarcelación*, que en general procede cuando la pena en expectativa no supera cierto tope en su máximo, o cuando resulta viable la aplicación de una pena en suspenso. Y aún en estos casos, se prevén causales obstativas, tales como la reincidencia o la existencia de procesos anteriores en trámite. En Argentina, este modelo comienza a ser fuertemente criticado a partir del fallo “Barbará” (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, 2003), que pone en cuestión la constitucionalidad de los parámetros excarcelatorios objetivos.

- En los sistemas acusatorios del mundo anglosajón, la regla general es la *libertad bajo fianza* del imputado. La posibilidad de graduar en más o en menos el monto de la fianza ofrece, desde esta perspectiva, cierta flexibilidad, en cuanto permite adecuar la intensidad de la caución a la gravedad del caso. La denegación expresa y absoluta de la libertad bajo fianza sólo ocurre por excepción, aunque sí es frecuente la imposición de fianzas muy altas que de hecho resultan impagables. En Estados Unidos, recién hacia 1960 se comienzan a plantear medidas alternativas a la fianza monetaria, a la que tampoco se logra desplazar del todo.

Como veremos, la reforma procesal penal se aparta expresamente del modelo inquisitivo, pero también reniega del componente económico que caracteriza al acusatorio anglosajón. Así, nuestro sistema consagra la libertad del imputado como regla general, y prevé un conjunto de medidas de control que en general no revisten carácter pecuniario.

El encarcelamiento preventivo: debates sobre su naturaleza y su legitimidad

§ 231. La prisión preventiva nos plantea dos problemas centrales, que son su *naturaleza* y su *legitimidad*. La pregunta por la naturaleza de la prisión preventiva remite al debate entre sustancialistas y procesalistas, mientras que la pregunta por la legitimidad confronta a legitimacionistas y críticos.

§ 232. En el debate sobre la *naturaleza de la prisión preventiva*, los posicionamientos serían los siguientes:

- La postura *sustancialista* considera que existe una identidad esencial entre la prisión preventiva y la pena de prisión, por cuanto en ambos casos se persigue evitar la reiteración delictiva y proteger a la sociedad de la delincuencia. La prisión preventiva operaría como un anticipo de la pena misma, por lo que sus finalidades serían las mismas (disuasión, castigo, reforma, etc.).
- La postura *procesalista* sostiene, en cambio, la diferenciación radical entre prisión preventiva y pena de prisión, correspondiendo a la primera una función meramente instrumental. Sus fines no son los fines de la pena, sino los fines del proceso: garantizar la averiguación de la verdad y la actuación de la pretensión punitiva; en síntesis, busca evitar la fuga del imputado y el entorpecimiento de la investigación.

§ 233. Por otro lado, la discusión sobre la *legitimidad de la prisión preventiva* da lugar a dos posiciones básicas:

- Llamariamos *legitimacionistas* a quienes avalan la legitimidad de la prisión preventiva.
- La postura *crítica* plantea la total ilegitimidad de la prisión preventiva.

Esta clasificación básica da lugar a múltiples entrecruzamientos, no faltando tampoco posturas híbridas. La escuela positiva, y el pensamiento autoritario en general, serían buenos ejemplos de *sustancialismo legitimacionista*, ya que avalan el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado o como mecanismo de política criminal. En cambio, quienes postulan la necesidad de abolir el encarcelamiento preventivo por considerarlo una violación al principio de inocencia, ya que funciona como un castigo anticipado, se enrolarían en un *sustancialismo crítico*. Desde esta postura, se critica la ingenuidad del procesalismo, en cuanto parece ignorar que la prisión preventiva, independientemente de sus fines declarados, funciona en la realidad como una pena anticipada. Por otra parte, entre los procesalistas hay quienes se focalizan en la dimensión jurídica y afirman que la prisión preventiva *es* una medida cautelar (*procesalismo legitimacionista*), y quienes bregan por restringir su aplicación a los casos en los que se verifica un peligro para los fines del proceso (*procesalismo crítico*), lo que da lugar a planteos garantistas o abolicionistas.

Principios limitadores

§ 234. Desde el punto de vista jurídico, las medidas de coerción sobre la persona imputada están sujetas a un conjunto de principios limitadores:

- *Instrumentalidad*. No pueden ser justificadas como anticipo de pena, por lo que sólo pueden aplicarse en la medida indispensable para garantizar los fines del proceso penal (CN, 14, 18; CADH, 7.5; Reglas de Mallorca, 16, 20; CPP, 208).
- *Trato de inocente*. Como consecuencia del principio anterior, las personas sometidas a prisión preventiva deben permanecer separadas de las que estuvieran cumpliendo condena (CADH, 5.4; CSFe, 9; CPP, 231).
- *Judicialidad*. Son dispuestas por la autoridad judicial, o excepcionalmente por otros sujetos pero con posterior control judicial (CADH, 7.5, 7.6; CSFe, 9; CPP, 205, 224).
- *Excepcionalidad*. La restricción de la libertad no puede aplicarse por defecto o como regla general (PIDCP, 9.3).
- *Proporcionalidad*. La restricción de la libertad debe guardar relación con la gravedad del delito atribuido, ya que no tendría sentido que la coerción durante el proceso fuera más gravosa que la pena misma que pudiera

imponerse (Reglas de Mallorca, 17; Reglas de Tokio, 3.1). Una manifestación concreta de este principio es que la prisión preventiva sólo puede aplicarse cuando el delito atribuido tuviera prevista pena de prisión de cumplimiento efectivo (CPP, 220.2).

- *Gradualidad* (o *subsidiariedad* de la prisión preventiva). Verificado el riesgo para los fines del proceso, debe evaluarse la viabilidad de medidas de baja intensidad, para pasar luego y de manera escalonada a considerar la aplicación de medidas más severas, pudiendo llegarse sólo en último término a la prisión preventiva (Reglas de Mallorca, 20; Reglas de Tokio, 6.1, 8.1).
- *Idoneidad*. La restricción debe ser mínimamente apta para cumplir la función de control de riesgo que se le asigna (implícitamente: CPP, 208). Por ejemplo, no tendría sentido dictar una medida de prohibición de acercamiento, si se alega que el imputado está amenazando telefónicamente a los potenciales testigos.
- *Provisoriedad*. La medida de coerción debe durar lo mínimo e indispensable para cumplir con su finalidad asignada, debiendo evitarse su mantenimiento más allá de este punto (Reglas de Tokio, 6.2; CPP, 206).

Requisitos

§ 235. En los sistemas reformados, la prisión preventiva está condicionada a la concurrencia de dos requisitos fundamentales: el *supuesto material* y la *necesidad de la medida*. Cabe tener presente que un sector de la doctrina considera que el primer requisito constituye el *presupuesto* de la medida, y el segundo su *fundamento*, con lo cual se enfatiza que existe un orden lógico entre los dos elementos: no cabe siquiera analizar la necesidad de la medida, si antes no se ha acreditado el supuesto material.

Supuesto material

§ 236. El *supuesto material* refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría o participación punible del imputado en el hecho investigado (CPP, 220.1). Lo que se exige es un juicio incriminatorio en grado de probabilidad, entendiéndose por tal el predominio de los elementos de cargo por sobre los de descargo. La fórmula parece bastante simple (de decir), pero ¿cómo, exactamente, se alcanza este nivel de conocimiento, en los primeros momentos del proceso?

Los códigos inquisitivos y mixtos acudían al instituto del *procesamiento*, que era esencialmente un pronunciamiento incriminatorio provisional. Una vez formalizada la declaración indagatoria del imputado, el juez instructor debía resolver su situación: la probabilidad positiva (predominio de los elementos de cargo) daba lugar al procesamiento del imputado, mientras que el juicio dubitativo acarreaba el dictado de *falta de mérito*. Ahora bien, todo esto ocurría en el marco de una investigación escriturizada, a cargo del propio juez que debía resolver, y dentro de un plazo bastante generoso cuyo vencimiento carecía de efectos inmediatos. En estas condiciones, el instructor podía permitirse valorar en profundidad la prueba que él mismo había colectado, según el sistema de la sana crítica racional. Así, el procesamiento era prácticamente una sentencia en cuanto a su estructura y contenido, y de hecho si no ocurría ninguna sorpresa durante el plenario, hasta podría decirse que el procesamiento era un adelanto de la sentencia.

Ahora bien, en un sistema acusatorio esto sencillamente no funciona. En primer lugar, porque quien dirige la investigación debe solicitar la medida coercitiva a un tercero, a quien deberá convencer. Esto que parece una obviedad, contrasta con la posición autosuficiente del juez de instrucción, que sencillamente debía convencerse a sí mismo. Además, aquí los plazos son mucho más acotados, y su vencimiento abre la vía liberatoria mediante la interposición de hábeas corpus. En este contexto, la fiscalía debe trabajar contrarreloj para coleccionar la evidencia necesaria, que además deberá sostener en audiencia pública. Obviamente, esto no debe ser entendido como un disvalor de nuestro actual sistema -que de hecho es más respetuoso de las libertades individuales-, pero sí debe ser considerado para comprender por qué *el supuesto material no puede ser construido con los mismos estándares cognoscitivos propios del sistema derogado*.

§ 237. Por eso la probabilidad, como formulación abstracta de un grado de conocimiento o de un estado cognoscitivo, debe ser reinterpretada dentro del marco general del nuevo sistema, que le impone dos pautas correctivas: la *limitación temática* y la *acreditación independiente*.

- La *limitación temática* refiere a la imposibilidad de adelantar a las audiencias previas cuestiones propias del juicio oral. A diferencia del viejo sistema, en el que la evidencia instructoria tenía carácter casi definitivo, aquí la acreditación a fondo del supuesto material implicaría directamente adelantar la prueba de cargo propia del juicio oral, o lo que es lo mismo, implicaría para el acusador la carga de probar anticipadamente la culpabilidad, en desmedro del esquema temporal del código y de la pro-

pia lógica de la oralidad. Por lo que debe concluirse que entre la acreditación del supuesto material y la prueba de cargo en el juicio no hay una mera diferencia de grado, sino que se trata de una diferencia sustancial que se basa en las distintas funciones de ambas instancias.

- Esta cierta flexibilización que se produce en la acreditación del supuesto material se compensa con el hecho de que dicho supuesto *no acarrea presunción alguna en cuanto a la necesidad de cautela*, que deberá ser acreditada de manera independiente. Una de las razones por las que en el viejo sistema el procesamiento tenía un estándar cognoscitivo tan exigente, era la importante derivación referida a la prisión preventiva, que se dictaba de manera automática según la gravedad de la escala penal. El nuevo sistema, que exige acreditar concretamente el riesgo procesal que se invoca, elimina este *efecto arrastre* y permite dar al supuesto material la justa relevancia que posee, como condición necesaria pero no autosuficiente para el dictado de la medida coercitiva. A lo sumo, la gravedad de la escala penal será un elemento -entre muchos otros- para elaborar la hipótesis de riesgo procesal.

§ 238. La aplicación de estas dos pautas correctivas que sintéticamente se han expuesto, da lugar a que en los sistemas reformados se defina el supuesto material con la exigencia, para la fiscalía, de contar con un *caso fuerte* o una *acusación seria* (en el derecho alemán, y con una formulación similar, se habla de *sospecha vehemente*). Esto significa, *que se cuente con evidencias suficientes, en relación al momento investigativo actual, para tener la expectativa de ir a juicio*.

- La *necesidad de evidencias suficientes* significa, concretamente, que la fiscalía deberá enumerar los elementos de convicción recolectados, indicando sintéticamente qué proposiciones fácticas se acreditarán con cada uno de ellos. Recordemos que no se trata de producir la prueba, ya que ello es una actividad propia del juicio. Pero sí deberá indicarse, por ejemplo, si se cuenta con testigos presenciales del hecho, si se cuenta con registros de video, si se han levantado huellas, e inclusive si hay medidas pendientes, como peritajes sobre los elementos secuestrados. Con todo este cúmulo de información, la fiscalía aún no ha probado absolutamente nada, pero sí está en condiciones de mostrarle al tribunal que tiene un caso fuerte, despejando así la sospecha de que se trate de una acusación caprichosa o inventada. Este elemento cumple, así, una importante función de garantía en favor del acusado.
- El cúmulo de evidencias debe ser evaluado *en relación al momento investigativo actual*. Si estamos a dos o tres días del inicio de la causa, nadie pretenderá que las evidencias sean aplastantes o concluyentes, pues eso -

insistimos- sería imponer anticipadamente el estándar cognoscitivo propio de la sentencia condenatoria. Esto es muy importante, ya que la fiscalía en esta instancia debe demostrar que hizo oportunamente todo lo que tenía que hacer, que no omitió ninguna diligencia relevante, y que los elementos que faltan ya fueron solicitados y se está aguardando el resultado. Por ejemplo, si se ordena un peritaje balístico, es frecuente que el dictamen llegue algún tiempo después: ello no impedirá sostener provisionalmente, con base en otros elementos, que el imputado realizó disparos con un arma de fuego. De igual modo ocurre con los peritajes psicológicos, o con los testimonios especiales que se reciben mediante cámara Gesell.

- En definitiva, la fiscalía no afirmará que el imputado es culpable. Lo que corresponderá afirmar es que, *al concluir la investigación en curso, estará en condiciones de formular acusación y solicitar la apertura del juicio oral*. Esta “promesa de acusación” es lo que fundamenta que el fiscal deba solicitar la medida coercitiva. Lo demás quedará para otro momento y con otros jueces.

Necesidad de la medida

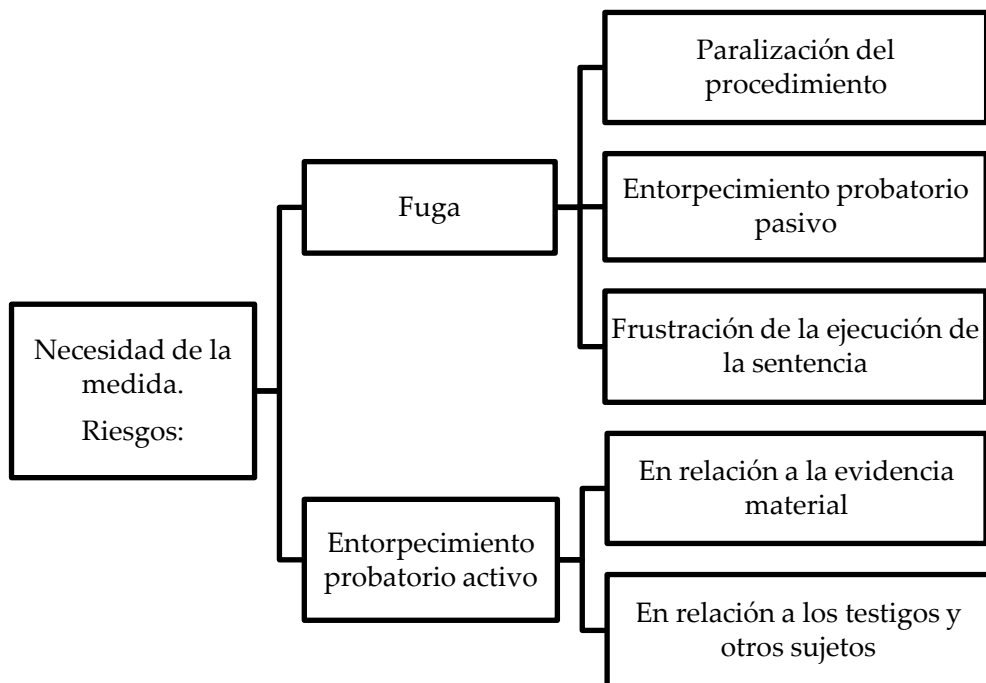
§ 239. Como se ha adelantado, esta flexibilidad del estándar cognoscitivo del supuesto material se compensa con el expreso requerimiento de *acreditar la necesidad de la medida*. Esta exigencia es central en los sistemas reformados, e implica la superación del viejo sistema excarcelatorio tabulado, en el que los delitos eran automáticamente “excarcelables” o “no excarcelables” según la escala penal aplicable.

La necesidad de la medida -de cualquier medida coercitiva- se basa en la existencia de una situación de *riesgo para la actividad probatoria o para las pretensiones de las partes* (CPP, 208); sólo con alguno de estos dos riesgos se tiene por configurado un *motivo específico de detención*. Específicamente, y en relación a las medidas coercitivas que afectan la libertad del imputado, estos riesgos pueden desagregarse de la siguiente manera:

- *Riesgo de fuga*. La fuga del imputado durante el proceso es el riesgo procesal más serio, y según el caso puede acarrear la *paralización del procedimiento* (por la prohibición del enjuiciamiento en rebeldía), la *frustración de las medidas probatorias que requieran de la cooperación pasiva del imputado* (por ejemplo, el reconocimiento en rueda o la extracción de fluidos corporales, refiriéndonos a las medidas cuya realización no supone necesi-

riamente el consentimiento del imputado) o la *frustración de la ejecución de la sentencia* (en caso de condena a pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo).

- *Riesgo de entorpecimiento probatorio activo*. Como hipótesis alternativa a la fuga, también existe el riesgo de que el imputado entorpezca activamente (no con su mera ausencia) la obtención de evidencias. Este riesgo tiene dos manifestaciones centrales: la *destrucción, alteración u ocultamiento de evidencia material* (por ejemplo: borrar rastros, destruir documentos) y el *contacto indebido con testigos* (por ejemplo: amenazas, sobornos o presiones de cualquier tipo), expresión que en sentido amplio abarca a testigos, testigos expertos, peritos, coimputados y hasta a los propios funcionarios que intervienen en el proceso.



¿Qué riesgos justifican el dictado de una medida coercitiva?

§ 240. Mucho se ha debatido acerca de qué riesgos deben admitirse como motivo o justificación para el dictado de medidas coercitivas. Centralmente, son dos los principales focos de discusión: la problematización de los motivos jurídicamente aceptados (riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento probatorio) y la postulación de otros motivos como legítimos (peligrosidad o riesgo de reiteración delictiva, alarma social).

Los *motivos jurídicamente aceptados* (riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio) han sido impugnados desde posiciones abolicionistas o garantistas. Así, se ha señalado, respecto del *riesgo de fuga*, el contrasentido que implica privar de libertad al imputado con el argumento de que ello es necesario para garantizarle su derecho de defensa en juicio (con lo cual estaría preso por su propio bien). Frente a esta argumentación perversa, doctrinariamente se ha propuesto aceptar el juicio penal en rebeldía.

Más problemático resulta el *riesgo de entorpecimiento probatorio*. El peligro de *destrucción, alteración u ocultamiento de evidencia material* puede justificar, a lo sumo, el arresto por un breve período, hasta tanto pueda montarse un perímetro y recolectarse la evidencia. Cumplidas esas actividades, se supone que la evidencia quedará bajo custodia y las huellas y rastros ya habrán sido levantados, con lo cual el imputado poco podrá tendrá para entorpecer. Por otra parte, el peligro de que el imputado establezca un *contacto indebido con testigos, peritos u otros sujetos* puede ser sumamente serio, y sin duda lo es cuando han mediado ofrecimientos desleales, amenazas o cualquier tipo de acercamiento violento. Ahora bien, también es cierto que los testimonios pueden asegurarse mediante el instituto del *anticipo jurisdiccional de prueba* (CPP, 298), lo cual tornaría innecesaria la privación cautelar de libertad. En todo caso, cabría considerar que el riesgo de entorpecimiento podría ser un justificativo válido sólo por un breve lapso, luego del cual la carga de asegurar la prueba pesaría sobre la fiscalía exclusivamente.

También se ha cuestionado la invocación de *riesgos mixtos, de fuga y entorpecimiento probatorio en forma conjunta*. Si bien esta posibilidad no está expresamente excluida, estos planteos deben hacerse con mucha prudencia, ya que siempre generan la posibilidad de caer en una contradicción insalvable: después de todo, si el imputado planea fugarse, ¿es probable que amenace a los testigos? Y al revés: si el imputado cuenta con buenas posibilidades de hacer desaparecer la prueba material, ¿por qué querría fugarse? ¿No le convendría comparecer a juicio y aprovechar la falta de prueba en su contra? Por supuesto que siempre podrá haber casos de excepción, pero ello no impide advertir que,

como pauta general, es poco estratégico -y poco serio- *alegar de todo o alegar por si las dudas*.

§ 241. Hasta aquí se ha hecho referencia a los riesgos procesales usualmente admitidos (fuga y entorpecimiento probatorio), como derivación del llamado *principio de instrumentalidad*. Sin embargo, de manera cíclica asistimos a intentos de instalar como motivos válidos de detención la peligrosidad del imputado, el riesgo de reiteración delictiva, y hasta la alarma social provocada por el hecho. No sólo en un sentido instrumental con respecto a motivos legítimos de detención (por ejemplo, planteando que por la enorme repercusión social del hecho el imputado tendría buenos motivos para fugarse), sino instituyendo estas circunstancias como motivos de detención autónomos, sin relación alguna con la fuga o el entorpecimiento probatorio.

- El *riesgo de reiteración delictiva* implicaría que muy probablemente el imputado, en caso de quedar en libertad durante el proceso, continuará con su actividad delictiva. Este motivo habla de una cierta habitualidad en el delito, que autorizaría a suponer futuras reincidencias.
- La *peligrosidad* implica también cierto riesgo de reiteración, aunque aludiendo particularmente a la figura de quien realiza comportamientos antisociales de manera morbosa o compulsiva, o a causa de una predisposición innata.
- La *alarma social* es un estado de conmoción pública, frecuentemente asociado a hechos que por su gravedad o por las características de los intervinientes provocan una gran movilización de la sensibilidad colectiva. Este estado de conmoción frecuentemente es visibilizado y amplificado por mensajes que se replican de manera estandarizada en los medios de comunicación masiva, contribuyendo al aumento de la inseguridad en sentido subjetivo (sensación de inseguridad).

La admisión de estos riesgos como motivos de detención presenta serios reparos desde el punto de vista constitucional, en cuanto implican la prosecución de fines ajenos a los del proceso mismo: prevención especial (evitación de la reiteración delictiva) o prevención general positiva (restablecimiento de la confianza social). En cuanto se fundamente la medida coercitiva en fines propios de la pena misma, se estará ante un anticipo de pena, violatorio de los principios de inocencia y juicio previo. Esto ha sido advertido por la jurisprudencia interamericana, que ha rechazado expresamente la postura sustancialista en el precedente “Suárez Rosero contra Ecuador” (Corte IDH, 1997).

Esto debería llevar a problematizar *incluso las medidas no privativas de libertad que explícitamente persiguen estos fines*, o lo que es lo mismo, que resultan

notoriamente inidóneas para asegurar los fines del proceso. Como ejemplos, en nuestro código se prevé la *cesación provisoria del estado antijurídico* (CPP, 207), la *inhabilitación provisoria para conducir automotores* (CPP, 208 bis), el *abandono del domicilio* (CPP, 219.4) y la *prohibición de tenencia de armas de fuego y de portación de armas de cualquier tipo* (CPP, 219.5). Como posible argumentos legitimadores, suelen esgrimirse la *aceptación del imputado* (cuando la medida opera como alternativa a la prisión preventiva) o la *distinta naturaleza de la medida* (se trataría, en algunos casos, de medidas innovativas o autosatisfactivas, o bien de medidas de coacción directa ante el delito en curso).

c) Medidas no privativas de libertad y medidas de atenuación

Nociones generales

§ 242. Hasta aquí se ha expuesto la problemática de las medidas de coerción haciendo especial referencia a la más gravosa de dichas medidas, que es la prisión preventiva o privación cautelar de la libertad ambulatoria. La posterior evolución legislativa, principalmente en los sistemas mixtos y acusatorios formales, fue generando una batería de medidas alternativas a la prisión preventiva, lo cual permitió cierta atenuación del sistema. Dichas medidas se planteaban inicialmente como *sustitutivas de la prisión preventiva*, lo que daba a entender que conceptualmente la prisión preventiva seguía siendo tomada como una suerte de regla general.

Actualmente, se ha llegado a la idea inversa, plasmada en el *principio de gradualidad de la coerción procesal*: se debe partir de considerar las medidas menos gravosas, e ir aumentando escalonadamente la intensidad según la estricta medida de la necesidad de cautela. Sin embargo, en Santa Fe esta gradualidad no se plasma en un catálogo único de medidas de intensidad creciente (como ocurre, por ejemplo, en el CPP Federal, 210), sino que se prevén separadamente dos catálogos de medidas de menor impacto: por un lado se regulan las *medidas no privativas de libertad* (CPP, 219), y por separado se prevén medidas de *atenuación de la coerción* (CPP, 222).

Diferenciación legal

Según el artículo 219, las medidas no privativas de libertad serían:

- La obligación de someterse al cuidado de una persona o institución (CPP, 219.1).
- La presentación periódica ante la autoridad (CPP, 219.2).
- La prohibición de salir de un ámbito determinado, o de concurrir a determinados lugares, o de mantener contacto con determinadas personas (CPP, 219.3).
- El abandono del domicilio (CPP, 219.4).
- La prohibición de tenencia de armas de fuego y de portación de armas de cualquier tipo (CPP, 219.5).
- La caución patrimonial (CPP, 219.6).
- La vigilancia electrónica (CPP, 219.7).
- La promesa de someterse al proceso penal (CPP, 219.8).

Por otra parte, el artículo 222 regula los siguientes casos de atenuación:

- La prisión domiciliaria (222.1).
- La prisión con salida diaria laboral y/o salida periódica para afianzar vínculos familiares (222.2).
- El ingreso del imputado a una institución educadora o terapéutica (222.3).

§ 243. Esta distinción legislativa entre medidas no privativas de libertad y medidas de atenuación presenta como ventaja una cierta facilidad en el deslinde conceptual entre una y otra especie de medidas coercitivas. Deslinde que tiene una clarísima consecuencia práctica, ya que sólo la prisión preventiva y su atenuación computan como cumplimiento de una eventual pena de prisión (CP, 24), y ello no ocurre con las medidas no privativas de libertad. Dicho de otra manera, el legislador considera que *todas las medidas previstas en el artículo 222 deben ser tratadas como una situación de encierro, y las del artículo 219 deben ser tratadas como una situación de libertad ambulatoria.*

Zonas grises y medidas combinadas o híbridas

§ 244. Lamentablemente, este esfuerzo diferenciador no impide que puedan existir zonas grises o situaciones ambiguas. Por ejemplo, una medida de no salir del ámbito territorial de una o dos manzanas, o de un pequeño paraje (CPP, 219.3), en algunos contextos puede equivaler a una prisión domiciliaria (CPP, 222.1). Y más aún: ciertamente no es lo mismo cumplir prisión domiciliaria en una mansión con piscina y cancha de golf (hubo casos muy cercanos a esta descripción), que en una pequeña vivienda precaria. Realizar una subsun-

ción ingenua, sin considerar las particularidades de cada situación concreta, puede contribuir a exacerbar el rasgo selectivo y clasista del sistema penal.

En cualquier caso, debe recordarse que los artículos 219 y 222 no prevén una enumeración taxativa de las medidas de coerción. Por lo que debe considerarse viable plantear medidas no previstas expresamente, o aplicar varias medidas del artículo 219 en forma conjunta. No ocurre lo mismo con el artículo 222, ya que las medidas de atenuación, por su propia naturaleza, no lucen acumulables entre sí. Sí es posible combinar medidas de ambas normas, es decir, reforzar la medida atenuada con alguno de los deberes o prohibiciones del artículo 219 (aunque esta posibilidad en algunos casos es resistida).

Como desprendimiento del carácter no taxativo del listado de medidas coercitivas, las mismas son de interpretación amplia, pudiendo ser flexibilizadas para adaptarse a la entidad del riesgo procesal que se intenta minimizar.

§ 245. Finalmente, debe aclararse que la *vigilancia electrónica* (CPP, 219.7) *no es una medida autónoma, sino un recurso técnico*. Como tal, puede ser adicionado como complemento a cualquier medida coercitiva (ya sea no privativa de libertad o de atenuación de la coerción). Es más: si el dispositivo depende de la red de telefonía fija (hay también con tecnología celular), lo más lógico es que complemente a una medida de prisión domiciliaria (CPP, 222.1). Su ubicación en el catálogo de medidas no privativas de libertad es sencillamente un error de técnica, que debe ser corregido por vía interpretativa.

d) Procedimiento y medidas coercitivas previas

Requisitos formales

§ 246. Las medidas coercitivas sobre el imputado se imponen por resolución judicial, previa audiencia contradictoria (CPP, 224). Esta instancia está supeditada a los siguientes requisitos formales:

- Debe *haberse celebrado audiencia imputativa* (CPP, 274), ya sea en instancia separada o como un primer momento dentro de la misma audiencia de medidas coercitivas. Esto tiene que ver con que la formalización de la imputación servirá para cumplir con el supuesto material de la medida solicitada, y además será la base para establecer la gravedad de la pena en expectativa a los efectos de evaluar la necesidad de la medida.

- Debe haber *solicitud del acusador* (CPP, 223), en concordancia con el principio acusatorio formal, que veda como regla la aplicación oficiosa de medidas de coerción.

Detención

§ 247. El carácter contradictorio de la audiencia resulta problemático cuando se trata de medidas coercitivas urgentes o cautelares, ya que el aviso previo al imputado podría desencadenar la fuga, precisamente el evento que intenta evitarse. Para sortear esta dificultad, nuestro sistema autoriza a la fiscalía a ordenar la *detención del imputado* (CPP, 214), al solo efecto de lograr su presentación y garantizar la aplicación de medidas coercitivas de mayor duración. De esta forma, la detención opera como una suerte de medida cautelar de la medida cautelar, ya que se despacha para garantizar la efectiva posibilidad de aplicar la prisión preventiva u otra medida restrictiva de la libertad.

En otros sistemas, la orden de detención es despachada por el tribunal a solicitud de la fiscalía (por ejemplo: CPP Federal, 215; CPP Entre Ríos, 340), lo que aparece como más respetuoso de la distinción entre los roles requirente y decisorio (principio acusatorio formal). Sin embargo, entre nosotros la facultad de detención por parte de la fiscalía fue avalada por la jurisprudencia, tomándose en cuenta que dicho organismo está regido por el principio de objetividad, y siempre que se habilite en un breve lapso la revisión judicial de la medida (fallo “Ramírez”, CSJSFe, 2015).

§ 248. La orden de detención debe ser escrita, pudiendo adelantarse verbalmente en casos de urgencia (CPP, 217). Como mínimo, debe contener:

- Los datos identificatorios del imputado.
- La descripción sintética del hecho que la motiva.
- La indicación de hacer efectiva o no la incomunicación.
- La indicación del juez a cuya disposición debe ponerse al detenido.

La puesta a disposición mencionada en último término se cumple con la simple indicación del colegio de jueces u oficina de gestión judicial competente, ya que la fiscalía no podría saber de antemano a qué magistrado le tocará intervenir. La redacción de la norma ha quedado algo anticuada, en virtud del abandono del viejo sistema de turnos rígidos y su reemplazo por nuevos mecanismos de división del trabajo (ley 13.018, 23).

§ 249. En lo sustancial, la detención está sujeta a los mismos requisitos que la prisión preventiva y la coerción personal en general, con alguna adaptación al hecho de encontrarnos en los momentos iniciales del proceso:

- El *supuesto material* se considera cumplido cuando los elementos reunidos en la investigación autorizaran a la fiscalía a formalizar audiencia imputativa.
- La *necesidad de cautela* se considera verificada cuando existan riesgos de que el imputado no se someterá al proceso, o riesgo de entorpecimiento probatorio.

§ 250. La detención es, por su propia finalidad, una privación de libertad de corta duración. Cesa en los siguientes casos:

- Por *orden de la fiscalía*, que puede dictarse hasta el momento en que el detenido fuera presentado ante el tribunal (CPP, 218). A partir de ese momento, su libertad sólo podrá ser ordenada judicialmente.
- Por *orden del tribunal*, en ocasión de la audiencia de solicitud de medidas coercitivas (CPP, 224), ya sea por la liberación del imputado o por el dictado de otra medida (dicho de otro modo, la prisión preventiva *cambia el título de la privación de libertad*, por lo que la detención se extingue como tal).
- Por *mora judicial*, en tres supuestos: por no haberse realizado la audiencia imputativa dentro del plazo de setenta y dos horas -que el tribunal puede prorrogar por veinticuatro horas más- desde la privación inicial de la libertad; por no solicitar la audiencia de medidas coercitivas una vez finalizada la audiencia imputativa; y por no realizarse la audiencia de medidas coercitivas dentro del plazo de setenta y dos horas -que el tribunal puede prorrogar por veinticuatro horas más- desde la solicitud (CPP, 274). En cualquiera de estos casos la inactividad judicial, dentro de los plazos o en las ocasiones explicadas, abre la posibilidad de interponer hábeas corpus en procura de la liberación inmediata de la persona detenida (CPP, 223).

Se ha objetado la constitucionalidad del plazo ordinario de setenta y dos horas, por considerarse que incumple con el estándar de *presentación sin demora del detenido ante un tribunal* (CADH, 7.5, 7.6). Por el momento, la Corte Suprema provincial ha evitado expedirse sobre el particular (ver caso “Torres”, CSJSFe, 2020; con la notable disidencia del ministro Erbetta, quien ingresando al fondo de la cuestión propone la inconstitucionalidad de aquel plazo).

Control jurisdiccional de la detención

§ 251. La detención, por ser una medida sumamente gravosa en cuanto implica la privación de la libertad ambulatoria (aún por un lapso relativamente breve), está sujeta a control por parte del tribunal dentro de un plazo relativamente breve. Dos son las cuestiones a controlar:

- *La concurrencia de los supuestos habilitantes de la detención*, cuestión que es propia de los sistemas que habilitan a la fiscalía a detener (en los sistemas judicialistas que hemos mencionado, se supone que el tribunal ya verificó estos extremos al momento de despachar la medida).
- *Las condiciones materiales de cumplimiento de la detención*. Este punto, que debería considerarse un estándar en todos los sistemas, refiere a cuestiones básicas como la identificación de la autoridad que efectuó la detención (o en su caso, la previa aprehensión), el lugar donde la persona estuvo alojada, el trato dispensado por el personal policial, si le fueron comunicados sus derechos y si recibió asistencia letrada.

En nuestro sistema, el control de detención no genera una audiencia propia y específica, sino que es una de las actividades que se cumplen *en el marco de la audiencia imputativa en sede judicial* (CPP, 274). Tampoco se regulan las cuestiones a controlar, ni se establecen consecuencias puntuales en caso de detención ilegal, todo lo cual debe ser construido judicialmente. Sería bastante claro que la ilegalidad de la detención por *falta de concurrencia de los supuestos habilitantes* (primera cuestión) debería acarrear la inmediata libertad del imputado. Por otra parte, ante *irregularidades en las condiciones de cumplimiento* (segunda cuestión) debería evaluarse de manera sumamente restrictiva cualquier eventual pretensión coercitiva por parte de la fiscalía.

Cuestiones problemáticas

§ 252. Hemos planteado que el fundamento de la detención es, principalmente, el riesgo de que el imputado se fugue y no comparezca voluntariamente a la audiencia de solicitud de medidas coercitivas. La detención funcionaría como una especie de *cautelar de la cautelar*, en relación a la prisión preventiva u otras medidas de mayor alcance. Esta idea amerita algunas precisiones:

- Nada impide a la fiscalía solicitar medidas coercitivas contra una persona que ha comparecido a la audiencia en estado de libertad. Eso sí, la defensa contará con una clara ventaja argumentativa cuando se discuta si

hay o no peligro de fuga (la presentación voluntaria del imputado será un elemento no menor para negar la existencia de este peligro).

- Por una cuestión de proporcionalidad, la detención tiene sentido como medida previa a la solicitud de prisión preventiva o medida de intensidad equivalente (222.2-3). En principio, la posibilidad de que se imponga una medida no privativa de libertad (y aún de la prisión domiciliaria) no constituye un gran incentivo para fugarse.
- Ahora bien, si se va a solicitar prisión preventiva, es porque se invocará un peligro procesal de gran intensidad, no evitable razonablemente por otro medio. En este escenario, no ordenar la detención luce como una total incoherencia: si existe riesgo de fuga, tal como la fiscalía va a sostener, ¿por qué darle al imputado la posibilidad de que efectivamente se fugue? Sin perjuicio de esto, debe señalarse que se han dado casos de solicitud de prisión preventiva sin detención previa (fallos “Ponce Asahad”, del 4-8-2020, y “Serjal”, del 11-8-2020, ambos del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario; aunque se trata de casos que pueden considerarse excepcionales y difícilmente permitan una comparación válida).

Aprehensión

§ 253. Por las mismas razones que fundamentan la necesidad de la detención como medida coercitiva previa (cautelar de la cautelar), existen casos que habilitan una medida previa a la detención: la *aprehensión*.

La aprehensión es una privación de libertad efímera, a punto tal que no tiene plazo regulado en días u horas. La autoridad policial deberá aprehender a quien sorprenda en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública, y en la misma situación, cualquier persona puede practicar la aprehensión entregando *inmediatamente* el aprehendido a la policía. En cualquiera de los dos casos, la autoridad policial deberá dar aviso *sin dilación alguna* a la fiscalía, quien decidirá el cese de la aprehensión o dispondrá la detención si fuera procedente (CPP, 212). Para el particular, pesa el deber de entrega inmediata del aprehendido. Para la policía, el deber de avisar sin dilación a la fiscalía. Cumplido dicho aviso, el fiscal actuante debe decidir y comunicar en ese mismo acto (es decir, al responder el llamado del personal policial) si ordena la detención o si debe liberarse al aprehendido. No está permitido que el fiscal posponga dicha decisión, o la supedita al avance de la investigación: se trata de un esquema binario, en el que debe decidirse o una cosa o la otra.

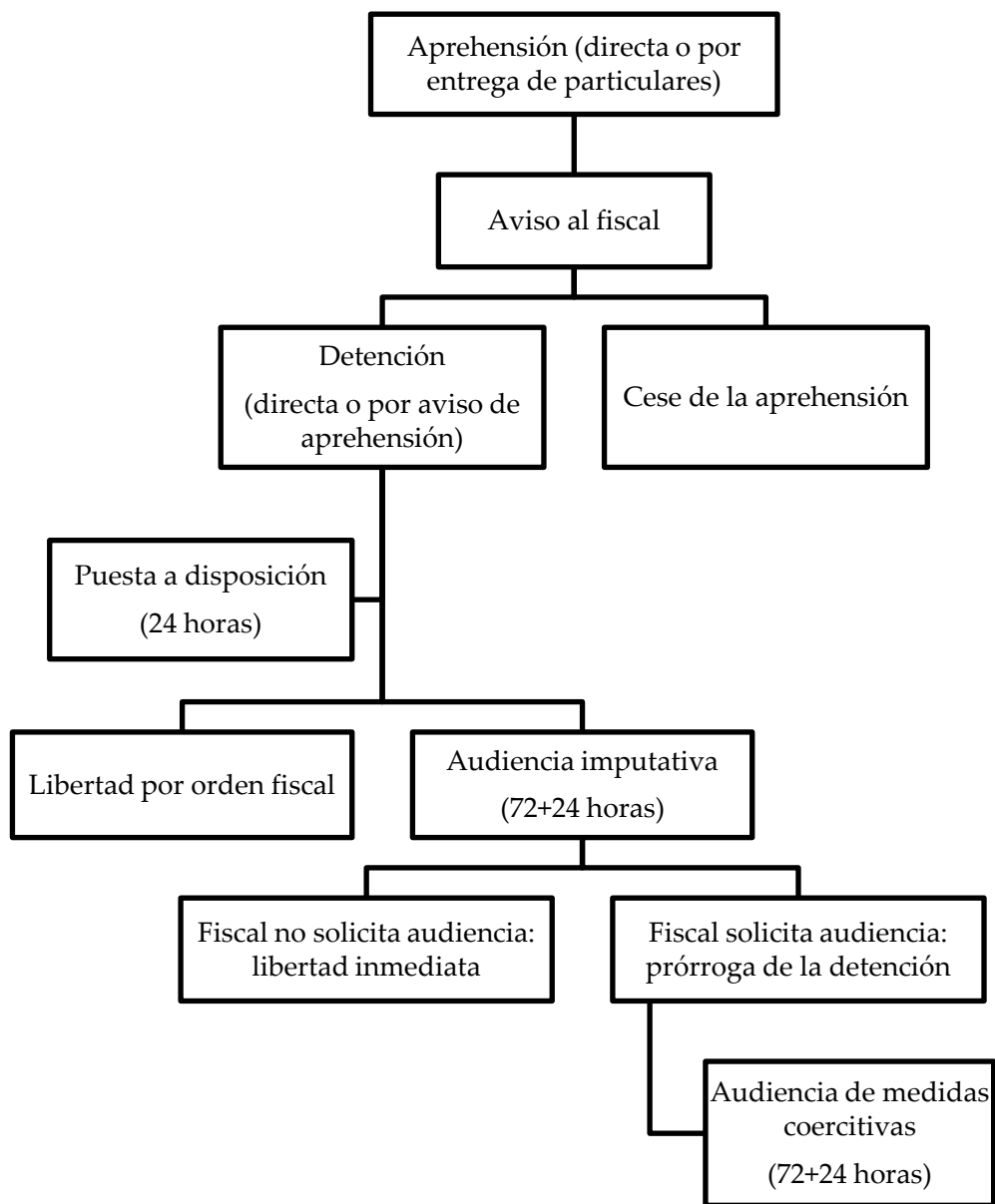
§ 254. A los efectos de la aprehensión, se considera que existe flagrancia en los siguientes casos:

- Cuando la persona fuera sorprendida en el momento de intentar o de cometer el hecho (supuesto de *flagrancia* en sentido estricto).
- Cuando fuera perseguida inmediatamente después de su comisión (supuesto de *cuasiflagrancia*).
- Cuando tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran presumir que acaba de participar en el mismo (supuesto de *flagrancia ficta*).

Cabe destacar que la aprehensión marca el inicio de la privación de libertad del imputado, a los efectos del plazo dentro del cual debe celebrarse la audiencia imputativa (CPP, 274). De no haber aprehensión previa, dicho plazo comenzará a correr una vez efectivizada directamente la detención.

Exposición esquemática

§ 255. Sintetizando los pasos previos a la audiencia de medidas coercitivas, podría formularse el siguiente esquema:



Actuación de la fiscalía en la audiencia de medidas coercitivas

§ 256. Ya en oportunidad de la audiencia de solicitud de medidas coercitivas (aunque recordemos que dicha solicitud puede tener lugar en la misma audiencia imputativa), la fiscalía intentará acreditar los extremos que hacen a su pretensión cautelar: supuesto material y necesidad de cautela. Hemos visto que en principio el supuesto material se verifica argumentativamente, con la descripción de los aspectos relevantes de la imputación y con la enumeración de los principales elementos de convicción con los que se cuenta hasta el momento.

En cuanto a la necesidad de cautela, debe acreditarse la situación objetiva de *riesgo*, ya sea de fuga o de entorpecimiento probatorio. Ahora bien, este riesgo es algo difícil de probar categóricamente, ya que en sí mismo no es otra cosa que una cierta expectativa sobre el comportamiento futuro del imputado. De ahí que en los sistemas reformados la acreditación del riesgo procesal se asiente sobre tres pilares fundamentales: las *pautas normativas*, la *prueba preconstituida* y la *inserción argumental*.

- ***Pautas normativas.*** Los propios códigos han traído siempre algún catálogo de factores de riesgo. Esto es perfectamente válido, a condición de que se entienda que se trata de pautas meramente orientativas, y nunca pueden operar como presunciones absolutas en desmedro de la libertad del imputado. En el código de Santa Fe, se prevén como pautas *la magnitud de la pena en expectativa, la importancia del daño a resarcir y la actitud que el imputado adoptara voluntariamente frente a él, la conducta procesal del imputado, la violación de medidas coercitivas previas, la rebeldía y la conducta esquivada, la falta de arraigo y la ausencia de residencia fija* (CPP, 221.1-7). Se advierte a simple vista que el catálogo es algo reiterativo (por ejemplo: la importancia del daño a resarcir influye en la magnitud de la pena en expectativa; la violación de medidas coercitivas y la rebeldía son manifestaciones puntuales de la conducta procesal del imputado), y hasta podría decirse que *los factores decisivos terminan siendo la pena en expectativa, la conducta procesal y el nivel de arraigo*.
- ***Prueba preconstituida.*** La práctica de otros sistemas reformados fue evidenciando la necesidad de contar con *prueba preconstituida* sobre aspectos considerados generalmente relevantes, tales como los antecedentes penales del imputado, su situación social y familiar o su comportamiento procesal previo. Esta práctica dio lugar a la creación de agencias especializadas -usualmente llamadas *oficinas de servicios de antelación al juicio*-,

encargadas de producir estos informes de manera estandarizada y de entregarlos a las partes antes de la audiencia de solicitud de medidas.

- ***Inserción argumental.*** Ahora bien, todos los elementos probatorios con los que se pudiera contar *no tienen en general un valor autosuficiente o concluyente*. Por el contrario, es necesario que las partes enmarquen esos datos en el contexto de una argumentación, a favor o en contra de la existencia de riesgo procesal. Por ejemplo: el hecho de que el imputado haya tenido un proceso anterior puede ser tomado como algo desfavorable; sin embargo, podría alegarse en su favor que siempre respetó las reglas de conducta que le fueron impuestas. El hecho de carecer el imputado de vínculos sociales y de medios económicos suele ser tomado como un factor de riesgo; ahora bien, eso también significa que tendrá menos recursos -como dinero y contactos en otros lugares- para darse a la fuga. Incluso el hecho de que la imputación sea muy grave puede ser contrarrestado con la presentación espontánea ante la autoridad. Todo se trata de presentar un argumento convincente y sustentado en los elementos de acreditación con los que hasta el momento se cuente.

Cabe aclarar que la audiencia de medidas coercitivas, al igual que ocurre en general con las audiencias previas al juicio, es eminentemente argumentativa y no probatoria. Los elementos de convicción que eventualmente deban utilizarse pueden ser presentados directamente al tribunal, sin que sea necesario (ni recomendable) su introducción por testigos como ocurre durante el juicio oral. Esto es válido tanto para los informes estandarizados (haya o no oficinas de servicios de antelación) como para el resto de los elementos que pudieran surgir de la investigación, tales como actas policiales (el acta donde consta que el imputado, al momento de ser detenido, dio un nombre falso o intentó darse a la fuga), objetos secuestrados (un sobre con pasajes al exterior y moneda extranjera) o comunicaciones interceptadas (mensajes de texto con amenazas a los testigos). Asimismo, la prueba testimonial debería quedar reservada para casos excepcionales y siempre que el dato a aportar por el testigo se considere esencial para resolver sobre la medida coercitiva. Como regla, debería bastar con la simple presentación de objetos, documentos e informes.

Posibles estrategias defensivas

§ 257. La estrategia de la defensa ante la solicitud de medidas coercitivas puede girar en torno a las siguientes alternativas:

- *Controvertir el supuesto material*, para lo cual deberá analizarse la solidez de los elementos de cargo listados durante la audiencia imputativa. El lado negativo de esta opción es que invita a la fiscalía a explayarse no tanto sobre el riesgo procesal *sino sobre la culpabilidad del imputado*, generando una mala predisposición en el tribunal.
- También puede *negarse la existencia del riesgo procesal* invocado por el acusador, señalando puntualmente los factores que abonen un grado fuerte de arraigo social y familiar (trabajo estable, contención por parte de su familia) o que atenúen la pena en expectativa (falta de condenas previas, viabilidad de una calificación jurídica más leve).
- Como un desprendimiento del punto anterior, también puede plantearse la *aplicación de una medida de menor intensidad* (ya sea no privativa de libertad o de atenuación), lo que implica admitir -o al menos, no negar- algún grado de riesgo procesal, aunque sea de menor intensidad.
- Es frecuente que en algunos casos directamente no quepa oponerse abiertamente, ni siquiera a la prisión preventiva. En este escenario, una estrategia posible es admitir momentáneamente la pretensión cautelar, *pero solicitando al tribunal que fije un plazo de duración de la medida*. Esta posibilidad resulta muy útil en casos graves y con prueba contundente (en los que la prisión preventiva luce inevitable), ya que impulsa a la fiscalía a agilizar la investigación y evita la prolongación innecesaria del encarcelamiento preventivo.
- Como último recurso, también es posible *aceptar la imposición de la prisión preventiva sin plazo*, a la espera de nuevos elementos que permitan plantear la revisión de la medida.

La decisión sobre cómo responder defensivamente a la solicitud de medidas requiere de un cuidadoso análisis del caso. También deberá cuidarse de no incurrir en contradicciones argumentativas insalvables, como cuando se sostiene la inexistencia de riesgo procesal y a continuación se pide una medida no privativa de libertad (que presupone algún nivel de riesgo).

También es posible que las partes acuerden previamente sus pretensiones, llegando a la audiencia con un *acuerdo cautelar*, aunque sea provisional. La práctica del acuerdo cautelar es particularmente frecuente cuando se trata de medidas no privativas de libertad, o de medidas atenuadas.

Rol del tribunal

§ 258. El tribunal debe resolver la cuestión en la misma audiencia. Como en todas las audiencias previas al juicio, le está permitido interactuar abiertamente con las partes, y hasta instar algún tipo de acuerdo.

Como derivación del principio acusatorio formal, queda vedado al tribunal aplicar medidas coercitivas de oficio, como también aplicar medidas más gravosas que las solicitadas por la partes. Las previsiones legales que habilitan la actuación oficiosa (CPP, 219, 222) deben ser interpretadas en el marco de la facultad judicial de aplicar medidas más leves a las solicitadas. Es decir, la solicitud del acusador fija el techo o tope máximo de coerción posible de resolver, y de ahí hacia abajo es posible aplicar toda la gama de medidas de menor intensidad, ya que la coerción reconoce grados y no hay por qué obligar al tribunal a optar por las pretensiones extremas (por ejemplo, aplicar prisión preventiva u ordenar la libertad lisa y llana). No estaríamos ante un supuesto de *coerción de oficio*, sino de *atenuación o sustitución de oficio* de una coerción efectivamente solicitada.

e) Vicisitudes de las medidas coercitivas

§ 259. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad están sujetas a *revisión, cesación y revocación*.

Revisión

§ 260. Atento a su carácter eminentemente provisional, las medidas coercitivas pueden ser *revisadas* por la misma la misma instancia que la ordenó, en los siguientes supuestos:

- ***Por acuerdo de partes*** (CPP, 225, primer párrafo), cuando se solicitara de manera conjunta atenuar o dejar sin efecto la medida impuesta. El acuerdo está sujeto a control judicial de legalidad, pudiendo resolverse sin audiencia.
- ***Por elementos probatorios sobrevinientes*** (CPP, 225, segundo párrafo), pudiendo agravarse o atenuarse la situación cautelar del imputado, a pedido de parte y previa audiencia.

- **Por el paso del tiempo** (CPP, 225, tercer párrafo). Cuando ésta fuera la única causal de revisión invocada, se exige un plazo de noventa días entre ambas audiencias.

La revisión de las medidas coercitivas puede tener lugar en cualquier momento procesal, previéndose específicamente que esto pueda ocurrir durante el procedimiento intermedio (CPP, 297.7).

Cesación

§ 261. La *cesación* de la prisión preventiva opera en los siguientes supuestos:

- **Por desproporción relativa.** Cuando su duración no guardara proporcionalidad con lapso de encarcelamiento efectivo que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena (CPP, 227.1). Esto exige cotejar la escala penal aplicable en cada caso, en relación a los plazos para obtener libertad condicional y libertad asistida (CP, 13; ley 24.660, 54). En particular, la cesación por esta causal es frecuente en delitos conminados con penas de hasta tres años de prisión, que permiten la liberación a los ocho meses.
- **Por desproporción absoluta.** Cuando hubieran transcurrido dos años (CPP, 227.2), plazo que la Cámara de Apelaciones puede prorrogar hasta por un año más a solicitud de la fiscalía (esta prórroga suele denominarse *extensión extraordinaria*). Este supuesto de cesación no rige habiendo sentencia condenatoria, aunque la misma no estuviera firme.

§ 262. También las medidas no privativas de libertad (CPP, 219) y las medidas atenuadas (CPP, 222) cesan en estos dos supuestos, debiendo realizarse los cálculos de la misma forma que con la prisión preventiva (CPP, 228). Con la particularidad de que en este caso el cese opera de pleno derecho, sin necesidad de resolución judicial.

Aunque el código no lo aclare expresamente, la equiparación del artículo 228 también debería acarrear el cese de la coerción cuando dentro de los plazos de cada supuesto se suceden distintas medidas (por ejemplo, ocho meses de prisión preventiva y dieciséis meses de prisión domiciliaria).

f) Otras medidas que afectan la libertad de las personas

§ 263. Ya hemos visto que existen medidas privativas de libertad de corta duración, como la aprehensión y la detención, que funcionalmente operan para asegurar la ejecución de medidas más duraderas como la prisión preventiva.

En esa tónica, existen otras medidas coercitivas que *limitan, restringen o condicionan* la libertad de las personas. Se trata también de medidas de corta duración, que se dictan para tutelar fines determinados y específicos.

Incomunicación

§ 264. Como medida accesoria, la fiscalía puede ordenar la *incomunicación* de la persona detenida (CPP, 215). La incomunicación cesa automáticamente una vez celebrada la audiencia imputativa, o vencido el plazo máximo previsto para su celebración. Como estos plazos han sido reformados y ahora es posible que la audiencia imputativa tenga lugar hasta noventa y seis horas después de la detención, debe recordarse que la Constitución Provincial limita la incomunicación a cuarenta y ocho horas, salvo prórroga por auto motivado del juez (CSFe, 9, tercer párrafo).

El código aclara que en ningún caso la incomunicación del detenido impedirá que éste se comunique con su defensor, en forma privada, inmediatamente antes de comenzar su declaración o antes de cualquier acto que requiera su intervención personal (CPP, 216). En rigor, y siguiendo a la práctica totalidad de la doctrina contemporánea, lo correcto es decir que *la incomunicación no rige para el defensor*.

También puede ordenarse la incomunicación, en forma autónoma, para que los testigos no se comuniquen entre sí ni con terceras personas antes de su declaración (CPP, 180).

Citación

§ 265. La *citación* se ordena cuando resulta necesaria la presencia del imputado, y no corresponde ordenar su detención por no existir riesgo procesal (CPP, 210). La presentación requerida puede tener por finalidad la identificación policial, la notificación de derechos o la celebración de audiencia imputativa en estado de libertad. También se libra citación a los testigos, como a toda persona convocada al proceso de forma obligatoria.

En todo caso, cabe aclarar que la citación conlleva el *apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública* (CPP, 150). De allí su carácter coercitivo, en cuanto implica una amenaza de privación de libertad.

Arresto

§ 266. El *arresto* (CPP, 211), por un plazo de hasta veinticuatro horas, puede ser dispuesto para individualizar a los presuntos responsables y a los testigos, en los primeros momentos de la investigación. Aunque no se indica expresamente, puede ser dispuesto por la autoridad policial, con conocimiento inmediato al fiscal.

El arresto puede ser individual o colectivo, y usualmente tiene lugar en situaciones de tumulto o pluralidad de personas. Cesa aún antes del plazo previsto, una vez identificada la persona arrestada y recabados sus datos de contacto.

Medidas de coerción genérica

§ 267. El código prevé *medidas de coerción genérica*, en cabeza del tribunal y de la fiscalía según el caso. Esto implica que ambos sujetos pueden disponer la intervención de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de sus órdenes y mandatos (CPP, 135).

Ya en el ámbito específico del juicio oral, corresponde al tribunal ejercer el poder de policía y disciplina en la audiencia. Puede disponer del auxilio de la fuerza pública, e incluso está facultado para sancionar en el acto (sin trámite alguno) con hasta diez días multa o arresto de hasta ocho días (no confundir con el arresto previsto en el CPP, 211) las infracciones al orden y seguridad, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala (CPP, 314).

g) Medidas de coerción real

Nociones generales y aplicación supletoria del CPCyC

§ 268. El código prevé un conjunto de medidas coercitivas reales, que recaen sobre cosas o bienes, no sólo de la persona imputada sino también de

terceros. Muchas de ellas (como el embargo, la inhibición general y la inscripción litigiosa) se rigen supletoriamente por la legislación procesal civil, con la particularidad de que se dictan no sólo para asegurar las reparaciones civiles sino también las penas pecuniarias y las costas del proceso.

Decomiso

§ 269. Como innovación, la ley prevé el *decomiso de los efectos y bienes relacionados con la actividad delictiva* (CPP, 239), para lo cual rige un procedimiento especial a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), creada por ley 13.579.

Secuestro de objetos y documentos

§ 270. El *secuestro de objetos y documentos* puede ser dispuesto por la fiscalía, o en caso de urgencia por la policía con aviso inmediato a la fiscalía (CPP, 240).

Están sujetos a secuestro los objetos relacionados con el delito, los que pudieran servir como evidencia y los que estuvieran sujetos a decomiso. Adicionalmente, se prevé el secuestro de todas las armas de fuego que tuviera en su poder la persona denunciada, en los procesos por amenazas, violencia familiar o de género, o en cualquier otro delito derivado de conflictos interpersonales, medida que en rigor no tiene un fin cautelar sino de prevención de nuevos delitos.

Está prohibido el secuestro de documentos que contengan comunicaciones entre el imputado y las personas que deban abstenerse de declarar como testigo, incluyendo las notas que éstos hubieran tomado, como también las documentaciones de exámenes médicos realizados al imputado bajo secreto profesional (CPP, 241).

El secuestro se formaliza mediante acta, a lo cual se agregan los recaudos tendientes a acreditar la cadena de custodia. Estos resguardos, que usualmente están regulados mediante instrucciones generales de la fiscalía, tienden a asegurar la inalterabilidad del objeto secuestrado, a los efectos de su acreditación como evidencia en juicio.

Síntesis del capítulo

1. *Se considera inherente al proceso penal que el tribunal y otros funcionarios tengan la potestad de aplicar medidas coercitivas. En particular, interesan aquellas que afectan o restringen la libertad del imputado, protegida constitucionalmente.*
2. *Dentro de los debates sobre la prisión preventiva, existen posturas sustancialistas y procesalistas (según asimilen o no la prisión preventiva a la pena misma de prisión, principalmente en cuanto a su finalidad), y posturas legitimacionistas y críticas, dando lugar a múltiples entrecruzamientos.*
3. *La prisión preventiva, y en términos más amplios las demás medidas que afectan la libertad del imputado, están sujetas a una serie de principios limitadores, y a dos requisitos esenciales: supuesto material y necesidad de la medida.*
4. *A la par de la prisión preventiva, se prevé una batería de medidas no privativas de libertad, como también la posibilidad de atenuar la coerción. Hay también otras vicisitudes, como la revisión y la cesación.*
5. *El procedimiento para aplicar una medida coercitiva da lugar a una audiencia contradictoria.*
 - a. *Normalmente, habrá pasos previos, que incluyen la detención como medida urgente a cargo del fiscal.*
 - b. *En este caso, se judicializa la audiencia imputativa y se impone al tribunal el deber de controlar la detención.*
6. *Hay otras medidas coercitivas que afectan la libertad de las personas de manera más acotada, y también se prevén medidas de coerción real.*

Capítulo 9. Alternativas al juicio contencioso

a) Las alternativas en la reforma procesal penal

Caracterización general

§ 271. Como se ha visto, la reforma procesal penal ha amplificado los mecanismos tendientes a descongestionar el sistema. Dicho de otro modo, ha ampliado el abanico de alternativas a la resolución mediante juicio oral contencioso.

En su configuración actual, estos mecanismos son herramientas esenciales en el diseño de una política de persecución penal, en varios sentidos:

- En primer lugar, porque disminuyen la carga de trabajo del sistema, liberando recursos y permitiendo direccionar la persecución penal hacia las manifestaciones más graves de criminalidad.
- Permiten priorizar los intereses reales de las víctimas por sobre el interés público en la represión del delito.
- Diversifican la respuesta estatal frente al delito y permiten a las fiscalías constituirse como agentes de pacificación social.
- Permiten liberar a las personas de estar sujetas a persecuciones notoriamente inviables.

Su surgimiento como institutos de excepción

§ 272. La existencia de vías alternativas al proceso penal tuvo manifestaciones parciales en el marco de los antiguos sistemas. Estas manifestaciones eran generalmente tratadas como anomalías o institutos de excepción, frente a lo que se consideraba el modo normal o estándar de desarrollo del proceso: el tránsito secuencial por todas sus etapas hasta el dictado de la sentencia.

Algunas de estas manifestaciones fueron:

- El sobreseimiento.
- La extinción de la acción penal por pago del mínimo de la multa (CP, 64).
- La extinción de la acción penal por pago del tributo evadido (ley 24.769, redacción original).
- La suspensión del juicio a prueba (CP, 76 bis y ss.).
- El procedimiento abreviado.

§ 273. En el marco de los antiguos sistemas, algunos de estos institutos eran explicados como “modos anómalos de terminación del proceso”, o como “obstáculos a la acción penal”, cuando no como “procesos especiales”.

El posterior desarrollo de estas figuras dejó en evidencia el absurdo de querer encasillar esta nueva realidad en las viejas teorías. En efecto, ¿cómo iba a creerse -por ejemplo- que el juicio abreviado era un instituto anómalo o excepcional, cuando hacia la década de 2000 buena parte de las condenas se dictaban de esta forma en las provincias que lo habían regulado?

Las alternativas en el nuevo sistema

§ 274. Hoy en día, en la práctica totalidad de los sistemas reformados se regulan criterios de oportunidad y el procedimiento abreviado. Estos dos institutos, junto con la suspensión del procedimiento a prueba -regulada subsidiariamente en el Código Penal-, absorben la mayor parte de la carga de trabajo de las fiscalías y tribunales. Por ello, resulta incorrecto seguir adjudicándoles una naturaleza anómala, excepcional o residual, y deben pasar a ser consideradas como una de las formas estándar de procesar los conflictos penales, a la par del juicio oral y público.

En este sentido, es de destacar la formulación del profesor Binder, que en su plan de obra traza la distinción entre *juicio compositivo* y *juicio de conocimiento*, como dos formas esenciales del proceso penal. Aunque aún no contamos con el desarrollo integral de esta idea (la obra está siendo publicada por volúmenes), desde ya nos parece una manera mucho más realista de describir cómo opera el proceso penal.

b) Concepto y tipos

Concepto y función genérica

§ 275. En un sentido amplio, se incluyen como salidas alternativas *todos aquellos institutos capaces de provocar una respuesta jurídica al caso penal, sin acudir al juicio contencioso*. Esta función negativa de evitación del juicio es lo que permite englobarlos bajo aquella la denominación común, sin negar las múltiples diferencias que existen entre ellos.

Tipología

§ 276. Si se atiende al rol de los sujetos, se observa que algunos de estos mecanismos dependen preponderantemente de las partes, aunque eventualmente con controles jerárquicos al interior de la fiscalía. Otros habilitan un mayor control por parte del tribunal, y finalmente otros son resueltos por el tribunal con independencia de que exista o no acuerdo.

Algunos consisten básicamente en un desistimiento de la acción penal o en alguna forma de desincriminación anticipada, mientras que otros implican una admisión de culpabilidad y acarrear la posibilidad de condena. En el medio, se ubican aquellos que anulan o suspenden el pronunciamiento de fondo, privilegiando la recomposición de las situaciones conflictivas. Esta clasificación, si bien presenta algún flanco para la crítica (presenta muy benignamente los mecanismos compositivos, obviando su impacto en eventuales futuros procesos), es comúnmente aceptada por la doctrina. Por lo que, al menos a fines pedagógicos, cabe subrayar esta clasificación:

- **Resoluciones desincriminatorias:** desestimación, archivo fiscal, archivo jurisdiccional y sobreseimiento.
- **Respuestas alternativas propiamente dichas o intermedias:** criterios de oportunidad y suspensión del procedimiento a prueba.
- **Mecanismos de abreviación:** procedimiento abreviado.

Por otra parte, algunos de estos mecanismos tienen *efecto definitivo* en cuanto clausuran la posibilidad de nuevas persecuciones por el mismo hecho, mientras que hay otros que admiten la reapertura con mayor o menor amplitud. En algunos casos, queda abierta la posibilidad de conversión de la acción penal pública en acción privada.

c) Desestimación y archivo preliminar

Caracterización general

§ 277. La *desestimación de la denuncia* (CPP, 273) es dispuesta por el fiscal, cuando no se pudiera proceder, se hubiera extinguido la acción penal, el hecho no fuera punible o no existieran elementos serios o verosímiles para iniciar fundadamente una investigación. Ordenada la desestimación, la denuncia es archivada.

Este instituto tiende a evitar el doble perjuicio que ocasiona la apertura de una investigación penal inidónea: el dispendio de recursos del sistema judicial, y la innecesaria afectación a la tranquilidad de las personas denunciadas.

§ 278. La desestimación es una forma de desistimiento temprano de la persecución penal, ya que puede ordenarse en forma inmediata, sin que resulte necesario realizar ninguna diligencia investigativa previa.

Causales

No se trata de un mecanismo discrecional, ya que requiere ser fundado en alguna de las causales previstas específicamente en la norma:

- La *imposibilidad de proceder* se da en supuestos de excepción previstos legalmente, como la no formulación de instancia privada (CP, 72; CPP, 17), la existencia de obstáculos fundados en privilegios constitucionales cuando el desafuero es negado o no se produce la destitución (CPP, 26-29), o las cuestiones previas y prejudiciales (CPP, 30-33).
- La *extinción de la acción penal pública* tiene lugar por muerte del imputado, amnistía o prescripción, y también -según lo previsto en la ley procesal- por aplicación de un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o cumplimiento de las condiciones de la suspensión del procedimiento a prueba (CP, 59). Sin embargo, debe advertirse que en algunos de estos casos puede corresponder el archivo fiscal (CPP, 289) o el sobreseimiento (CPP, 306), particularmente en caso de prescripción de la acción penal habiendo persona imputada.
- La *falta de punibilidad del hecho* se refiere genéricamente a la ausencia de cualquiera de los elementos analíticos que hacen a su caracterización como delito o a su penalización. Así, debe desestimarse la denuncia si del hecho relatado no se desprende una conducta, o si ésta es atípica, jus-

tificada o inculpable, o si media un supuesto de exclusión de la punibilidad.

- La *falta de elementos serios y verosímiles para iniciar fundadamente una investigación* es, como causal de desestimación, toda una novedad en la región. Aquí estamos ante un caso en el que habría delito, pero no hay pistas que permitan orientar la investigación. No cualquier déficit probatorio habilita esta opción -ya que justamente la actividad investigativa tiene por finalidad obtener evidencia-, pero si el caso es totalmente inviable es mejor asumirlo con sinceridad, bajar las expectativas y enfocarse en los casos que sí puedan resolverse. La desestimación por este supuesto debe evaluarse también en función de la gravedad del delito, pudiendo desestimarse con mayor agilidad en los casos más leves.

En caso de que se individualice a los supuestos autores o partícipes del hecho, sólo puede desestimarse la denuncia si aún no se ha celebrado audiencia imputativa (CPP, 274). Si esta audiencia ya tuvo lugar, la posterior inidoneidad de la persecución penal debería acarrear el archivo fiscal (CPP, 289). Para evitar confusiones con este otro instituto, resulta preferible llamar *archivo preliminar* al que se dicta como consecuencia de la desestimación de la denuncia.

Procedimiento

§ 279. La desestimación es dispuesta por el propio fiscal, sin necesidad de intervención judicial homologatoria. Impide la posibilidad de una nueva persecución por los mismos hechos, aunque esta cláusula sólo tiene sentido habiendo alguna persona imputada en peligro de persecución múltiple. Además, existen tres vicisitudes que obstan a la firmeza de la desestimación: el *recurso*, la *conversión* y la *reapertura*.

§ 280. La víctima, o en su caso el querellante, pueden recurrir la desestimación ante el Fiscal Regional (CPP, 291). La negativa de éste, a su vez, es recurrible ante el Fiscal General. En ambos casos, se resuelve previa investigación sumaria, y en caso de revocarse la desestimación, el superior puede impartir instrucciones y designar un nuevo fiscal.

Más allá de lo criticable que resulte la regulación de este recurso en sede fiscal (que termina desnaturalizando los roles directivos y provocando múltiples incoherencias), la posibilidad de plantear impugnaciones contra los actos de la fiscalía está presente en la mayoría de los sistemas reformados. De alguna manera, viene a reemplazar a la apelación de las resoluciones instructorias del

viejo sistema. La novedad del código santafesino es que el recurso no es resuelto en sede judicial, sino por la propia estructura directiva de la fiscalía.

§ 281. Denegado por el Fiscal General el recurso contra la desestimación, la víctima o el querellante pueden instar la conversión de la acción penal pública en privada, formulando querella en el plazo de sesenta días hábiles (CPP, 291).

Esta opción convierte a la víctima en querellante sustitutivo, habilitando la continuación del proceso sin participación de la fiscalía. Esta sobreamplificación del rol de la víctima -que implica una importante concesión al principio acusatorio material- ha despertado voces críticas, en cuanto puede obstar a los objetivos de política criminal que fundamentan en general las salidas alternativas. Es decir, bajo este régimen la desestimación sólo sirve para disminuir la carga de trabajo de la fiscalía, pero no para descongestionar el sistema en su conjunto ni para evitarle a las personas la amenaza de un proceso inviable.

§ 282. El fiscal puede disponer la reapertura de la investigación (CPP, 293), previa autorización del Fiscal Regional, si la situación probatoria se ve modificada por elementos sobrevinientes. La falta de venia regional invalida lo actuado, y permite a la persona que eventualmente resulte imputada oponer la excepción de archivo.

No se regula un plazo máximo para la reapertura, por lo cual el fiscal puede disponerla siempre que no haya prescripto la acción penal por el delito respectivo. Tampoco procede la reapertura cuando la víctima o querellante ya instó la conversión de la acción penal.

d) Archivo fiscal

Caracterización general

§ 283. El *archivo fiscal* (CPP, 289) procede cuando, habiéndose formalizado audiencia imputativa (CPP, 274), la investigación finalizara con resultado desincriminante o insuficiente para acusar.

Este instituto opera como una especie de sobreseimiento impropio, dispuesto por el propio fiscal cuando advierte que concurre alguno de los supuestos que habilitaría al imputado a plantear el sobreseimiento en sede judicial (CPP, 306). De alguna manera, se le reconoce al acusador un rol de mayor

objetividad, quitándole de encima el deber -impuesto por las antiguas legislaciones- de asumir por defecto una postura incriminadora.

§ 284. El archivo fiscal es una forma de desistimiento de la persecución penal ya iniciada, por lo que sus presupuestos son más estrictos que para la desestimación:

- Requiere que la investigación se encuentre agotada, es decir, que no haya más medidas para practicar.
- Debe haberse celebrado audiencia imputativa (CPP, 274).
- Si hubiera querellante, debe haberse cumplido con el trámite previo (287, 288). Este trámite consiste en explicarle la decisión a tomar y darle la oportunidad de manifestar sus eventuales discrepancias, que serán resueltas por el Fiscal Regional.

Causales

§ 285. Las causales de archivo fiscal son las siguientes:

- *Certeza negativa* (CPP, 289.1.a-b-c). Cuando fuera *evidente* que media una causal extintiva del ejercicio de la acción penal u otra de carácter también perentorio, que el hecho investigado no se cometió o no encuadra en una figura penal, que el delito no ha sido cometido por el imputado o media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria. Se trata de los típicos motivos de sobreseimiento en casi todas las legislaciones.
- *Insuficiencia probatoria insuperable* (CPP, 289.2). Cuando no hubiera suficientes elementos de prueba para fundar la requisitoria de apertura del juicio y no fuera razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas. De alguna manera, este supuesto viene a coincidir con el antiguo auto de falta de mérito.

Procedimiento

§ 286. El archivo es dispuesto por el propio fiscal, sin necesidad de intervención judicial homologatoria. Impide la posibilidad de una nueva persecución por los mismos hechos, aunque está sujeto a las mismas vicisitudes que la desestimación: el *recurso*, la *conversión* y la *reapertura*.

Estas tres vicisitudes están previstas de manera conjunta para la desestimación y para el archivo fiscal (CPP, 291-293), lo cual es un grosero error,

ya que el archivo por certeza negativa conlleva una valoración conclusiva de la persecución penal, al menos respecto de la fiscalía. La reapertura en estas condiciones sería contradictoria con la propia conducta previa del actor penal, cuya posición debe ser fundamentada desde una posición de objetividad y coherencia. De todos modos, vale aclarar que en este caso nada obsta a que la defensa solicite directamente el sobreseimiento (CPP, 306).

Para evaluar la viabilidad de la reapertura, no sólo debería considerarse la seriedad y coherencia de la posición asumida, sino también el plazo dentro del cual se produce. Ello para evitar la picardía de utilizar este mecanismo para evitar el plazo habilitante del archivo jurisdiccional (CPP, 290).

Por lo demás, la posibilidad de recurrir el archivo y eventualmente instar la conversión de la acción penal (CPP, 291) se superpone con la previa intervención del querellante (CPP, 287-288). Con lo cual se consagra una doble intervención del Fiscal Regional, que actuará tanto en la consulta previa como en el recurso posterior.

e) Archivo a solicitud de la defensa y archivo jurisdiccional

Instancia defensiva

§ 287. El archivo fiscal puede ser *instado por la defensa*, habiendo transcurrido diez meses desde la formalización de audiencia imputativa (CPP, 290). Si la fiscalía accede a la solicitud, dispondrá el archivo por alguno de los supuestos de dicho instituto.

En rigor, la instancia defensiva puede ser planteada en cualquier momento, pero el cumplimiento del plazo legal resulta necesario para volver operativo el instituto y desencadenar las consecuencias previstas ante la negativa del fiscal.

Si bien el archivo a solicitud de la defensa puede disponerse por cualquiera de los supuestos previstos (CPP, 289), el instituto cobra un mayor sentido en caso de insuficiencia probatoria insuperable (CPP, 289.2), funcionando como un sucedáneo del antiguo “sobreseimiento por duda” previsto en el viejo sistema.

Ante la certeza negativa (CPP, 289.1.a-b-c) tiene una utilidad marginal, ya que para la defensa siempre será preferible instar el sobreseimiento (CPP, 306), logrando así el efecto de cosa juzgada.

§ 288. El doble régimen de los casos de certeza negativa -como supuestos de archivo fiscal y de sobreseimiento- resulta un tanto curioso. En su origen, representa el intento de desjudicializar las soluciones desincriminatorias: el archivo dispuesto por el propio fiscal funciona *casi* como un sobreseimiento por abandono de la acción pública. Sin embargo, la figura del archivo fiscal se encuentra actualmente tan complejizada en su regulación, que probablemente en algunos casos hasta resulte más fácil obtener el sobreseimiento.

Archivo jurisdiccional

§ 289. La negativa expresa o tácita del fiscal permite llevar el caso ante el juez de la IPP, que resolverá en audiencia y en su caso dispondrá el *archivo jurisdiccional* (CPP, 290). Ante la negativa del juez, queda a la defensa la posibilidad de reiterar el procedimiento cada seis meses.

A pesar de la regulación un tanto mezclada del archivo fiscal y el archivo jurisdiccional, los efectos de ambos institutos difieren notablemente. Las vicisitudes del archivo fiscal (recurso, conversión y reapertura) no alcanzan al archivo jurisdiccional, que en este sentido viene a funcionar como una especie de sobreseimiento anómalo. Aunque el código no lo diga expresamente, hace cosa juzgada, impidiendo una nueva persecución por el mismo hecho en relación al imputado en cuyo favor se dicta.

Con lo cual se da la curiosa situación de que la solicitud de archivo beneficia más al imputado cuando es inicialmente rechazada por el fiscal -y aceptada luego por el juez-, que cuando es compartida. Por lo que, en caso de haber consenso, debería preferirse el sobreseimiento por presentación conjunta (CPP, 306).

f) Sobreseimiento

Caracterización general

§ 290. El *sobreseimiento* (CPP, 306) es un pronunciamiento jurisdiccional que tiene lugar ante la evidencia de que concurre alguna de las causales desincriminatorias previstas en la ley.

Funcionalmente equivale a una absolución anticipada, aunque es correcto aclarar que se trata de una resolución que trunca el procedimiento e impide el avance de la pretensión punitiva. Tiene valor de cosa juzgada, en cuanto impide una nueva persecución por el mismo hecho en relación al imputado en cuyo favor se dicte.

Causales

§ 291. El sobreseimiento procede en los casos de *certeza negativa* que están previstos como supuestos de archivo fiscal, por lo que el código directamente remite a aquella norma (CPP, 306, en relación al 289.1.a-b-c). Los tres subincisos contienen los casos típicos de sobreseimiento en casi todas las legislaciones:

- *Causal perentoria*: típicamente, extinción de la acción penal (289.1.a).
- *Causal objetiva*: el hecho no se cometió o no encuadra en una figura penal (289.1.b).
- *Causal subjetiva*: el hecho no ha sido cometido por el imputado, o media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria (289.1.c).

Es necesario que la concurrencia de alguno de estos supuestos sea *evidente*. La evidencia, categorizada doctrinariamente como certeza negativa, se logra cuando hay elementos suficientes para persuadir al juzgador de que toda otra diligencia investigativa resulta vana. Es un estándar de valoración sumamente exigente, ubicado en el extremo opuesto de la *certeza positiva* necesaria para condenar.

En cambio, no se prevé el sobreseimiento por *duda insuperable*, que antiguamente operaba transcurrido un cierto tiempo a partir del auto de falta de mérito. Actualmente, el juicio dubitativo puede dar lugar al archivo fiscal (CPP, 289.2) o al archivo jurisdiccional (CPP, 290). En el primer caso, la siempre latente posibilidad de reapertura (CPP, 293) deberá analizarse en función de los principios de *plazo razonable* y *prohibición de persecución múltiple*, ya que en definitiva el efecto de cosa juzgada dependerá de la actitud remisa del fiscal, no existiendo siquiera la opción de plantear directamente el sobreseimiento como tiene en los otros supuestos.

Sobreseimiento por presentación conjunta

§ 292. El código de Santa Fe admite expresamente el *sobreseimiento por presentación conjunta*, mediando acuerdo de partes. En este caso, el instituto tramita prácticamente igual que las restantes soluciones alternativas. La presentación se realiza por escrito, y el juez resuelve previo control de legalidad. La convocatoria a audiencia es facultativa para el tribunal.

La redacción de la norma (CPP, 306) parece sugerir que el sobreseimiento por presentación conjunta se basa exclusivamente en el acuerdo de partes, siendo innecesario encuadrar el caso en alguna de las causales ya explicadas. De acuerdo a una interpretación basada en el principio acusatorio adversarial, estaríamos ante un supuesto autónomo respecto de las causales perentoria, objetiva y subjetiva (CPP, 306, en relación al 289.1.a-b-c).

Sin embargo, esta supuesta autonomía del sobreseimiento consensual queda desautorizada por la propia norma, que impone al magistrado el deber de controlar la legalidad de la presentación. Dicho control de legalidad consiste en verificar si los hechos relatados por las partes en la presentación conjunta encuadran en alguna de las causales taxativamente previstas.

§ 293. Debe tenerse presente que el control judicial de legalidad es esencialmente un *control de adecuación jurídica*, que no se extiende a valorar la suficiencia de la prueba. Por lo tanto, no cabría rechazar el planteo de sobreseimiento por no haberse logrado el estándar de certeza negativa, ya que en este caso el acuerdo de partes cumple el efecto de anular la necesidad misma de prueba. A lo que cabe agregar que la producción de prueba supone algún grado de controversia, y esto difícilmente tenga lugar en una audiencia consensual.

Sobreseimiento a pedido de parte

§ 294. No habiendo acuerdo, el sobreseimiento se pronuncia *a pedido de parte*. La instancia da lugar a una audiencia, en la que se debate la solicitud y eventualmente se produce prueba.

Efectos

§ 295. Cuando el sobreseimiento diera lugar a la aplicación de una medida de seguridad, el tribunal debe abstenerse de imponerla y remitir la causa al tribunal de juicio. Esta cláusula replica la cesura del juicio (separación entre el

debate sobre la autoría culpable y el debate sobre la necesidad de pena), y tiende a evitar la aplicación expedita de medidas de seguridad contra inimputables. Esta precaución es más importante aún en un sistema que admite el sobreseimiento consensual, cuya utilización con cierta ligereza puede dar lugar a reclusiones manicomiales innecesarias y dispuestas sin contradictorio.

§ 296. El sobreseimiento impide una nueva persecución por el mismo hecho en relación al imputado en cuyo favor se dicte. Hace cosa juzgada, sin perjuicio de eventuales debates sobre la modificación o el cese de las medidas de seguridad que fueran impuestas en su consecuencia.

g) Criterios de oportunidad

Caracterización general

§ 297. Los *criterios de oportunidad* (CPP, 19) son supuestos legales en los que la fiscalía puede prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal, o desistirla si ya la ha ejercido. En nuestro sistema, funcionan como excepciones frente a la regla que establece la obligatoriedad de la acción penal pública (CP, 71; CPP, 16), siendo en definitiva una manifestación específica del *principio de oportunidad*.

§ 298. La aplicación de un criterio de oportunidad supone la existencia de un caso penal mínimamente idóneo, que haya superado la instancia de la desestimación (CPP, 273). Para decirlo con toda claridad, lo que se desiste es la persecución de un hecho con apariencia delictiva y líneas investigativas idóneas. Es más, es perfectamente posible que el autor esté individualizado y que existan pruebas contundentes de su culpabilidad. Nada de eso obsta a la aplicación del instituto.

En nuestro sistema este desistimiento es *reglado y controlado*. Reglado, porque los supuestos de desistimiento están establecidos en la propia ley procesal. Y controlado, porque es una facultad sujeta a controles internos en la propia Fiscalía y a la interacción con otros sujetos procesales.

Funciones

§ 299. Los criterios de oportunidad cumplen una función de economía procesal y descongestión del sistema, que comparten con las demás alternativas al juicio contencioso. Frente al fenómeno de la selección clandestina e incontrolada de causas penales, permiten explicitar y transparentar los criterios de priorización de casos en un marco de responsabilidad funcional. Pero también cumplen funciones más específicas, que por supuesto irán teniendo mayor o menor incidencia según el caso concreto:

- Son una herramienta de descriminalización indirecta de conductas delictivas socialmente aceptadas, toleradas, éticamente defendidas o respecto de las cuales existe un menor interés estatal en su sanción.
- Priorizan el interés de la víctima del delito, permitiendo arribar a soluciones reparatorias o conciliatorias.
- Realizan a nivel práctico principios fundamentales como los de lesividad, proporcionalidad, subsidiariedad y humanidad.
- En algunas legislaciones, permiten a la fiscalía resolver negocialmente situaciones de gran complejidad, como tomas de rehenes, incidentes internacionales, procesos de paz o investigaciones sobre criminalidad organizada.

Supuestos legales

§ 300. El código de Santa Fe regula los criterios de oportunidad en particular (CPP, 19), en una norma que se ha vuelto un tanto compleja debido a las limitaciones y excepciones que se le han incorporado. Sintéticamente, los supuestos son los siguientes:

- **Por disposición de la ley.** Cuando el Código Penal o las leyes penales especiales lo establezcan o permitan al Tribunal prescindir de la pena (19.1). Ejemplos: tentativa inidónea, delito susceptible de condena condicional.
- **Insignificancia.** Cuando se trate de hechos que por su *insignificancia* no afecten gravemente el interés público (19.2). Ejemplos: el hurto de un televisor, la lesión consistente en un puñetazo. Debe tenerse en cuenta que, si la insignificancia posee relevancia penal sustantiva (hurto de lapicera, lesión consistente en una cachetada), no corresponde aplicar el criterio de oportunidad sino archivar: en estos casos, la conducta resultaría atípica por aplicación del *principio de lesividad*.

- ***Pena natural.*** Cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado sean de tal gravedad que tornen innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena (*pena natural*, 19.3). Ejemplos: el conductor imprudente que causa la muerte de su propio familiar, el ladrón que queda parapléjico al ser abatido por la policía.
- ***Insignificancia relativa.*** Cuando la pena en expectativa carezca de importancia con relación a la pena ya impuesta por otros hechos (19.4). Es una forma especial de insignificancia, aplicable por ejemplo al recluso que quema su colchón a modo de protesta, pero que también puede usar un fiscal santafesino para desistir de procesar por delitos menores a los prófugos de otra provincia al momento de ser recapturados. Otras legislaciones admiten este supuesto considerando la pena *a imponerse* por otros hechos, lo que permite dar prioridad al juzgamiento de los delitos más graves.
- ***Conciliación.*** Cuando exista *conciliación* entre los interesados. En el caso de los delitos patrimoniales no violentos (19.5), se exige que el imputado haya *reparado los daños y perjuicios* causados. También procede en relación a los delitos culposos, lesiones leves, amenazas y violación de domicilio, aunque con limitaciones (19.6).
- ***Por disposición de la ley en cuanto a la ejecución.*** Cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable en estado terminal o tenga más de setenta años (19.7). Esta es una modalidad especial de la cláusula del inciso 1, ya que en estos casos la ley penal permite el cumplimiento de la pena en detención domiciliaria. Por eso mismo, debe estimarse que el criterio de oportunidad es aplicable analógicamente a todos los supuestos de dicho instituto (CP, 10; ley 24.660, 32).

Limitaciones

§ 301. Los criterios de oportunidad se encuentran sujetos a limitaciones legales, que en general tienden a reservar este mecanismo para los delitos más leves, a evitar su imposición a víctimas particularmente vulnerables y a evitar que los casos de corrupción queden impunes. Las exclusiones más usuales son: delitos cometidos con violencia o intimidación, con utilización de armas de fuego, delitos de funcionarios públicos, que comprometan la seguridad o el interés público, que comprometan el interés de un menor de edad, casos de violencia de género.

Dentro de estas limitaciones se incluye la necesidad de que el imputado acuerde la *reparación del daño* en los casos de insignificancia, pena natural y

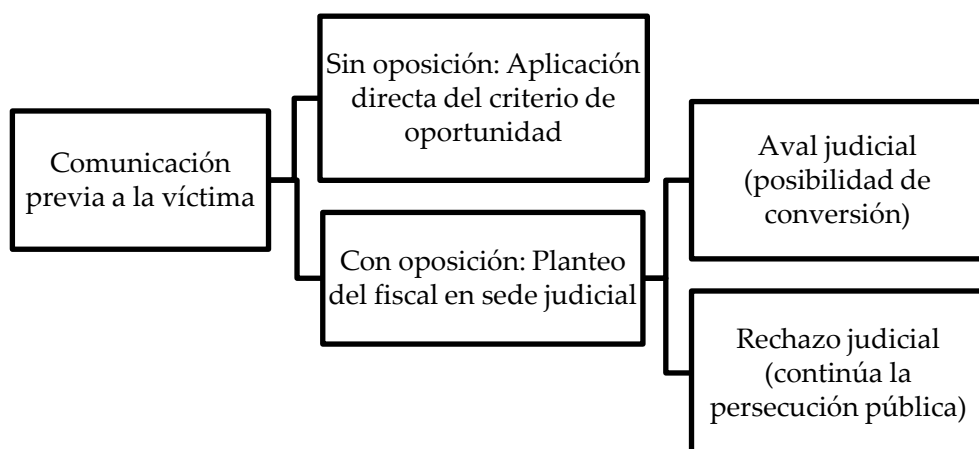
conciliación (19, penúltimo párrafo), y el requerimiento de *venia del Fiscal Regional* cuando el delito desistido tuviera una pena máxima de seis años o más (19, último párrafo).

Procedimiento

§ 302. El procedimiento para la aplicación de un criterio de oportunidad tiene alguna variación, dependiendo de quién tome la iniciativa y de qué actitud asuman las demás partes.

- Si no hay oposición de la víctima, la fiscalía puede aplicar directamente un criterio de oportunidad, disponiendo por sí misma el archivo de la investigación.
- La defensa puede solicitar a la fiscalía la aplicación del instituto, sin recurso alguno en caso de negativa. Si se da curso al pedido, debe darse conocimiento a la víctima, quien podrá formular oposición, y si no la formula no podrá luego instar la conversión de la acción penal. Es conveniente interpretar que esta mecánica también es aplicable al supuesto del inciso anterior, ya que de lo contrario no queda claro qué efectos produce la intervención de la víctima.
- La oposición de la víctima permite instar la celebración de una audiencia, en la que el tribunal controlará la legalidad de la posición sostenida por la fiscalía. Si dicha postura es avalada, la víctima podrá instar la conversión de la acción penal dentro de los sesenta días. En caso contrario, o vencido dicho término, la acción penal quedará extinguida.

Asumiendo que la fiscalía toma la iniciativa de aplicar un criterio de oportunidad, o que recepta favorablemente la solicitud de la defensa, el procedimiento sería esquemáticamente el siguiente:



De las distintas alternativas que ofrece el procedimiento, se observa que sólo el supuesto de aplicación directa por parte del fiscal (al que se llega únicamente con el acuerdo expreso o tácito de la víctima) permite que la aplicación de un criterio de oportunidad cumpla en alguna medida con sus múltiples funcionalidades.

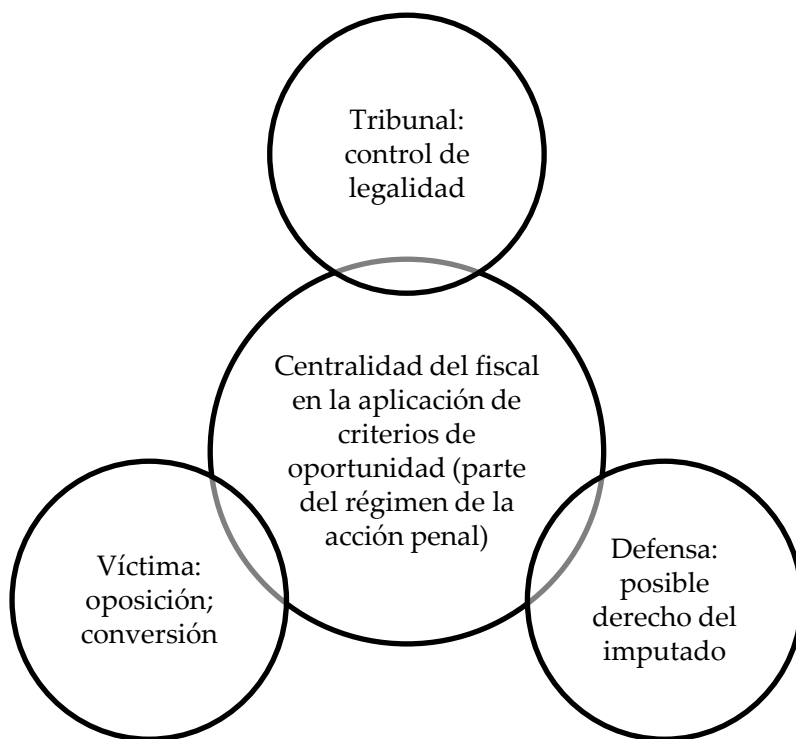
Observaciones a la regulación actual del instituto

§ 303. En su regulación actual (CPP, 21-22), el procedimiento resulta un tanto confuso. Pero en general, pueden formularse las siguientes observaciones:

- La aplicación de un criterio de oportunidad es una facultad primaria de la fiscalía, por tratarse de un instituto que integra el régimen de la acción penal. No obstante, se ha intentado respetar el interés de todas las partes, lo cual obviamente agrega complejidad.
- El código habilita al tribunal a controlar la legalidad de la postura de la fiscalía, lo que violenta el principio acusatorio en cuanto habilita al juez a inmiscuirse en el ejercicio de la acción penal.
- La posibilidad de conversión de la acción penal, si bien obedece a loables intenciones de reivindicar la figura de la víctima, termina desnaturalizando el instituto, que no llega a cumplir con sus finalidades proclamadas. Si la víctima tiene medios para insistir lo suficiente, nada impide que lleguen a juicio contencioso casos de insignificancia, pena natural o baja peligrosidad, no lográndose siquiera economizar recursos del sistema judicial.

- La defectuosa redacción de la norma (que define con demasiada amplitud los supuestos de controversia) permite interpretar que el juez puede aplicar un criterio de oportunidad *aun mediando oposición del fiscal*, ejerciendo el control de legalidad ante el planteo de la defensa. De prosperar esta interpretación, se reconocería al imputado el *derecho a gozar de un desistimiento de la acción pública*, con lo que los criterios de oportunidad pasarían a tener alguna similitud mayor con la suspensión del procedimiento a prueba: ya no estaríamos en el ámbito de la acción penal, sino en el de los obstáculos legales a la persecución. Esta posibilidad, que por supuesto resulta discutible en cuando desnaturaliza el régimen de la acción penal, amerita que el control de legalidad a solicitud de la defensa se ejerza de manera sumamente estricta, evitando intrusar facultades propias de la fiscalía.

§ 304. Así las cosas, la idea inicial -que, por otra parte, campea en todas las legislaciones de corte acusatorio formal- es que los criterios de oportunidad integran el régimen de la acción penal, y por lo tanto constituyen una facultad exclusiva o preponderante de la fiscalía. Sin embargo, en nuestro sistema la interacción de la fiscalía con los restantes actores del proceso genera supuestos de tensión, que la ley resuelve desplazando la toma de decisiones hacia afuera de la propia fiscalía, lo cual permite dudar de la verdadera naturaleza del instituto.



h) Suspensión del procedimiento a prueba

Caracterización general

§ 305. La *suspensión del procedimiento a prueba* (CP, 76 bis a 76 quater; CPP, 24) es un pronunciamiento jurisdiccional que suspende el avance del proceso penal, por un plazo durante el cual el imputado se compromete a observar determinadas reglas de conducta.

Desde su recepción en la legislación argentina se ha debatido si este instituto consagra un *derecho del imputado*, o si es asimilable a un *criterio de oportunidad*. El célebre plenario "Kosuta" (CNCP, 1999) es un buen muestrario de esta diversidad de miradas sobre su naturaleza jurídica.

La postura actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le atribuye carácter penal sustantivo, en cuanto le aplica llanamente el principio de legali-

dad contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional (fallo “Acosta”, CSJN, 2008). Por lo que, con la interpretación amplia propiciada en aquel precedente, puede hablarse de un *derecho del imputado a obtener la suspensión del procedimiento a prueba*, al menos en el marco de la regulación contenida en el Código Penal.

La reforma de 2015 estableció que esta normativa tiene carácter subsidiario, rigiendo en primer término la que establezcan las leyes procesales correspondientes. Sin embargo, el código de Santa Fe aún conserva la regulación de complemento propia de un momento anterior a esta “desfederalización”. Por lo que habrá que integrar ambas normativas, hasta que la legislación local se apropie por completo del instituto.

Funciones

§ 306. Además de cumplir con la función de descongestión común a todas las alternativas, la suspensión del procedimiento a prueba tiene dos funciones específicas:

- **Valorizar a la víctima.** Permite tener en cuenta la situación concreta de la víctima, revalorizándola como protagonista originario del conflicto social y priorizando que el daño sufrido sea reparado.
- **Evitar efectos criminógenos.** Tiende a evitar los efectos criminógenos que el mismo sistema penal provoca cuando somete a persecución a un infractor primario, tales como la estigmatización, el deterioro de los mecanismos de contención social (exclusión de la vida familiar, escolar o laboral), o la identificación cultural con trayectorias criminales más extensas. En síntesis, evita que el imputado ingrese a un circuito institucional del cual luego le resultará muy difícil salir.

Más allá de estas funciones puntuales, la suspensión a prueba funciona como una primera advertencia, que insta a desistir de la conducta delictual. En caso de no ser acatada, el sistema penal irá produciendo reacciones cada vez más severas, hasta llegar al verdadero punto de inflexión que es la pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Este conjunto de respuestas penales de gravedad creciente hace que el sistema en su conjunto se vuelva más escalonado, con capacidad de desplegar la mínima violencia que resulte necesaria para evitar daños mayores.

Procedencia

§ 307. La suspensión del procedimiento a prueba procede cuando el máximo de la pena aplicable al imputado no exceda de tres años (CP, 76 bis, primer y segundo párrafo). No obstante, los partidarios de la tesis amplia consideran que existe otro supuesto: cuando las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal (cuarto párrafo).

El código de Santa Fe adopta decididamente la postura amplia, y remite a los casos en que sea procedente la aplicación de una condena de ejecución condicional (CPP, 24). También de conformidad con la tesis amplia, admite la aplicación del instituto cuando el delito previera pena de inhabilitación, aplicándose la misma como regla de conducta (en contra: CP, 76 bis, octavo párrafo).

§ 308. También se ha debatido la procedencia del instituto cuando hubiera dictamen negativo de la fiscalía. Para quienes consideran que la suspensión a prueba es un criterio de oportunidad, el acuerdo de la fiscalía resulta ineludible para su otorgamiento. Sin embargo, desde la tesis amplia se ha replicado que un derecho del imputado no podría estar sujeto a la conformidad de su adversario. Otros sostienen, en el marco de la normativa nacional (CP, 76 bis), que el consentimiento del fiscal es necesario sólo en el supuesto del cuarto párrafo (mínimo no superior a tres años), pero no en el caso del primer párrafo (máximo no superior a tres años).

El código de Santa Fe establece que la suspensión a prueba puede ser solicitada *por la fiscalía, con el acuerdo del imputado y de su defensor* (CPP, 24). Aunque la mención a la fiscalía parece asimilar el instituto a un criterio de oportunidad, la negativa del fiscal no impide su aplicación según la normativa nacional subsidiaria (CP, 76), con el alcance amplio establecido en “Acosta”.

Contenido del acuerdo y procedimiento

§ 309. El acuerdo entre partes deberá contener los siguientes puntos:

- El plazo de prueba, que deberá fijarse entre uno y tres años (CP, 76 ter).
- La forma de reparación del daño (CP, 76 bis, tercer párrafo).
- Las reglas de conducta que deberá observar el imputado (CP, 76 ter), para lo cual la norma remite a las reglas previstas para la condena condicional (CP, 27 bis).

- Eventualmente, el pago del mínimo de la multa, la inhabilitación como regla de conducta y el abandono en favor del Estado de los bienes procedentes del delito.

Presentado el acuerdo, se convocará a audiencia, en la que se debatirá la procedencia del planteo y la razonabilidad de la oferta reparatoria. Como el acuerdo presupone el consentimiento de la fiscalía, el rechazo por parte del juez sólo podría estar fundado en cuestiones de estricta legalidad, evitando inmiscuirse en valoraciones de conveniencia político-criminal propias del MPA.

Improcedencia

§ 310. La normativa nacional establece causales de improcedencia de la suspensión del procedimiento a prueba:

- Delitos con participación de funcionarios públicos (CP, 76 bis, séptimo párrafo).
- Delitos previstos en las leyes 22.415 y 24.769 (CP, 76 bis, último párrafo), es decir, delitos aduaneros y tributarios.
- Incumplimiento de reglas de conducta de una suspensión anterior (CP, 76 ter, último párrafo).

Se ha sostenido la improcedencia del instituto cuando se trata de delitos cuyo juzgamiento y sanción resulta imperativo por mandas constitucionales o convencionales, como el *atentado contra el orden constitucional*, la *usurpación de funciones constitucionales* y los *delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento* (CN, 36), los *actos de tortura* (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 4), o los *hechos de corrupción* (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 30) y en general las *graves violaciones a los Derechos Humanos* (caso “Barrios Altos vs. Perú”, Corte IDH, 2001, con base en los artículos 8 y 25 de la CADH).

Finalmente, se ha dicho que no procede ninguna alternativa a la definición del caso en la instancia de debate oral cuando se trata de *hechos de violencia contra la mujer* (fallo “Góngora”, CSJN, 2013, con base en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer [“Convención de Belém do Pará”]). Esta postura ha merecido varias críticas, por no hacer distinción alguna en relación a la gravedad del delito, y fundamentalmente por no atender al interés de la víctima, que en el caso concreto puede incluso preferir una solución compositiva. Además, según el criterio de “Góngora” no sólo resulta improcedente la suspensión a prueba,

sino también cualquier otra vía procesal distinta del juicio que aquí llamamos “contencioso”, no dando lugar siquiera a que el imputado que desea declararse culpable celebre un procedimiento abreviado.

Casos especiales

§ 311. La suspensión a prueba podrá ser otorgada por segunda vez, transcurridos ocho años desde el vencimiento del plazo de prueba fijado en el proceso anterior (CP, 76 ter, sexto párrafo).

Si el imputado ha tenido una condena condicional anterior, la suspensión a prueba podrá ser otorgada siempre que fuera procedente una nueva condena condicional. Ello será viable si el nuevo delito hubiera sido cometido luego de ocho años desde la primera condena firme, y luego de diez años si ambos delitos fueran dolosos (CP, 27, segundo párrafo).

Alternativas en cuanto al cumplimiento

§ 312. La suspensión podrá ser dejada sin efecto si el imputado comete un nuevo delito o incumple con las reglas de conducta durante el plazo fijado, como así también si posteriormente surgen elementos que modifiquen la expectativa de condicionalidad de la pena aplicable. Esta decisión requiere la celebración de audiencia, en la que deberá oírse al imputado y a su defensor.

§ 313. El cumplimiento positivo de la totalidad de las pautas contenidas en el acuerdo permitirá declarar extinguida la acción penal, y en consecuencia se dictará el sobreseimiento del imputado.

i) Procedimiento abreviado

Caracterización general

§ 314. El *procedimiento abreviado* (CPP, 339-345) es un instituto que permite acordar entre las partes la aplicación de una pena, prescindiendo del debate contradictorio.

La definición es intencionalmente superficial, ya que la caracterización del instituto dependerá del modelo que se adopte. Por ello, resulta necesario iden-

tificar las distintas formas de abreviación procesal, dando cuenta del sistema en el que se inserta cada una.

§ 315. La necesidad de que el imputado preste su colaboración para abreviar los procedimientos ha estado presente en prácticamente todos los sistemas procesales, y se ha plasmado de diversas formas. Así, el sistema inquisitivo recurrió a la confesión como forma de librar al indagado del tormento y lograr la expiación. Los antiguos pueblos germanos aceptaban reemplazar el combate y acudir a la reparación, logrando de esta forma la pacificación entre clanes.

No fue sino hasta que lograron erigirse precarias garantías en favor del acusado, que se problematizó lo que implicaba -en términos de derechos individuales- la renuncia a la defensa en juicio y la aceptación de una condena.

Mecanismos de abreviación formal

§ 316. Los sistemas mixto y acusatorio formal, derivados de los modelos inquisitivos de la Europa continental, aceptan con muchas limitaciones el tinte negocial que este tipo de acuerdos le imprimen al proceso penal. En este contexto, se consagraron *mecanismos de abreviación formal*, que se entendieron compatibles con el principio de obligatoriedad de la acción penal:

- La posibilidad de realizar una instrucción abreviada y pasar directamente al juicio oral.
- La posibilidad de acordar la supresión de la etapa intermedia.
- La posibilidad, en los delitos leves, de sustituir la prueba de cargo por la confesión lisa y circunstanciada por parte del imputado.
- La facultad de acordar la mutua renuncia a la apelación (pacto de instancia única).

Abreviación material en el sistema continental

Algunas legislaciones (en particular: CPP Italiano, OPP Alemana, LEC Española) avanzaron hacia *mecanismos de abreviación material*, que permiten negociar inclusive el monto de la pena a imponerse. Esta idea, un tanto resistida inicialmente, dio lugar al juicio abreviado tal como se lo conoce en los sistemas de tipo acusatorio formal y mixto. Sus principales caracteres son los siguientes:

- Son mecanismos de abreviación material condicionados por el principio de obligatoriedad de la acción penal, en el marco de un sistema que plantea como fin del proceso la reconstrucción de la verdad histórica.

- La aceptación por parte del imputado equivale a una confesión o al reconocimiento de los hechos, con lo cual el procedimiento viene a ser una confesión condicionada a la aceptación del acuerdo.
- El tribunal tiene el deber de dictar sentencia fundada, no pudiendo suplirse esta tarea por una mera homologación del acuerdo de partes, por lo cual suele asignarse valor probatorio a las constancias del expediente y a la confesión del imputado.
- El tribunal conserva la facultad de rechazar el acuerdo, usualmente en dos casos: desacuerdo con la calificación jurídica propuesta, e insuficiencia probatoria. Esto significa que debe haber una adecuación entre las pruebas aportadas, los hechos relatados y su calificación legal. No es admisible, por ejemplo, que la fiscalía obtenga la conformidad del imputado a cambio de una calificación legal más leve, o de la supresión de un agravante.
- El tribunal está impedido de aplicar una pena mayor a la acordada por las partes, pero sí puede aplicar una pena menor, e incluso puede absolver.
- La pena negociada suele estar sujeta a topes legales, que en algunos sistemas pueden ser superados mediando autorizaciones especiales.

Este sistema, con alguna variante, aparece en las legislaciones argentinas del sistema mixto a partir de la década de 1990. En Santa Fe, fue introducido mediante una reforma parcial al viejo código escriturista, ya en el año 2003. Es también el modelo vigente en Entre Ríos y en el orden nacional.

Abreviación material en el sistema adversarial

§ 317. El *sistema adversarial* conoció, desde sus orígenes, la posibilidad de abreviar materialmente el procedimiento mediante el acuerdo de partes. Salvando las múltiples particularidades de cada legislación, este sistema puede caracterizarse de la siguiente manera:

- Son mecanismos de abreviación que se corresponden con la enorme discrecionalidad que posee la fiscalía para disponer del contenido de la pretensión penal, en el marco de un sistema que persigue la resolución de los conflictos y la pacificación social.
- Se entiende que el imputado, al manifestar su aceptación, renuncia a la posibilidad de defenderse en juicio público.
- La función del tribunal se limita a verificar que el imputado esté informado de las consecuencias jurídicas del acuerdo y manifieste libremente

su aceptación. Cumplida esta formalidad, dictará sentencia homologando el acuerdo de partes.

- El tribunal no puede rechazar el acuerdo, aunque sí puede reducir la pena o dejarla sin efecto. Con lo cual se entiende que la negociación abarca no sólo el monto de la pena, sino también la calificación jurídica. Dicho de otra manera, los fiscales pueden ofrecer calificaciones legales más benignas, si consideran que esto es necesario para lograr la aceptación del imputado y de su defensa.
- La pena negociada no está sujeta a ningún tope: se puede acordar desde una multa hasta la pena capital.

Si bien este sistema es característico del mundo anglosajón, la incorporación de ciertos rasgos adversariales en los procesos de reforma de América Latina produjo en algunos contextos una cierta “liberalización” de los procedimientos abreviados. De hecho, legislaciones como la alemana y la española ya acusan esta transformación, lo cual permite a alguna doctrina denunciar que el proceso penal norteamericano ha *colonizado* los sistemas europeos.

Críticas

§ 318. El juicio abreviado, en cualquiera de sus versiones, ha sido objeto de múltiples críticas:

- *Críticas relacionadas con su incompatibilidad con otros principios del sistema.* Alguna doctrina tradicional encuentra que el instituto no combina muy bien con el principio de obligatoriedad de la acción penal, por cuanto faculta a la fiscalía a disponer parcialmente de la pretensión punitiva. También desde ese marco teórico, se ha reprochado el carácter negociado que le imprime al proceso penal, en detrimento del principio de reconstrucción de la verdad histórica.
- *Críticas relacionadas con la vulneración de garantías del imputado.* También se ha señalado que la consagración del juicio abreviado implica el sacrificio, en mayor o menor medida, de garantías individuales del imputado. Así, se ha sostenido que el instituto viola la protección constitucional contra la autoincriminación, en cuanto coacciona al imputado a declararse culpable para no arriesgarse a sufrir una pena más severa si decide ir a juicio. Por otra parte, se ha criticado lo inapropiado de la misma expresión “juicio abreviado”, para designar un mecanismo que priva al acusado precisamente de una instancia garantizadora como es el juicio oral y público. En el marco de los modelos adversariales, se ha di-

cho que el juicio abreviado es contrario a la manda constitucional que establece el juicio por jurados. A este tipo de críticas, que apuntan a una supuesta inconstitucionalidad del instituto, suele oponerse el carácter renunciante del derecho de defensa en juicio, y el derecho del imputado a librarse rápidamente de la exposición a un juicio público.

- *Críticas relacionadas con su utilización abusiva o con su expansión desmedida.* Parte de la doctrina -aún aquella que acepta con reservas el juicio abreviado- advierte contra el carácter expansivo que ha adquirido en otros sistemas (en Estados Unidos, cerca del 95% de las condenas son negociadas). En sintonía con esta crítica, que apunta al funcionamiento real del instituto, están los que se resignan a su existencia, reclamando mayores controles para evitar su utilización abusiva. Otros acotan que esta utilización extensiva del juicio abreviado en el sistema norteamericano obedece a otros factores, como lo complejo y oneroso de afrontar un juicio por jurados, sumado al aumento de los mínimos penales, que prácticamente obliga a aceptar la condena negociada.

Aunque muchas de estas críticas son contestadas con astucia, en general se reconoce que el mayor aval al juicio abreviado radica en su innegable utilidad práctica. Junto con los criterios de oportunidad y el archivo fiscal, el juicio abreviado es una de las herramientas procesales que más aporta a la descongestión del sistema y a la economización de recursos del aparato judicial.

Regulación en el Código de Santa Fe

§ 319. El código de Santa Fe regula el procedimiento abreviado de la siguiente manera:

- El acuerdo debe contener la descripción del hecho, la calificación legal propuesta y la pena solicitada por la fiscalía (CPP, 339.2-3).
- La pena propuesta debe estar fundamentada de modo similar a una sentencia, respetando las pautas de individualización contenidas en el Código Penal (CP, 40-41) y guardando relación con los hechos investigados (CPP, 339.3).
- El imputado, asistido por su defensor, debe prestar su conformidad, aceptar el acuerdo y declararse culpable del hecho atribuido (CPP, 339.4).
- En caso de haber querellante, se regula una instancia previa de consulta, pudiéndose formular oposición (CPP, 340).
- Si bien no se regulan causales de rechazo judicial del acuerdo, se impone el aval del Fiscal Regional cuando hubiera oposición del querellante,

cuando se propusiera una pena mayor de seis años de prisión, y cuando se hubiera acordado una calificación legal más leve en relación a la audiencia imputativa (CPP, 339.5-6). Cuando la pena propuesta fuera mayor de ocho años de prisión, se requiere adicionalmente el aval del Fiscal General (CPP, 339.6). Como resguardo adicional, cuando la pena acordada fuera mayor a ocho años de prisión, la sentencia debe ser dictada por un juez distinto del que resuelve la admisibilidad formal del acuerdo (CPP, 341).

§ 320. La regulación del procedimiento abreviado en Santa Fe se aparta del esquema acusatorio formal que en general tiene el código, e incorpora caracteres que claramente se corresponden con el modelo adversarial: la aceptación del imputado como mera declaración de culpabilidad, el reemplazo de la prueba por el acuerdo de partes, la inexistencia de causales de rechazo. Si bien no se autoriza expresamente que el acuerdo altere la calificación jurídica, esto tampoco está previsto como causal de rechazo. Sí se prevé la necesidad de venia regional para apartarse de la calificación establecida en la audiencia imputativa, lo cual se condice con el mayor componente político en la figura de los organismos directivos de la fiscalía.

No obstante, esta concepción adversarialista ha sido limitada fuertemente por la jurisprudencia: según el criterio actual de nuestra Corte provincial, corresponde al tribunal exigir a la fiscalía que indique las evidencias sobre la existencia de los delitos en grado de certeza, para resolver luego en forma oral y en la misma audiencia (fallo “Ruiz”, CSJSFe, 2019).

Y aun omitiendo toda mención al precedente “Ruiz”, el sistema no termina de ser totalmente discrecional, ya que existen controles internos en la fiscalía, cuya elusión acarrea la inadmisibilidad del planteo y su rechazo por motivos formales. Además de las eventuales responsabilidades institucionales y penales de los propios fiscales en caso de infracción a estos mecanismos.

Síntesis del capítulo

1. *La reforma procesal penal incluye un conjunto de institutos, predominantemente compositivos o negociales, que funcionan como alternativas a la resolución del caso por vía del juicio oral.*
2. *Desestimación: es una forma de desistimiento temprano de la acción penal, por inidoneidad del caso.*
3. *Archivo fiscal: es una forma de desistimiento de la acción, una vez que ya se ha celebrado audiencia imputativa. Se asemeja a un sobreseimiento en cuanto a sus causales, ya que requiere certeza negativa o duda insuperable. La negativa del fiscal a archivar, cumplidas ciertas condiciones, puede dar lugar al pedido de archivo jurisdiccional.*
4. *Sobreseimiento: es un pronunciamiento desincriminatorio, por certeza negativa, con efecto de cosa juzgada material. Se debaten los alcances del sobreseimiento por presentación conjunta, y qué rol le incumbe al tribunal en este caso.*
5. *Criterios de oportunidad: son supuestos de desistimiento reglado y controlado de la acción, por motivos predominantemente de política criminal. En su regulación actual, se reconoce una mayor intervención al tribunal, por lo cual su naturaleza también se discute.*
6. *Suspensión del procedimiento a prueba: es un instituto previsto originariamente en el Código Penal, que algunos hoy asimilan a un criterio de oportunidad. Existen distintas posturas sobre su procedencia (tesis amplia y restringida), prevaleciendo en la actualidad la tesis amplia.*
7. *El procedimiento abreviado es una forma de resolución del caso que implica la aceptación negociada de la condena por parte del imputado. Existen distintos modelos, que reconocen a las partes mayor o menor margen de negociación (por ejemplo, la posibilidad de alterar la calificación jurídica, o de aplicar penas menores a las previstas). En Santa Fe la regulación muestra rasgos claramente adversariales, aunque la jurisprudencia ha amplificado los alcances del control judicial.*

Capítulo 10. Etapas previas al juicio

a) Investigación penal preparatoria (IPP)

Nociones generales

§ 321. Siguiendo el sistema acusatorio formal, nuestro código regula una etapa investigativa, eminentemente preparatoria, cuya dirección se encomienda a la fiscalía. El objetivo central de esta etapa es identificar a los autores y partícipes del hecho reputado como delictivo, y recolectar los elementos que permitan llevar el caso a juicio o eventualmente lograr una alternativa consensuada.

La dirección de la IPP está a cargo de la fiscalía, que actuará con la colaboración de los organismos investigativos. La actividad investigativa está sujeta al control por parte del tribunal y de la defensa.

Relación con los organismos investigativos

§ 322. En primer lugar, la fiscalía se relaciona con las agencias encargadas de llevar adelante la investigación penal, quienes actúan bajo delegación. En nuestro caso, puede tratarse de:

- El Organismo de Investigaciones del MPA.
- La Policía de Investigaciones (luego denominada Agencia de Investigaciones Criminales), que en Santa Fe funciona como una subdivisión interna de la propia policía.
- La policía común, en la medida en que cumpla funciones investigativas.
- Las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria), en la medida en que se les requiera colaborar en investigaciones a nivel provincial o tomar parte en investigaciones conjuntas.

En concreto, las tareas investigativas podrán ser desarrolladas por alguno de estos actores, según las características del caso, los protocolos internos de la fiscalía y las limitaciones jurídicas e institucionales de cada agencia. Así, el Organismo de Investigaciones del MPA tiene regulado legalmente en qué casos puede intervenir, siendo un organismo creado para investigaciones de alta complejidad. En un segundo escalón se ubicaría la Agencia de Investigaciones Criminales, en cuanto es una rama especializada de la propia policía. La policía común, además de intervenir investigativamente en los casos de menor complejidad, colabora en los demás casos cumplimentando las primeras diligencias y asegurando la escena.

Cualquiera de estos organismos, en cuanto actúe en el marco de una investigación penal, se encuentra en una situación de subordinación funcional respecto de los fiscales intervinientes. En la estricta medida de sus facultades investigativas, la autoridad del fiscal está por encima de cualquier directiva impartida por los superiores jerárquicos de la institución que se trate.

Rol del tribunal durante la IPP

§ 323. La intervención del órgano judicial durante la IPP se produce de manera intermitente, ya que no sólo el juez no está a cargo de la investigación, sino que tampoco posee facultades generales de supervisión. En nuestro sistema, la función del juez durante la etapa investigativa está limitada a los casos en que existe objetivamente el riesgo de afectar derechos fundamentales de las personas. En estos supuestos, se impone la intervención judicial como una forma de garantizar que aquellas afectaciones pasen por el filtro de un tercero no involucrado en el resultado de la investigación.

Este nuevo rol del juez durante la etapa investigativa le ha valido en otras provincias la denominación de “juez de garantías” o “juez de control”. En Santa Fe se denomina *juez de la investigación penal preparatoria*, lo que ni siquiera se corresponde con su función real ya que también interviene en el procedimiento intermedio.

Audiencia imputativa (formalización de cargos)

§ 324. El código prescribe que en determinado momento deben formalizarse los cargos contra el imputado, para lo cual se regula la *audiencia imputativa* (CPP, 274). Hasta que esta instancia no se cumple, la fiscalía no podrá

solicitar medidas coercitivas contra el imputado, ni tampoco podrá formular acusación.

En su regulación actual, que ha sido objeto de varias reformas, la audiencia imputativa puede tener uno de los siguientes formatos:

- *Imputativa en sede fiscal*, cuando la persona imputada se encuentra en estado de libertad. Se trata en rigor de una *seudoaudiencia*, dado que no se desarrolla en estrados judiciales ni interviene un tribunal. El Anteproyecto de 1993 reemplazaba esta instancia por una comunicación escrita, y por nuestra parte sostenemos que actualmente es posible adoptar ese formato por acuerdo de simplificación entre partes (CPP, 13).
- *Imputativa en sede judicial*, cuando la persona imputada se encuentra detenida. En este caso la audiencia debe celebrarse dentro de las setenta y dos horas (con posibilidad de prórroga de hasta veinticuatro horas) desde el inicio de la privación de libertad, y tendrá lugar frente al tribunal, que deberá realizar el *control de detención*. También en esta misma audiencia pueden solicitarse medidas coercitivas, aunque la fiscalía bien puede optar por pedir una audiencia específica a tal fin.

Los sujetos que intervienen en la audiencia imputativa son el fiscal, el imputado, el defensor técnico y eventualmente el querellante si estuviera constituido. Además de la eventual presencia del magistrado, si el imputado (o uno de ellos, si fueran varios) estuviera detenido.

Durante la audiencia imputativa se cumplen las siguientes actividades:

- El *control de detención* debería ser la primera actividad en cumplirse, cuando el imputado estuviera detenido.
- La fiscalía *informará al imputado* el hecho atribuido, su calificación jurídica, los elementos probatorios obrantes y los derechos que le asisten.
- El imputado podrá solicitar ser oído, e incluso manifestar su conformidad para ser interrogado por el fiscal. A los efectos de decidir si hace uso de este derecho, podrá entrevistarse privadamente con su defensa técnica.
- En esta instancia es altamente recomendable (y el código lo sugiere en el artículo 275.3) que la fiscalía ponga a disposición del imputado y de su defensa *propuestas concretas para la aplicación de salidas alternativas al juicio oral*, tales como la suspensión a prueba y el procedimiento abreviado.

Esta última actividad funciona mejor cuando se trata de una imputativa en sede fiscal, instancia que tiene el potencial para convertirse un *espacio de negociación* entre partes y de resolución pacífica de los conflictos.

§ 325. En cuanto a su funcionalidad, y sintetizando algunos elementos ya expuestos, la audiencia imputativa produce los siguientes efectos:

- Fija inicialmente el hecho atribuido, lo que tendrá un impacto directo sobre el principio de congruencia. A tal punto, que si posteriormente se modificaran los hechos atribuidos o su calificación legal, o se pretendiera atribuir un hecho nuevo, se impone la realización de una nueva audiencia (CPP, 281).
- Permite materializar el derecho del imputado a ser oído.
- Permite canalizar tempranamente la aplicación de salidas alternativas.
- Brinda ocasión para el control judicial de la detención.
- Impone una mínima observancia del derecho de defensa (materializado en la posibilidad de contestar la imputación delictiva) como presupuesto para la aplicación de medidas coercitivas (CPP, 219 -último párrafo-, 220 -último párrafo-).
- Una vez realizada, permite a las partes acceder a las actuaciones (salvo que se ordenara su reserva: CPP, 259).
- Formaliza la situación procesal del imputado, que como hemos visto nace con anterioridad (CPP, 100). A partir de este momento, comenzará a correr el plazo de diez meses que hará exigible el dictado de archivo fiscal o en su defecto la resolución de archivo jurisdiccional (CPP, 289, 290). En idéntico sentido, si con posterioridad a la audiencia imputativa la fiscalía arriba a un juicio desincriminatorio o dubitativo (por insuficiencia probatoria insuperable), dicho juicio dará lugar al archivo fiscal (CPP, 289), ya que cuando una persona es formalmente imputada tiene derecho a que su posterior desvinculación del proceso quede también formalizada.

Conclusión de la IPP

§ 326. Concluida la IPP sin haberse adoptado una salida alternativa, el fiscal podrá *formular acusación* y llevar el caso a juicio oral (CPP, 294). La pieza acusatoria deberá contener los datos personales del imputado, el relato de los hechos, los fundamentos de la acusación y los elementos de convicción que la motivan, la calificación legal aplicable, la solicitud de pena o medida de seguridad con sus fundamentos correspondientes y la solicitud de apertura del juicio (CPP, 295.1-6).

Con la acusación se acompañarán los documentos y medios de prueba materiales que se tuvieran (CPP, 295, penúltimo párrafo). También se prevé la

posibilidad de formular *acusación alternativa*, indicando las circunstancias de hecho que permitirían encuadrar la conducta del imputado en una calificación jurídico penal distinta (CPP, 295, último párrafo).

b) Procedimiento intermedio

Nociones generales

§ 327. Como se ha adelantado, el código regula un *procedimiento intermedio* entre la investigación y el juicio. Si bien la existencia de esta etapa no es algo novedoso (en los antiguos sistemas, consistía en un decreto o auto de elevación a juicio), es justo decir que los sistemas reformados la han amplificado notablemente.

En cuanto a su naturaleza, habría al menos dos posiciones que señalar:

- ***Procedimiento no autónomo dentro de la IPP.*** Hay quienes evitan hablar de *etapa intermedia*, y consideran al procedimiento intermedio como *una parte de la etapa de investigación penal preparatoria*. Desde esta posición, se aduce que si el procedimiento intermedio se reconociera como una auténtica etapa, el principio de preclusión impediría que aquí puedan sanearse actos investigativos, porque ello implicaría volver a una etapa ya clausurada.
- ***Etapa procesal autónoma.*** Por nuestra parte, encontramos preferible reconocerle al procedimiento intermedio el carácter de etapa procesal. Para ello, consideramos no menor el hecho de que la amplificación de la etapa intermedia es uno de los temas centrales en los modernos procesos de reforma en América Latina, y es un complemento necesario de sistema de alternativas al juicio oral. En cuanto a la objeción relacionada con el principio de preclusión, cabe señalar que dicho principio proviene del marco teórico del proceso civil (o en el mejor de los casos de la Teoría General del Proceso), por lo cual su alcance en el marco del proceso penal resulta siempre discutible.

Así, nuestra etapa intermedia amplificada (o procedimiento intermedio, aclarando que utilizamos ambas expresiones como equivalentes) puede perseguir, según el caso, una de dos finalidades: *evitar el juicio*, o *sanear el juicio*.

Finalidades

§ 328. La *finalidad primaria* del procedimiento intermedio es evitar la realización de juicios orales innecesarios. Atento a que esta etapa se abre una vez agotada la investigación y formulada la acusación, su lógico presupuesto es que las partes no hayan arribado a una solución de tipo negocial. Esto puede deberse a dos factores: o el caso es sumamente grave y las posiciones son irreductibles, o las partes han negociado con negligencia. En el primer supuesto, no queda mucho por hacer en cuanto a esta finalidad primaria: el fiscal debe acusar, y el imputado tiene derecho a defenderse en juicio. Ahora bien, si llegamos hasta aquí porque las partes no han sabido acercar sus posiciones, porque no se molestaron en dialogar o sencillamente porque no se les ocurrió hacer otra cosa (caso muy frecuente), no parece lógico que deba utilizarse el recurso más costoso del sistema judicial para suplir la ineficacia profesional. Esto no es algo que incumba sólo a las partes, ya que no hay ningún derecho a gastar los dineros públicos en litigar por litigar. Por ello, en este momento procesal el juez tiene la facultad de interactuar con las partes, proponiendo la adopción de salidas alternativas siempre que ello fuera viable.

Este rol proactivo del juez en la etapa intermedia despierta alguna perplejidad. Ello se debe, principalmente, a que suele extenderse indebidamente la mecánica del juicio oral a las audiencias previas (como luego se verá). Pero también a que no siempre está claro cómo y hasta qué punto el juez puede salirse de su posición de prescindencia. Concretamente, hay que señalar que el juez no puede presionar ni influir indebidamente a ninguna de las partes para que se avenga a una solución negociada, y en particular debe guardar la mayor prudencia al sugerir la aplicación del juicio abreviado. Sí puede, en cambio, preguntar a los acusadores qué tipo de propuestas han formulado, indagar por los motivos de la no aceptación, e incluso formular alguna propuesta superadora dentro de lo que el caso permita. Pero si las partes insisten en resolver su disputa mediante el juicio oral, no cabe clausurarles esa posibilidad.

Siguiendo con la finalidad primaria de evitar juicios orales innecesarios, también es posible utilizar la etapa intermedia para plantear nulidades, excepciones y mecanismos extintivos. Así por ejemplo, si se plantea la nulidad de un acto del cual se derivan todos los posteriores, o cuyo peso probatorio sea tan decisivo que hace tambalear el caso de la acusación, es altamente recomendable hacerlo en esta ocasión. De lo contrario, la nulidad deberá declararse en la sentencia, y luego de desarrollado un juicio oral absolutamente innecesario.

También puede plantearse el sobreseimiento, que en cuanto a sus efectos constituye un mecanismo extintivo de la persecución penal. Esto no obsta a

seguir considerándolo un mecanismo de resolución alternativa, ya que también admite la vía consensual.

§ 329. Ya sea por la importancia del caso o por la tozudez de las partes, es inevitable que algunos casos pasen a juicio oral. Ante este escenario, el juez del procedimiento intermedio tiene aún una *finalidad secundaria o subsidiaria* que cumplir: evitar que los juicios orales se vuelvan engorrosos. Aquí deberá analizarse la pertinencia de la prueba ofrecida en relación a los hechos a acreditar, y fundamentalmente deberá prestarse atención a la prueba sobreabundante o de cualquier forma innecesaria. El fundamento de esta segunda finalidad es el mismo que el de la finalidad primaria: la necesidad de evitar que las partes malgasten los recursos del sistema judicial. Por ello, el juez en esta instancia podrá:

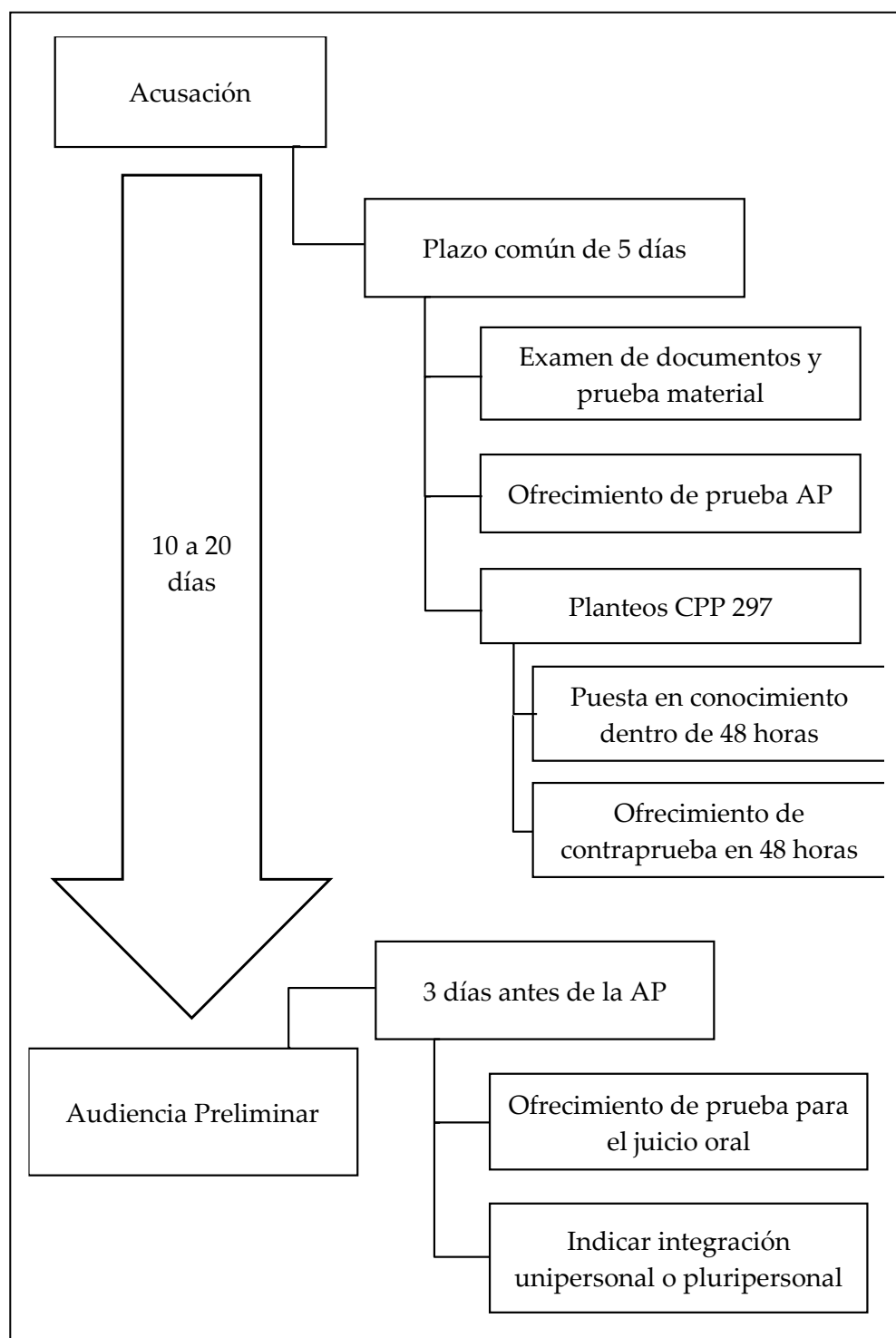
- Proponer acuerdos probatorios respecto de hechos no controvertidos. Esto es particularmente recomendable cuando se invoca una defensa activa (por ejemplo, que el hecho se cometió en estado de necesidad justificante), ya que dicha línea argumental supone reconocer en parte la plataforma fáctica del acusador. De arribarse a un acuerdo parcial en este punto, el debate podrá limitarse a si se verifican o no los presupuestos fácticos de esta defensa, no siendo necesario producir prueba sobre el hecho principal. También puede acudir a este mecanismo cuando se trata de circunstancias notorias o cuyo conocimiento se presupone en los intervinientes, tales como la minoría de edad, el vínculo familiar, la identidad de género o la condición de funcionario público.
- Instar a las partes para que desistan de prueba sobreabundante. Esto puede ocurrir porque hay pruebas objetivamente mejores que otras (por ejemplo, cuando se pretende probar por testigos algo que fue absolutamente captado por cámaras de video), o sencillamente porque se ofrecen demasiados testigos en relación a la gravedad e importancia del hecho que se pretende probar. Esto último depende -insistimos- del caso concreto: quinientos testigos no son demasiados para un caso de genocidio, pero sí lo son para un puñetazo en la cancha de fútbol. En cualquiera de estos casos, si las partes no reducen voluntariamente su caudal probatorio a una cantidad razonable, el juez puede desechar la que se considere excesiva.

Aspectos procedimentales

§ 330. El procedimiento intermedio comienza con la formulación de la acusación (CPP, 294). El núcleo de esta etapa es la audiencia preliminar (CPP, 296), a la que se llega luego de algunas instancias escritas de intrincada regulación.

- La audiencia debe ser convocada en un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte (CPP, 296, segundo párrafo).
- Desde la fecha de la convocatoria, se abre un plazo común de cinco días en el que las partes podrán examinar los documentos y las pruebas materiales (CPP, 296, primer párrafo). De esta forma, se materializa el *descubrimiento* de la prueba de cargo, y se da la posibilidad a la defensa para que prepare su estrategia procesal y ofrezca prueba de contrarresto.
- Dentro del mismo plazo común de cinco días, las partes podrán, por escrito: señalar los vicios formales de la acusación, oponer excepciones, solicitar el sobreseimiento, proponer la aplicación de un criterio de oportunidad, solicitar la suspensión del juicio a prueba, hacer planteos relativos a medidas cautelares, solicitar anticipo jurisdiccional de prueba, proponer la aplicación del procedimiento abreviado, proponer la conciliación o realizar planteos relativos a la preparación del juicio (CPP, 297.1-11).
- También dentro de aquel plazo común de cinco días, las partes podrán ofrecer la prueba específicamente para las cuestiones propias de la audiencia preliminar (CPP, 300).
- De realizarse alguna presentación de las previstas en el artículo 297, la misma será puesta en conocimiento de las demás partes dentro de las cuarenta y ocho horas (CPP, 297, último párrafo). Desde esta puesta en conocimiento, las demás partes tendrán a su vez cuarenta y ocho horas para ofrecer su propia prueba específica de la audiencia preliminar (CPP, 300, segundo párrafo).
- Tres días antes de la audiencia preliminar, las partes deberán ofrecer la prueba para el juicio oral, acompañando la nómina de testigos y la documental, y deberán indicar si a su criterio corresponde que el tribunal se integre de manera unipersonal o pluripersonal (CPP, 299).

Esquemáticamente, la estructura de esta etapa sería la siguiente:



Críticas a la regulación actual

§ 331. Como puede advertirse, la actuación de las partes en la etapa intermedia aparece completamente tabulada. Se ha privilegiado que los litigantes vengan con los deberes ya hechos, lo cual tal vez sirva para minimizar el pánico escénico, pero a costa de quitarle toda espontaneidad a la audiencia. Asimismo, la concatenación de plazos hace que se pase de corrido y con muy poca antelación, de las cuestiones propias de la audiencia preliminar a la preparación del juicio propiamente dicho. Por ejemplo, si se formulan planteos a tenor del artículo 297 del CPP, la réplica de las partes puede darse hasta nueve días después del decreto de puesta en conocimiento de la acusación, pudiendo superponerse esta actividad con el ofrecimiento de prueba para el juicio oral, que puede tener lugar entre siete y diecisiete días desde aquella puesta en conocimiento (según la AP se fije en un plazo de diez a veinte días, y de ahí tres días antes...). Es decir, se llega al extremo de ofrecerse prueba para un juicio que bien podría no tener lugar si prospera un planteo que extinga, paralice o retrotraiga el proceso (por ejemplo: CPP, 297.1,3,4,5,6,9,10).

Esta sobreescriturización acarrea algunos problemas adicionales. Como las partes llegan a la audiencia preliminar con las presentaciones ya realizadas, normalmente las exposiciones orales son redundantes y poco claras, por el inevitable deseo de que la alegación oral coincida con el planteo escrito. Es decir, la instancia se convierte casi en una *audiencia leída*, con resultados muy poco satisfactorios dadas las importantes finalidades que esta etapa debe cumplir. En general, también estas audiencias suelen ser muy largas como para que las partes -¡y el tribunal!- mantengan debidamente la atención e interactúen de manera provechosa.

En general estamos hablando de problemas prácticos o empíricos, pero que están fuertemente condicionados por errores en el diseño legal. Dependerá de los operadores que esta etapa despliegue toda su funcionalidad, evitándose así que el sistema se sobrecargue de juicios orales innecesarios y engorrosos.

c) Audiencias previas al juicio

La oralización de las etapas previas y el surgimiento de las APJ

§ 332. Los actuales procesos de reforma traen como innovación la *oralización de casi todas las instancias decisivas del proceso penal*. Ello trae aparejado que, así como se estudian las técnicas de litigación propias del juicio oral, deban considerarse también los aspectos técnicos de las audiencias previas al juicio (APJ). Dicho de otro modo, las APJ tienen una especificidad técnica que amerita un estudio y hasta un entrenamiento diferenciado.

Dentro de las APJ se incluyen todas las que tienen lugar durante la etapa investigativa, como así también la audiencia preliminar, durante el procedimiento intermedio. Puede afirmarse en general que cualquier decisión judicial previa al juicio oral debe ser solicitada y argumentada en una audiencia específica. Sin embargo, también encontramos que:

- Las cuestiones cautelares (allanamiento, interceptación, secuestro) se despachan sin conocimiento de la contraparte, por obvias razones de efectividad. Con lo cual no generan audiencia, o generan una audiencia unilateral (por ejemplo: CPP, 259, tercer párrafo).
- Algunos planteos no controvertidos permiten al tribunal resolver directamente sin audiencia, lo cual hace surgir por defecto una tramitación escrita. Evidentemente, la idea ha sido descomprimir la agenda judicial, reservando el mecanismo de la audiencia principalmente para cuando el asunto se manifiesta litigioso.
- Existen audiencias que no tienen por objeto lograr un pronunciamiento jurisdiccional, sino materializar una instancia garantizadora. Así ocurre, por ejemplo, con la *audiencia imputativa* y con el *control de detención*.
- Finalmente, hay audiencias sin tribunal o *seudoaudiencias*, como la *imputativa en libertad* o la *declaración previa de testigos* durante la etapa investigativa. A pesar de su denominación, estas instancias no pueden considerarse realmente audiencias según su acepción constitucional (CADH, 8.1).

Caracterización

§ 333. El universo de las APJ es de lo más variado, desde el momento en que ni siquiera están enunciados legalmente los supuestos que dan lugar a

audiencia. Hay, por ende, audiencias innominadas o atípicas. Pero en general, puede trazarse la siguiente caracterización:

- Son audiencias *de objetivos limitados*. Se discute lo que constituye el objeto puntual del planteo, sin que quepa extenderse a cuestiones no agendadas. Sí hay, en casos puntuales, *audiencias multipropósito*, como puede ser la *imputativa en sede judicial*, que incluye el control de detención y hasta puede incluir la solicitud de cautelares, o la *audiencia preliminar*. Pero en general, y fuera de estos supuestos, se considera un acto de mala fe procesal realizar planteos ajenos al temario de la audiencia.
- Son audiencias *no tabuladas o de estructura flexible*. A diferencia del juicio oral, en el que cada paso está cuidadosamente regulado según un cierto orden, aquí puede haber un grado menor de rigidez. Si se quiere, son audiencias más descontracturadas, en cuanto los intervinientes pueden interactuar con más libertad, siempre y cuando se garantice a todas las partes el derecho a ser oídas.
- Como desprendimiento de lo anterior, *el propio tribunal tiene un rol más proactivo* que en el juicio oral (donde esta proactividad será vista como una pérdida de imparcialidad). En las APJ, el juez puede instar acuerdos de parte, requerir información adicional o solicitar aclaraciones. También puede, sin tanta sutileza, apurar a los litigantes cuando éstos en sus exposiciones se vayan por las ramas. Claro que esto tiene límites, ya que le seguirá estando vedado producir prueba de oficio y resolver en sentido más gravoso a lo solicitado por la acusación.
- Son audiencias *preponderantemente argumentativas*, puesto que en general no admiten la producción de prueba con la misma mecánica que en juicio. Como ya se ha señalado, la actividad probatoria se cumple escalonadamente según el grado de controversia, y hay un cierto orden ideal según se trate de testigos o de evidencia material. En términos generales, en las APJ suele haber un predominio de la prueba documental, y en particular de la *prueba preconstituida*.
- Como resultado de todo lo anterior, se espera que las APJ sean *breves y ágiles*. Las audiencias largas y tediosas, además de ser una carga poco tolerable para todos los intervinientes, atrasan el cronograma de sala y complican la agenda de trabajo de los participantes. Si bien es difícil fijar pautas temporales de manera abstracta, puede estimarse que una APJ debería durar entre cinco y diez minutos en la mayoría de los casos, y hasta treinta minutos en los supuestos más complejos. Para ello, las partes deben ser concisas en sus planteos, y el juez debe censurar de inmediato cualquier divagación.

Más allá de las APJ: las audiencias diversas al juicio

§ 334. Finalmente, y aunque ello implique un cierto apartamiento de la temática del capítulo, debe mencionarse que existe una tendencia a extender la mecánica de las audiencias previas al juicio a todas aquellas instancias orales en las que se decide un objeto preciso y limitado.

Esta mención luce pertinente, ya que precisamente en Santa Fe la reforma ha oralizado el recurso de apelación, y también son orales los incidentes durante la ejecución de la pena. Es decir, ya no se trata únicamente de los momentos previos al juicio, sino también de los momentos posteriores (en particular, los momentos recursivo y ejecutivo).

Por lo que cabe una aclaración: tal como comienza a advertirse en doctrina, las audiencias previas al juicio son una subespecie de una categoría más amplia, las *audiencias distintas al juicio*, o *audiencias diversas al juicio*, o *audiencias alternativas al juicio*. Bajo esta denominación más amplia, se incluirían todas aquellas instancias resolutivas orales que comparten una caracterización y una metodología de trabajo común, con la obvia exclusión del juicio de conocimiento plenario o contencioso.

Síntesis del capítulo

1. *La investigación penal preparatoria o IPP está a cargo del fiscal -siguiendo el modelo acusatorio formal-, con control judicial.*
 - a. *Este control en general se activa en instancias que suponen una afectación a los derechos de las personas intervinientes.*
 - b. *En esta etapa, deben formalizarse los cargos contra el imputado mediante la audiencia imputativa.*
 - c. *La IPP concluye cuando se adopta una salida alternativa, o cuando se formula requerimiento de acusación.*
2. *Se prevé una etapa intermedia, cuyas principales finalidades son agotar las posibilidades de llegar a una salida alternativa, y en el último de los casos sanear el juicio. El núcleo de esta etapa es la audiencia preliminar, que está precedida por una serie de actuaciones escritas entre las partes (ofrecimientos de prueba y otros planteos).*
3. *Las audiencias previas al juicio son un producto de la reforma, en cuanto implican la oralización de las etapas previas. Su desarrollo dio lugar a un conjunto de técnicas específicas de litigación. Hoy se habla también de audiencias distintas o diversas al juicio, para incluir las instancias orales recursivas y ejecutivas.*

Capítulo 11. Juicio oral y sentencia

a) Caracterización general de la etapa de juicio

La centralidad del juicio

§ 335. Hemos visto que la incorporación de mecanismos resolutivos alternativos al juicio que llamaríamos “contencioso” (y que Binder llama “proceso de conocimiento”) no disminuye en modo alguno la importancia y la centralidad que esta etapa posee. Muy por el contrario, el amplio margen de negociación que tienen las partes para arribar a soluciones compositivas realza aún más la etapa de juicio, a la que ahora no se llega por inercia, sino por una decisión consciente y estratégica de los litigantes: van a juicio oral, porque quieren ir a juicio oral, o porque les parece que es la opción que mejor satisface sus intereses.

Se ha señalado que en los modelos inquisitivos y mixtos la etapa instructoria prácticamente determinaba el resultado del pleito. Así, observaba Maier que *la instrucción se fagocitó al juicio*, aludiendo al debilitamiento del plenario como escenario de debate contradictorio, producto de la incorporación de materiales provenientes de la etapa preparatoria.

La reforma procesal reaccionó fuertemente contra esta tendencia, fortaleciendo el carácter oral y contradictorio del juicio. Prácticamente todos los actos que en los modelos mixtos implicaban lectura de documentos, fueron reemplazados por la actuación presencial directa: la lectura de la acusación, por los alegatos de apertura; la lectura de testimonios, por el interrogatorio cruzado.

Caracteres

§ 336. Para realizar una caracterización sintética, puede decirse que la etapa de juicio es:

- *Contenciosa* (contradictoria en sentido material).
- *Adversarial* o *de partes* (contradictoria en sentido formal).
- Oral.
- Pública.
- Estructurada o rígida.
- Limitadora del conocimiento del tribunal.

A continuación, expondremos sintéticamente cada uno de estos caracteres.

§ 337. La instancia de juicio oral supone que *el caso se definirá en términos irremediablemente contenciosos*. Aquí el conflicto penal no se resolverá negociando o acercando posiciones, sino enfrentando cognoscitivamente dos (o más) teorías del caso, que se suponen incompatibles al menos parcialmente. Y al final de ese enfrentamiento, la cuestión quedará enmarcada en una opción binaria: condena o absolución, sin que quepan las soluciones intermedias. Por eso se dice que esta etapa es contradictoria en sentido material, porque materializa la confrontación entre partes en cuanto al fondo del caso sometido a proceso.

En este enfrentamiento, todas las partes se están jugando ganar o perder con respecto al contenido de sus pretensiones. Adicionalmente, la persona imputada se estará jugando mucho más, si se piensa que es en definitiva quien tendrá que asumir las eventuales sanciones penales que se impongan en caso de declararse su culpabilidad.

Este riesgo adicional en cabeza del imputado supone que también sus facultades defensivas puedan desplegarse en forma completa. Si bien la defensa penal funciona en todas las etapas del proceso, es en la etapa de juicio donde se desarrollará en su sentido más clásico: como un conjunto de herramientas para resistir y contrapesar la actividad acusatoria.

§ 338. Hemos dicho que el código santafesino sigue en términos generales el modelo acusatorio formal, aunque es clara la presencia de rasgos adversariales en lugares y temáticas específicas. Pues bien, la regulación del juicio oral es precisamente uno de esos ámbitos donde se observa un *predominio del principio adversarial*, lo que marca un contraste con otras etapas procesales.

Algunas manifestaciones del principio adversarial en la etapa de juicio son:

- La posición de *absoluta neutralidad* en la que se coloca al tribunal, vedado por completo de cualquier posible actuación de oficio durante el debate. Esto se complementa con la prohibición expresa de aplicar penas más graves que las solicitadas por los acusadores (CPP, 335).

- La mecánica probatoria del *interrogatorio cruzado*, en la que pesa sobre las partes tanto la formulación de preguntas como su control mediante las objeciones (CPP, 325, 325 bis). En el mismo sentido, el hecho de que cada parte determine el orden de la prueba que presenta (CPP, 323).
- El hecho de *que sean las partes las que definen el objeto procesal* al momento de los alegatos de apertura (CPP, 317), en reemplazo de la antigua práctica (de los códigos mixtos) de dar lectura al requerimiento acusatorio. Esto determina un estilo de litigación con un claro formato bilateral desde el inicio.

§ 339. Que el juicio sea oral no parecería ser un dato llamativo, dado que prácticamente todo el proceso es oral, aún las etapas previas. Sin embargo, debe señalarse como nota distintiva de los sistemas reformados la *búsqueda de la oralidad efectiva*.

Cuando se habla de oralidad efectiva, se alude por oposición a una de las mayores críticas al funcionamiento real del sistema mixto en América Latina: la oralidad meramente ritual de un modelo de enjuiciamiento basado en la incorporación promiscua de prueba por lectura.

Un juicio verdaderamente oral es aquel en el que se verifican los llamados *corolarios o reglas de la oralidad*:

- **Inmediación.** El debate y la prueba tiene lugar frente a todos los intervinientes, por lo que el tribunal percibe directamente todo lo que ocurre y forma su convicción sin la intermediación de las actas escritas. Esta regla va acompañada de ciertas cláusulas de complemento que tienden a evitar la desnaturalización de la forma oral, como la prohibición de la lectura de memoriales (CPP, 311), el uso restrictivo de declaraciones previas (CPP, 326, segundo párrafo) y la oralización de la prueba material (CPP, 326, tercer párrafo).
- **Celeridad.** Tiene que ver con la agilidad de la audiencia oral como método de resolución, frente al ritualismo burocrático que frecuentemente genera la tramitación escrita.
- **Concentración.** En el ámbito de la audiencia, se concentran actividades que en un trámite escrito se hubieran producido con separación temporal unas de otras. Por ejemplo, los testigos pasan uno tras otro, no hay una audiencia para cada testigo.
- **Continuidad.** La audiencia se desarrolla de corrido hasta agotar su cometido, al menos como regla. En el juicio oral, si se suspende el debate por más de quince días, el mismo será invalidado y deberá reiniciarse (CPP, 312).

- **Identidad física del juzgador.** Los magistrados que dictan la sentencia deben ser físicamente los mismos que presenciaron la totalidad del debate, como condición de validez del resolutorio. Si a mitad de un juicio o de una audiencia el juez -o uno de ellos si el tribunal es pluripersonal- padece un impedimento insuperable, no queda más alternativa que reiniciar la etapa correspondiente.

Como derivación del carácter netamente oral del juicio, *la registración del debate se realiza por medios audiovisuales*. Esto permite que, en caso de interponerse recursos contra la sentencia, el tribunal de alzada cuente con el soporte material adecuado para cumplir con el *máximo esfuerzo revisor*. La práctica del registro audiovisual en todos los casos (y más allá del supuesto de negarse la integración plural, previsto en el CPP, 143) tiende también a erradicar la nefasta práctica de *hacer constar todo en acta* en miras a la eventual impugnación: la idea es que los litigantes trabajen para convencer al tribunal de juicio, no para plantar futuros agravios.

§ 340. La **publicidad del juicio** tiende a posibilitar el control republicano de los actos de gobierno. Además, constituye una garantía esencial para la persona acusada, en cuanto visibiliza cualquier posible arbitrariedad por parte del tribunal.

Que el juicio sea público significa que debe realizarse a puertas abiertas, con posibilidad efectiva de ser presenciado por cualquier persona sin mayores formalidades. En este sentido, debe llamar nuestra atención cierta práctica restrictiva que se observa en algunos foros, consistente en requerir al público que acredite algún tipo de interés en el caso (por ejemplo, ser familiar de la persona imputada). Otra práctica desalentadora es la falta de exhibición pública de la agenda judicial, lo que obliga a los asistentes a tener que pasar por ciertos filtros institucionales (preguntar en mesa de entradas, identificarse ante un puesto policial, etc.) antes de acceder a presenciar una audiencia. Esto no ocurre siempre y no ocurre en todos lados, pero igualmente conviene estar atentos.

Excepcionalmente, el tribunal puede disponer que el debate se lleve a cabo a puertas cerradas, cuando la publicidad pudiera afectar a quien alegue su condición de víctima, a terceros o a la seguridad del Estado (CPP, 311).

§ 341. El juicio oral es **estructurado o rígido**, en contraposición al carácter relativamente flexible de las audiencias previas (APJ). A pesar de la mala prensa que estos adjetivos puedan tener, aquí cierta estructuración es indispensable para materializar garantías básicas de las partes, y especialmente de la persona acusada.

- *En cuanto los actos* que tienen lugar durante el juicio, la estructuración en etapas y secuencias rígidas permite que las partes conozcan de antemano los pasos procesales que siguen. Esto evita las sorpresas -que en el marco de un proceso son *siempre* desagradables- y brinda tiempo de preparar adecuadamente cada intervención.
- *En cuanto a los roles*, la rigidez extrema es la garantía contra cualquier extralimitación: así como no corresponde exigir a la defensa que colabore con el proceso como si fuera un auxiliar del juez, tampoco debe tolerarse que tribunal que produzca prueba de oficio o intervenga proactivamente en su producción. Cada uno debe atenerse de manera estricta al rol que desempeña, sin interferir en las funciones de los demás intervinientes.

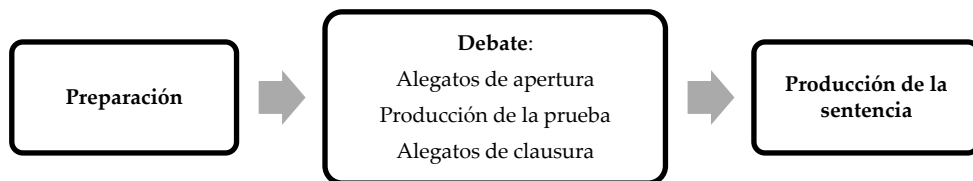
§ 342. La instancia de juicio es *limitadora del conocimiento del tribunal*, por cuanto en ella se exponen las distintas teorías del caso en pugna, de cuya confrontación surge el objeto litigioso. El tribunal debe resolver exclusivamente en base a lo manifestado por los litigantes, sin poder incorporar hechos nuevos o no previstos en los alegatos de apertura. Respecto de los hechos atribuidos a la persona acusada, la limitación es más estricta, ya que no puede alterarse la base fáctica contenida en el auto de apertura de juicio (CPP, 304.2).

El juicio también opera como *instancia limitadora en cuanto a la prueba*, ya que la sentencia no puede basarse en elementos de convicción no incorporados al debate (CPP, 333.2). En esta categoría se incluyen las constancias del legajo investigativo, como también las fuentes extraprocesales (como publicaciones en medios masivos, o el conocimiento privado del juez sobre una materia determinada).

b) Estructura y desarrollo

Esquema general

§ 343. Hemos visto que el juicio oral tiene tres momentos bien diferenciados: *preparación, debate y producción de la sentencia*. Durante el debate tendrán lugar, secuencialmente, los *alegatos de apertura*, la *producción de la prueba* y los *alegatos de clausura*.



Preparación del debate

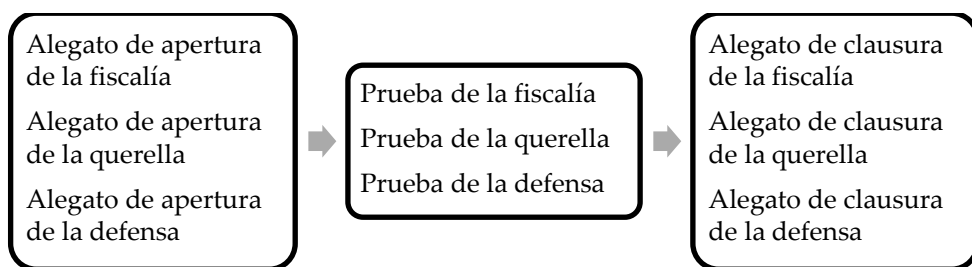
§ 344. La *preparación del debate* incluye centralmente tres actividades: la integración del tribunal, la fijación de fecha y hora de inicio del juicio, y el libramiento de citaciones.

- La *integración del tribunal* se realiza por sorteo u otro método aleatorio, designándose uno o tres jueces según corresponda. Una vez resueltos los eventuales pedidos de apartamiento, se notifica la integración definitiva.
- Integrado el tribunal, *se fija fecha y hora de inicio del juicio*. La fecha debe oscilar entre los diez y los treinta días corridos, lo que sirve a las partes para prepararse adecuadamente.
- Con la fijación de audiencia, deben *librarse las citaciones* a todos los intervinientes (testigos, peritos) y ponerse las actuaciones a disposición del tribunal.

Debate

§ 345. El *debate* es algo más complejo, pero esquemáticamente puede desagregarse en tres actividades: alegatos de apertura, producción de la prueba y alegatos de clausura. En cada una de estas tres actividades, elementales razones de salvaguarda del derecho de defensa imponen que sea la acusación la que actúe primero. En caso de haber fiscal y querellante en forma conjunta, la fiscalía actúa primero.

En la hipótesis más compleja (caso con fiscal y querellante), el esquema sería el siguiente:



En los demás supuestos el esquema es idéntico, sólo que según el caso será sin querella (actuando la fiscalía exclusivamente) o sin fiscalía (delitos de acción privada, originaria o por conversión). Ante la pluralidad de imputados, habrá asimismo varias defensas que actuarán según un orden impuesto para el caso.

Debe quedar absolutamente claro que *esta estructura es inamovible en cuanto a las etapas que la componen* (alegatos-prueba-alegatos). No resulta admisible, por ejemplo, que la fiscalía pretenda convocar a un nuevo testigo luego de producida la prueba de la defensa, ni que se agregue prueba una vez cumplidos los alegatos de clausura. Sí puede haber alguna flexibilidad, en casos excepcionales, *dentro de cada una de estas etapas*: por ejemplo agregándose testigos de refutación, o replicando el alegato de la contraparte.

§ 346. Entrando al análisis de cada una de estas etapas, los **alegatos de apertura** (CPP, 317, segundo párrafo) constituyen la instancia en la que cada litigante postulará ante el tribunal su teoría del caso. Harán uso de la palabra en el orden ya explicado, sintetizando la línea de la acusación y de la defensa respectivamente. La parte que está alegando no puede ser interrumpida por las demás ni por el tribunal, ni aun con el pretexto de corregirle inexactitudes o señalarle errores. Sin embargo, el litigante puede ser urgido -de oficio o a pedido de parte- en caso de manifiesto abuso de la palabra. No está previsto que las partes puedan hacer réplica en los alegatos de apertura.

En los sistemas adversariales se prevé la posibilidad de que la defensa posponga su alegato de apertura hasta que la fiscalía presente su prueba. Esta cláusula es particularmente garantizadora, ya que permite postular una teoría defensiva con base en la prueba efectivamente producida en el debate. Nuestro código no hace esta concesión, con lo cual si la defensa no hace uso de la palabra en los alegatos de apertura se entiende que desiste de esa facultad.

La **producción de la prueba** sigue como regla la mecánica del interrogatorio cruzado: cada testigo (en sentido amplio) es interrogado en primer lugar por la

parte que lo ofreció, y luego por las demás (CPP, 325 bis). Cada litigante decide el orden en el que presenta su prueba (CPP, 323), lo cual es coherente con la idea de *proceso de partes* que impera en la etapa de juicio. Las pruebas producidas deben haber sido admitidas en la etapa intermedia (CPP, 303.9), aunque puede ofrecerse *prueba nueva* durante el juicio alegando fundadamente que antes se la desconocía (CPP, 324).

Hay dos sujetos que también pueden declarar por fuera de la regla del interrogatorio cruzado: la *víctima*, a quien normalmente se le reconoce el derecho a ser oída luego de los alegatos de clausura (por interpretación extensiva del CPP, 80.10), y la *persona imputada*, que puede realizar declaraciones espontáneas en cualquier momento del juicio (CPP, 318, 320). A diferencia de otras legislaciones, el código santafesino no prevé que el imputado tenga la última palabra, aunque esto igualmente se cumple (un poco porque resulta garantizador, un poco por costumbre).

§ 347. Finalizada la producción de prueba, corresponde dar la palabra a las partes para que hagan sus *alegatos finales* (o *de clausura*, o *discusión final*; CPP, 329). Los alegatos finales tienen dos grandes diferencias con respecto a los de apertura:

- Contienen una teoría del caso que ahora se completa con una *teoría probatoria definitiva*. Es decir, el litigante debe analizar su teoría inicial, y enriquecerla con una *propuesta de valoración de la prueba* dirigida al tribunal. No se excluye que, a la luz de los hechos que efectivamente se han podido probar, las partes moderen o reformulen parcialmente sus pretensiones iniciales (por ejemplo, la fiscalía puede solicitar la absolución).
- Como consecuencia de lo anterior, esta *es una instancia que se supone más extensa*, a punto tal que admite réplicas. Sin embargo, las réplicas están limitadas a los argumentos adversarios que antes no hubieran sido discutidos.

Una vez cumplida la discusión final, y eventualmente las palabras finales de la víctima y de la persona imputada, se clausura el debate.

Producción de la sentencia

§ 348. La última etapa del juicio es la *producción de la sentencia*, que procedimentalmente tiene dos aspectos: la forma y plazo para su comunicación y la formación de la voluntad plural.

El código faculta al tribunal a escalonar la comunicación del contenido de la sentencia: el *decisorio* (sería la parte dispositiva) se comunica en audiencia, en un plazo no mayor a dos días, que admite una prórroga hasta de tres días más, mientras que los *fundamentos*, si no son dados a conocer en la misma audiencia, pueden diferirse hasta por cinco días más.

Las reglas sobre *formación de la voluntad plural*, que obviamente operan cuando el tribunal es pluripersonal, están reducidas al *orden de tratamiento de las cuestiones* (CPP, 332). No hay, en cambio, reglas sobre votación y mayorías. Sin embargo, habiendo orden de tratamiento es pacíficamente aceptado que se vota por separado cada cuestión (el sistema opuesto sería el de la “solución global”). Si hay distintas posturas en cuanto al monto de la pena a imponer (tratándose de penas divisibles), cabe estar al promedio de los tres votos (CPP, 138).

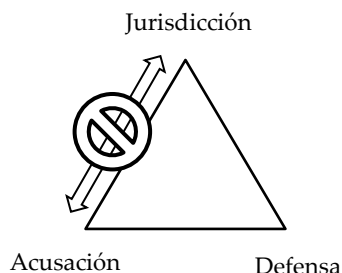
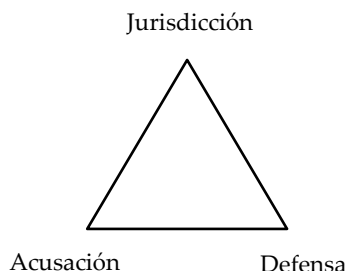
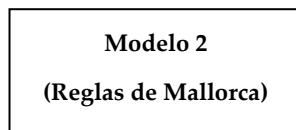
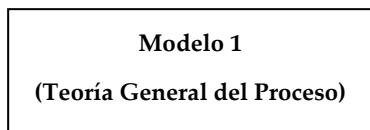
c) Rol de los sujetos

El tema desde la TGP y desde las Reglas de Mallorca

§ 349. Hemos visto que nuestro proceso penal se rige en términos generales por el modelo acusatorio formal, que impone una clara división entre los roles de acusación, defensa y jurisdicción. Esto se corresponde con la idea misma de proceso, como debate entre dos iguales ante un tercero imparcial, por lo cual un sector de la doctrina señala esta equidistancia entre los sujetos como una derivación de la Teoría General del Proceso.

Sin embargo, debe recordarse que entre nosotros el principio acusatorio formal no surge únicamente como una construcción teórica, sino como un fenómeno político en el marco de las reformas de los viejos modelos inquisitivos y mixtos en la Europa continental. De ahí que en instrumentos más actuales se insista particularmente en la *separación entre las funciones de persecución y juzgamiento* (Reglas de Mallorca, 2.1). Es decir que:

- Desde un punto de vista teórico, el modelo exige la separación de las tres funciones procesales básicas: acusación, defensa y jurisdicción (Modelo 1).
- Pero desde un punto de vista garantizador, lo que realmente debe preocuparnos es *que las funciones de acusación y jurisdicción se encuentren absolutamente separadas* (Modelo 2).



§ 350. Con todo, no se trata de miradas excluyentes sino complementarias. La equidistancia entre contendiente, resistente y juzgador (en el vocabulario de la TGP) es claramente un valor que hace al debido proceso, no sólo en materia penal. Adicionalmente, en materia penal la historia ha enseñado a estar particularmente atentos a la confusión de roles entre quien persigue y quien juzga: la instrucción judicial, la facultad del tribunal de interrogar al imputado y a los testigos, y hasta las medidas para mejor proveer, son algunas manifestaciones de esta confusión de roles. Confusión que en general tiende a colocar al tribunal en un lugar cercano al de la acusación, en desmedro de la garantía de imparcialidad y de la posición jurídica del imputado y de la defensa.

Sin embargo, es correcto plantear en términos más amplios la necesaria equidistancia *entre todas las partes*, ya que también es posible que el tribunal se inmiscuya indebidamente en el caso de la defensa. Por ejemplo, ordenando de oficio prueba de descargo, o formulando preguntas aclaratorias a los testigos con la intención de obtener una respuesta favorable al acusado. Ante la posibilidad de esta práctica, que de hecho se ha observado en sistemas inquisitivos y mixtos, debe reconocerse que la mirada de la Teoría General del Proceso resuelve el tema más adecuadamente que las Reglas de Mallorca.

Por eso no se plantean ambos enfoques como contrapuestos, sino que hay entre ambos una *diferencia de énfasis* sobre un aspecto puntual en la interrelación de los sujetos procesales.

Rol del tribunal

§ 351. Particularmente en la etapa de juicio, esta separación de roles es tajante. En cuanto al tribunal, esto implica que debe permanecer en una actitud pasiva durante la totalidad del debate. Tiene terminantemente prohibido formular preguntas, impulsar o proponer medidas de prueba, y en general hacer cualquier tipo de sugerencia o recomendación a las partes sobre el contenido de sus pretensiones o sobre sus respectivas estrategias procesales. Cualquiera de estas acciones por parte del tribunal o de alguno de sus integrantes, constituye causal de apartamiento (CPP, 68).

§ 352. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal tiene a su cargo la *dirección del debate*. Esta función de dirección se cumple ordinariamente aceptando o rechazando los pedidos de las partes, y resolviendo las objeciones e incidencias que se produzcan (CPP, 316). No obstante, puede actuar aún de oficio en cuestiones de orden y disciplina. También corresponde al tribunal participar en el llamado a testigos y peritos, la toma de juramento, los interrogatorios de identificación y en general en todas las cuestiones formales inherentes al desarrollo del proceso.

Ante un planteo concreto o meramente para ordenar el proceso, el tribunal puede convocar a las partes a conferenciar privadamente. Esta posibilidad resulta útil para formular advertencias a las partes, y para acordar pautas de trabajo sobre alguna cuestión particularmente delicada (por ejemplo, en relación a la forma de interrogar a la víctima o a un testigo menor, o para tratar la posibilidad de disponer que un acto se realice a puertas cerradas).

§ 353. Cuando el tribunal estuviera integrado pluripersonalmente, se designará a uno de sus integrantes para que actúe como presidente y ejerza las funciones directivas. Por supuesto que esto no impide que los demás integrantes del tribunal formulen sugerencias, ni tampoco que el juez presidente los consulte antes de tomar una decisión o de resolver un planteo.

En otros sistemas, se establece legalmente un mayor grado de división funcional al interior del tribunal: por ejemplo, asignándose roles de *juez presidente* (quien dirige la audiencia), *juez relator* (el que va tomando nota de las principales cuestiones) y el *juez vocal* (liberado de otras tareas durante el debate, es el que simplemente se dedica a enfocar su atención en el juicio, a efectos de emitir

el primer voto, con el que los demás pueden concurrir o disentir). Nuestro código no prevé expresamente esta división de roles, pero nada impide que de hecho se adopte por consenso algún esquema de trabajo similar.

Rol de la fiscalía

§ 354. Puede decirse que la fiscalía tiene un rol ineludiblemente protagónico durante el juicio, en un múltiples sentidos:

- Ha sido la fiscalía la que ha solicitado la apertura del juicio oral, y es sobre quien pesa primordialmente (aun habiendo querellante conjunto) la responsabilidad de argumentar y acreditar su caso en procura de obtener una condena.
- Adicionalmente, la fiscalía es responsable también de dirigir la investigación penal, con lo que también debe cargar con los eventuales déficits de los organismos investigativos que actuaron bajo sus directivas y supervisión.
- A diferencia de la defensa -que, como veremos, puede ser activa o pasiva-, la labor del acusador es *necesariamente activa*, sin que su falta de actividad pueda ser suplida por el tribunal.

Rol de la querella

§ 355. Recordemos que el rol de acusador puede ser cumplido tanto por la fiscalía como por la querella, o bien por ambos en forma conjunta. Si bien hay una relativa asimilación legal entre el fiscal y el querellante (CPP, 97), está claro que no pesan sobre éste más responsabilidades que las derivadas de su propio interés como parte.

La persona imputada

§ 356. Se considera esencial la presencia de la persona imputada en el debate, a fin de garantizar el eventual ejercicio de su defensa material. Este derecho se materializa, básicamente, con la posibilidad de declarar voluntariamente cada vez que lo solicite (CPP, 318, 320), y con la consiguiente prohibición del juicio en rebeldía.

Sin embargo, el código de Santa Fe relativiza dicha prohibición al permitir la continuación del debate en la ausencia del imputado, siempre que haya estado al momento de la apertura (CPP, 125, segundo párrafo, y 310).

Rol de la defensa técnica

§ 357. El rol de la defensa admite variaciones. Para empezar, debe decirse que la estrategia defensiva está supeditada siempre a la voluntad y a la decisión de la persona imputada. De ningún modo la opinión técnica está por encima de esta decisión, que es enteramente individual.

Admitido este condicionamiento, la estrategia defensiva puede adquirir alguna de las siguientes modalidades:

- La *defensa pasiva*, que consiste en aguardar a que la acusación presente su caso sin esgrimir una teoría del caso propia. Esto es posible centralmente porque pesa sobre el acusador la carga de la prueba, por derivación del principio de inocencia. Normalmente esta estrategia incluye una súbita activación de la defensa al momento de los alegatos finales, ocasión en la que se pretenden exponer las falencias de la acusación.
- La *defensa positiva*, es la que plantea una teoría del caso propia y completa (que incluye la teoría probatoria). Esto puede adquirir la modalidad de una *defensa de coartada* (el imputado estaba en otro lugar al momento de los hechos), de la *desviación hacia otro sospechoso* (plantea que el hecho pudo haber sido cometido por otra persona) o de la *invocación de una eximente* (por ejemplo, reconocer en parte el hecho pero plantear que se cometió en legítima defensa), entre otras posibilidades. En general, conviene que este tipo de defensa sea planteada con tiempo: preferentemente en los primeros momentos de la investigación.

Hay otros abordajes que suelen combinarse con alguna de las dos modalidades básicas descriptas, como el cuestionamiento sistemático de la prueba de cargo, el planteo de nulidades o exclusiones probatorias, y en general la desacreditación de la labor fiscal y policial. También puede darse una estrategia de *control de daños*, cuando se considera inviable toda otra línea defensiva más ambiciosa (por ejemplo, plantear figuras penales menos gravosas, o circunstancias atenuantes).

d) La sentencia

Nociones generales

§ 358. Hemos visto que la producción de la sentencia constituye la última etapa del juicio, y que procedimentalmente tiene dos aspectos: la forma y plazo para su comunicación y la formación de la voluntad plural. La sentencia es el último acto del juicio de conocimiento, y agota la instancia de mérito (sin perjuicio de la eventual actividad impugnativa o ejecutiva).

Se habla de *sentencia material* para referirse a aquella que efectivamente se pronuncia sobre el fondo de la imputación objeto del proceso, condenando o absolviendo al acusado. Por el contrario, se considera sentencia sólo en sentido *formal* la que recepta un impedimento para pronunciarse sobre el fondo, como por ejemplo una causal extintiva de la acción penal (en este caso, alguna doctrina habla de “sentencia de sobreseimiento”).

Estructura

§ 359. En cuanto a su estructura, la sentencia contiene los siguientes elementos:

- **Formales:** Refieren a la forma escrita y a los datos de individualización del proceso. En algún caso se ha admitido la forma oral (con registro audiovisual), mediando acuerdo de simplificación.
- **Descriptivos:** Es la parte que relata el contenido de las actuaciones, describiendo sintéticamente los hechos del caso, las diligencias realizadas y los planteos de las partes.
- **Valorativos:** Hacen a la fundamentación de la sentencia, tanto en sus aspectos fácticos (valoración de la prueba) como jurídicos (análisis de las disposiciones legales aplicables). La manifestación formal más corriente de estos elementos son los llamados “considerandos”.
- **Dispositivos:** Es la parte final del resolutorio, en la que se enuncia el pronunciamiento absolutorio o condenatorio en relación a cada imputado, la cita de las disposiciones legales aplicables y en su caso la individualización de la pena o medida de seguridad a aplicar. También puede contener el pronunciamiento sobre costas, el cómputo de la pena y el destino de los efectos secuestrados.

El deber de fundamentación

§ 360. Nos detendremos ahora en el análisis de uno de los requisitos de la sentencia, que es su *fundamentación* o *motivación*. Existen variadas posturas sobre la relación entre estos dos términos:

- **La parte y el todo.** La fundamentación refiere a la sentencia en su conjunto, mientras que la motivación alude a la parte de la sentencia en la que se expresa el sentido del decisorio. La motivación sería una parte de la fundamentación.
- **Hechos y derecho.** La motivación refiere a los aspectos fácticos, y la fundamentación a los aspectos jurídicos. Esta distinción tiene algún predicamento en la doctrina española y latinoamericana. Entre nosotros es sostenida por Baclini y Schiappa Pietra, quienes sin embargo se inclinan por utilizar ambos términos en forma indistinta.
- **Por qué y en base a qué.** En sentido similar, se ha dicho que motivar es dar las razones para fallar en determinado sentido, y fundamentar es expresar en qué normas se basa el decisorio. Entre nosotros, Erbetta, Orso, Franceschetti y Chiara Díaz parecen adherir a esta postura. Con algún grado de coincidencia, Roxin atribuye a la ordenanza alemana la exigencia de fundamentación (indicación del derecho y de los hechos comprobados) pero no de motivación (los motivos decisivos para la convicción del tribunal).
- **Aspectos interno y externo.** La motivación alude a las razones que determinan el sentido del decisorio, mientras que la fundamentación es la exteriorización de esos motivos. Siguiendo este criterio y respecto del juicio por jurados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que *todo veredicto siempre tiene motivación, aunque como corresponde a la esencia del jurado, no se expresa* (caso “V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua”, Corte IDH, 2018).
- **Fundamentación como correlato.** También en relación al juicio por jurados, la Corte nacional ha dicho que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamientos, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia (fallo “Canales”, CSJN, 2019). Esta postura parece contradecir la anterior (lo que es curioso, ya que en “Canales” se alude al precedente interamericano), en cuanto rechaza la idea de fundamentación como expresión de motivos y se inclina por basar el concepto en la coherencia o correlación entre lo postulado, lo probado y lo resuelto.

- *Términos equivalentes o equiparables.* La gran mayoría de la doctrina (Maier, Vázquez Rossi, Binder, entre muchos otros) considera que los términos “fundamentación” y “motivación” son equivalentes o prácticamente sinónimos. En el caso de Santa Fe, el propio código los equipara (ver CPP, 140, que en su título habla de “fundamentación” y en su contenido de “motivación”). Es también nuestra opinión, ya que aun reconociendo que algunos de estos criterios distintivos son científicamente útiles y válidos, en general consideramos más práctico utilizar ambos términos de manera indistinta. Salvo que estemos en una temática específica en la que estas distinciones de detalle cobran mayor relevancia, como ocurre con el *juicio por jurados* (donde se falla por íntima convicción) o con la *sentencia abreviada* del derecho alemán (que permite prescindir de fundamentación si las partes renuncian anticipadamente al recurso).

§ 361. Desde una perspectiva constitucional, el deber de fundamentación se sustenta en dos argumentos centrales:

- *Que permite la impugnación del decisorio.* En general, se afirma que la fundamentación de la sentencia coloca a las partes en condiciones de evaluar la posibilidad de interponer recursos. Y ya en la vía recursiva, la fundamentación legal y racional del fallo es lo que permite su revisión integral por el tribunal de alzada (lo cual es concordante con la doctrina del fallo “Casal”, CSJN, 2005). Por el contrario, un fallo dictado simplemente por íntima convicción sería por naturaleza irrevisable, y por ende violatorio del derecho al recurso (CADH, 8.2.h).
- *Que permite el control republicano externo.* Explica Maier que la fundamentación del fallo se deriva de la forma republicana de gobierno (CN, 1), y que posibilita hacer efectiva la responsabilidad externa -civil, penal, administrativa- de los jueces. En un sentido más amplio, agrega Roxin que la fundamentación de la sentencia debe mostrar a los participantes que se ha administrado justicia.

Pero debe aclararse que ambos argumentos operan sólo en relación a los jueces técnicos, y no cuando el juicio es por jurados populares. En relación al primer argumento, el margen de revisabilidad del decisorio depende en gran medida de las posibilidades concretas del caso (tal como se lo reconoce el citado precedente “Casal”), las que varían notablemente según se trate de tribunales técnicos o de jurados populares. En cuanto al segundo argumento, la Corte nacional ha dicho que el deber de fundamentación se relaciona con el carácter no electivo de los jueces, quienes como funcionarios deben rendir

cuentas de sus decisiones. Razonamiento que obviamente no se aplica a los jurados (fallo “Canales”, CSJN, 2019).

No obstante, en nuestro contexto la fundamentación de la sentencia ha despertado un interés superlativo. Esto resulta llamativo, ya que si algo impone la Constitución Nacional es precisamente el juzgamiento por jurados (CN, 24, 75.12 y 118), y en todo caso el deber de fundamentación resulta una exigencia subsidiaria frente al incumplimiento de aquella manda. No se ha puesto tanto esmero en cumplir con la Constitución, como en mejorar su incumplimiento.

En nuestro medio no se acepta la posibilidad de limitar esta exigencia aunque las partes desistan anticipadamente del recurso (como ocurre con la ya mencionada *sentencia abreviada* del derecho alemán). En general predomina la idea de que el deber de fundamentación es de orden público, por lo que rige con prescindencia del interés de las partes.

e) Correlación entre acusación y sentencia

Nociones generales

§ 362. Elementales razones de salvaguarda del derecho de defensa imponen la necesaria *correlación entre acusación y sentencia* (CPP, 335), ya que es evidente que nadie puede defenderse de aquello por lo cual no lo acusan. Esta exigencia de correlación tiene dos aspectos bien diferenciados: el *principio de congruencia* y la *imposibilidad de aplicar sanciones más severas que las solicitadas*.

El principio de congruencia

§ 363. El *principio de congruencia*, en una primera aproximación, implica que la sentencia no puede apartarse del hecho contenido en la acusación o en sus ampliaciones. Sin embargo, el principio es más exigente, y refiere a la inalterabilidad del hecho intimado a lo largo de diversas instancias del proceso: en la audiencia imputativa (CPP, 275.1), en el requerimiento acusatorio (CPP, 295.2), en la resolución de apertura del juicio (CPP, 304.2), en el alegato de apertura de los acusadores (CPP, 317, segundo párrafo), en el alegato final de los acusadores (CPP, 329), y finalmente en la sentencia (CPP, 333.1, 335).

En caso de surgir nuevos elementos que alteren los hechos intimados, habrá que determinar en qué medida es posible incorporar dichos elementos a la actual plataforma fáctica:

- **Hechos complementarios.** Si se trata de hechos nuevos que modifican la calificación legal o la pena *del mismo hecho objeto del debate*, o que integran la continuación delictiva (hechos complementarios), es posible *ampliar la acusación* durante el debate (CPP, 321). Para este caso, el código en su redacción original preveía la posibilidad de suspender el debate a pedido de la defensa, y establecía que debía recibirse nueva declaración al imputado, todo lo cual resultaba indudablemente más garantizador (CPP, artículo derogado 322).
- **Hechos autónomos.** En cambio, si se modificaran los hechos intimados o se pretendiera atribuir un hecho nuevo que no necesariamente integre o complemente la imputación originaria (hechos autónomos), debe recurrirse a la *ampliación de la audiencia imputativa* (CPP, 281). Se entiende que esta posibilidad cabe únicamente durante la etapa investigativa, ya que una vez iniciado el debate la retroacción en perjuicio del imputado implicaría una modalidad prohibida de persecución múltiple.

Congruencia y calificación jurídica

§ 364. Se discute si el principio de congruencia abarca también la calificación jurídico-penal. Es decir, si el tribunal al momento de dictar sentencia puede encuadrar los hechos del proceso en una calificación distinta a la postulada por los acusadores. Va de suyo que el problema se plantea cuando la calificación jurídica es más gravosa, ya que como regla el principio de congruencia no impide adoptar un encuadre legal más benigno.

Es claro que la cuestión no puede resolverse aplicando sin más la regla de inalterabilidad respecto de los hechos, porque aquí entra a jugar el deber de los jueces de aplicar el orden jurídico (cuyo conocimiento se presume en los magistrados). Sin embargo, hay dos aspectos en los que el cambio de calificación jurídica puede afectar de modo concreto las garantías del imputado:

- ***En cuanto pueda dar lugar a valorar circunstancias no tenidas en cuenta inicialmente por no interesar al tipo penal contenido en la acusación.*** Por ejemplo, si se acusa por lesiones graves (CP, 90), y durante el juicio se acredita que la lesión ocasionó a la víctima un estado depresivo probablemente incurable, por lo que el tribunal encuadra la conducta como lesiones gravísimas (CP, 91). En este ejemplo, está claro que la defensa no

tuvo oportunidad de advertir la invocación de un agravante, y en consecuencia se vio privada de ofrecer argumentos y prueba de descargo (por ejemplo, alegar que la depresión muy raramente se considera incurable). La jurisprudencia ha sostenido que el cambio de calificación jurídica no lesiona el debido proceso, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado (fallo “Sircovich”, CSJN, 2006). La situación funciona aun cuando se postule un encuadre jurídico más benigno, si dicho encuadre contiene un elemento que no pudo ser debatido durante el juicio (Erbetta, Orso, Franceschetti y Chiara Díaz dan el ejemplo de la condena por estupro, cuando se acusó por violación y no se debatió sobre la inmadurez sexual de la víctima). Para evitar esta situación, la fiscalía puede indicar de antemano las circunstancias que podrían dar lugar a una calificación distinta, sirviendo tal indicación como acusación alternativa (CPP, 295, último párrafo).

- ***En cuanto pueda determinar la imposición de sanciones mayores a las solicitadas.*** Esto puede darse cuando el encuadre del tribunal da lugar a un mínimo que supera la pena solicitada por el fiscal (por ejemplo, si la fiscalía encuadra el hecho como robo [CP, 164] y solicita una pena de cuatro años de prisión, y el tribunal encuadra el hecho como robo con armas [CP, 166.2], que prevé un mínimo de cinco años). En este caso, parece claro que el tribunal tiene libertad para variar la calificación jurídica, pero respetando como tope la pena solicitada por el acusador. Es decir, debe limitarse a condenar en el marco de lo planteado por la acusación, pero puede dejar a salvo su disenso sobre la calificación jurídica aplicable (esta posibilidad cabe no sólo por razones éticas, sino también por la eventual responsabilidad que pudiera derivar de la aplicación incorrecta del derecho).

Nótese que en ambos casos el problema surge cuando el cambio de calificación jurídica trae un *efecto arrastre*, ocasionando una modificación de la plataforma fáctica (primer supuesto) o dando lugar a sanciones mayores a las solicitadas (segundo supuesto). Por lo que en ninguno de los dos casos estamos ante un verdadero “principio de congruencia jurídica”, sino ante los efectos proyectados por otros dos principios: el de *congruencia fáctica* y la *proscripción de la actuación de oficio*.

Hay legislaciones que pretenden soslayar el efecto arrastre, permitiendo que el tribunal advierta al imputado que podría ser aplicable otra figura penal. Esta advertencia tendría el efecto de posibilitar el ejercicio de la defensa también en relación al encuadre jurídico propuesto por el tribunal. Sin embargo, esta solución no luce aceptable, por dos razones: primero, porque erosiona la sepa-

ración entre las funciones requirente y decisoria, y segundo, porque permite un adelantamiento de opinión en detrimento de la imparcialidad del tribunal.

Imposibilidad de aplicar sanciones más severas que las solicitadas

§ 365. La segunda manifestación de la correlación entre acusación y sentencia es la *imposibilidad de aplicar sanciones más severas que las solicitadas por los acusadores*. La exigencia también se relaciona con el derecho de defensa, ya que en definitiva uno se defiende de la solicitud de pena sostenida durante el debate, no resultando posible anticipar ni responder un eventual agravamiento de oficio.

§ 366. La cuestión resulta problemática, en cuanto exige determinar en qué punto de la actividad persecutoria se considera fijada la solicitud de pena. Esto porque el término “acusación” posee al menos dos acepciones bien diferenciadas:

- *Sentido estricto*: Acusación como *acto*, que en nuestro sistema se materializa en la requisitoria de acusación (CPP, 294). Desde este punto de vista, la acusación es un acto único, que una vez cumplido abre paso a la actividad de la defensa.
- *Sentido amplio*: Acusación como *actividad*, que debe sostenerse activamente y en sentido incriminatorio a lo largo de todo el proceso, dando lugar correlativamente a progresivas instancias de defensa.

No se trata de que uno de estos significados sea correcto y el otro no. Lo que ocurre es que el término se utiliza en ambos sentidos, según el lugar en que nos encontremos en la sistemática del código. Evidentemente la acusación es un acto, porque así se denomina la instancia del CPP, 294. Pero es también una actividad, porque la proscripción de la actuación judicial de oficio implica que cada resolución contraria al imputado deba ser sostenida específicamente por los acusadores: así ocurre con la imposición de medidas coercitivas (CPP, 205, 220, 223), con la elevación de la causa a juicio (CPP, 295), y finalmente con la imposición de penas y medidas de seguridad (CPP, 335). La regla opera también en materia impugnativa, ya que la modificación de una resolución en perjuicio del imputado requiere ineludiblemente de un acto recursivo en tal sentido por parte del acusador (CPP, 391, tercer párrafo).

§ 367. La relevancia de distinguir entre *acusación-acto* y *acusación-actividad* se manifiesta ante una situación típicamente problemática: cuando la fiscalía, al momento de los alegatos finales, pide la absolución. En este caso, ¿puede el

tribunal condenar igualmente? Y aun si pide la condena, ¿puede el tribunal imponer una pena mayor a la solicitada?

Llegar al estado actual de la cuestión no fue simple. La Corte nacional fue variando su postura, en algunos casos como consecuencia de sus propios cambios de integración.

- En el caso “Tarifeño” (CSJN, 1989), la Corte anuló una condena dictada habiendo requerimiento absolutorio del fiscal, por entender que no había mediado acusación. Aquí claramente se hace referencia a la acusación en sentido amplio, entendiendo que la pretensión acusatoria debe ser sostenida para ser válida (*acusación-actividad*).
- La doctrina “Tarifeño” sería sostenida en casos posteriores, con diferentes fundamentos y mayorías variables en cada secuela. Cabe mencionar que en “Santillán” (CSJN, 1998), la Corte aclara que el requisito de acusación, como exigencia del debido proceso, no contiene distingo en cuanto al carácter público o privado del que la formula. Por lo que, aun no habiendo requerimiento acusatorio por parte de la fiscalía, igualmente puede dictarse condena con base en la acusación del querellante particular.
- En “Marcilese” (CSJN, 2002), la Corte varía su postura y entiende que la requisitoria de elevación a juicio es la acusación indispensable para garantizar el debido proceso, no así los alegatos finales. En otras palabras, se pasa a la idea de *acusación-acto*.
- Más tarde la Corte volverá, con diferencias de detalle, a la idea de *acusación-actividad*. Primero en el fallo “Mostacchio” (CSJN, 2004), por remisión a una de las secuelas de “Tarifeño” (el fallo “Cáseres”, de 1997). Luego en “Amodio” (CSJN, 2007), a través de un voto disidente fundado no sólo en el derecho de defensa, sino también en los principios derivados del modelo acusatorio formal.

f) Una cuestión pendiente: la cesura del juicio

Nociones generales

§ 368. La *cesura del juicio* es un instituto típico de la tradición anglosajona, y vinculado originariamente al juicio por jurados. Consiste básicamente en la división del juicio de conocimiento en dos etapas:

- La *primera etapa*, en la que se debate la autoría o participación de la persona acusada en un hecho punible. Esta primera etapa finaliza o se corta (de ahí lo de *cesura*) con el pronunciamiento absolutorio o condenatorio.
- La *segunda etapa*, que se abre en caso de haber un pronunciamiento de condena, en la que se individualiza la sanción a aplicar.

Funciones

§ 369. En su contexto de origen, la cesura del juicio marca también los límites de la actuación del jurado, ya que en la etapa de individualización de la pena interviene únicamente el juez técnico. Lo cual ya ha dado lugar a alguna crítica en la doctrina y la jurisprudencia estadounidense.

Sin embargo, el instituto de la cesura también resulta aplicable en sistemas de enjuiciamiento con tribunales técnicos (como por ahora ocurre en nuestro caso). La evidente ventaja del sistema es que permite a la defensa concentrarse en su teoría del caso primaria, dejando para una etapa posterior las cuestiones únicamente relacionadas con el monto de la pena (en algunos sistemas, la discusión sobre la calificación jurídica queda también para la segunda etapa).

No habiendo cesura, la defensa queda en la incómoda situación de tener que esgrimir subsidiariamente argumentos de atenuación, en forma conjunta con su tesis principal. Por ejemplo, deberá decir: *“Mi defendido no cometió el homicidio. Pero si lo cometió fue en forma culposa, no dolosa. Y en el último de los casos, sus características personales lo hacen merecedor, en una escala de ocho a veinticinco años, de una pena más bien cercana a los ocho años”*. Un argumento tal carece por completo de poder de convicción, a punto tal que no convence ni a quien lo dice.

Situación en Argentina y a nivel local

§ 370. En nuestro país, la cesura del juicio aparece regulada en el nuevo código federal (CPP Federal, 304), y en los códigos de Chubut y Neuquén (que, con diferencias menores, permiten ofrecer prueba específica para la segunda etapa).

En doctrina se insiste en avanzar con una regulación similar en Santa Fe. Mientras tanto, no cabría descartar que en casos puntuales pueda caber una *cesura de creación judicial*, tendiente a salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso.

Síntesis del capítulo

1. *La etapa de juicio tiene una regulación que tiende a salvaguardar las posibilidades de actuación de las partes, y en particular de la defensa. Por la misma razón, la actuación de las partes debe sujetarse estrictamente al rol que a cada uno le incumbe, sin invadir las atribuciones de los demás intervinientes.*
2. *El núcleo del juicio está dado por el debate, que es la etapa en la que las partes postulan y acreditan su caso, de manera pública y contradictoria.*
3. *El juicio oral concluye ordinariamente con el dictado de la sentencia. Entre otros requisitos, la sentencia debe guardar correlación con la acusación. Se debate el alcance de esta correlación en relación a los hechos, a la calificación jurídica y a la sanción, siendo posible derivar cada postura de determinado modelo de proceso.*
4. *Una propuesta que se abre paso en la doctrina y en otras legislaciones es la cesura del juicio, que implica la división del debate en dos etapas: una en la que se discute la autoría o participación en el hecho punible, y otra en la que se analiza específicamente la sanción aplicable.*

Capítulo 12. Recursos

a) Lo conceptual y lo terminológico

Nociones generales

§ 371. Hemos visto el sentido garantizador que han adquirido los recursos, a pesar de ser en su origen (sistema inquisitivo) un mecanismo de control jerárquico al interior de la estructura judicial. Toca ahora analizar los recursos desde otra perspectiva, enfocando sus aspectos conceptuales y técnicos en función de su regulación actual.

En sentido amplísimo, los recursos son mecanismos por los cuales determinados sujetos procesales pueden atacar resoluciones que le producen agravio, buscando que las mismas sean reformadas o sustituidas.

Criterios restrictivos y mecanismos de naturaleza dudosa

§ 372. Otras definiciones contienen requisitos más específicos:

- La mayoría de la doctrina exige que se trate de resoluciones propiamente judiciales, es decir, dictadas por el órgano jurisdiccional.
- Suele exigirse también que el mecanismo active la intervención de un órgano jurisdiccional distinto -y eventualmente superior en jerarquía- al que dictó la resolución originaria (efecto devolutivo).
- Finalmente, también se añade que el recurso se dirige contra una resolución que no se encuentra firme, precisamente para evitar que cobre firmeza.

§ 373. Estos tres requisitos tienden, correlativamente, a dejar fuera del ámbito recursivo a los siguientes mecanismos:

- Las impugnaciones contra los actos y resoluciones de la fiscalía, en el marco del modelo acusatorio formal. Por ejemplo, la *oposición a la aplicación de un criterio de oportunidad* (CPP, 21) o la *disconformidad con la destimación o el archivo fiscal* (CPP, 291). En igual sentido, la *revisión de sanciones disciplinarias en la etapa ejecutiva* (CPP, 434) y en general la *revisión judicial de decisiones de la administración penitenciaria* (ley 24.660, 4.a). La impugnación de actos de sujetos no jurisdiccionales puede considerarse actividad recursiva en la medida en que se atacan *actos resolutivos* o *con contenido jurídico*, y no meros actos materiales que en todo caso son atacables por otros medios (por ejemplo, hábeas corpus).
- La llamada *reposición, revocatoria o reconsideración* (CPP, 392), medio impugnativo tendiente a que el mismo tribunal que dictó la resolución atacada la revoque por contrario imperio. De igual modo, el pedido de *aclaratoria* (CPP, 337).
- La *revisión de condena firme* (CPP, 409), que para buena parte de la doctrina no es propiamente un recurso sino una demanda impugnativa autónoma.

En definitiva, la cuestión parece derivar en un problema terminológico, a punto tal que muchos de los institutos no considerados “recursos” sí reciben el nombre de “medios de impugnación”. Lo cual es irrisorio, ya que *recurrir* e *impugnar* son prácticamente la misma cosa. Por eso nos inclinamos por un *concepto amplio de recursos*, comprensivo de todo lo que nuestro derecho positivo trata como tal, e independientemente de su concordancia o no con un modelo teórico. Desde ya postulamos que *recursos, medios de impugnación, medios de revisión* y *remedios procesales* son expresiones sinónimas, cuyo uso nos resulta indistinto.

b) Clasificación

Recursos en sentido estricto y en sentido amplio

§ 374. Partiendo del ya explicado concepto amplio de recursos, la primera y más lógica distinción debe hacerse entre *aquellos que se dirigen contra resoluciones jurisdiccionales* (recursos en sentido estricto) y *los que impugnan la actividad de otros sujetos* (recursos en sentido amplio, o medios impugnativos especiales o atípicos).

En la misma tónica preliminar, cabe señalar como *medios recursivos especiales o atípicos* a la aclaratoria y a la queja por recurso denegado. La *aclaratoria* (CPP, 337), porque si bien puede considerarse en sentido amplio un recurso, *no necesariamente expresa un agravio contra la resolución*, sino que sólo persigue aclarar algún punto dudoso o suplir una omisión material. En cuanto a la *queja* (CPP, 390), técnicamente es un medio para abrir la instancia recursiva originalmente planteada: es algo así como *un recurso contra el decreto que declara inadmisibile un recurso*.

Recursos ordinarios, extraordinarios y excepcionales

§ 375. Dentro de los recursos contra resoluciones jurisdiccionales, la clasificación más clásica es la que distingue los recursos *ordinarios* de los *extraordinarios*, y dentro de estos últimos los *excepcionales* y los *no excepcionales*.

- ***Recursos ordinarios***. Los que permiten un nuevo examen de lo decidido sin limitaciones en cuanto a los motivos ni exigencias que no sean comunes. Son recursos ordinarios la *reposición* y la *apelación*.
- ***Recursos extraordinarios***. Los que plantean mayores recaudos o que limitan los posibles motivos de agravio. Es extraordinario el *recurso de inconstitucionalidad local*, y lo son en otros sistemas la *casación* (CPP Entre Ríos, 511; aunque los motivos de agravio son más bien amplios) y en general el *recurso contra la sentencia dictada en juicio oral* (CPP Federal, 358, 359). A su vez, los recursos extraordinarios que pueden considerarse ***excepcionales*** son la *revisión* y la *inconstitucionalidad nacional*, a lo que podrían agregarse el derogado recurso de *inaplicabilidad de la doctrina legal* (CPP 1971 [derogado], 479) y el *pedido de tribunal pleno* (LOPJ, 28; hoy en día implícitamente derogado en materia penal por ley 13.018).

c) Conceptos básicos de la mecánica recursiva

§ 376. Las disposiciones generales en materia de recursos tienden a determinar si una resolución es recurrible, mediante qué recursos, quiénes pueden recurrir, cómo debe recurrirse, cómo tramita el recurso interpuesto y qué resultados produce. Estas preguntas dan lugar, respectivamente, a los conceptos básicos de la mecánica recursiva: *recurribilidad objetiva y subjetiva, condiciones de interposición, sustanciación y efectos*.

Recurribilidad objetiva y subjetiva

§ 377. La ***recurribilidad objetiva*** está sujeta a la regla de *taxatividad*: las resoluciones son recurribles sólo en los casos y por los medios expresamente establecidos (CPP, 380). Así, se establece una cláusula de cerramiento respecto de los dos primeros interrogantes de la mecánica recursiva: qué resoluciones son recurribles, y mediante qué recursos en particular lo son.

Sin embargo, veremos que en algunos casos particulares esta regla ha sido flexibilizada, dando lugar a verdaderos abusos recursivos que dilatan innecesariamente los procesos. Dicho sea esto con excepción del recurso contra la sentencia, que como se ha explicado tiene actualmente un carácter garantizador.

§ 378. La ***recurribilidad subjetiva*** se establece también de manera taxativa. Como regla, la facultad de recurrir corresponde sólo a quien le fuera expresamente acordada, siempre que tuviera un interés directo en la eliminación, revocación o reforma de la resolución (CPP, 380, segundo párrafo).

De todos modos, esta taxatividad es limitada al establecerse como regla que todos pueden recurrir *cualquier resolución contraria a su interés* (CPP, 381-383). La fiscalía presenta dos particularidades: puede recurrir incluso a favor del imputado (posibilidad simpática pero discutible en un modelo acusatorio), y puede también recurrir en contra de su propia opinión previa, en cumplimiento de instrucciones de los órganos directivos (CPP, 381).

La exigencia de agravio o interés directo impone que la resolución produzca un perjuicio concreto a quien recurre. En general este perjuicio debe evaluarse cotejando lo resuelto con la pretensión que fuera esgrimida, aunque alguna doctrina plantea la posibilidad de agravarse en base a los fundamentos del resolutorio (por ejemplo, ante una absolución por aplicación del beneficio de la duda, la defensa podría agravarse solicitando que se absuelva por haberse probado que el acusado no cometió el hecho punible).

§ 379. La recurribilidad, tanto en sentido objetivo como subjetivo, puede ser *genérica o específica*.

- La ***recurribilidad genérica*** es la que se determina en las reglas ya analizadas, o en la regulación de cada recurso en particular.
- La ***recurribilidad específica*** surge de reglas orgánicamente separadas (en nuestro caso, reglas que están fuera del Libro V del CPP), que pueden hallarse diseminadas en distintos lugares del código. Mayormente, aunque no de manera necesaria, refieren a la impugnabilidad objetiva.

§ 380. Son *reglas de recurribilidad específica* el carácter irrecurrible de la resolución sobre incumplimiento de reglas de conducta (CPP, 24, último párrafo), la apelabilidad de la resolución sobre excepciones (CPP, 35), la apelabilidad de las resoluciones de planteos de inhibitoria (CPP, 62.2-4), la apelabilidad resolución sobre constitución de querellante (CPP, 96, último párrafo), la apelabilidad de la resolución sobre cesación del estado antijurídico (CPP, 207), la revocabilidad y apelabilidad de la resolución sobre inhabilitación provisoria para conducir (CPP, 208 bis), la apelabilidad de las resoluciones sobre medidas coercitivas (CPP, 226), la irrecurribilidad de la prórroga de la detención (CPP, 274), la irrecurribilidad de la resolución sobre actos definitivos (CPP, 284), la recurribilidad de la resolución del procedimiento intermedio (CPP, 303, último párrafo), la irrecurribilidad del auto de apertura a juicio (CPP, 305), la irrecurribilidad de la decisión de realizar el debate a puertas cerradas (CPP, 311), la regulación de la aclaratoria (CPP, 337; esto en la inteligencia de que es un mecanismo de naturaleza recursiva), la apelabilidad de la duplicación de términos (CPP, 346), la irrecurribilidad del archivo del procedimiento para la reparación del daño (CPP, 368), la apelabilidad de la desestimación y de la declaración de incompetencia en el hábeas corpus (CPP, 375), la apelabilidad de la resolución de hábeas corpus (CPP, 379) y la irrecurribilidad de las resoluciones en el trámite del procedimiento de flagrancia (CPP, 379 quinquie).

Para quienes pensamos que las resoluciones de la fiscalía son susceptibles de recurso, son también *reglas de recurribilidad específica* la oposición a la aplicación de un criterio de oportunidad (CPP, 21), la irrecurribilidad de la resolución del Fiscal Regional en caso de disenso entre la fiscalía y la querella (CPP, 288) y la recurribilidad de las resoluciones de archivo fiscal y desestimación (CPP, 291).

Condiciones de interposición

§ 381. Las *condiciones de interposición* son la *forma*, el *plazo* y el *lugar*, exigencias formales que, junto con la recurribilidad objetiva y subjetiva, determinan la admisibilidad de la instancia recursiva.

§ 382. La *forma* impuesta como regla es la *presentación por escrito*, aunque se admite la reposición verbal durante las audiencias (CPP, 385). Además de la forma escrita, se exige determinar con precisión los puntos de la decisión que fueran impugnados (CPP, 384). Aunque algunos recursos tienen un mayor grado de formalidad que otros, el nuevo sistema en general no tolera la interposición infundada (como ocurría en el viejo código con la apelación, que se fundaba luego al momento de expresar agravios). En general se requiere de

asistencia letrada, correspondiendo al tribunal garantizar la debida defensa técnica cuando el interesado manifiesta por sí mismo su voluntad recursiva (mediante el llamado recurso in pauperis; ver fallos “Gordillo”, CSJN, 1987, y “Núñez”, CSJN, 2004; a nivel local y en el mismo sentido: “Presidente”, CSJS-Fe, 2006).

§ 383. Asimismo, los recursos deben interponerse *dentro del plazo que la ley establece*, que varía en cada caso. Salvo la ya comentada reposición verbal, que debe manifestarse de inmediato.

§ 384. Finalmente, deben interponerse en el *lugar* o ante el *órgano* correspondiente, que como regla es el tribunal que dictó la resolución cuestionada (materialmente, la OGJ respectiva). En los recursos cuya resolución corresponde a una instancia superior, el tribunal recurrido suele tener a cargo el examen de admisibilidad previo a su elevación. Si la instancia es declarada inadmisibile, puede interponerse *queja por recurso denegado* directamente ante el superior (CPP, 390; también denominado *recurso directo* o *recurso de hecho*).

Sustanciación

§ 385. La *sustanciación* es el trámite que se imprime al recurso una vez interpuesto. Según el caso, esta actividad puede incluir la elevación al superior, la vista o traslado a la contraparte y la producción de prueba.

El trámite varía sensiblemente según la instancia de interposición sea oral o escrita, aunque la tendencia en este último supuesto es hacia la oralización del trámite posterior.

La instancia recursiva puede desistirse antes de ser resuelta. La defensa técnica no puede desistir sin mandato expreso de la persona defendida, posterior a la fecha de interposición (CPP, 388).

Efectos

§ 386. En cuanto a los *efectos* del recurso, debe distinguirse el momento de la *interposición* del momento de la *resolución sobre su procedencia*.

- La *interposición* de un recurso tiene *efecto suspensivo* sobre la ejecución de la decisión impugnada, salvo disposición en contrario o que se trate de materia cautelar o coercitiva (CPP, 387).

- La **resolución sobre la procedencia** del recurso puede traer como efecto la *confirmación*, la *anulación*, la *revocación* o la *modificación* del decisorio, en forma total o en relación a un aspecto determinado.

Cuando se trata de un recurso resuelto por una instancia superior, tanto la anulación como la revocación pueden dar lugar a una *resolución material* (la resolución de alzada dicta en forma directa la resolución de fondo), o bien a una *resolución de reenvío* (se declara la anulación o revocación y se devuelve el caso a la instancia originaria para que se dicte un nuevo pronunciamiento).

§ 387. En materia penal, existen tres cláusulas de salvaguarda o garantía, que modifican la producción de efectos en relación a las personas imputadas:

- **Extralimitación benigna.** El tribunal de alzada puede resolver puntos no abarcados por los agravios, exclusivamente para mejorar la situación del imputado (CPP, 391, segundo párrafo).
- **Prohibición de agravamiento.** Las resoluciones recurridas solamente en favor del imputado no pueden ser modificadas en su perjuicio (CPP, 391, tercer párrafo).
- **Efecto extensivo.** El recurso interpuesto en favor de un coimputado favorece a los demás, salvo que se base en motivos exclusivamente personales (CPP, 386).

d) Recursos en particular

Reposición

§ 388. El recurso de *reposición* (también llamado *revocatoria* o *reconsideración*) procede contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, a fin de que el mismo tribunal que las dictó las revoque o modifique por contrario imperio (CPP, 392).

Como regla debe interponerse por escrito y de manera fundada, en el plazo de tres días. Luego de una vista a la contraparte por el plazo que el tribunal determine, debe resolverse en tres días.

Cuando la resolución impugnada fuera dictada en audiencia, la reposición debe interponerse y fundarse verbalmente, resolviéndose en el acto previa vista al contradictor. En este caso, la instancia impugnativa opera como *protes-*

ta, impidiendo que el acto se tenga por consentido a los efectos de un posible recurso contra la resolución de fondo (ver CPP, 395).

Apelación

§ 389. El recurso de *apelación*, en su origen, se corresponde con la mecánica del juicio escrito. La forma escrita coloca al tribunal recurrido y al de alzada en una situación de paridad respecto del conocimiento de la causa: básicamente, cualquier tribunal en posesión del expediente puede acceder al mismo grado de conocimiento, ya sea que se encuentre en primera, segunda o vigésima instancia. La misma lógica hace que en el sistema mixto sólo sean apelables las resoluciones dictadas durante la instrucción escrita, mientras que la sentencia dictada en juicio oral es atacable como regla sólo por casación.

Pues bien, en Santa Fe se ha optado por conservar el recurso de apelación, pero adaptándolo al funcionamiento de un sistema por audiencias. Sigue siendo un *recurso ordinario*, ya que no impone limitación alguna en cuanto a los motivos que habilitan el reexamen de la decisión en la alzada. Esta amplitud obedece a múltiples factores (jurídicos, políticos, pragmáticos), pero en lo que aquí interesa viene a satisfacer el estándar de *máximo esfuerzo revisor* delineado en “Casal” (CSJN, 2005).

§ 390. El recurso de apelación procede en los casos especialmente previstos por la ley (recurribilidad específica), y de manera genérica contra las resoluciones que causen un gravamen irreparable, contra la sentencia definitiva y contra los autos que resolvieran sobre la acción, la pena o una medida de seguridad, o que rechazaran el procedimiento abreviado o la suspensión del procedimiento a prueba. Además, en relación al imputado también abarca los supuestos de revisión de sentencia firme (CPP, 394).

§ 391. A pesar de su amplitud, las condiciones de interposición de la apelación aparecen mucho más ordenadas que en el antiguo código. Así, se impone la forma escrita y con firma letrada, ante el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada. Asimismo, el acto de interposición deberá fundar separadamente cada motivo de apelación, indicando concretamente los errores de juicio o de procedimiento en que se hubiera incurrido y cuál es la solución pretendida (CPP, 398). El plazo de interposición es de diez días para la sentencia, tres días para resoluciones cautelares y cinco días para los demás casos.

Luego de un plazo común de examen, el recurso se sustancia en audiencia oral y pública. En esta instancia, las partes podrán ampliar su fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no introducir nuevos agravios (CPP, 401).

§ 392. La decisión colegiada se rige por las reglas comunes (CPP, 138), pudiendo dictarse *sentencia de reenvío* o *sentencia material*.

§ 393. *Sentencia de reenvío* (CPP, 404, primer párrafo). La sentencia de reenvío es la que revoca o anula total o parcialmente el decisorio, y devuelve el caso a primera instancia para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Según el caso, deberá renovarse la actividad procesal indispensable para poder resolver. Esto es particularmente problemático cuando se revoca o anula una sentencia dictada en juicio oral por vicios de procedimiento, ya que ello acarreará la necesidad de hacer un nuevo juicio.

En la sentencia de reenvío, el tribunal deberá *indicar el objeto concreto del nuevo juicio, procedimiento o resolución* (CPP, 404).

Para el caso de sentencia de reenvío, el Código prevé tres *cláusulas de salvaguarda* que operan en favor del imputado:

- *Limitación a la integración del tribunal* (CPP, 405, primer párrafo). No podrán intervenir en el nuevo juicio los jueces que hubieran conocido en el anterior. La cláusula tiende a salvaguardar la imparcialidad del tribunal que intervendrá en el nuevo juicio, de conformidad con las pautas del precedente “Llerena” (CSJN, 2005).
- *Prohibición de agravamiento* (CPP, 405, primer párrafo). Si el reenvío procede como consecuencia de un recurso interpuesto únicamente en favor del imputado, en el nuevo juicio no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primero. Se trata de un desprendimiento de la prohibición de agravamiento genérica que rige en materia recursiva (CPP, 391, tercer párrafo). La norma concede *validez residual* (al solo efecto de operar como tope) a la sentencia revocada o anulada.
- *Irrecorribilidad de la nueva absolución* (CPP, 405, primer párrafo). Si en el segundo juicio se obtiene una segunda absolución, la misma es inimpugnable. La cláusula tiende a evitar la posibilidad de *recursos al infinito* por parte de los acusadores, ante continuas absoluciones. Implica en alguna medida la flexibilización del carácter bilateral de nuestro sistema recursivo: pueden recurrir tanto los acusadores como la defensa, pero el recurso de los acusadores es susceptible de mayores limitaciones.

§ 394. *Casos de sentencia material* (CPP, 404, segundo párrafo). El tribunal resolverá directamente sin reenvío en los siguientes casos:

- cuando se dicte la absolución del procesado.
- cuando se declare la extinción de la acción o la pena.
- cuando se disponga el cese de una medida de seguridad.

- cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia o resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio o procedimiento.

En estos supuestos corresponde resolver materialmente el caso, ya sea confirmando, revocando o modificando el decisorio, en forma total o parcial.

La norma deja a salvo el derecho del imputado a recurrir la sentencia, lo que usualmente habrá que considerar cuando la sentencia material en alzada resulte más gravosa que la sentencia apelada (por ejemplo, cuando se revoca una absolución y se dicta una condena). La salvaguarda del recurso en este caso ha sido resuelta en la práctica mediante la *apelación horizontal*, que es resuelta por otros jueces distintos, también de segunda instancia.

Casación, casación ampliada y recurso innominado

§ 395. En los procesos penales delineados según el sistema mixto, la sentencia dictada en juicio oral resultaba impugnabile mediante *recurso de casación*. La particularidad de este recurso era que originariamente estaba limitado al análisis de errores de juicio en la interpretación del derecho, funcionando más bien como un medio de unificación de la jurisprudencia.

Tras varios jalones en su evolución posterior, y luego del fallo “Casal” (CSJN, 2005), los sistemas con casación hicieron algo parecido a lo que en Santa Fe ocurrió con la apelación: la convirtieron en otra cosa, dejándole apenas el nombre. Así ocurre en Entre Ríos con su recurso de casación, que en rigor procede tanto por cuestiones de derecho como de hecho y prueba (CPP Entre Ríos, 511). En otros contextos, la ampliación o flexibilización del recurso de casación se produjo por obra de la jurisprudencia y no del legislador.

§ 396. En el nuevo ordenamiento federal, directamente se ha prescindido de la cuestión del nombre. Simplemente se regula el *control de las decisiones judiciales* (CPP Federal, 344), a través de un recurso cuyos supuestos de procedencia varían según qué resolución se pretende impugnar y quién pretende hacerlo (impugnabilidad objetiva y subjetiva).

Inconstitucionalidad

§ 397. Tanto a nivel local como nacional, existen recursos específicos tendientes a salvaguardar la supremacía constitucional. En general, estos *recursos de inconstitucionalidad* están reservados a los máximos órganos jurisdiccionales

de cada sistema (CSFe, 93.1; ley 7055). Son extraordinarios y excepcionales, porque proceden sólo ante una particular especie de error de juicio:

- Cuando se hubiere cuestionado la congruencia con la Constitución de la Provincia de una norma de jerarquía inferior y la decisión haya sido favorable a la validez de ésta.
- Cuando se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución de la Provincia y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él.
- Cuando las sentencias o autos interlocutorios mencionados no reunieren las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

En cualquier caso, debe tratarse de sentencia definitiva o acto de efecto equivalente. Asimismo, el agravio constitucional debe haber sido introducido y mantenido en todas las instancias del proceso (ley 7055, 1).

El recurso debe interponerse dentro de los diez días, ante el tribunal que dictó la resolución definitiva. En el acto de interposición, debe tratarse separadamente la *admisibilidad formal* del recurso de las cuestiones inherentes a la *procedencia en cuanto al fondo* (ley 7055, 3).

Luego de un traslado a la contraparte por diez días (ley 7055, 4), el tribunal recurrido se pronunciará sobre la admisibilidad (ley 7055, 6). Si admite el recurso, elevará el expediente a la Corte Suprema, que resolverá previo dictamen del Procurador General.

Recurso Extraordinario Federal

§ 398. A su turno, la ley nacional 48 regula el *recurso extraordinario federal*. El recurso procede contra las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia, y su resolución corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sus limitados supuestos de procedencia son los siguientes:

- Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez.
- Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.

- Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.

Tratándose de un recurso tendiente a proteger la supremacía constitucional, se prevén estrictas condiciones de admisibilidad. De hecho, la Corte Suprema puede rechazar discrecionalmente el recurso por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia (CPCyC Nación, 280).

Revisión

§ 399. El *recurso de revisión* (CPP, 409) procede en todo tiempo y en favor del condenado, y en algunos casos también puede ser instado en favor de éste después de su muerte. Es un recurso extraordinario y excepcional, por varias razones:

- En cuanto al *objeto impugnable*, ya que se dirige contra una sentencia condenatoria firme.
- En cuanto es *unidireccional* (sólo opera en favor del condenado) y en principio no tiene plazo.
- En cuanto a sus limitadísimos *supuestos de procedencia*, que en general refieren a casos de *cosa juzgada írrita o fraudulenta*.
- En cuanto se interpone y tramita *ante el máximo tribunal provincial*: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Los excepcionales supuestos de procedencia refieren a la *incompatibilidad entre la condena impugnada y otra sentencia posterior irrevocable* (CPP, 409.1-2), o a la *existencia de vicio o delito en la obtención de la condena* (CPP, 409.3). También se admite la revisión por *nuevos hechos* o por *nuevas pruebas sobrevinientes* (CPP, 409.4).

Otros códigos admiten como motivo de revisión el dictado de una *ley posterior más benigna* (CPP Entre Ríos, 527.e; admitiéndose también la revisión por jurisprudencia posterior más benigna: 527.f). Entre nosotros, este supuesto tramita como *incidente de ejecución* (CPP, 428).

Síntesis del capítulo

1. *Existen variadas posturas respecto de qué se entiende por recursos, ante lo cual aquí se adopta un enfoque amplio, que incluye prácticamente todo mecanismo de naturaleza impugnativa.*
2. *Los conceptos básicos de la mecánica recursiva son pautas que establecen qué resoluciones son recurribles y por qué medio, quiénes están legitimados para hacerlo, cómo se tramita el recurso y qué efectos es susceptible de producir.*
3. *Dentro de los recursos en particular, en Santa Fe se ha mantenido nominalmente el recurso de apelación, aunque con notorias modificaciones basadas en la naturaleza oral del proceso. Otros sistemas tienen recursos asimilables, bajo el formato de la casación o bien de forma innominada.*

Capítulo 13. Procedimientos especiales

a) Algunas distinciones: procedimientos especiales e institutos compositivos

§ 400. A la par del procedimiento común o estándar, la legislación prevé procedimientos especiales en función de distintos motivos. En la mayoría de los casos se trata de reglas que alteran sólo parcialmente el régimen común. Por otra parte, en los procedimientos especiales con un mayor grado de autonomía, el régimen común igualmente se aplica como norma subsidiaria.

Los distintos procedimientos especiales responden a criterios como la distinta gravedad o complejidad del caso, el menor interés estatal, la situación de la persona imputada y la distinta naturaleza del objeto procesal.

§ 401. Debe señalarse que parte de la doctrina encuadra como procedimientos especiales a algunos de los institutos que aquí se tratan como *alternativas al juicio oral*. En particular, esto ocurre con el *procedimiento abreviado*, y ocurrió en algún momento con la *suspensión del procedimiento a prueba*. En nuestra opinión, este erróneo encuadramiento conceptual obedece a dos razones:

- La primera es que, efectivamente, algunos de estos institutos *parecen especiales*, en cuanto la legislación limita su procedencia a ciertos topes relacionados con el monto de la pena (ya sea en el mínimo o en el máximo de la escala, o en la cuantía de la pena acordada). Así ocurría con el procedimiento abreviado cuando fue introducido durante la vigencia del sistema anterior, y así ocurre en general con la suspensión de procedimiento a prueba.
- La segunda razón es que, desde la óptica de los modelos inquisitivos y mixtos, en los que aún no se hablaba del principio de oportunidad, estos nuevos institutos *resultaban inexplicables*. Sencillamente no encajaban en el modelo teórico de los autores clásicos del sistema mixto (Vélez Ma-

riconde, Clariá Olmedo, Levene [h]), y su relación con el fenómeno de las alternativas o mecanismos de descongestión se fue comprendiendo luego, ya en el marco de los actuales procesos de reforma. Sin embargo, existían, y como existían, había que ubicarlos en algún lugar del programa. Y se los ubicó, casi por descarte, con los procedimientos especiales.

b) Procedimientos especiales basados en la distinta gravedad y complejidad del caso

Nociones generales y antecedentes

§ 402. La menor gravedad de la infracción siempre fue un criterio definitorio en orden a la regulación de procesos especiales. Centralmente, la idea es que el proceso penal “estándar” puede flexibilizarse, abreviarse o acotarse, permitiendo el juzgamiento simplificado de las ofensas de menor trascendencia.

Esta idea conoció múltiples formatos. Los antiguos sistemas escritos preveían el *procedimiento correccional*, para el juzgamiento simplificado de los delitos considerados menores. El juicio correccional, además de contener abreviaciones menores en cuanto a formas y plazos, permitía prescindir de la prueba de cargo si había confesión lisa y circunstanciada por parte del imputado.

Procedimiento contravencional

§ 403. Actualmente, el criterio de menor gravedad de la infracción se refleja en el juzgamiento de las contravenciones provinciales. Sin embargo, cabe aclarar que el régimen previsto en el Código de Convivencia (ley 13.774) no se ha apartado significativamente del régimen general para el juzgamiento de los casos más graves, más allá de algún grado mayor de concesión al principio de oportunidad.

En otras legislaciones, el juzgamiento de ofensas menores ha dado lugar a salidas más creativas y ciertamente más expeditivas, como *procedimientos monitorios*, *por mandato* o *por aceptación de decreto*: básicamente, el procedimiento inicia con la sentencia, y el infractor tiene la posibilidad de un recurso posterior (algo así como lo que ocurre aquí con la aceptación de un ticket por mal estacionamiento).

Procedimiento por flagrancia

§ 404. El *procedimiento por flagrancia* puede aplicarse cuando el presunto autor fuera sorprendido en el momento de intentar o de cometer el hecho, o fuera perseguido inmediatamente después de su comisión, o tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran presumir que acaba de participar en el mismo. Sin embargo, en delitos con armas de fuego este procedimiento especial pasa a ser obligatorio (CPP, 379 bis).

En lo sustancial, el trámite (CPP, 379 quater) prevé el tratamiento de la situación cautelar del imputado, la posibilidad de acordar salidas alternativas y finalmente la solicitud de elevación a juicio oral. En este último caso, hay un plazo especial para ofrecer prueba y para agotar el trámite con el querellante.

Procedimiento extendido

§ 405. El *procedimiento extendido* (CPP, 346) consta de una única cláusula de duplicación de términos, que puede activarse cuando la tramitación sea compleja a causa de:

- Pluralidad de hechos.
- Elevado número de imputados o víctimas.
- Casos de delincuencia organizada o transnacional.

En cualquiera de estos casos, la fiscalía puede solicitar al tribunal la duplicación de todos los términos previstos en el código. Quedan fuera los términos acordados entre partes, y en general se considera que los plazos relativos a medidas coercitivas no son abarcados por la cláusula de duplicación.

c) Procedimiento por delito de acción privada

§ 406. El *procedimiento por delito de acción privada* inicia directamente con la presentación de la querella privada (CPP, 350), es decir que no se regula una etapa investigativa o preparatoria completa (sí se prevé alguna diligencia mínima en el CPP, 355). El escrito de formulación de querella constituye la pieza acusatoria sobre la que se basará la totalidad del procedimiento, debiendo contener los datos del querellado, la relación precisa del hecho, la calificación legal y las pruebas que se propongan.

Dentro del trámite posterior, se prevé una *audiencia de conciliación* (CPP, 356), lo cual es coherente con una mecánica de juzgamiento pensada para los delitos contra el honor.

Rige el principio dispositivo, por lo que se admite el desistimiento expreso y tácito de la querella.

d) Noticia de otros procedimientos especiales

Procedimiento para la reparación del daño

§ 407. El código regula un *procedimiento especial para la reparación del daño* (CPP, 364), que puede instar el querellante únicamente contra el condenado penalmente. Viene a ser una versión simplificada -y con menos estorbo- de la vieja figura del actor civil en el proceso penal.

Como la pretensión se basa en la preexistente condena penal, la instancia debe limitarse a expresar concretamente los daños sufridos y a indicar la reparación deseada o el importe de las indemnizaciones pretendidas (CPP, 366). De esta instancia se corre traslado al condenado, quien podrá fundadamente oponerse al procedimiento. De no mediar oposición, el tribunal resolverá previa audiencia sobre el pedido de reparación.

Hábeas Corpus

§ 408. El proceso de *hábeas corpus* no es estrictamente un proceso penal especial. Pertenece al universo más amplio de los procesos constitucionales, aunque se lo suele considerar “penal por afinidad”.

La demanda o denuncia de *hábeas corpus* (CPP, 370) procede ante un acto u omisión de la autoridad pública que arbitrariamente y en violación de normas constitucionales implique:

- Una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, sin orden escrita de autoridad competente;
- El mantenimiento manifiestamente ilegítimo de una privación de la libertad inicialmente dispuesta por orden escrita de autoridad competente;

- Una agravación ilegítima de las formas y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin perjuicio de las facultades propias del Juez del proceso si lo hubiera.

La denuncia o demanda es *informal*, y puede iniciarla cualquier persona en favor del amparado, sin necesidad de poder ni patrocinio. También para evitar que pueda desvirtuarse el sentido garantizador del instituto, se asigna *competencia indistinta* a cualquier juez letrado de la provincia (CSFe, 9; CPP, 372).

Dentro del trámite posterior, el momento central es el dictado del *auto de hábeas corpus*. Mediante este acto, el juez ordenará la *presentación personal del amparado*, y en su caso la producción de los informes sobre la situación presuntamente lesiva (CPP, 376). El procedimiento se resuelve en una audiencia contradictoria, con participación de todos los intervinientes y de la autoridad requerida (CPP, 377).

Proceso penal juvenil

§ 409. El *régimen penal juvenil* se encuentra actualmente en vías de reforma, buscándose un cierto ajuste al modelo acusatorio formal. El sistema actualmente vigente para el juzgamiento de menores punibles puede considerarse inquisitivo sin atenuantes, por cuanto concentra en los organismos estatales funciones requirentes, decisorias e incluso asistenciales y tutelares.

Dentro de las particularidades de este régimen, destaca la permanente indefinición de la situación jurídica del imputado. En definitiva, casi nunca se llega a una instancia propiamente de conocimiento (juicio contradictorio), sino que se van adoptando sucesivas medidas de una dudosa naturaleza cautelar o asistencial, que terminan constituyendo la forma estándar de respuesta punitiva.

Síntesis del capítulo

1. *Desde una perspectiva actual, muchos de los mecanismos que se consideraban procedimientos especiales hoy constituyen medios resolutivos alternativos. Por lo que la categoría de procesos especiales ha quedado notablemente reducida en su contenido.*
2. *Los procedimientos especiales vigentes obedecen a distintos motivos, como la distinta gravedad o complejidad del caso, el menor interés estatal, las características de la persona involucrada o la distinta naturaleza del objeto procesal.*

Capítulo 14. Ejecución penal

a) Aspectos procesales del derecho de ejecución penal

Surgimiento

§ 410. El surgimiento del Derecho de Ejecución Penal como rama autónoma dentro de las disciplinas que estudian el sistema penal, ha estado atravesado por factores de distinto tipo. Centralmente, hubo a partir de la segunda mitad del siglo XX una clara toma de conciencia, motorizada por las catástrofes humanitarias implicadas en el encierro a gran escala.

Esta toma de conciencia tuvo múltiples manifestaciones, algunas más vinculadas a la necesidad de atenuar los rigores del cumplimiento de la pena mediante formas anticipadas de liberación o formas alternativas de cumplimiento. Así, un primer orden de transformaciones estuvo dado por el surgimiento y la revalorización de los institutos liberatorios o de flexibilización del encierro, cuyo prototipo es la *libertad condicional*.

Sin embargo, la preocupación abarcó también el modo de establecer controles efectivos sobre lo que ocurría en los ámbitos de encierro. Así, con distintos abordajes comienzan a ensayarse formas de inspección, supervisión y control, organizadas desde distintos ámbitos institucionales y dirigidas a los ámbitos de encierro institucional.

Dos modelos de control de los lugares de encierro

§ 411. El control institucional sobre los lugares de encierro tuvo dos manifestaciones bien diferenciadas: el *inspectorado de prisiones* y el *juzgado de ejecución*.

- El *juzgado de ejecución* fue la respuesta en el mundo continental, al hecho innegable de que los juzgados comunes no mostraban el más mínimo interés en cómo sus sentencias eran cumplidas. La idea de que “cada tribunal controla sus propias sentencias” se reveló casi de inmediato como un despropósito, dando paso a la idea de un juzgado con competencia funcional especializada.
- El *inspectorado de prisiones*, institución de vieja data en el mundo anglosajón, se organizó como un servicio de supervisión. Su función principal es producir evaluaciones periódicas y objetivas, para ser presentadas ante instancias superiores y servir de insumo para la formulación de políticas públicas y planes de reforma.

Los juzgados de ejecución penal

§ 412. Entre nosotros nunca se desechó del todo el modelo del inspectorado de prisiones, a punto tal que ambos modelos conviven en nuestra legislación (ley 24.660, 208, 209). Sin embargo, desde la década de 1980 Argentina incursionará en la creación de *juzgados de ejecución penal*, según los lineamientos del modelo continental.

Sintéticamente, los principales caracteres de este modelo son los siguientes:

- Es un juzgado *especializado en materia penitenciaria*, con funciones exclusivamente atinentes a la etapa de ejecución de la pena.
- En general, el juzgado *se emplaza físicamente dentro de la cárcel*, denotando su función específica y su orientación funcional.
- Cumple con tres funciones básicas: individualiza la pena en la etapa ejecutiva, actúa como alzada contra las decisiones de la administración penitenciaria y tiene a su cargo la superintendencia general del sistema.

Es difícil no advertir la concepción paternalista implícita en el modelo, no sólo en cuanto al trato con el condenado sino también en relación a las propias autoridades penitenciarias. El juez de ejecución es una especie de figura benévola, no atada en general por las formas del debido proceso ni sujeta a incómodas reglas de garantía.

Estos rasgos irían a durar mucho más que los propios juzgados especializados. Hacia la etapa de implementación del nuevo proceso penal en Santa Fe, resultaba poco explicable la presencia física de los jueces de ejecución dentro de las cárceles. Estaban ahí más por inamovilidad que por tener que cumplir con alguna función real: la reforma se había olvidado de ellos.

b) Ejecución de la pena privativa de libertad

La ley 24.660 y el Código de Santa Fe

§ 413. En este contexto, fueron delineándose las funciones clásicas de control judicial de la pena privativa de libertad en Argentina. La propia legislación nacional consagra los aspectos centrales del modelo, al establecer que será de competencia judicial durante la ejecución de la pena: resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado (ley 24.660, 4.a) y autorizar todo egreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria (ley 24.660, 4.b). Las dos funciones señaladas, junto con la de superintendencia o supervisión general (ley 24.660, 208), materializan en Argentina la adopción del modelo continental.

En Santa Fe, el Código de 2007 dejó prácticamente intocado el diseño funcional del juzgado de ejecución penal. Con alguna diferencia de detalle, las *atribuciones* y la *orientación funcional* del tribunal especializado (CPP, 419, 420) siguen el perfil impuesto dos décadas antes.

La abolición del fuero especializado

§ 414. Las leyes complementarias del nuevo sistema sí marcaron una diferencia más clara. Concretamente, el sistema de jurisdicción penal instituido por la ley 13.018 resulta incompatible con la idea de un juzgado de ejecución especializado.

En este sentido, la ley 13.018 vino finalmente a derogar la pauta de competencia específica, quedando la materia de ejecución como *una función a cumplirse de manera anual y por sorteo* (ley 13.018, 23, cuarto párrafo). Sin embargo, con algo de inconsistencia se estableció que la función de ejecución debía cumplirse solamente en los distritos donde funcionen establecimientos penitenciarios (ley 13.018, 23, séptimo párrafo), lo que deja sin respuesta la situación de los presos alojados en establecimientos policiales o de otro tipo.

En cualquier caso, hoy queda claro que los incidentes de ejecución tramitan mediante audiencia oral y pública, según los principios y la mecánica del nuevo sistema. Quedará para el debate en qué medida las *funciones extraprocesales residuales* siguen marcando la agenda de trabajo de los operadores de la ejecución penal.

Los incidentes de ejecución

§ 415. En el ámbito de los incidentes de ejecución, sin duda revisten importancia aquellos en los que se resuelven institutos liberatorios o de soltura anticipada. Centralmente, a partir de institutos como la *libertad condicional*, la *libertad asistida*, las *salidas transitorias* y la *semilibertad*, lo que hace el tribunal es terminar de individualizar la pena durante la etapa de ejecución.

En esa tarea individualizadora, además de interactuar con las partes en el ámbito específico de la audiencia, deberá también contar con prueba específica proveniente de la agencia penitenciaria: el dictamen del *organismo técnico criminológico* (OTC). En rigor, la intervención del OTC constituye una forma especial de peritaje, cuya elaboración resulta ineludible como actividad previa a la tramitación del incidente.

c) Ejecución de penas y medidas no privativas de libertad

§ 416. El otro gran capítulo del derecho de ejecución penal está dado por el régimen de las *penas y medidas no privativas de libertad*. Normativamente, se trata de un universo que nos resulta conocido: lo tenemos a mano cada vez que alguien resulta obligado a cumplir determinadas reglas de conducta de manera ambulatoria o fuera de un ámbito institucional de privación de libertad (CP, 27 bis; CPP, 219, 222.1).

Este ámbito es sin duda menos atemorizante que el de la pena privativa de libertad, aunque tampoco carece de complejidad. Centralmente, el desafío actual es cómo lograr mecanismos de control efectivo sobre el cumplimiento de reglas de conducta, que permitan contar con un menú de medidas no privativas de libertad efectivas y controlables. De ello depende que efectivamente pueda acudirse a mecanismos alternativos a la prisión preventiva o a la pena misma, en el marco de una política criminal reductora del poder punitivo.

Síntesis del capítulo

1. *La necesidad de ejercer un control externo sobre los lugares de detención y sobre el cumplimiento de las penas dio lugar a distintos modelos. En el ámbito continental,*

surgen los juzgados especializados en ejecución penal. En Argentina, se tomaría parcialmente este modelo, con algunas variaciones.

- 2. La reforma procesal en Santa Fe eliminó el fuero especializado, y pasó a considerar la materia penal ejecutiva como una función que se cumple de manera rotativa entre distintos jueces.*
- 3. Además de la cuestión específicamente carcelaria, una parte muy importante de la ejecución penal es el control y supervisión de las medidas no privativas de libertad.*

Lecturas de complemento

BACLINI, Jorge C. y SCHIAPPA PIETRA, Luis A., *Código Procesal Penal de Santa Fe. Comentado, anotado y concordado* (2 tomos), Juris, Rosario, 2017.

— *Código Procesal Penal de Santa Fe. Comentarios a la reforma de la ley 13.746*, Juris, Rosario, 2018.

BAYTELMAN, Andrés A. y DUCE, Mauricio J., *Litigación penal. Juicio oral y prueba*, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2018.

BINDER, Alberto M., *Derecho procesal penal* (5 tomos, obra en desarrollo), Ad-Hoc, Buenos Aires, 2013-2021.

— *Introducción al derecho procesal penal* (2ª ed.), Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005.

CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., *Derecho procesal penal* (3 tomos; actualizados, respectivamente, por Jorge E. Vázquez Rossi, Carlos A. Chiara Díaz y Jorge R. Montero), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001.

CORVALÁN, Víctor R., *Derecho Procesal Penal. Análisis crítico del procedimiento penal*, Nova Tesis, Rosario, 2010.

DE OLAZÁBAL, Julio, *Constitucionalización del proceso penal santafesino*, Ediciones UNL, Santa Fe, 2010.

— *El Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe*, Ediciones UNL, Santa Fe, 2014.

ERBETTA, Daniel; ORSO, Tomás; FRANCESCHETTI, Gustavo, y CHIARA DÍAZ, Carlos, *Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe comentado. Ley 12.734*, Zeus, Rosario, 2008.

- HENDLER, Edmundo S., *Derecho Penal y Procesal Penal de los Estados Unidos*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996.
- LORENZO, Leticia, *Manual de litigación*, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2012.
- MAIER, Julio B. J., *Derecho procesal penal* (3 tomos), Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004-2011.
- *La Ordenanza Procesal Penal Alemana. Su comentario y comparación con los sistemas de enjuiciamiento penal argentinos* (2 tomos), Depalma, Buenos Aires, 1978-1982.
- OLIVA, Juan Manuel, “El modo de probar en las audiencias previas”, en *VI Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal: profundizando la reforma procesal penal en Santa Fe*, Rosario, 10 y 11 de agosto de 2017, pág. 83-94.
- “Legalidad, oportunidad y disponibilidad”, en *Conclusiones, conferencias y ponencias del 1º Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal: Análisis crítico de la ley 12.734 y leyes complementarias*, Rosario, 8 y 9 de noviembre de 2012, pág. 77-82.
- PASTOR, Daniel R., *Tensiones: ¿Derechos fundamentales o persecución penal sin límites?*, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004.
- ROXIN, Claus, *Derecho procesal penal* (trad. de la 25ª ed. alemana), Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000.
- TOMÉ GARCÍA, José Antonio, *Curso de Derecho Procesal Penal* (2ª ed.), Dykinson, Madrid, 2019.
- VÁZQUEZ ROSSI, Jorge E., *Crisis de la Justicia Penal y Tribunal de Jurados*, Juris, Rosario, 1998.
- *Derecho procesal penal* (2 tomos), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004.
- ZALAMEA LEÓN, Diego, *Audiencias diversas al juicio*, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2021.

